

# العقود الإدارية

وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة  
ولائحته التنفيذية وأحكام المحكمة الإدارية العليا  
وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

الأستاذ الدكتور  
السيد أحمد محمد مرجان

أستاذ القانون العام  
والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون  
بدمنهور جامعة الأزهر

الطبعة الثانية

١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م

بسم الله الرحمن الرحيم

## المقدمة

أصبحت العقود الإدارية أداة محورية في يد الإدارة الحديثة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية، في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠، وما يشهده العالم من تطور متسارع في أنماط الإدارة العامة وأساليب تسيير المرافق العامة بانتظام واطراد دون توقف. وتعتمد الإدارة في مباشر أعمالها القانونية على وسيلتين: القرارات الإدارية الصادرة بإرادة منفردة، والعقود الإدارية التي تتم بتلاقي إرادتين. وقد تطورت نظرية العقود الإدارية في الفقه والقضاء الفرنسي والمصري في ظل القواعد والمبادئ العامة للقانون الإداري، ونصوص قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨<sup>(١)</sup> ولائحته التنفيذية<sup>(٢)</sup>. والدور الفعال للقضاء الإداري، وبالأخص أحكام المحكمة الإدارية العليا، وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والتي لعبت دورًا كبيرًا في وضع القواعد المنظمة، وحل إشكالياتها العملية.

**أهداف الدراسة:** تهدف الدراسة إلى:

- ١- التعريف بالعقد الإداري، معيار تمييزه، أركانه، أنواعه.
- ٢- بيان طرق وأساليب إبرام العقد الإداري الأصلية والاستثنائية.
- ٣- ذكر مراحل وقيود وإجراءات إبرام العقد وفقا لقانون التعاقدات ولائحته.

---

(١) الجريدة الرسمية، العدد ٣٩ مكرر (د)، بتاريخ ٣/١٠/٢٠١٨م.  
(٢) الصادر بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩، الوقائع المصرية، العدد ٢٤٤ تابع (ب) في ٣١ أكتوبر سنة ٢٠١٩م.

٤- إبراز الآثار القانونية المترتبة على انعقاد العقد "الحقوق والالتزامات"

٥- توضيح مرحلة تنفيذ العقد وكيفية تسوية منازعاتها.

### حدود الدراسة:

تركز الدراسة على تسليط الضوء على النظام القانوني للعقود الإدارية في

مصر، بأسلوب سهل وبسيط للطالب؛ باعتبارها مقررا جامعيًا مستقلًا.

### منهجية الدراسة:

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي المقارن، مستندة إلى:

١- نصوص قانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية.

٢- المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا.

٣- فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

٤- المقارنة أحيانًا مع بعض تجارب دول القانون المقارن.

**خطة الدراسة:** تنقسم الدراسة إلى أربعة أبواب رئيسة، على النحو التالي:

**الباب الأول:** الإطار النظري للعقد الإداري.

**الباب الثاني:** طرق إبرام العقود الإدارية.

**الباب الثالث:** المراحل والإجراءات المنظمة لإبرام العقد الإداري.

**الباب الرابع:** الآثار المترتبة على انعقاد العقد الإداري وتنفيذه

ومنازعاته.

(ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير) ،،،

المؤلف

## الباب الأول

### الإطار النظري للعقد الإداري

أهداف الباب الأول: بنهاية الباب، يكون الطالب قادرًا على:

- ١- تعريف العقد الإداري، وتحديد معيار تمييزه.
  - ٢- التعريف بقانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية.
  - ٣- الوقوف على المبادئ الحاكمة لإبرام العقد الإداري.
  - ٤- تحديد أركان العقد الإداري.
  - ٥- صور وأنواع العقد الإداري التقليدية والإلكترونية.
- تمهيد وتقسيم:** يمكن دراسة هذا الباب من خلال ثلاثة فصول، هي:
- الفصل الأول: تعريف العقد الإداري ومعياري تمييزه.
  - الفصل الثاني: أركان العقد الإداري.
  - الفصل الثالث: أنواع العقد الإداري.

## الفصل الأول

### تعريف العقد الإداري ومعياري تمييزه

ويمكن تناوله في ثلاثة مباحث، على النحو التالي:

### المبحث الأول

#### ماهية العقد الإداري وتطوره ومعياري تمييزه

وهو ما يمكن تناوله في ثلاثة مطالب:

#### المطلب الأول

#### مفهوم العقد الإداري وتمييزه عن غيره

أولاً: مشكلة تحديد مفهوم العقد الإداري:

يطلق العقد، ويراد به: الالتزام الناشئ بين طرفين، بقصد الشد، والربط، والتوثيق، والضمان، والعهد.. الخ. يؤكد قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)<sup>(١)</sup> أي الربوط.

وتحديد مفهوم العقد الإداري ليس أمراً سهلاً<sup>(٢)</sup>، لعدم وجود تعريف موحد جامع مانع له؛ يؤكد أن المشرع -على غير عادته- عرفه في المادة (١/ بند ١٣) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات بأنه: "محرر يتم إبرامه بين ممثل الجهة الإدارية والمتعاقد، ويتضمن التزامات محددة ومتقابلة بين طرفيه". كعقود الأشغال العامة، والتوريد.

(١) سورة المائدة، من الآية ١.

(2) André de Laubdere, F. Moderne, P. Delvolvé: Traité des contrats administratifs, T.1, L.G.D.J., 1983, P.17 et s..

أما تحديد مفهوم العقد الإداري لدى الفقه، فيثير مشكلة صعبة ومعقدة، تكمن في مواجهة النتائج والآثار المترتبة عليه للأطراف والغير، والصالح العام. ومما زادها تعقيدا لجوء الإدارة في فرنسا ومصر إلى عقود الصفقات والمشروعات المركبة والمتشابكة ومتعددة الأطراف، وبناء على مبادرة القطاع الخاص. فضلا عن إبرام العقود فيما بين الأشخاص العامة، مما نتج عنه نظريتين: مادية تركز على المراكز القانونية الموضوعية وطبيعة الأعمال وجوهرها. وشكلية تركز على الأشكال والإجراءات المقررة قانونا<sup>(١)</sup>.

ويتحدد العقد عند أنصار النظرية المادية الفرنسية-ديجي- بموضوعه، والآثار المترتبة عليه، ويعرفه بأنه: عمل يتولد عنه مركز ذاتي كالبائع والمشتري. لذا يفرقون بين العقد والاتفاق، وفكرة العقد الخاص. ويخلص إلى أن العقد الإداري شأنه شأن باقي العقود له ذات الخصائص، والآثار إلا أن غايته المتعلقة بالمرفق العام هي من أثبتت له صفة الإدارية. وأما العقد عند أنصار النظرية الشكلية الفرنسية -أندريه دي لوبادير-: اتفاق يولد مراكز شخصية أو ذاتية، وأنه لا بد من أن يتم التوافق بين الإرادتين من خلال الأشكال والإجراءات المقررة. فالاتفاق لا يعتبر عقدا وإن ولد مركزا لائحيا يمكن تعديله، خلاف المقرر في القانون الخاص.

---

(١) المستشار د/ عبد الفتاح صبري أبو الليل: أساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق - دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، ١٩٩٤، ص ٩ وما بعدها.

ويرى بعض الفقه<sup>(١)</sup> أن العقد هو: عمل قانوني من جانبين بقصد إنشاء

التزام أو تعديله، أو إلغائه. يقوم على العناصر التالية:

١- توافق أو النقاء إرادتين متقابلتين. ٢- ينشئ التزاما، أي مركزا قانونيا فرديا. ٣- العقد عمل قانوني من جانبين وليس من جانب واحد كالقرار الإداري. وعرفه آخر<sup>(٢)</sup> بأنه وفقا للتعريف الغالب في القانون الخاص: "توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه".

وعرفته المحكمة الإدارية العليا، بأنه: "اتفاق قانوني تُبرمه جهة إدارية مع شخص طبيعي أو اعتباري؛ بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، ويتضمن شروطاً استثنائية تُميز طبيعته عن العقود المدنية، وتُخضعه لأحكام القانون العام"<sup>(٣)</sup>. ويمكن الأخذ بالتعريف القضائي للعقد الإداري. ويختلف الفقه حول تحديد المعيار المميز له، المعيار العضوي، أو الشكلي إلا أن المعيار المختلط الأرجح كمعيار لتمييزه فقها وقضاء<sup>(٤)</sup>. وانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة لروابط القانون الخاص هو اختصاص متعلق بالنظام العام..<sup>(٥)</sup>

(١) د/ ثروت بدوي: النظرية العامة في العقود الإدارية، بدون، ط ١٩٦٣، ص ٥.  
(٢) د/ سليمان محمد الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية- دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، القاهرة، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م، ص ١٠٠. د/ عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في القانون المدني، مطبعة النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٥، ج ١، ص ١٣٨.  
(٣) حكمها في الطعن رقم ٢٣٤٢ لسنة ٥١ ق، جلسة ٢٧/١/٢٠٠٧.  
(٤) د/ جابر جاد نصار: العقود الإدارية، مركز جامعة القاهرة، ٢٠١٥م، ص ٢٦.  
(٥) حكمها في الطعن رقم ٦٤٣٠٦ لسنة ٦٦ ق. عليا، ورقم ٦٦٨٤٩ لسنة ٦٦ ق. عليا، جلسة ٢٨/١١/٢٠٢٣. لدى المستشار د/ محمد علاء زعزع: موسوعة التعاقدات العامة- المناقصات والمزايدات في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٢٥، المبدأ (٢٢)، ص ٢٦.

## ثانيا: مقارنة العقود الإدارية بعقود القانون الخاص:

يتفقان في المسمى، فكلاهما عقد يقوم على مبدأ الرضائية. "فالعقد الإداري كالعقد المدني لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء أو تعديل التزامات تعاقدية..."<sup>(١)</sup>. ويختلفان في الآتي:

### ١ - الطرف العام:

فالعقد الإداري يقوم على التراضي بين طرفين، أحدهما الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة<sup>(٢)</sup> يتمتع بامتيازات السلطة العامة. في حين لا يشترط ذلك في عقود القانون الخاص.

### ٢ - الغرض العام:

فهدف الإدارة في العقد الإداري تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق عام<sup>(٣)</sup> وتغليب الصالح العامة، دون أن يحتج الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين. بعكس هدف الأفراد في عقودهم الخاصة تحقيق مصالح خاصة، باعتبارها مصالح متساوية، ولا يجوز تعديلها أو فسخها أو إنهاؤها دون إرادة الطرف الآخر<sup>(٤)</sup>.

٣- طرق الإبرام: فالعقد الإداري يتبع في إبرامه أساليب ووسائل خاصة، أصلية أو استثنائية، تختلف عن وسائل إبرام عقود القانون الخاص.

---

(١) فتوى الجمعية العمومية رقم (٩٦٢) بتاريخ ٦/٣٠ / ٢٠٢١، ملف رقم ٥٣٣٠/٢/٣٢. لدى المستشار د/ محمد علاء زعزع: موسوعة، مرجع سابق، ص ٢٥.  
(٢) فتوى الجمعية العمومية السابقة رقم (٩٦٢) بتاريخ ٦/٣٠ / ٢٠٢١.  
(٣) الطعن السابق رقم ١٠٥٩ لسنة ٧ق، بتاريخ ١٩٦٣/٥/٢٥.  
(٤) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي ١٢٥٠٤ و ١٣٥٩٢ لسنة ٦٧ ق. عليا، جلسة ٢٠٢٣/٩/٣. لدى المستشار د/ محمد علاء زعزع: موسوعة، مرجع سابق، ص ٢٧.



#### ٤ - الآثار وسلطات الإدارة:

فختلف الحقوق والالتزامات الناشئة عن إبرام العقد الإداري عن المقرر في عقود القانون الخاص، تتسع وتضيق حسب سلطة الإدارة، ومقتضيات المرفق والصالح العام.

#### ٥ - الاختلاف في الموضوع والنظام القانوني والقضاء المختص:

فموضوع العقد الإداري يختلف عن موضوع عقود القانون الخاص- وإن اتفقا في المسمى أحيانا كعقد التوريد والمقولة- وتبعاً له يختلف القانون المنظم لكل منها، والقضاء المختص بنظر المنازعات العقدية. وقد تخضع الإدارة في بعض تصرفاتها وأعمالها إلى القانون الخاص، خضوعاً اختيارياً أو بحكم القانون، وفقاً لطبيعة العمل، وتصرف الإدارة في أموالها وممتلكاتها كالأفراد، أو لمصلحتها، ورغبة منها في رفع الشبهة عن تصرفاتها.

وتبعاً له اختصاص القضاء العادي بنظر منازعاتها<sup>(١)</sup>. فتصرف جهة الإدارة بالبيع لأموالها الخاصة وتحديد سعر المتر بها، هو تصرف متفرع عن حق الملكية وهو من مسائل القانون الخاص، يدخل في نطاق اختصاص محاكم القضاء العادي دون محاكم مجلس الدولة<sup>(٢)</sup>.

---

(١) أستاذنا د/ فؤاد محمد النادي: القانون الإداري، الكتاب الموحد المقرر على طلاب كلية الشريعة والقانون والشعب المناظرة، بدون، العام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠، ص ١٥.  
(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٥٦٩٩٥ لسنة ٦٧ ق. العليا، جلسة ٢٠٢٢/١٠/٢٥. لدى المستشار د/ محمد علاء ززع: موسوعة، مرجع سابق، ص ٦٥.

## المطلب الثاني

### التطور التاريخي لمفهوم العقد الإداري

تُعد فرنسا مهد فكرة العقد الإداري، حيث ظهرت الحاجة إلى تنظيم العلاقات العقدية التي تُبرمها الإدارة مع الأفراد في أعقاب الثورة الفرنسية، خاصة مع التوسع في إنشاء المرافق العامة. فقبل الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ لم تكن هناك تفرقة بين العقود المدنية وعقود الإدارة، وكلها كانت تخضع للقانون المدني.

وبعدها بدأ التمييز بينهما، وظهر اتجاه يفرض على الإدارة الالتزام بالقانون العام إذا تعاقدت في شأن يخص المرافق العامة، حيث تميّزت العقود التي تبرمها الدولة بخضوعها لقواعد خاصة تحمي المرفق العام. وترتب على الأخذ بمعيار التفرقة بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية أن اعتبرت العقود الإدارية من اختصاص القضاء العادي وليس الإداري، وهذه قاعدة شاذة. الأمر الذي حدا بالمشرع الفرنسي التدخل للنص على اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة ببعض العقود، كعقد الأشغال العامة، وعقد الالتزام، والقرض العام.

وهي ما عرفت في نطاق تحديد اختصاص القضاء الإداري بفكرة العقود الإدارية بتحديد القانون<sup>(١)</sup>. إلا أنها فكرة معيبة؛ لأن التحديد ليس من عمل المشرع، ويتناقض مع الدور المنوط به، مما اضطر مجلس الدولة

---

(١) د/ جمال عثمان جبريل: العقود الإدارية- إبرام العقد الإداري وصحته، الكتاب الأول، دار السعيد للطباعة، شبين الكوم، ١٩٩٥، ص ٤.

الفرنسي التدخل لإدخال بعض العقود دون نص تشريعي، كعقد المعاونة، وعقود الكهرباء والمياه والنظافة، وغاز الاستصباح في المدن؛ باعتبارها من قبيل عقد الأشغال العامة، وفقا لقاعدة قياسا على وقياسا عليه<sup>(١)</sup>.  
كما أن الأمر لا يخرج عن فروض ثلاثة<sup>(٢)</sup>:

إما أنها عقودا إدارية بطبيعتها، كعقد الأشغال العامة، وعقد الالتزام.  
أو عقودا مدنية بطبيعتها حتى ولو كانت الإدارة طرفا فيها كعقود بيع أملاك الدولة الخاصة.

أو أنها عقودا ذات طبيعة مزدوجة، غير إدارية بطبيعتها وتقبل خصائصها أن تكون إدارية، أو مدنية في أحوال أخرى، كعقود التوريد.  
ولقد شكل مجلس الدولة الفرنسي نقطة تحول بعد تأسيسه عام ١٧٩٩؛ حيث اختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود المبرمة من قبل الإدارة. وصدر أول حكم قضائي مميز للعقد الإداري في قضية "بلانكو Blanco" جلسة ٨ فبراير ١٨٧٣ عن محكمة التنازع الفرنسية Tribunal des Conflits، حيث قررت إن الإدارة لا تُعامل معاملة الأفراد، وأن عقودها تُخضع لأحكام القانون الإداري، وليس لقواعد القانون المدني.

ثم انتقل المفهوم إلى الدول التي تأثرت بالنموذج الفرنسي، ومنها مصر؛ حيث تبنت فكرة العقد الإداري، خاصة منذ إنشاء مجلس الدولة المصري عام ١٩٤٦، وما تلاه من قوانين كالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥، ومن

(١) د/ ثروت بدوى: نظرية فعل الأمير في القانون الإداري، جامعة السوربون، فرنسا، ١٩٥٤، ص ١٧.

(٢) د/ جابر جاد نصار: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٢٦ وما بعدها.

وقتها أصبح القاضي الإداري هو قاضي القانون العام بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية حتى القانون الحالي رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والذي نص في المادة (١٠/ حادي عشر): "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ... حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر". وذكره بعض العقود علي سبيل المثال؛ لقوله: أو بأي عقد إداري آخر.

كما استقر القضاء في العديد من أحكامه على تمييز العقد الإداري عن غيره، منها أن: "العقد الإداري هو ما تُبرمه جهة إدارية بقصد تسيير مرفق عام ويشتمل على شروط استثنائية تُعد من مظاهر السلطة العامة"<sup>(١)</sup>. إذ المبدأ الحاكم للعقود الإدارية هو ضمان استمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد<sup>(٢)</sup>.

ومع تطور العمل الإداري، وتزايد الحاجة إلى ضمان وجود منافسة حقيقية، ومكافحة الفساد المالي والإداري من ممارسات الخداع أو التواطؤ والاحتيال والرشوة وغيره، والحاجة إلى توحيد قواعد التعاقد الإداري، صدر القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، ثم صدرت **لائحته التنفيذية** عام ٢٠١٩ وتعديلاتها المختلفة.

---

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٣٤٢ لسنة ٥١ ق، جلسة ٢٠٠٧/١/٢٧.

(٢) فتوى الجمعية العمومية رقم (٤٣٠) بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢١، ملف رقم ٤٦٦٥/٢/٣٢. المستشار د/ محمد علاء زعزع: موسوعة، مرجع سابق، ص ٢٦.

وقد أكدت أحكام القضاء الإداري وفتاويه أن تطبيق هذا القانون وغيره لا يُغيّر من الطبيعة الإدارية للعقود التي تتدرج في نطاقه، ما دامت تتوافر فيها معايير العقد الإداري؛ إذ لا يوجد في مصر ما يعرف بالعقود الإدارية بنص القانون، وهو مسلك محمود للمشرع؛ لقصره اختصاص القضاء الإداري على مجالات القانون العام<sup>(١)</sup>. يؤكدته فتاوها أن: "قانون التعاقدات ما هو إلا قانون إجرائي يحكم عملية إبرام العقد، وليس فيما تضمنه من قواعد إجرائية أن تؤثر في أركان العقد، أو تغير من طبيعتها، أو تحددها بطريقة معينة بما يتسبب في إعاقة الخاضع له وتعطيله عن أداء دوره"<sup>(٢)</sup>.

### المطلب الثالث

#### عناصر المعيار المميز للعقد الإداري<sup>(٣)</sup>

يقوم العقد الإداري في فرنسا على عنصرين<sup>(٤)</sup>: أحدهما ثابت وهو المعيار العضوي، المتمثل في الطرف العام، أحد أشخاص القانون العام. وثانيهما: عنصرا متغيرا يعرف بالمعيار التعااقبي أو التخييري، والمتمثل في احتواء العقد على شروط استثنائية غير مألوفة، أو إشراك المتعاقد

(١) د/ سليمان الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق ص ٥١.  
(٢) فتوى الجمعية العمومية رقم (٨٤٣) بتاريخ ٢٠١٧/٥/٦، ملف رقم ٥٠٧/١/٥٤.  
المستشار د/ محمد علاء زعزع: موسوعة، مرجع سابق، ص ٢٦.  
(٣) للمزيد، يراجع: مؤلفات القانون الإداري، والعقود الإدارية. د/ ثروت بدوي: المعيار المميز للعقد الإداري، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة- كلية الحقوق، مج ٢٧، ع ٣، ٤. ديسمبر ١٩٥٧، ص ١١٥-١٨٥. جمال الدين جودة اللبان: المعيار المميز للعقد الإداري، مجلة إدارة قضايا الحكومة، مج ٨، ع ٣، سبتمبر ١٩٦٤، ص ٦١-١٤٣. وليم سليمان قلادة: اتجاهات حديثة في المعيار المميز للعقد الإداري، مجلة مجلس الدولة، مج ٨، ع ١٠، ١٩٦٠، ص ٤٩٢-٥٠٩.  
(٤) المستشار د/ عبد الفتاح صبري أبو الليل: أساليب التعاقد، مرجع سابق، ص ٢٥.

مع الإدارة في التنفيذ ذاته لمرفق عام. فتوافر أحدهما يسبغ الصفة الإدارية على العقد، أو يخضعه لنظام استثنائي<sup>(١)</sup>.

وبالمقابل يكاد يجمع الفقه والقضاء الإداري المصري ويستقر على إسباغ الصفة الإدارية على العقد إذا ما قام على أسس أو شروط ثلاثة مجتمعة، تتمثل في: أن تكون الإدارة طرفا في العقد. وصلة موضوع العقد بالمرفق العام. والأخذ بأساليب ووسائل القانون العام، بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص<sup>(٢)</sup>.

وهو ما سنوضحه فيما يلي:

#### أولاً: الطرف الإداري العام في العقد الإداري

يشترط لاعتباره إدارياً أن تكون جهة الإدارة أو أحد أشخاص القانون العام طرفاً أساسياً فيه، حتى ولو كان طرفاً خاصاً يتصرف بصفته وكيلاً عن الدولة- كعقود الأشغال العامة-؛ لأن حقيقة الوكالة تعني أن الشخص العام ما زال هو أحد أطراف العقد<sup>(٣)</sup>. وهو ما يعرف في فرنسا "بالمعيار العضوي أو العنصر الثابت"، وهو معيار بديهي ومنطقي لا بد من توافره، وإلا غدا العقد من عقود القانون الخاص لا العام؛ إذ هو شرط

---

(1) Auby et Drago: Traité de contentieux administratif, 2<sup>e</sup> édition, 1975, T.1, P.378 et s.

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٦٤٣٠٦ لسنة ٦٦ ق. عليا، ورقم ٦٦٨٤٩ لسنة ٦٦ ق. عليا، جلسة ٢٨/١١/٢٠٢٣. سابق في ذات المؤلف.

(3) V. Geroges Dupuis; Marie- José Guédon et Patrice chrétien: droit administratif, 9<sup>éd</sup>. 2004, P.414.

مفترض وليس بمعيار<sup>(١)</sup>. وقد حددت م ١/٥٢ مدني الأشخاص المعنوية العامة، وأنها تنقسم إلى نوعين، الأول: الأشخاص العامة الإقليمية، والتي تباشر اختصاصها بحسب النطاق الجغرافي المحدد لها، وأهمها: الدولة والمحافظات.

والثاني: الأشخاص العامة المصلحية أو المرفقية، ويطلق عليها المؤسسات والهيئات العامة، وهي مرفق عام يدار عن طريق مصلحة عامة تكون مقيدة بالغرض الذي أنشئت من أجله، كمصلحة السكة الحديد، وهيئة البريد، والجامعات وغيرها. بالإضافة إلى النقابات المهنية. ويقصد **بالإدارة**: الإدارة بمفهومها الفني الدقيق، مركزية كانت كالوزارات، أو لا مركزية كالمحافظات والمدن، وتختص باعتماد طرق التعاقد المقررة قانوناً، واتباع إجراءاتها من خلال السلطة المختصة.

وتحدد **الجهة الإدارية** في قانون التعاقدات: (أي من الجهات العامة أو الهيئات أو الوحدات المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، وما يتبعها من صناديق خاصة أو حسابات على النحو المبين في المادة المشار إليها).

وتؤكد المادة الأولى منه: (يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وتسري أحكامه على الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من

---

(١) ماهر فيصل صالح: معايير الوصف الإداري للعقد، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية - كلية القانون، مج ٢، ع ٢٠٦، العراق، ٢٠١٣، ص ١٤٧. دار المنظومة.

وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها بصفة أساسية على الاشتراكات المالية من أعضائها، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها، أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين أو القرارات).  
ويلاحظ استخدام المشرع في قانون التعاقدات ولائحته مسميات مختلفة للإدارة كإدارة التعاقدات، والإدارة الطالبة أو المستفيدة، ولكل معناها الخاص<sup>(١)</sup>، ولكنها تتبع الجهة الإدارية الأم والأصلية.

وقد أخذ المشرع بالمعيار المختلط؛ لتحديد الأشخاص الإدارية العامة، ودور الممثل القانوني لها.

يؤكد تعريف السلطة المختصة في قانون التعاقدات بأنها: (الوزير، ومن له سلطاته، أو المحافظ، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو الصندوق، أو من يعادلهم من سلطات في الجهات المنصوص عليها في

---

(١) إدارة التعاقدات: هي فرع أو قسم أو وحدة إدارية تابعة للجهة الإدارية؛ وفقا للتقسيم الإداري المنشأ بموجب نص م (٣) من القانون: "تنشأ بالجهة الإدارية إدارة للتعاقدات أيا كان مستواها الوظيفي بالهيكل التنظيمي، تشكل من عدد كاف من العناصر المؤهلة والمدرية، وفقا للاختصاصات المحددة بها". أما الإدارة الطالبة أو المستفيدة، فهي: "الإدارة المسؤولة عن تحديد المتطلبات بمحل التعاقد طبقا لمهامها أو احتياجاتها". م (١) من اللائحة.



المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، كل في نطاق اختصاصه). وهو ما يفهم منه أن السلطتين التشريعية، والقضائية لا يجوز لها إبرام العقود الإدارية وفقا للاختصاص الدستوري والتشريعي المحدد لوظيفة الأساسية، وإن جاز للقيادات الإدارية بهما ذلك وفقا للصفة الإدارية وليست الفنية. فللوزير وغيره سلطة إبرام العقد الإداري بصفته الإدارية وليست السياسية. كما لا تعتبر السلطة التشريعية طرفا في العقد الإداري المعلق إبرامها على شرط موافقتها وإذنها، كالقرض العام<sup>(١)</sup>. أو صدور قانون عنها كعقد التزام المرافق العامة.

وبالمقابل رفض القضاء الإداري وصف العقد الإداري وسريان أحكام قانون التعاقدات على بعض الجهات الإدارية الخاصة، والهيئات والمصالح، حتى ولو تدخلت الإدارة في اقتراح أو فرض بعض الشروط، أو دفع الأطراف للتعاقد، أو وقعت بجانب أحد الأفراد المتعاقدين؛ إما بسبب قانون إنشاءها، أو طبيعة المال، عام أو خاص.

وقد أفتت بسريان قانون التعاقدات على جميع الهيئات العامة، ومن بينها الجامعات- وأن المقصود بالسلطة المختصة في تنفيذ أحكامه- أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، ورؤساء الوحدات ذات الطابع الخاص لهم سلطات رئيس المصلحة<sup>(٢)</sup>. في حين أفتت بعدم اعتبار مديريات

---

(١) المستشار د/ عبد الفتاح صبري أبو الليل: أساليب التعاقد، مرجع سابق، ص ٣٤.  
(٢) فتوى رقم ٢٦٤ بتاريخ ١٦/٥/٢٠٠١، ملف رقم ٦٩/١/٥٨. المستشار د/ محمد ماهر أبو العينين: العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات في قضاء واقتناء مجلس الدولة حتى عام ٢٠٠٤، دراسة تحليلية لأراء الفقهاء وأحكام وفتاوى مجلس الدولة- الكتاب الأول، دار أبو المجد، القاهرة، ٢٠٠٣، ص ٢٥٣.

الخدمات بالمحافظات كمديرية الصحة والإدارات الصحية والمستشفيات  
مصالح عامة وفقا للدستور، ومن ثم لا يتمتع مديرها بسلطات رئيس  
المصلحة أو من له سلطاته فيما يتعلق بالاتفاق المباشر<sup>(١)</sup>.

وأفتت بخضوع الإذاعة والتلفزيون، والبنك المركزي لقانون التعاقدات بموجب قانون الإنشاء واعتبارهما هيئة عامة<sup>(٢)</sup>. وخضوع عقد منح التزام الطرق السريعة<sup>(٣)</sup> بنظام البوت (B.O.T) لقانون التعاقدات العامة. في حين لا تخضع لأحكامه بعض عقود الهيئة العامة للبترو، والنقابات والغرف التجارية والاتحادات المهنية، وأشخاص القانون الخاص كالجمعيات التعاونية التعليمية؛ لكون أموالها أموالا خاصة لا عامة<sup>(٤)</sup>.

ولا يسبغ تعاقد وزارة الأوقاف مع مقاول مباني على عقدها الطابع  
الإداري؛ لأنها لم تتعاقد بصفتها سلطة عامة، بل شخصا من أشخاص  
القانون الخاص بوصفها ناظرة على وقف.

وأيا كان أضحت جميع جهات الدولة، وأشخاص القانون العام خاضعة لأحكام قانون التعاقدات فيما لم يرد في شأنه نص خاص. وأن العبرة في الصفة الإدارية هي بنيتها لأحد الطرفين وقت إبرام العقد الإداري، فإن

---

(١) فتوى الجمعية العمومية رقم (٦٤٩) بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢، ملف رقم ٦٦٩/١/٥٤. المستشار د/ محمد علاء زعزع: موسوعة، مرجع سابق، المبدأ (٣٧٥)، ص ٨٧٢.  
(٢) فتوى رقم ٣٥١ في ٢٠/٥/١٩٩٩، ملف رقم ٣٥١/١/٥٤. والفتوى رقم ٧٠٢ في ٨/١١/١٩٩٩، ملف رقم ١٩٩٢/١/٥٨. المستشار د/ محمد أبو العينين: العقود الإدارية، المرجع السابق، ص ٢٢٣.  
(٣) فتوى رقم ٦٠١ في ١٧/٨/٢٠٠٣، ملف رقم ١٤/٢/١٠. المرجع السابق، ص ٢٤٩.  
(٤) فتوى إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات في الملف رقم ١٩٩٢/٦/١٨. المرجع السابق، ص ٢٢٤.

تغيرت لأي سبب كان، فإن هذا لا ينزع عن العقد صفته الإدارية، وبالمقابل لا يتحول العقد إداريا إذا كان أحد طرفيه شخصا معنويا خاصا ثم تحول واكتسب وصف شخص معنوي عام<sup>(١)</sup>.

### ثانيا: تعلق موضوع العقد بالمرفق العام

وهو ما يعرف في فرنسا "بالمعيار التخييري أو التبادلي" مع شرطي السلطة العامة، أو الشروط الاستثنائية، فيكتفي بأيهما. أو بالمعيار الموضوعي؛ لقصره على أن يرتبط موضوع العقد الإداري بتنفيذ المرفق العام ذاته دون حاجة للبحث عما إذا كان العقد يتضمن شروطا استثنائية من عدمه.

ويعتبره الفقه<sup>(٢)</sup> والقضاء المصري شرطا ثانيا ومكملا لصفة المتعاقد، باعتبار المرافق العامة الطابع والمجال الأصل لنشاط الحكومة، تعمل تحت إشراف الدولة؛ لسد حاجة عامة مع خضوعه لنظام قانوني معين، وقابليته للتعديل وفقا لتطوير الحاجة<sup>(٣)</sup>.

وقد استقر القضاء الإداري الفرنسي منذ حكمه الشهير في قضية الزوجين برتان "Arrêt Bertin" على اعتبار العقد إداريا إذا كان يؤدي إلى

---

(١) د/ محمد بكر حسين: العقد الإداري والتحكيم، مكتبة السعادة، طنطا، ١٩٩٣، ص ١٠.

(٢) د/ حمدي محمد العجمي: المرجع في العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية - دراسة تحليلية مقارنة، معهد الإدارة العامة، الرياض - السعودية، ٢٠١٨، ص ٤٦. المستشار د/ محمد حامد الجمل: نظرة جديدة للمرافق العامة، ج ١، مجلة مصر المعاصرة، مج ٦٣، ع ٣٥٠، القاهرة، ١٩٧٢، ص ٧١٧.

(٣) المستشار/ بدوي إبراهيم حمودة: تطور نظرية المؤسسات العامة في ظل النظام الاشتراكي في الجمهورية العربية، مجلة مجلس الدولة، س ١١، ١٩٦٢، مطابع مؤسسة أخبار اليوم، ص ٥.

اشترك المتعاقد مع الإدارة مباشرة في تسيير المرفق العام<sup>(١)</sup> حتى ولو لم يتضمن أية شروط استثنائية<sup>(٢)</sup>. ووفقا له تم التوسع في نطاق تطبيق المعيار الموضوعي "معيار المرفق العام"، فاعتبر العقد إداريا إذا كان يشكل أسلوبا لأداء الخدمة المرفقية، والقيام بعمل هو من اختصاص المرفق العام، كتقديم سلعة أو خدمة معينة.

مثال: تنازل إدارة التموين لوسيط يتمثل في المنظمات المهنية عن مهمة تسليم الدقيق للمخابز وإعادة توزيعه بموجب قرار وزير المالية والتموين في ١٩٤٥/٤/٩، بأن سلمت مخزون الدقيق للمقاطعات التي لا تعاني نقصا بدلا من المقاطعات التي تعاني نقصا، مما جعله عقد إداريا<sup>(٣)</sup>.

وقضت محكمة التنازع الفرنسية بأن العقد يعتبر إداريا إذا كان يلزم العامل أو الموظف بالمساهمة في إدارة المرفق العامة مباشرة. حيث أسندت إحدى المحليات إلى السيدة "Dame Mawerand" في أكتوبر ١٩٤٦ مهمة نظافة إحدى المدارس المحلية، والعناية بأجهزة التدفئة خلال فصل الشتاء، وأيضا مهمة حراسة الأطفال خلال السنة الدراسية، وفترة جنى العنب عام ١٩٥٢.

---

(١) تتلخص وقائعه في إبرام عقد شفوي بينهما مع الإدارة الفرنسية في ٢٤ نوفمبر ١٩٤٤؛ لتقديم الوجبات الغذائية بمقابل ٣٠ فرنك عن كل شخص للرعايا السوفييت اللاجئين المتواجدين بأحد المراكز، بهدف إعادة ترحيلهم إلى وطنهم. وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي هذه الظروف كافية لإسباغ الصفة الإدارية على هذا العقد دون حاجة للبحث عن وجود ظروف استثنائية من عدمه.

(2) P. Weil, Le critère du contrat administratif en crise, Mélange Waline, L.G.D.J., 1974, P.833 et s.

(3) C.E., 14 Novembre 1958, R.P.555.

ويترك للقضاء مهمة التمييز بين ما يعتبر من الأعمال مساهمة مباشرة من عدمه، لصعوبة تحديدها.

وأما قبل صدور حكم الزوجين برتان، فأسست فكرة العقد الإداري على أساس المرفق العام- باعتباره محورا لكل نظريات القانون الإداري، ولوجود علاقة وثيقة بينهما- على نظريات ثلاثة<sup>(١)</sup>:

الأولى: نظرية الهدف الحال والمباشر: فالعقد يعتبر إداريا إذا كان موضوعه يتعلق بتحقيق هدف مباشر وحال لتسيير وإدارة المرفق العام وإلا فلا. إلا أنها نظرية معيبة، ولا تصلح للتمييز بين الهدف المباشر وغيره، ولم يعول عليها القضاء كثيرا.

الثانية: نظرية اشتراك المتعاقد نفسه في تسيير وإدارة المرفق العام: بأن يقوم بدور رئيس، أو يكون شريكا في إدارته. وترتكز على فكرتين: تحديد طبيعة الاستخدام أو الطبيعة الإدارية للعقد - كعقد الامتياز، وعقد إجارة الأشخاص أو التوظيف- وما إذا كان المتعاقد يشترك في تسيير وإدارة المرفق العام بصفة مؤقتة موسمية أو دائمة. وفكرة الصفة الإدارية للعقد، ومدى قيامها على روابط القانون العام.

الثالثة: نظرية المرافق العامة الإدارية الذاتية، وهي ما تقوم على التفرقة بين المرافق العامة الإدارية والاقتصادية، فالأولى مرافق عامة إدارية بحسب طبيعتها وذاتيتها، ومنوط بها إبرام العقود الإدارية، كعقود التطوع

---

(١) للمزيد: د/ عبد الفتاح أبو الليل: أساليب التعاقد، مرجع سابق، ص ١٢٠ وما بعدها.

بالجيش<sup>(١)</sup>. والثانية مرافق اقتصادية ليست بطبيعتها إدارية، مما يجعل عقودها من قبيل العقود الخاصة. بالإضافة إلى فكرة الصالح ومقتضيات سير المرافق العامة وانتظامه، وإن كانت هذه الفكرة تصلح أساسا كشرط لممارسة السلطة العامة، وغيره أكثر منها أساسا قانونيا<sup>(٢)</sup>. وهو ما جرى عليه قضاء مجلس الدولة المصري في العديد من أحكامه<sup>(٣)</sup> وفتاويه.

**ثالثا: تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص**  
وهو ما يعرف في فرنسا "بالمعيار التخييري أو التبادلي"، أو بالمعيار المادي، فيكتفى بشرط الصفة الإدارية للمتعاقد، وبأي من المعيارين الموضوعي أو المادي، بعكس النظام المصري الذي يعتبره شرطا أساسيا وجوهريا، وعنصرا حاسما<sup>(٤)</sup> لا بد من وجوده مع الشرطين السابقين، مجتمعة لتمييز العقد الإداري عن غيره، وإلا انتقت عنه الصفة الإدارية. ويقصد به: أن يحتوي العقد الإداري على شروط استثنائية غير مألوفة في قواعد القانون الخاص، ولا يمكن إدراجها في عقود القانون الخاص؛ لكونها تحمل المتعاقد التزامات غير مقبولة في القانون المدني والتجاري.

(1) C.E., 29 janvier 1947, R.D.P., 1948, P.78. Conc. Waline.

(٢) د/ أحمد عياد: مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، ١٩٧٣، ونشرتها دار النهضة العربية، القاهرة، ص ٢٦٦.

(٣) منها: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعين رقمي (١٣٥٩٢، ١٢٥٠٤) لسنة ٦٧ ق. عليا، جلسة ٢٠٢٣/٩/٣. المستشار د/ محمد علاء زعزع، مرجع سابق، ص ٢٧. وفتوى الجمعية رقم (٥٣٥) بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٤، ملف رقم ٥٢٠/١/٥٤. المرجع السابق، ص ٢٨.

(٤) د/ جابر جاد نصار: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٣٩ وما بعدها. بندر محمد عويّزب العتيبي: الشروط الاستثنائية كمعيار مميز للعقد الإداري، رسالة ماجستير، حقوق القاهرة، ٢٠٠٩، ص ١٩. د/ قرواز فرحات: الشروط الاستثنائية غير المألوفة ودورها في تكييف العقد الإداري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، الجزائر، مج ٧، ١٤، جوان ٢٠٢٢، ص ٢٠٧٣.

وقد جرت الأحكام القضائية على تعريفها بأنها: الشروط التي تمنح المتعاقدين حقوقا، أو تحملهم التزامات غريبة في طبيعتها عن تلك التي يمكن أن يوافق عليها المتعاقد في نطاق القوانين المدنية والتجارية<sup>(١)</sup>. أو: شروطا تمنح السلطة العامة امتيازات غير مألوفة في القانون الخاص<sup>(٢)</sup>. أو: شروطا تختلف بطبيعتها عن تلك التي يمكن إدخالها في عقد مشابه في القانون المدني<sup>(٣)</sup>.

ويعتبر أول ظهور قضائي لها في قضية شركة الجرانيت أو الرخام في ٣١ يولييه ١٩١٢ حيث اعتبر مفوض الحكومة "بلوم" أن معيار العقد الإداري هو اتصاله بمرفق عام وتضمنه شروطا استثنائية غير مألوفة<sup>(٤)</sup>. وهو ما أصبح معيارا بالنسبة لسائر العقود الإدارية كعقود القرض، والتأمين البحرية، والنقل البري، بل طبقته المحاكم القضائية بطريقة أكثر وضوحا، فلا تعتبر عقودا إدارية تلك التي لا تحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، ولا تتعلق بالمرافق العامة<sup>(٥)</sup>. وأيما كان، تسميتها "العناصر غير المألوفة" أو "الشروط غير المألوفة" فيعرفها دي لوبادير: تلك الشروط وثيقة الصلة بالقانون العام، وتحمل طابعه في محتواها وغرضها.

---

(1) C.E., 20 octobre 1950, Stein, Rec. P.505.

(2) C.E., 21 janvier 1948, Société Panaroya, S.1949-36.

(3) C.E., 19 Juin 1952, Société, des Combustibles et Carburants nationaux. Rec. P.628.

(4) C.E., 31 Juill. 1912, G.A., P.110.

(٥) المستشار د/ عبد الفتاح أبو الليل: أساليب التعاقد الإداري، مرجع سابق، ص ٨٧.

ويري آخرون بأنه: لا يمكن تحديدها، بل يمكن ردها إلى أفكار رئيسية كالشروط التي تتضمن امتيازات الإدارة دون المتعاقد، والشروط التي تخول المتعاقد مع الإدارة بعض السلطات الاستثنائية في مواجهة الغير، واشتراكه في إدارة المرفق العام، والإحالة إلى دفاتر شروط معينة تتضمن شروطا استثنائية.

ويمكن رد صور الشروط الاستثنائية إلى الأفكار الآتية<sup>(١)</sup>:

١ - الشروط التي تتسم بطابع السلطة العامة: بأن تشتمل على عناصر غريبة على علاقات القانون الخاص، أو تمنحها امتيازاً من امتيازات السلطة العامة، كحقها في التعديل، والإشراف والرقابة والتوجيه وإضافة شروط جديدة بشرط ألا يصل إلى حد فسخ العقد الأصلي<sup>(٢)</sup>، وليس للطرف الآخر إلا الحق في التعويض إن كان له وجه. وهذا على خلاف الأصل في العقود المدنية<sup>(٣)</sup>.

٢ - الشروط التي تعطى المتعاقد مع الإدارة سلطات استثنائية في مواجهة الغير: بأن تخوله على خلاف الأصل الحق في ممارسة بعض

---

(١) للمزيد، د/ عبد الفتاح أبو الليل: أساليب التعاقد الإداري، مرجع سابق، ص ٩٦ وما بعدها. د/ جمال جبريل: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٤٩ وما بعدها. د/ جابر جاد نصار: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٤٥ وما بعدها.  
(٢) فتوى الجمعية رقم (٧٦) بتاريخ ١٩/١/٢٠٢٢/ ملف رقم ٦٦٢/١/٥٤. المستشار د/ محمد علاء زعزع: موسوعة، مرجع سابق، ص ٣١.  
(٣) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن ١٥٢٠، س ٢٢، جلسة ١٩٥٧/٤/٢٠، المكتب الفني، ص ٩٣٧. مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في العقود الإدارية في أربعين عاماً، من أول أكتوبر ١٩٥٥ إلى آخر ١٩٩٥، العدد الخاص بمناسبةيوبيل الذهبي لمجلس الدولة، ص ٣٠٥ وما بعدها. وحكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - في الطعن رقم ٤٢٢١، والطعن رقم ٤٥٥٩ لسنة ٥٠ ق. عليا، غير منشور، ص ٣.



مظاهر السلطة العامة التي هي من اختصاص الإدارة، وبالقدر الذي يستلزمه تنفيذ العقد الإداري. مثال: الشروط التي تخول الملتزمين في عقد الالتزام الحق في اقتضاء وفرض رسوم معينة من المستفيدين فهذا بمثابة تفويض منها، أو حق نزع الملكية. وإعطاء المقاول سلطة الاستيلاء المؤقت على العقارات، أو شغلها مؤقتاً لمدة محدودة دون توقف على رضا ملاكها. وهو قد يمتد إلى عقود أخرى مقارنة لها<sup>(١)</sup>.

**٣- الشروط غير المألوفة التي لا يمكن تفسيرها إلا وفقاً لنظرية العقود الإدارية وتنفيذها يستوجب استخدام قواعدها:** فسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات لا يمكن تفسيرها إلا من خلال فكرة سير المرافق العامة بانتظام واطراد. ونظريات إعادة التوازن المالي لا يمكن تفسيرها إلا في إطار مبادئ وقواعد القانون الإداري، وتوافر شروطها من عدمه.

**٤- الشروط غير المألوفة في عقود القانون الخاص:** فللقاضي الإداري حرية كبيرة في تقدير مدى اعتبار الشروط الواردة بالعقد غير مألوفة في القانون الخاص من عدمه. وقد قضى باعتبار العقود التي تتعلق بإنشاء الأغراض المتعلقة بالمدن إدارية؛ بسبب التزامات المرافق العامة وشغل الدومين العام<sup>(٢)</sup>. والشروط التي تعطي الإدارة الحق في إيقاف التنفيذ بدون إنذار سابق تعتبر شروطاً غير مألوفة<sup>(٣)</sup>.

---

(1) C.E., 27 Juill. 1950, Peulabeuf, Lebon, P.668.

(2) C.E., 25 juin 1952, Marmignon, Lebon, P.331.

(3) C.E., 8 janvier 1965, Lebon, P.7.

٥- الشروط غير المألوفة المتعلقة بالمصلحة العامة: كالشروط المتعلقة بعقد امتياز مسرح، والتي تهدف إلى تغليب الاعتبارات الفنية على الاعتبارات المالية والتجارية للعقد، وإسباغ الصفة الإدارية عليه. واعتماد عقود النقل في زمن الحرب لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

٦- شرط الإحالة إلى دفاتر شروط معينة: كالشروط الواردة بكراسة الشروط أيا كان مضمونها فإنها تعد من الشروط الاستثنائية غير المألوفة<sup>(١)</sup>. وإن قضى مؤخرا بعدم اعتبارها ذلك<sup>(٢)</sup>. والشرط الذي يجعل الاختصاص للقضاء الإداري بنظر منازعات العقود الإدارية<sup>(٣)</sup>.

وفرق بين الشروط الاستثنائية غير المألوفة، وبين النظام الاستثنائي الخاص الذي يخضع له العقد. والأمر متروك لسلطة القاضي الإداري.

## المبحث الثاني

### التعريف بقانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية

يمثل قانون تنظيم التعاقدات نقلة نوعية؛ لصدوره في ضوء توجه الدولة نحو تطوير منظومة الشراء الحكومي، وتحقيق مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص والمنافسة، وترشيد الإنفاق العام، وعدم قدرة نصوص قانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨<sup>(٤)</sup> الملغى<sup>(٥)</sup> علي مواكبة

---

(1) C.E., 17 novembre 1967, Roudier de la Brille, P.428.

(2) C.E., 2 octobre 1981, Commune de Bor.

(٣) د/ جمال جبريل: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٥٣.

(٤) الجريدة الرسمية، العدد (١٩) مكرر، في ٨ مايو ١٩٩٨.

(٥) المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

التغيرات الاقتصادية والتقنية. ويعد قانون التعاقدات ولائحته التنفيذية هو الشريعة العامة الواجبة الاتباع والتطبيق لدى الجهات الإدارية.

ويحوى القانون (٩٣) مادة، موزعة على سبعة أبواب. بينما أنت لائحته التنفيذية في (١٨٠) مادة موزعة على سبعة أبواب. شمل الآتي:

**أولاً: الأحكام العامة:** وردت بالباب الأول (م ١ : ٥) قانون، وقسمه إلى فصلين: التعريفات وأهداف القانون، والتنظيم المؤسسي للتعاقدات. (إدارة التعاقدات والمهام الموكولة إليها). ويقابله باللائحة: المواد (١ : ٨)، وقسم إلى ثلاثة فصول: التعريفات وأهداف القانون، التنظيم المؤسسي للتعاقدات العمومية، ويشمل: الهيئة العامة للخدمات الحكومية. وإدارة التعاقدات والمهام الموكولة إليها، والمبادئ العامة. **وثانياً: مبادئ وطرق التعاقد (المبادئ الحاكمة للتعاقد):** وردت بالباب الثاني (م ٦ : ٧) قانون. وباللائحة مبادئ التعاقد المواد (٩ : ١١).

**وثالثاً: القواعد العامة في الطرح والتعاقد:** وردت بالباب الثالث (٨ : ٥٢) قانون، وقسم إلى أربعة فصول حسب مراحل إبرام العقد: (ما قبل الطرح، ثم الطرح، ثم الترسية والتعاقد - وقسم الفصل الثالث على خلاف المشهور<sup>(١)</sup> إلى فرعين: اللجان. وأحكام الترسية والتعاقد - ومرحلة تنفيذ العقد). وباللائحة: الباب الثالث، المواد (١٢ : ٥٢)، وقسمه إلى خمسة فصول: الأول: مرحلة ما قبل الطرح، المواد (١٢ : ٣٦). وقسمه إلى

---

(١) تلاحظ وجود عيب صياغة تشريعية، ومخالفة المنهج العلمي بتقسيم الفصل إلى فروع بدلا من مباحث ومطالب، وترقيم، وطول في العرض.

سبعة فروع: (التعاقد المستدام، وخطة الاحتياجات، وتخطيط التعاقد، (١٢ : ١٤). الالتزام بتوافر الاعتمادات المالية والتصاريح والتراخيص اللازمة، (١٥ : ١٦). طلب المعلومات وطلب إبداء الاهتمام، (١٧ : ١٨). إعداد المواصفات الفنية، (١٩ : ٢٦). دراسة السوق وأسس وضع القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي، (٢٧ : ٢٩). مبلغ التأمين المؤقت ومذكرة الطرح، (٣٠ : ٣٢). كراسة الشروط والمواصفات، (٣٣ : ٣٦).

**والثاني: مرحلة الطرح، المواد (٣٧ : ٥٩).** وقسمه إلى ثمانية فروع: الإعلان أو الدعوة، م ٣٧. التأهيل المسبق، (٣٨ : ٤١). الإيضاحات والاستفسارات، (٤٢ : ٤٣). إعداد وتقديم العطاءات وحفظها (٤٤ : ٤٨). المظروف الفني (٤٩ : ٥٠). المظروف المالي، (٥١ : ٥٤). وفاة صاحب العطاء والتعاقد من الباطن (٥٥ : ٥٧). التعاقد مع العاملين بالجهة الإدارية وسريان العطاءات (٥٨ : ٥٩).

**والثالث: مرحلة الترسية والتعاقد، المواد (٦٠ : ٨٦)،** وقسمه إلى فرعين: اللجان (٦٠ : ٦١). وأحكام الترسية والتعاقد، م ٦٢ : ٨٦، وقسمه إلى خمسة أقسام: إجراءات البت الفني، م ٦٢ : ٦٩. وإجراءات البت المالي، م ٧٠ : ٧٨. الترسية وإخطار العطاء الفائز، م ٧٩ : ٨٠. والتأمين النهائي، م ٨١ : ٨٢. حظر التقدم بأكثر من عطاء، حظر تعديل العطاء والفصل في الخلاف وإيضاح أسباب عدم القبول، م ٨٣ : ٨٦.

**والرابع: مرحلة تنفيذ العقد (٨٧: ١٠٣)**، وقسمه إلى سبعة فروع: إدارة  
وتحرير العقد، م٨٧: ٨٨. والقواعد العامة في الصرف والسداد، م٨٩:  
٩١. والدفعة المقدمة وصرف الدفعات تحت الحساب، م٩٢: ٩٣.  
وتحصيل المستحقات، م٩٤: ٩٥. وتعديل حجم العقد أو قيمته، م٩٦: ٩٧.  
والتأخير في تنفيذ العقد، والتقاعس عن الاستلام، م٩٨: ٩٩. فسخ العقد  
الوجوبي أو الجوازي ووفاء المتعاقد، م١٠٠: ١٠٣. **والخامس: شروط**  
**تنفيذ العقود**، م١٠٤: ١٢٠، وقسمه إلى ثلاثة فروع: الشروط العامة  
لتنفيذ العقود، م١٠٤: ١٠٦. وشروط تنفيذ عقود توريد المنقولات واستلام  
العقارات، م١٠٧: ١١٥. وشروط تنفيذ عقود المقاولات، م١١٦: ١٢٠.  
**ورابعاً: شراء واستتجار المنقولات والعقارات والتعاقد على مقاولات**  
**الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية:** وردت  
بالباب الرابع (٥٣: ٦٦) قانون. وباللائحة (١٢١: ١٣٩).

**وخامساً: بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها**  
**الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات**  
**والمشروعات (التصرف في الأموال العامة).** وردت بالبواب الخامس  
(٦٧: ٧٢) قانون. وباللائحة: (١٤٠: ١٥٠).

**وسادساً: التعاقدات ذات الأحكام الخاصة:** القانون: وردت بالبواب  
السادس (٧٣: ٨٠) قانون. وباللائحة: (١٥١: ١٦٥). وتتضمن ٣  
فصول: التعاقد على الدراسات الاستشارية، م١٥١: ١٦١. التعاقد مع

مقدمي الخدمات الأساسية والمشروعات الصغيرة، م١٦٢: ١٦٣.  
التعاقدات بناء على مبادرة من القطاع الخاص، وعقود الصفقات،  
م١٦٤: ١٦٥. **سابعًا: الأحكام الختامية والمتفرقة:** وردت بالباب  
السابع، م٨١: ٩٣. وبالإضافة م١٦٦: ١٨٠.

### المبحث الثالث

#### المبادئ الحاكمة لإبرام العقود الإدارية

نصت المادتين (٦) من قانون التعاقدات، و(٤) من لائحته التنفيذية  
على أن: "تخضع إجراءات وطرق وأساليب التعاقد لمبادئ الشفافية،  
وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص".

وهو ذات ما قرره في أهداف القانون م(٣/٢) - لذا كان يجب حذف م٦  
منعًا للتكرار - من ضرورة تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة  
وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح. وأن  
يلتزم العاملون بالجهات الإدارية بإنفاذ ما ورد من معايير ومبادئ  
الشفافية، ويحظر تعارض المصالح فيما يؤديه من إجراءات التعاقد،  
وعليهم مراعاة مدونة السلوك الوظيفي التي تصدر عن وزير المالية.  
ومراعاة ممارسات أعمال الحيدة والمعايير المتعارف عليها.

يؤكدده فتاها أن: "البين من استعراض جميع أحكام قانون تنظيم  
التعاقدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ أنها تتعلق بتنظيم الإجراءات السابقة

على إبرام تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكامه، وتقوم هذه الإجراءات في مجملها على مبادئ العلانية والشفافية والنزاهة وإتاحة سبل التنافس المشروعة بين جميع راغبي التعاقد مع الجهات الإدارية، فهو قانون قوامه الرئيسي العلانية في كافة مراحل وإجراءات التعاقد بهدف الوصول إلى أفضل شروط وأحسن مزايا تحقق مصلحة هذه الجهات"<sup>(١)</sup>.

واتفق مع بعض الفقه<sup>(٢)</sup> في أن المبادئ الرئيسة الحاكمة لإبرام العقود الإدارية تنوع إلى ثلاث مجموعات: مبادئ تتعلق بالقانون الخاص، وأخرى بالقانون الإداري، وثالثة بعملية الإبرام ذاتها. وهو ما نوضحه:

**أولاً: المبادئ الحاكمة لإبرام العقود الإدارية والمتعلقة بالقانون الخاص:** وهي ما تتعلق إجمالاً في مبدأي الرضائية، والمفاوضة.

فالعقد الإداري كعقود القانون الخاص تقوم على مبدأ الرضائية، والذي يفترض توافق الإرادتين، أي كان طريقة تعاقد، وبصفة خاصة الممارسة، والاتفاق المباشر، بعكس المناقصة فتتعلق بهامش محدود من الرضائية.

ويقصد بالرضا: التعبير عن الإرادتين المتقابلتين دون ضرورة تطلب شكلية معينة. بعكس القانون العام فيستلزم الشكل الكتابي كوسيلة لإثبات توافق الإرادتين، وإلا كان العقد باطلاً؛ باعتبارها عقوداً نموذجية ونمطية.

وأما مبدأ المفاوضة فهو من سمات القانون الخاص، يعني: تبادل المنافع بين الطرفين بشكل يحقق التعادل والتوازن. أو القيام بنشاط أو

---

(١) الفتوى رقم (٦١٨) بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٠، ملف رقم ٦٢٠/١/٥٤. لدي المستشار د/محمد علاء زعزع، موسوعة، مرجع سابق، ص ٢٥٨.  
(٢) المستشار د/ عبد الفتاح صبري أبو الليل: أساليب التعاقد، مرجع سابق، ص ٤٠٦.

سلوك ذي صبغة تجارية، في جو من الصراحة والثقة من الطرفين، دون تحويله إلى منازعة؛ تهدف الإدارة منه الحصول على أحسن الشروط. وتتقسم المفاوضة إلى خارجية، وداخلية. فالمفاوضة الخارجية: تنظم العلاقة بين الإدارة والمقاولين؛ بهدف الحصول على أحسن الشروط فنيا واقتصاديا وأثناء مرحلة التنفيذ.

وأما المفاوضة الداخلية: فتتظم العلاقة بين الإدارة المتعاقدة "المشتري العام" مع المرفق المستخدم لهذه المنتجات لتحديد احتياجاتها. مثال: قيام إدارة المشتريات بالجامعة بالشراء الموحد ثم ترسل كل كلية احتياجاتها إلى الجامعة لتقوم لجنة الاحتياجات بالموافقة وتوزيعها بما يحقق العدالة، وسد حاجة الكليات وفق معايير محددة، كالجودة وغيرها. وقد أدى تطور الحياة الإدارية والاقتصادية المعاصرة إلى تطور دور الدولة، وحلول فكرة المفاوضة محل امتيازات السلطة العامة في كثير من الميادين، وخصوصا في إطار العقود الإدارية<sup>(١)</sup>.

**ثانيا: المبادئ الحاكمة للتعاقد الحكومي والمتعلقة بالقانون الإداري:**

وهي ما تتجسد في عدة مبادئ، من أبرزها ما يلي:

#### ١ - مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص:

وهو ما يعتبر أحد المبادئ الرئيسة للقانون الإداري، وقانون العقود العامة، وقد احتل مكانا متميزا منذ القرن الماضي في وضع الأسلوب

---

(١) المستشار د/ عبد الفتاح صبري أبو الليل: أساليب التعاقد، مرجع سابق، ص ٤٠٨.



العام في اختيار المتعاقدين، وتنظيم عملية مراحل إبرام العقد الإداري، وحالات الاستبعاد، والأولية والأفضلية بمنح بعض المشروعات، وغيرها من الحالات التي قد يستحيل فيها تطبيق مبدأ المساواة لضرورات واعتبارات المصلحة<sup>(١)</sup>.

ويتعين احترام مبدأ المساواة من قبل الكافة، من خلال إقراره بين جميع المتنافسين، دون تفرقة أو تمييز بينهم، سواء بالتمييز القانوني المباشر أو غير المباشر، أو بالتمييز الفعلي. فلا يتم إعفاء بعض المتنافسين من شروط معينة دون الآخرين، أو إضافة شروط، أو حذفها، أو تعديلها لهم<sup>(٢)</sup>. وهي ليست مساواة مطلقة.

ويستحيل أن يحدث تمايزا في الأحكام بالنسبة للمراكز القانونية الموحدة أو المتشابهة، وفكرة المصلحة العامة؛ تبعا لاختلاف الوضع الاقتصادي للأفراد وبالأخص في مجال العقود الإدارية<sup>(٣)</sup>.

يؤكدده فتواها بأن المشرع استهدف بموجب قانون تنظيم التعاقدات تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام عن طريق التأكيد على تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، وتطوير طرق التعاقد لتتماشي مع التطورات الاقتصادية وتلبي احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية. كما أعلى من قيم العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص؛ وذلك للقضاء على

---

(١) د/ عبد الفتاح أبو الليل: أساليب التعاقد، مرجع سابق، ص ٤١٢. وقارن ص ٤١٤ وما بعدها.

(٢) د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة: الأسس، مرجع سابق، ص ١٥٩.

(٣) المستشار د/ عبد الفتاح أبو الليل: أساليب، المرجع السابق، ص ٤١٣ وما بعدها.

ممارسات الاحتيايل والفساد والاحتكار تشجيعا للجهات الخاضعة لأحكام قانون التعاقدات على تبني حلول مبتكرة وتقنيات متطورة لتوفير متطلباتها وتهيئة المناخ الذي يكفل المنافسة وتكافؤ الفرص<sup>(١)</sup>.

وقد يرد على مبدأ المساواة بعض الاستثناءات لاعتبارات شخصية - بسبب مركزهم القانوني، أو الجنسية، أو طبيعة النشاط. مثال: حظر الموظفين العموميين والعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون التعاقدات التقدم بالذات أو بالواسطة بطلبات أو عروض، ولا يجوز شراء أصناف منهم أو تكليفهم بأعمال من الاشتراك في المناقصة<sup>(٢)</sup>.

أو لاعتبارات نوعية<sup>(٣)</sup>، كالحالات التي يتم التعاقد عليها في أسلوب المناقصة المحدودة، والمناقصة الدولية، والاتفاق المباشر.

## ٢ - مبدأ المشروعية ومراعاة المصلحة العامة:

وهو ما يُعد الركيزة الأساسية للعقود الإدارية، ويقضي أن تلتزم به الإدارة في جميع مراحل التعاقد، وعلى رأسها قانون تنظيم التعاقدات العامة ولوائحه التنفيذية. كما يلتزم المتعاقد بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد. وإلا ترتب على مخالفته بطلان العقد أو بعض شروطه. وأكدته أحكام القضاء وفتاويه.

---

(١) الفتوى رقم (٢٢٨٦) بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠، ملف رقم ٦٢٣/١/٥٤. ورقم (٢١١٥) بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٠، ملف رقم ٦٢١/١/٥٤. لدي المستشار د/ محمد علاء زعزع: موسوعة، مرجع سابق، ص ٢٥٨.

(٢) المادة (٢٦) من القانون.  
(٣) د/ فايز بن زايد الحارثي: مبدأ المساواة في العقود الإدارية والاستثناءات الواردة عليه في القانون الإداري السعودي، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهننا الأشرف، ع ٢٦، ج ٣، ٢٠٢٣، ص ٢٨٧٧ وما بعدها.

### ٣- مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد:

وهو أحد المبادئ الأساسية في القانون الإداري التي تحكم عمل المرافق العامة، والمقامة بقصد إشباع خدمات أساسية وحاجات عامة لجمهور المواطنين. لذا وجب عدم تعطيلها، بل المحافظة على دوام سيرها وعملها بانتظام واطراد، ودون توقف أو انقطاع وإلا فقد الأفراد فرصة الانتفاع من خدمات المرفق العام<sup>(١)</sup>. فطول إجراءات تنفيذ العقد في أي مرحلة قد يفوت على المتعاقد فرصة مالية أو استثمارية.

### ٤- مبدأ تنفيذ العقد الإداري التزام وحق معا:

يُعد تنفيذ العقد من جانب المتعاقد مع الإدارة التزامًا وحقًا في آن واحد؛ فهو ملتزم قانونًا بتنفيذه وفقًا للقواعد القانونية المقررة وكراسة الشروط والمواصفات، وبنود العقد في المواعيد المحددة. ولا يجوز له الامتناع عن تنفيذ التزاماته أو التوقف عنها من تلقاء نفسه، مهما كانت الأسباب، كالتذرع بتقصير الإدارة، أو إخلالها ببعض التزاماتها. بل يظل مسئولًا عن تنفيذ العقد بأكمله<sup>(٢)</sup>. باعتباره وسيلة غايتها النفع العام وليس الإدارة.

(١) د/ محمود الجبوري: ضمانات الأفراد في الإجراءات الإدارية، إريد للبحوث والدراسات، مج ١، ع (١)، ١٩٩٨، ص ٩٦ وما بعدها.

(٢) د/ إبراهيم الشهاوي: الامتياز بنظام (B.O.T) وأهميته الاقتصادية، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، مج ١٣، ع ٢، ديسمبر ٢٠٠٥، ص ٣٣٦.

**ثالثا: المبادئ الذاتية للتعاقد الإداري وفقا لقانون التعاقدات والقضاء:**

وهي مبادئ ذاتية خاصة أساسية، يلزم توافرها في بعض العقود الإدارية، حسب موضوعها، وطبيعتها الخاصة. وتتمثل في الآتي:

١- ضرورة توافر شرط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة الواجب توافرها في مقدمي العروض، وغيرها من المعايير الموضوعية المحددة من قبل جهة الإدارة، ضمن شروط الطرح<sup>(١)</sup>، وبما يتفق وأحكام القانون واللائحة. مثال: إصدار الإدارة طلب تأهيل مسبق للمشتغلين بنوع نشاط معين محل العملية المزمع طرحها.

٢- تفضيل المنتجات والمصنوعات والخدمات الوطنية المصرية في العقود الحكومية، وما يعامل معاملتها من منتجات وخدمات الدولة الأخرى، وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥<sup>(٢)</sup>، والزام الإدارات بها عند التعاقد؛ تشجيعا من المشرع للمنتج المصري المحلي.

٣- التقيد بالثمن المتفق عليه في العقد ما لم يوجد مانع قانوني: فقضت بأن: (حقوق المتعاقد تتحدد أصلا طبقا لنصوص العقد.. فالأسعار المتفق عليها تقيد طرفيه كأصل عام،.. ذلك أن الشروط المتعلقة بالمقابل النقدي في العقد تنسم بطبيعة الاستقرار..)<sup>(٣)</sup>.

---

(١) المادة (٣٢) من قانون التعاقدات الحكومية.  
(٢) الجريدة الرسمية، ع (٣) مكرر في ١٧ يناير ٢٠١٥ م. ولائحته التنفيذية المنشورة بالوقائع المصرية، ع (٢١٩) (تابع) في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٥ م. وهو: "كل منتج صناعي يتم إنتاجه في داخل جمهورية مصر العربية، أو في المناطق الحرة.  
(٣) حكم الإدارية العليا في الطعين رقمي ٧١١١٨ و ٧٤١٧٥ لسنة ٦٧ ق. ع، جلسة ٢٠٢٣/٨/٣١. وحكمها في الطعن رقم ٧٤٢٦١ لسنة ٦٣، جلسة ٢٠٢٢/٦/٢٨. المستشار د/ محمد علاء زعزع، مرجع سابق، ص ٥٨٥ وما بعدها.

٤ - سريان القوانين واللوائح التي تم التعاقد في ظلها ما لم يقرر العكس، وهو ما أكدته الكتاب الدوري لسنة ٢٠١٩<sup>(١)</sup> في أن العمليات التي تم الإعلان عنها، أو توجيه الدعوات لها، أو إصدار أمر الإسناد بالنسبة للاتفاق المباشر، أو التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ تظل خاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم ٩٨ لسنة ١٩٨٩ ولائحته التنفيذية؛ لحين إتمام التنفيذ<sup>(٢)</sup>. وقضى به القضاء الإداري في العديد من أحكامه، ومنها أن: (الأصل في القاعدة القانونية سريانها على الوقائع التي تتم من تاريخ العمل بها. ويستثنى منه العقود؛ إذ تظل المراكز العقدية الجارية حتى بعد صدور قانون جديد، محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا القانون الجديد..."<sup>(٣)</sup>).

٥ - إلزام المتعاقدين بقبول تعديل العقد زيادة أو نقصا، وله الحق في التعويض. كونها القوامة على تنظيم المرفق وتحديد قواعد تسييره.

---

(١) رقم (٣) لسنة ٢٠١٩، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بتاريخ ٢٠/١/٢٠١٩.  
موقع الهيئة العامة للخدمات الحكومية. <http://www.gags.gov.eg/Home/Low182> (2)  
(٣) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٢٤٠٢ لسنة ٦١ ق.ع، جلسة ٢٠٢٠/٢/٢٥. المستشار د/ محمد علاء، مرجع سابق، ص ٢١٢ وما بعدها. وفي الطعن رقم ١١٧٢ لسنة ٣٧ ق.ع، جلسة ٢٠٠٠/٢/١٥، المكتب الفني، س ٤٥، القاعدة (٥١)، ص ٤٨١. والطعن رقم ٦٣١٦ لسنة ٤٤ ق.ع، جلسة ٢٠٠١/٤/٢٨. مكتب فني، س ٤٦، القاعدة (١٤٨)، ص ١٥٥١.

## الفصل الثاني

### أركان العقد الإداري

#### تمهيد وتقسيم:

استقر القضاء الإداري الفرنسي والمصري على أن أركان العقد سواء كان مدنيا أو إداريا تنحصر في التراضي والمحل والسبب<sup>(١)</sup>. إذ يتشابهان من حيث التكوين في وجوب توافر الأركان العامة اللازمة للانعقاد، وهي: الرضا، المحل، السبب، والشكل عند الاقتضاء.

وسوف نتناول أركان العقد الإداري في أربعة مباحث رئيسة، كالتالي:

#### المبحث الأول

##### الرضا كركن من أركان العقد الإداري

##### أولاً: تعريف الرضا وأهميته وشروطه:

الرضا هو التعبير الصريح والصحيح عن الإرادة، باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفاً، وغيره من المقرر قانوناً؛ بقصد إحداث أثر قانوني، يتمثل في إبرام العقد أياً كان موضوعه وطبيعته.

ويُعد الرضا ركناً جوهرياً في تكوين العقود جميعاً، إذ لا ينعقد العقد إلا إذا تلاقت إرادتان على وجه مطابق. بشرط أن يكون هناك إيجاب وقبول. وأن يكون خالياً من عيوب الإرادة المعروفة، حتى يكون صحيح قانوناً.

---

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٤٦ ق. ع، بجلسة ٢٠٠٥/٢/١، المجموعة، مرجع سابق، ص ٥١٥.

والعقد الإداري شأنه شأن عقود القانون الخاص يقوم أساساً على وجود إرادتين متطابقتين، ومتوافقين لقيام الرابطة العقدية، بما اصطُح عليه بالإيجاب والقبول. بحيث إذا لم يوجد هذا التراضي، أو تخلفت شروط صحته، كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال حسب الأحوال<sup>(١)</sup>.

وقد نصت المادة (٨٩) مدني على أن: "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد".

وهو ما يسري أيضاً على العقد الإداري، مع مراعاة أن رضا الإدارة يخضع أحياناً لإجراءات شكلية، مثل موافقة السلطة المختصة، أو إدراج الاعتماد المالي، وغيرها.

كما أن إرادة الإدارة مقيدة بمبدأ المشروعية والسلطة التقديرية المقيدة، والمبادئ الحاكمة لإبرام العقد.

ولا يشترط إ فراغ الإرادتين للمتعاقدين في شكل معين، يل يكفي التقاء الإرادتين حتى تقوم شروط وبنود العقد مقام القانون، وتصبح حاكمة للعلاقة بين الطرفين، وبذلك يضحى العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون<sup>(٢)</sup>.

---

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا رقم ٢٩٧ - ١٦ق، بتاريخ ١٩٧٤/٦/٢٩، ٤٥٠/١٥٢/١٩، المجموعة، مرجع سابق، ص ٧٣٣ وما بعدها.  
(٢) الفتوى رقم ١٥٥٣، بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٣، ملف رقم ٦٩٩/١/٥٤. المستشار د/محمد علاء ززع: موسوعة، مرجع سابق، ص ٥.

## ثانياً: آلية التعبير عن الإرادة في العقود الإدارية:

يتم التعبير عادةً في الإيجاب والقبول. ويتمثل الإيجاب في العرض الذي تتقدم به الإدارة الطالبة أو المستفيدة، والمسئولة عن تحديد احتياجاتها ومتطلباتها، المرتبطة بمحل التعاقد إلى مجتمع الأعمال-المتعاملون مع الجهات الإدارية من الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين والمتزايدين وغيرهم- وحسب طبيعة العقد؛ بغرض الحصول على قبوله من عدمه.

وهو ما يلزم معه وجود اتصال وارتباط أحدهما بالآخر حتى يمكنه التعبير البات عن قبوله حتى ينعقد العقد صحيحاً ومنتجاً لآثاره<sup>(١)</sup>.

ووفقاً للأصل العام أن من يوجه الإيجاب في العقد الإداري إنما يوجهه على أساس الشروط العامة المعلن عنها، والتي تستقل الإدارة بوضعها دون أن يكون للطرف الآخر حق الاشتراك في ذلك، وليس لمن يريد التعاقد إلا أن يقبل هذه الشروط أو يرفضها، فإذا أراد الخروج في عطائه على هذه الشروط كان على الإدارة استبعاده من هذا العطاء<sup>(٢)</sup>.

فالتعاقد مع الإدارة لا يكون كالطرف المذعن في عقود الإذعان، إذ لا مثيل لها في العقود الإدارية، فالمقاول في عقد الأشغال يكون بالخيار بين تعاقد مع جهة الإدارة مع علمه سلفاً بالقيود المقررة قانوناً، أو يتعاقد

---

(١) د/ حمدي العجمي: المرجع، مرجع سابق، ص ٧٤. محمد بدر أحمد علوي: الطبيعة القانونية للعطاء في المزايدات إيجاب أم قبول، المجلة القانونية، كلية الحقوق، فرع الخرطوم- جامعة القاهرة، مج ١٣، ع ٣٦، أغسطس ٢٠٢٢، ص ٦٦٦ وما بعدها.  
(٢) حكمها في الطعن رقم ٣٣٣ لسنة ١٠٠٠، بتاريخ ١٢/٢/١٩٦٧، مكتب فني ١٣، ص ١٦٦.



في ظل القانون الخاص وفق مصلحته الخاصة. فالنية المشتركة للمتعاقدين هي أساس تحديد الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد الإداري<sup>(١)</sup>. وبذلك يفترق الإيجاب عن الدعوة للتعاقد والموجهة إلى أشخاص محددين؛ إذ قد جرى القضاء على أن الإعلان عن إجراء مناقصة أو مزيدة أو ممارسة لتوريد أو لبيع بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاء ليس إلا دعوة على التعاقد، وأن التقدم بالعطاء وفقا للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها هو الإيجاب الذي ينبغي أن يلتقي عنده قبول الإدارة لينعقد العقد، وهذا القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يتحقق وجوده القانوني إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه<sup>(٢)</sup>.

وتأكيداً له تعد مستندات الطرح في المناقصات والمزايدات بمثابة العرض من جهة الإدارة، وأن التقدم بالعطاء يعد إيجاباً من مقدم العطاء- صاحب العطاء أو من يفوضه في تقديم عطائه للجهة الإدارية-، وأن رسو العطاء على العطاء الفائز-الأفضل شروطاً والأقل سعراً أو الذي يتم ترجيحه والذي تم إخطاره بالترسية عليه- إنما هو القبول الذي يصدر من الإدارة، وأنه متى اتصل علم الموجب بصدور القبول عن طريق

---

(١) د/ محمد سعيد حسين أمين: المبادئ العامة، مرجع سابق، ص ١٦.  
(٢) حكمها السابق في الطعن رقم ١٧٠١٦ لسنة ٥٥ ق. ع، بجلسة ٢٧/٢/٢٠١٨. المستشار د/ محمد علاء زعزع: موسوعة، مرجع سابق، ص ٦. وأيضاً د/أماني حلمي عمر: الضوابط القانونية لصحة إجراءات الإيجاب والقبول بالعقد الإداري- دراسة فقهية قضائية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، حقوق عين شمس، مج ٥٨، ع ١٤، ج ١، يناير ٢٠١٦، ص ٤٣٣.

الإخطار برسو العطاء يكون العقد قد انعقد وإن لم يفرغ في محرر مكتوب، إذ أن الكتابة وسيلة إثبات<sup>(١)</sup>.

كما يعد عرضاً إعلان الجهة الإدارية عن طلب إبداء الاهتمام للمشتغلين بنشاط معين، أو طلب التأهيل المسبق للموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أو الاستشاريين وغيرهم للقيام بتنفيذ أحد العقود بالكفاءة المطلوبة قبل دعوتهم لتقديم العطاءات.

ولا يجوز التعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر وفقاً للمادتين (٦٢، ٦٣) من قانون التعاقدات إلا بناء على ترخيص وموافقة السلطة المختصة المقررة قانوناً. بعكس العقود النموذجية التي تحددها اللائحة التنفيذية فيجري التعاقد بناءً عليها دون تفاوض حر كما في العقود المدنية، بعد مراجعة إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لأنماطها. م ٩٠ قانون التعاقدات

### **ثالثاً: عيوب الإرادة في العقد الإداري:**

بالرغم من أن جهة الإدارة تمثل طرفاً قوياً في العقد، لما لها من مكنة وقدرة قانونية تمنحها مباشرة اختصاصاتها، فالأهلية التي تتمتع بها الأشخاص الاعتبارية هي أهلية منضبطة نصاً بالقانون، لارتباطها الحتمي بالطبيعة القانونية للشخص الاعتباري ووظائفها<sup>(٢)</sup>.

إلا أن إرادتها قد يشوبها العيب، لسبب أو لآخر، ومن أبرز هذه العيوب:

---

(١) الفتوى رقم ٦٧٩ بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٩. المستشار د/ محمد علاء زعزع: موسوعة، مرجع سابق، ص ٨.  
(٢) الفتوى رقم ١٣٠٦ بتاريخ ٩/٧/٢٠٢٠. المستشار د/ محمد علاء زعزع: موسوعة، مرجع سابق، ص ١٥.

## ١ - الغلط:

هو حالة تقوم بالنفس تحمل على توهم غير الواقع، وغير الواقع إما أن يكون واقعة غير صحيحة يتوهم الإنسان صحتها، أو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتها<sup>(١)</sup>. أي يتولد في ذهن ممثل الإدارة وهم كاذب يجعله يتصور الأمر على غير الحقيقة أو الواقع، بأن تكون الواقعة صحيحة فيتوهم عدم صحتها، أو العكس غير صحيحة فيتوهم صحتها.

أو هو: الغلط في مادة الشيء ذاتها. كالغلط المباشر في الشيء أو في صفاته الجوهرية، مثال: عدم وضع حدود للترميم أو التبليط، أو الغلط غير المباشر في الشيء<sup>(٢)</sup>.

ويختلف عن الخطأ المادي رغم التداخل بينهما، في أن الغلط هو أحد عيوب الإرادة، يؤدي إلى بطلان العقد نتيجة وهم كاذب، فالإرادة موجودة لكنها صدرت من شخص غير مقدر لأبعادها، لأنه ليس على بيئة كاملة من معطياتها. بعكس الخطأ فهو عملية منفصلة عن الرضا؛ نتيجة زلة قلم أو خطأ في الحساب، لذا يطلق عليه الغلط في القيمة، أو الغلط في الحساب، فلا غلطات للقلم ويتخذ في شأنه قواعد التصحيح<sup>(٣)</sup>.

ونادراً ما يُقبل الغلط كعيب في إرادة الإدارة في العقد الإداري، لمروره بمراحل وإجراءات عدة ما قبل وبعد الطرح، ومرحلة الترسية، فضلاً عن مهارة واحترافية أطراف العقد مما يصعب معه حدوث توهم كاذب، إلا إذا

(١) د/ عبد الرزاق السنهوري: الوسيط، مرجع سابق، ص ٣٨٢. وغيره.  
(٢) المستشار د/ عبد الفتاح أبو الليل: أساليب التعاقد، مرجع سابق، ص ٤٩٣.  
(٣) د/ حمدي العجمي: المرجع في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٨٤.

تعلق بواقعة جوهرية وخذعت الإدارة. متى بلغ حدا من الجسامة بحيث يتمتع معه المتعاقد على إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. وقد قضت بأن: "المتعاقد إذا ما توهم على غير الواقع من الظروف والملابسات التي أحاطت بالتعاقد أن التوريد كان محددا له أن يتم خلال أيام أو أسابيع قليلة من تاريخ التعاقد وليس شهورا ذات عدد واستبان من الظروف والملابسات التي أحاطت بالتعاقد أن المتعاقد كان سيمتتع عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط الذي شاب إرادته فإنه يكون على حق في طلب إبطال العقد للغلط الجوهرى إذا ما اتصل بالمتعاقد الآخر"<sup>(١)</sup>.

## ٢ - التدليس:

وهو أحد عيوب الإرادة أو الرضا الموجبة لبطلان العقد، يحدث نتيجة استعمال طرق احتيالية من جانب المتعاقد الآخر بشكل مخطط أو مدبر، أثناء إبرام العقد أو أثناء تنفيذه؛ للتأثير على إرادة الإدارة والغرر بها وتضليلها. ولا يشترط فيه أن يتعلق بصفة جوهرية في محل العقد كالغلط، بل يكفي مجرد وقوعه لطلب البطلان.

وتتمثل عناصر التدليس في القانونين المدني والإداري في عنصرين:

١ - استعمال الطرق الاحتياطية، ليس بالكذب فحسب، بل بالاعتماد على العناصر الشخصية والموضوعية للمتعاقد، فقد يكون السكوت والكتمان طريقا احتياطيا<sup>(٢)</sup>.

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا السابق رقم ٢٩٧ لسنة ١٦ق، بتاريخ ١٩٧٤/٦/٢٩.  
(٢) المستشار د/ عبد الفتاح أبو الليل: أساليب التعاقد، مرجع سابق، ص ٥١٠.

٢- نية التضليل وقصد التدليس من المتعاقد أو من يمثله لدفع المتعاقد الآخر وحمله على التعاقد معه، أو التعبير به بتصوير عرضه أنه من أفضل العروض، تبلغ من الجسامة، بحيث لولاها لما أبرم العقد.  
ويقع التدليس على ممثلي الجهة الإدارية، وبالتبعية يعتبر واقعا على الشخص المعنوي. لذا قضت أنه: "إذا ثبت أن المتعاقد لجأ إلى وسائل احتيالية أثّرت في إرادة الإدارة عند التعاقد، جاز لها المطالبة ببطالان العقد أو إنهائه"<sup>(١)</sup>.

ويقع على الطرف المدلس عليه عبء إثبات وقوع الطرق الاحتيالية ودفعه للتعاقد، ولا يكفي مجرد الادعاء فقط.

ويفرق الفقه المدني الفرنسي بين التدليس الدافع أو الأساسي والذي يترتب عليه البطلان، وبين التدليس العارض الذي لا يترتب عليه البطلان، ولم يثبت أن القضاء الإداري الفرنسي قد ميز بينهما بعد<sup>(٢)</sup>.

### ٣- الإكراه:

هو ضغط تتأثر به إرادة شخص فيندفع إلى التعاقد، نتيجة رهبة نفسية أو خوف توجده الوسائل المادية أو النفسية المستخدمة في الإكراه، والتي تبعث في نفس المتعاقد رهبة تصور له أن خطرا جسيما يتهدهده أو غيره مما يؤثر في نفسه إن لم يبرم العقد.

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٤٣٢ لسنة ٤٣ ق. ع، جلسة ٢٠٠٠/٤/١٥.

(٢) المستشار/ عبد الفتاح أبو الليل: المرجع السابق، ص ٥١٧ وما بعدها.

ويشترط فيه توافر عنصرين: العنصر الموضوعي والمتمثل في الوسائل المادية التي تهدد بخطر جسيم محقق. والعنصر النفسي وهو الرهبة النفسية التي تدفع للتعاقد، بالإضافة إلى كون الإكراه غير مشروع. ويتعلق الإكراه بالعنصر الإرادي للإدارة عنصر الحرية والاختيار بعكس الغلط والتدليس فيتعلقان بالعنصر العقلي للإرادة، وإن اشتركا في الأثر. ووقوع الإكراه في مجال العقود الإدارية نادر الحدوث، حتى ولو وقع فإن ما يطلبه المتعاقد هو التعويض فقط وليس بطلان العقد. ويقضى له القاضي الإداري بالتعويض على افتراض وقوع الإكراه ضمنيا<sup>(١)</sup>. وقد قضت بأنه: "لا وجه أيضا لما يدعيه الطاعن من أنه وقع تحت سلطان الرهبة والخوف من بطش المسؤولين بمجلس المدينة، إن لم يدعن للتعاقد ذلك أنه لم يقم دليلا على أن أحدا من المسؤولين بمجلس المدينة قد لوح للطاعن بأية وسائل لإكراهه على التعاقد.."<sup>(٢)</sup>.

#### ٤- الغبن:

هو التفاوت الكبير بين ما يقدمه أحد المتعاقدين وما يحصل عليه في المقابل.

وقد ثار خلاف حول مدى اعتباره سببا من أسباب بطلان العقد من عدمه. فاعتبره الفقيه الفرنسي جيز أحد عيوب الإرادة وليس من المسائل المتعلقة بسبب أو محل العقد.

---

(١) المستشار د/ عبد الفتاح أبو الليل: أساليب التعاقد، مرجع سابق، ص ٥١٩.  
(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا السابق رقم ٢٩٧-١٦ق، بتاريخ ٢٩/٦/١٩٧٤.

أما اتجاه القضاء الإداري فلا يعول كثيرا على قيمة الشيء محل العقد كشرط من شروط صحة العقد؛ إذ يهدف إلى استمرارية المرافق العامة في أداء مهمتها وضمان استقرار العقود.

وقد رفض مجلس الدولة الفرنسي العديد من الدعاوى المتعلقة بعدم تناسب المقابل الذي حصل عليه المتعاقد مع الإدارة، كما لا يجوز لموظف الدولة التمسك بالغبن في بيع عقارات الدولة التي تقوم على حرية المنافسة والمساواة بين المتنافسين، وتعتد الإجراءات بما يكفل تحقق الحماية المطلوبة لبيع عقارات الدولة<sup>(١)</sup>.

#### رابعاً: رضا الإدارة وضرورة موافقة السلطة المختصة:

لما كان يُشترط في الرضا بالعقد الإداري ما يُشترط في سائر العقود فإن الإدارة لا تُعتبر قد عبّرت عن رضاها الكامل بإبرام العقد إلا إذا صدر التعبير عن الإرادة من الجهة الإدارية المختصة قانوناً، وفق الإجراءات المقررة قانوناً. فلا يكفي فيها مجرد توقيع رئيس المصلحة -عميد الكلية مثلاً- على العقد، بل لا يتم العقد ولا ينتج آثاره القانونية إلا بعد موافقة السلطة الإدارية المختصة -رئيس الجامعة-، وفقاً لنصوص قانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية.

وقد نصت م ٣٩: (على إدارة التعاقدات إخطار مقدمي العطاءات بنتائج قرارات اللجان بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء فور اعتماد السلطة

---

(١) المستشار د/ عبد الفتاح أبو الليل: أساليب التعاقد، مرجع سابق، ص ٥٢٧.

**المختصة لها** بخطابات ترسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس، بحسب الأحوال، وفقا لعناوينهم وبياناتهم...).

ويفهم منه أن الرضا الإداري لا ينعقد بتمامه إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وموافقة السلطة المختصة ليست مجرد إجراء شكلياً، بل هي جزء لا يتجزأ من ركن الرضا في العقد الإداري، وأحد القيود المقررة التي تتم باسم الإدارة، ويتوقف عليها انعقاد العقد صحيحاً من عدمه.

## المبحث الثاني

### المحل كركن من أركان العقد الإداري

#### أولاً: تعريف المحل وأهميته:

المحل هو: موضوع العقد، أي العمل ذاته، الذي يلتزم المتعاقد بتنفيذه وأدائه قبل الآخر. أو: "الشيء الذي يلتزم المدين القيام به لصالح الدائن، إما بنقل حق عيني، أو إنشائه، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل"<sup>(١)</sup>. لذا فالمحل يحدد التزامات كل طرف من أطرافه.

وغالباً ما يلتزم المتعاقد بتقديم خدمة، أو تنفيذ عمل لصالح مرفق عام، أو بيع أو شراء أو استغلال مال عام حسب موضوع كل عقد. فالتزامه

---

(١) د/ عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في القانون المدني، مرجع سابق، ص ٢٣٩.



في عقد التوريد، يكون بتسليم المواد أو البضائع. وفي عقد الأشغال العامة يكون بتنفيذ المشروع محل العقد كإنشاء كلية أو مستشفى ونحوه. ويُعد المحل من الأركان الجوهرية لانعقاد العقد، إذ لا يقوم التعاقد بدون موضوع يهدف إليه الطرفان. وهو ما يلزم الجهات الإدارية وإدارة التعاقدات بتحديد محل الطرح وموضوع العقد بشكل دقيق ومحدد تحقيقاً للصالح العام.

ويحظر اللجوء إلى تجزئة محل العقود محل الطرح، بتقسيمها إلى أجزاء، لكل منها كمياته وبنوده وقيمتها<sup>(١)</sup>؛ بغرض تغيير طريق التعاقد، أو بقصد التحايل على الموافقات المرتبطة بالحدود والنسب والسلطات المالية لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات المقررة قانوناً، وغيرها من ضوابط وضمانات مقررة<sup>(٢)</sup>.

كما لا يجوز أن يقوم المتعاقد الأصلي بالتنازل أو التعاقد مع الغير من الباطن؛ بقصد تنفيذ جزء من محل العقد.

#### ثانياً: طبيعة المحل في العقود الإدارية:

يتخذ المحل في نطاق العقود الإدارية طبيعة خاصة؛ لارتباطه بالمرفق العام من جهة، فغالبا ما يكون المحل مرتبطاً بتسيير أو تطوير مرفق عام، وتحقيق المصلحة العامة من جهة أخرى، فلا ينعقد العقد الإداري

---

(١) للتفصيل، عبد الرحمن بن عيسى محمد النعمي: حظر تجزئة المنافسة العامة - دراسة تحليلية تطبيقية في النظام السعودي، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهما الأشراف، ٢٥٤، ج ٢، ٢٠٢٢، ص ١١٤٤ وما بعدها.  
(٢) المادة ١٠ من قانون التعاقدات.

صحيحاً إذا لم يكن محلّه يحقق مصلحة عامة، سواء مباشرة أو غير مباشرة. مثال: عقد الأشغال العامة، عقد الامتياز، عقد التوريد. يؤكدته فتاها أنه: "يتعين على الهيئات العامة أن تقوم بنفسها على تحقيق الأغراض المنوطة بها... استعمالا للرخصة المخولة لها في قانون أو قرار رئيس الجمهورية بإنشائها أو تنظيمها، بما يخدم أغراضها أو يعينها على تحقيق هذه الأغراض"<sup>(١)</sup>.

### ثالثاً: شروط محل العقد الإداري:

يشترط فيه ذات ما يشترط في سائر العقود، وللقاضي الإداري أعمال سلطته التقديرية، وأن يراقب توافر الشروط، دون التقيد بنصوص القانون المدني<sup>(٢)</sup>. إذ يشترط ما يلي:

- ١ - أن يكون محل العقد مشروعاً، وقابلاً للتعامل فيه. أي غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، أو القوانين أو اللوائح، وإلا أصبح باطلاً. كالتعاقد على توريد سلع محظورة، أو مواد ضارة بالصحة العامة.
- ٢ - وأن يكون موجوداً وممكناً مادياً وقانوناً وقت إبرام العقد، أو قابلاً للوجود بعد ذلك مستقبلاً، وليس مستحيلاً وإلا كان باطلاً. فلا يجوز التعاقد على شراء أصول غير مملوكة بعد، ما لم تكن قابلة للتعيين والتملك مستقبلاً. أو التعاقد مع شركة أجنبية ممنوعة من العمل بالدولة.

---

(١) الفتوي رقم (٩٦٩) بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٠٦، ملف رقم ٢٥٤/١/٤٧. المستشار د/محمد علاء زعزع: موسوعة، مرجع سابق، ص ١٩ وما بعدها.  
(٢) المستشار د/ عبد الفتاح أبو الليل: أساليب، مرجع سابق، ص ٥٣٤ وما بعدها.

وأتفق مع بعض الفقه<sup>(١)</sup> في أن الاستحالة النسبية لا يترتب عليها بطلان العقد الإداري سواء كانت الاستحالة سابقة على وجود العقد أم لاحقة، وإنما تجعل العقد في الحالتين قابلاً للفسخ فقط وليس باطلاً.

٣- وأن يكون معينا بذاته، أو بنوعه ومقداره، ومعلومًا علماً نافياً للجهالة، أو قابلاً للتعيين، وليس مجهولاً جهلاً فاحشاً. وإلا صار باطلاً. كمن يتعاقد على توريد بضائع أو سلع دون أن يحدد الكمية، والمواصفات، والمواعيد. أو توريد مياه صالحة للشرب لإحدى المدارس دون تحديد كمية معينة يلزم بتوفيرها يومياً... أو يتعاقد دون تحديد سعر، أو دون تحديد المقابل المستحق لقاء نقل السيارات<sup>(٢)</sup>. وغيره.

### المبحث الثالث

#### السبب كركن من أركان العقد الإداري

أولاً: تعريف السبب وأهميته: يقصد به: الدافع القانوني أو الغاية أو الغرض المشروع والمباشر الذي من أجله التزم كل طرف بالتعاقد. أو: الغرض المباشر الذي يقصد الملتمزم الوصول إليه من وراء رضاه التحمل بالتزامه<sup>(٣)</sup>.

وسبب الالتزام هنا يغطي فكرتين متميزتين: مقابل الالتزام. وياعث الالتزام. فكل تصرف تتداخل فيه الأسباب القريبة والغايات البعيدة.

(١) المستشار د/ عبد الفتاح أبو الليل: أساليب، مرجع سابق، ص ٥٣٣ وما بعدها.  
كإشارة المرجع السابق، ص ٥٣٣. (2) C.E.; 24 Mai 1968, Rec. P.331.  
(٣) د/ عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في القانون المدني، مرجع سابق، ص ٥٥٤.

ويلعب السبب المنشئ دوراً في الحماية الفردية، في حين يلعب السبب الغائي دوراً هاماً في الحماية الاجتماعية للمجتمع. ففي عقود المعاوضة الملزمة للجانبين فإن سبب التزام كل منهما هو التزام الآخر، ففي عقد البيع مثلاً يلتزم البائع بنقل ملكية الشيء المبيع للمشتري وتسليمه له رغبة في الحصول على الثمن، وفي المقابل يلتزم المشتري بدفع الثمن رغبة في الحصول على المبيع.

ويُعد السبب ركناً جوهرياً لصحة العقد، إلى جانب الرضا والمحل. إلا أنه يختلف عن المحل، فإذا كانت الإجابة عن المحل هي بماذا التزم المدين؟ فإن الإجابة عن السبب تتضمن لماذا التزم المدين؟ أو لماذا أراد المدين أن يلتزم؟<sup>(١)</sup>.

ويحتل السبب في العقد الإداري أهمية خاصة؛ لارتباطه بالمصلحة العامة، واحتياجات المرفق العام، وبالهدف من التعاقد في ذاته.

ولا يكفي توافر النية أو الباعث الشخصي لأحد الطرفين، بل يجب أن يكون السبب مشروعاً، واضحاً، ومستمدّاً من حاجة حقيقية للمرفق العام، وأن يتطابق مع أهداف الإدارة، وإلا عُدَّ العقد باطلاً لانعدام أحد أركانه.

وإذا كان للقاضي الإداري أن يراقب مشروعية السبب من عدمه، فإن الأحكام القضائية قليلة جداً في هذا الشأن، منها ما قضت به محكمة القضاء الإداري في حكم قديم لها: (... ومن حيث إن التزام صاحب

---

(١) د/ عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق، ص ٥٥٤. د/ حمدي العجمي: المرجع، مرجع سابق، ص ٩٢.

المطحن بإنتاج عدد معين من أوقات الدقيق الصافي من كل أردب من القمح الذي تقوم بتسليمه إليه سلطات التمويل، ثم مساءلته عن عدم انتاج هذا المقدار يجب أن يقوم على سبب قانوني.

وهذا السبب يكون إما بنص في التشريع، أو بنص في لائحة صادرة من جانب المطحن يمثل هذه المعدلات المقررة عند إبرامه العقد مع جهة الإدارة التي تهيم على مرفق التمويل في البلاد، وإما باتفاق يتضمن ذكر المعدل المقصود، وينبه إلى ضرورة الإنتاج على مقتضاه فإذا جاء خلوا تماما من مثل هذا النص فقد يسترشد القاضي بما هو من مستلزمات العقد وفقا للعرف الجاري في التعامل بحسب طبيعة كل التزام<sup>(١)</sup>.

**ثانياً: عناصر السبب في العقد الإداري: تتمثل في:**

١- **وجود السبب:** أي أن يكون هناك باعث حقيقي على التعاقد من قبل الإدارة، كالحاجة إلى إنشاء طريق أو بناء مستشفى، أو شراء معدات. ويعول القضاء الإداري الفرنسي على قيام السبب ووجوده عند إبرام العقد، لرفض بطلان العقد<sup>(٢)</sup>.

٢- **مشروعية السبب:** فلا يتعارض الهدف من العقد مع القانون أو النظام العام أو المصلحة العامة. يؤكد نص م ١٣٢ مدني: (١- يكون العقد باطلا إذا التزم المتعاقدون دون سبب أو لسبب ممنوع قانونا

---

(١) حكمها في القضية رقم ٣٤٨٠ لسنة ٩ بجلسة ٢ يونيو ١٩٥٧. مشار إليه لدى د/سليمان الطماوي، الأسس، مرجع سابق، ص ٣٤١. والمستشار د/ عبد الفتاح أبو الليل: أساليب، مرجع سابق، ص ٥٤٧. د/ حمدي العجمي: مرجع سابق، ص ٩٣.  
(2) C.E., 19 février, 1988, Sarl pore gestion c/c ne de saint Ouen, D.A., 1988, no. 175.

ومخالف للنظام العام أو للآداب. ٢- ويفترض في كل التزام أن له سببا مشروعاً ولو لم يذكر في العقد ما لم يقيم الدليل على غير ذلك).

٣- **عدم مخالفة السبب لأهداف جهة الإدارة:** فلا يجوز مثلاً تعاقد الجهة الإدارية لتفضيل متعهد معين على غيره، أو لتحقيق منفعة شخصية، وإلا اعتبر من باب التواطؤ والاحتيال والفساد ومجانبة المصلحة العامة، رغم توافر باقي الأركان.

### ثالثاً: حالات البطلان لانعدام أو عدم مشروعية السبب

١- **حالة انعدام السبب:** حيث يبطل العقد الإداري إذا لم يكن له سبب موضوعي حقيقي غير موجود ولا ينتج أي أثر، باعتباره أحد أركان العقد. لذا قضى ببطلان عقد شركة الرسائل البحرية، لانعدام السبب<sup>(١)</sup>.

٢- **حالة غياب السبب بعد إبرام العقد:** وهو ما يبرر فسخ العقد لا بطلانه. فالأصل أن التطوع بالمساهمة أمر اختياري، فإذا لم تقم جهة الإدارة بتنفيذ المشروع الذي قدم العرض من أجله فإن سبب العقد يزول.

٣- **حالة عدم مشروعية السبب:** يبطل العقد إذا كان السبب غير مشروع، بأن كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة. والأحكام القضائية لهذه الحالة نادرة الحدوث. فيندر قيام المقاول باستئجار مبني أو شاطئ من الإدارة لإدارته للقمار، وإلا طبقنا أحكام التدليس. ويشترط توافر العلم المشترك لطرفي العقد، والباعث غير المشروع للتعاقد.

---

(١) المستشار د/ عبد الفتاح أبو الليل: أساليب التعاقد، مرجع سابق، ص ٥٤٨.

٤ - حالة إذا ما تبين أن الإدارة تعاقدت لغرض شخصي أو غير مرتبط بخدمة عامة: متي ثبت أن الإدارة تتكسب من المصلحة العامة، أو أنها تخالف قاعدة تخصيص الأهداف.

مثال: إبرام عقد توريد أجهزة لمستشفى حكومي، تبين لاحقاً أنها لا تلبي حاجة فعلية، وإنما تمت بناءً على ضغوط شخصية، وتحقيق مكاسب خاصة. أو تم التعاقد بالمخالفة للاعتمادات المالية المخصصة.

وإذا كان السبب غير المشروع هو الذي دفع إلى التعاقد فلا وجه للتمسك بفكرة الانحراف في استعمال السلطة<sup>(١)</sup>.

## المبحث الرابع

### الشكلية في بعض صور العقود الإدارية

أولاً: مبدأ الرضائية كأصل عام:

يشكل مبدأ الرضائية الأصل العام في تكوين العقود بوجه عام، سواء كانت مدنية أو إدارية، حيث يكفي تلاقي الإرادتين لإنشاء العقد، دون اشتراط شكل معين ما لم يقرره القانون.

وهو ما لا يسود مطلقاً في العقود الإدارية<sup>(٢)</sup>، إذ يحد منه خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية، وما يتفرع عنه من التزامها اتباع إجراءات وشكليات

---

(١) المستشار د/ عبد الفتاح أبو الليل: أساليب، مرجع سابق، ص ٥٥٧. د/ محمد حمد علام: مدى خضوع العقود الإدارية لأحكام وقواعد القانون الخاص-دراسة مقارنة، بدون، ٢٠٢٥، ص ١٥١ وما بعدها.

(٢) د/ محمد حمد علام: مدى خضوع العقود الإدارية لأحكام وقواعد القانون الخاص-دراسة مقارنة، بدون، ٢٠٢٥، ص ١٥١ وما بعدها.

معينة تسبق أو تصاحب أو تلحق إبرام العقد، تحقيقاً للرقابة، وضماناً لحسن التصرف في المال العام.

يؤكدده فتاها: (وإنه في مجال عقود الإدارة فإنها تخضع من حيث الأصل لقاعدة التحرر من الشكليات، فإذا لم يشترط المشرع صراحة إجراء شكليا معينة في إبرام العقد...) (١).

### ثانياً: مفهوم الشكلية في العقود الإدارية

يقصد بها: ضرورة اتباع الإجراءات القانونية والمالية والإدارية التي يلزم اتباعها عند إبرام العقد الإداري، والتي تمثل شرطاً لازماً لانعقاده أو لنفاذه. بمعنى آخر إلزام القانون للإدارة باتباع إجراءات محددة، أو إفراغ العقد في قالب رسمي معين لصحته أو لنفاذه.

وتمثل الشكلية قيداً جوهرياً على إرادة الإدارة في إبرام العقود، وعنصرًا لا غنى عنه في كثير من حالاتها؛ بهدف ضمان الشفافية، وفرض الرقابة. ويفرض المشرع العديد من القيود والضوابط الشكلية الإجرائية والموضوعية في مختلف مراحل إبرام العقد. وبالأخص في عقود التوريد والأشغال العامة، وعقد الامتياز.

### ثالثاً: الطبيعة القانونية الإلزامية للشكلية في العقود الإدارية:

تُعد الشكلية المقررة بنص إجراءً جوهرياً لازماً، يترتب على مخالفتها البطلان، وانعدام الأثر القانوني واعتباره كأن لم يكن.

---

(١) الفتوى رقم (١٥٥٣) بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٣. المستشار د/ محمد علاء زعزع: موسوعة، مرجع سابق، ص ٥.



وفرق بين شروط الصحة والنفاد، فالأولى لا ينعقد العقد إلا باتباع الشكل فيها، كضرورة أخذ الموافقة السابقة. أما الثانية فيكون العقد صحيحاً بين طرفيه، غير نافذ في مواجهة الغير إلا بعد إتباع إجراء معين. وتتعلق الشكالية بالنظام العام يتمسك به، وعدم مخالفته. فالكثابة شرط جوهرى لوجود نص، أو لطبيعة العقد، كعقد الامتياز وإلا صار العقد معدوماً.

يؤكدده فتواها: " .. وأنه وإن كان العقد غير المكتوب يعد وسيلة غير مألوفة في المجال الإداري، نظرا إلى جنوح الإدارة عادة إلى إثبات روابطها العقدية بالكثابة، فإنه لا يزال يؤدي دورا كاملا لبعض أنواع العقود، وقد تتضمن خطوات التعاقد وثائق مكتوبة ولو لم يفرغ العقد في النهاية وثيقة مكتوبة، وينعقد العقد صحيحا منتجا لآثاره القانونية.." (١).

---

(١) الفتوي رقم (١٢٧٩) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣، ملف رقم ٥٦٧٩/٢/٣٢. وفتواها رقم (٣٨٠) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦، ملف رقم ٧٣٨/٦/٨٦.

## الفصل الثالث

### أنواع العقد الإداري

بعيداً عن الخوض في غمار تقسيمات العقود الإدارية على نهج العقود المدنية<sup>(١)</sup> فإن العقود الإدارية تتنوع بحسب طبيعتها، سواء من حيث محل العقد، أو طبيعة الإدارة المتعاقدة، أو وسيلة إبرامها، أو شكل تنفيذها<sup>(٢)</sup>، وخاصة في ظل التحول الرقمي وتوسع الإدارة في استخدام المنظومة الإلكترونية، وأخذها بالعقود الإلكترونية.

وسوف نتناول أهم صور العقود الإدارية، وأكثرها شيوعاً وعملاً فيما يلي:

### المبحث الأول

#### عقد التزام أو امتياز المرافق العامة

يُعد من أبرز وأشهر وأقدم صور العقود الإدارية المسماة ذات الطابع الاقتصادي، بدأ في الظهور في أواخر القرن الثامن عشر في فرنسا، عندما منحت الحكومة الفرنسية لإخوان بيرييه امتياز توزيع المياه في باريس عام ١٧٨٢<sup>(٣)</sup>. ويتخذ صوراً عدة: عقد امتياز أو التزام المرافق العامة، واستغلال الموارد الطبيعية، وامتياز (BOT) المتطور المتعدد<sup>(٤)</sup>.

---

(١) للمزيد يراجع مؤلفات القانون الخاص. د/ نذير بن محمد الطيب أوهاب، نظرية العقود، مرجع سابق، ص ١٨ وما بعدها.

(٢) د/ جمال جبريل: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٣٤٣. د/ عمر حلمي وآخرون: المبادئ العامة في العقود، مرجع سابق، ص ١١٣.

(٣) أستاذنا د/ ماجد الحلو: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ١٩٣.

(٤) د/ حمدي العجمي: المرجع، مرجع سابق، ص ٩٦.

أولاً: مفهوم عقد امتياز المرافق العامة وتمييزه عن غيره

عرفته المادة (٦٦٨) مدني بأنه: "عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن".

ونظمت أحكامه المواد (٦٦٨ - ٦٧٣) مدني.

**ويقصد به فقها:** عقد إداري يتم بين جهة الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات، يتولى الملتزم بمقتضاه إدارة مرفق عام اقتصادي على نفقته ومسئوليته واستغلاله فترة معينة من الزمن، مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين، مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة، فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة عقد الامتياز<sup>(١)</sup>.

أو: "العقد الذي يتعهد بمقتضاه فرد أو شركة ببناء أو صيانة مشروع عام -بنفسه أو بمقاول- في مقابل استغلال المشروع خلال فترة محددة"<sup>(٢)</sup>. وكان يعرف حتى أواخر القرن التاسع عشر بعقد الامتياز بأشغال عامة. مثال: اتفاق الإدارة مع المقاول على شق قناة أو ترعة أو تمهيد طريق عام وإعطائه حق الاستغلال لفترة محدودة.

---

(١) د/ سليمان الطماوي: الأسس العامة، مرجع سابق، ص ١٠٦. د/ عبد الغنى بسيوني: القانون الإداري، الدار الجامعية، بيروت، بدون، ص ٤٢٦. د/ جمال جبريل: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٣٤٦. د/ عمر حلمي وآخرون: المبادئ العامة في العقود، مرجع سابق، ص ١٥٢. د/ حمدي العجمي: المرجع، مرجع سابق، ص ٩٦.

(٢) د/ عزيزة الشريف: دراسات في نظرية العقد الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٧، ص ٧٣.

ويختلف عقد الامتياز بأشغال عامة عن غيره كعقد الأشغال العامة (١).  
وطريقة الاستغلال المباشر، وطريقة المؤسسات العامة. وعقد الإجارة من حيث مسئولية إنشاء مرفق، وأسلوب منح المقابل النقدي. وعن التراخيص الإدارية والمؤقتة، والتي تعد من قبيل القرارات الإدارية (٢).

وبعد من المرافق ذات الطابع الاقتصادي، والتي تدار عن طريق أسلوب الامتياز في دول الاقتصاد الحر، مرافق النقل الداخلي، ومرفق الكهرباء والغاز. وامتياز التفريغ والشحن بالموانئ، واستغلال المناجم والمحاجر. وتعد المرافق الصناعية والتجارية هي المجال الرحب لعقود امتياز المرافق العامة، إلا أن الواقع العملي في فرنسا يثبت أن عقود الامتياز بدأت تمتد لتشمل مرافق عامة إدارية كالتزام الطرق العمومية، والكباري والأنفاق وأماكن انتظار السيارات والمستشفيات (٣).

### ثانياً: خصائص عقد امتياز المرافق العامة:

يتسم بعدة خصائص تميزه عن غيره من أهمها:

١- عقد إداري بطبيعته، وبصفة مستمرة، وله موضوع محدد؛ يتمثل في إدارة مرفق عام ذي صبغة اقتصادية، يحقق عائداً مادياً، وفقاً لقواعد وشروط محددة سلفاً من قبل المشرع. وقد اعتبره القضاء العادي عقداً من عقود القانون العام (٤)، قبل إنشاء مجلس الدولة، نظراً لخصائصه

---

(١) د/ عمر حلمي وآخرون: المبادئ العامة في العقود، مرجع سابق، ص ١٥٣.  
(٢) د/ علي الخطار: عقد امتياز المرافق العامة وتطبيقاته في الأردن، مؤته للبحوث والدراسات، المجلد السابع، العدد الخامس، ١٩٩٢، ص ٢٣ وما بعدها.  
(٣) د/ جمال جبريل: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٣٥١ وما بعدها.  
(٤) يؤكد حكم محكمة القاهرة المختلطة، الصادر في ١٢ إبريل ١٩١٧.

الإدارية. كما أصدر المشرع القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ بالتزام المرافق العامة بتعديلاته المختلفة، والذي يعد بمثابة النظام العام<sup>(١)</sup>.

٢ - عقد إداري مؤقت بطبيعته، محدد بمدة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاثين عاما أو لمدد طويلة نسبيا، ولا يكون أبديا أو لمدة غير محددة<sup>(٢)</sup>.

٣ - عقد الالتزام ذات طبيعة خاصة؛ لأنه يتضمن وفقا للرأي الراجح فقها وقضاء نوعين من الشروط هما:

-الشروط اللائحية: تتعلق بطبيعة الخدمة، وشروط استغلال المرفق وتنظيمه وتسييره، وتحديد رسوم الانتفاع، والأحكام المتعلقة بالعاملين في المرافق، وتأمين سير المرفق، والمساواة بين المنتفعين.

وتملك الإدارة تعديلها فقط بإرادتها المنفردة، دون توقف على قبول الملتمز<sup>(٣)</sup>.

- والشروط التعاقدية: وهي شروط يمكن الاستغناء عنها، ولا يتصور وجودها لو أن الإدارة تولت استغلال المرفق بنفسها استغلالا مباشرا. وتستمد قوتها من إرادة الطرفين دون المنتفعين، لتعلقها بالحقوق والأعباء المالية المتبادلة بينهما. وتبرز في شروط المدة، والمزايا المالية، وتنفيذ الأشغال العامة، واسترداد المشروع. ولا يجوز تعديلها إلا بموافقة الملتمز.

(١) د/ عمر حلمي وآخرون: المبادئ العامة في العقود، مرجع سابق، ص ١٥٥.  
(٢) الفتوى رقم (٤٩٩) بتاريخ ٢٠١٠/٨/٣٠، ملف رقم ٦٧٢/٢/٣٧. المستشار د/ محمد علاء زعزع، الموسوعة، مرجع سابق، ص ١٠٠. وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٤٤٠ - ١١١، جلسة ١٩٧٠/١/١٧، ١٤٠/٢٣/١٥، مجموعة المبادئ، مرجع سابق، ص ٦٦٥ وما بعدها.  
(٣) حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم ١١٠ لسنة ١٣ ق. مبدأ رقم ٢٣، مجموعة المكتب الفني، ص ٢٧.

٤ - يتحمل الملتزم نفقات المشروع وأخطاره أو مخاطره المالية. إلا أن مبدأ دوام سير المرافق العامة قد يدفع الدولة للتدخل أحياناً.

٥ - يقوم الملتزم باستغلال المرفق مقابل تعويض نقدي يحصله من المنتفعين في صورة رسوم، تحدد في جداول التعريفة التي يتضمنها العقد، أو قائمة الشروط والالتزامات. وتتدخل الإدارة للزيادة أو النقص.

٦ - يعد اختيار طريقة الامتياز دون غيرها لإدارة أحد المرافق العامة من الأمور التقديرية التي تدخل في اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية بلا معقب عليها من القضاء.

٧ - يكون منح الامتياز أو الالتزام بناء على قانون أو قرار بقانون؛ إذ لا تنشأ عقود الامتياز ولا تعدل إلا بمقتضى قانون.

يؤكد نص المادة (٣٢٢/٢، ٣) من دستور ٢٠١٤م: (...ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحة، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون...). وهو ذات ما قرره المادة الأولى من القانونين رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧، والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥٨ المعدل. مثال: عقد الالتزام الخاص بالبحث عن البترول واستغلاله في مناطق جنوب أبو سنان، وجنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية<sup>(١)</sup>.

---

(١) بالقانون رقم ١٣٥ لسنة ٢٠١٩، الجريدة الرسمية - العدد ٢٨ مكرر (و) - س ٦٢، ١٤ ذي القعدة ١٤٤٠هـ، الموافق ١٧ يولييه ٢٠١٩م.

ثالثاً: الآثار المترتبة على عقد الامتياز: يترتب عليه عدة آثار خاصة بالإدارة، والملتزم، والمنتهقين. وهو ما سنوضحه فيما يلي:

#### ١/ثالثاً - حقوق والتزامات الجهة الإدارية:

لما كانت الدولة هي المكلفة أصلاً بإدارة المرافق العامة، فإنها إذا عهدت إلى غيرها أمر القيام بها، لم يخرج الملتزم في إدارته عن أن يكون معاوناً لها ونائباً عنها في أمر هو من أخص خصائصها، ... ولا يعتبر هذا تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضامنة مسئولة قبل أفراد الشعب عن إدارته واستغلاله...

ومن ثم فإن عقد الالتزام يجعل الملتزم في مركز لائح عام يتضمن تحويل الملتزم حقوقاً مستمدة من السلطة العامة في حدود ما يقتضيه قيام المرفق وإدارة الخدمة العامة للجمهور بانتظام واضطراب، ويسوغ للدولة حقاً ثابتاً في تعديل هذا المركز بإرادتها المنفردة<sup>(١)</sup>.

وتتمثل حقوق والتزامات الجهة الإدارية في الآتي:

- ١ - سلطة الرقابة والإشراف والتوجيه على تنفيذ الالتزام؛ ضماناً لحسن سير المرفق العام وفقاً لشروط وبنود العقد، حتى ولو لم ينص عليها. وتُعد هذه السلطة من النظام العام، لا يجوز التنازل عنها أو تقييدها.
- ٢ - سلطة إجبار الملتزم على تنفيذ شروط العقد كاملةً، وفي المواعيد المحددة، دون إخلال بحقها في اتخاذ ما يلزم حال إخلاله أو تقصيره.

(١) من حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٢٨٥ لسنة ٣١ ق. العليا، جلسة ١٩٩٢/٢/٩. المستشار د/ محمد علاء زعزع، موسوعة، مرجع سابق، ص ١٠١.

٣- سلطة تعديل شروط العقد اللائحية فقط دون التعاقدية بإرادتها المنفردة، وخاصة ما يتصل بتحديد أسعار، ومقابل الانتفاع بخدمات المرفق، أو مواعيد العمل، أو ضوابط التشغيل.

٤- سلطة توقيع الجزاءات المناسبة على الملتزم إذا أخلّ بشروط العقد، أو قصر في أداء خدمات المرفق، ومن أبرزها: الغرامات المالية المقررة بموجب العقد، الفسخ الاتفاقي للعقد، والإسقاط أو الفسخ بقوة القانون، والاسترداد الإداري للامتياز قبل انتهاء المدة المتفق عليها، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، مع التزام الإدارة بشراء المشروع، وتعويضه. وقضت بأن: "سحب الالتزام أو إسقاطه كلاهما من الألفاظ المرادفة لمعنى واحد هو رفع يد الملتزم مع حق مانح الالتزام في الاستيلاء على الأدوات اللازمة لإدارة المرفق جبرا عن الملتزم؛ إذا اختل المرفق اختلالا جزئيا أو كليا، أو ارتكب الملتزم مخالفات جسيمة، أو تكرر إهماله"<sup>(١)</sup>. ويجب على الإدارة مراعاة الضمانات القانونية المقررة للملتزم<sup>(٢)</sup>.

## ٢/ ثالثا- التزامات الملتزم في عقد الامتياز:

تقع على عاتق الملتزم عدة التزامات، من أبرزها ما يلي:

١- الالتزام بتنفيذ موضوع العقد، وفقاً للشروط والمواصفات الفنية والمالية المحددة في العقد، وطبقاً للجداول الزمنية المتفق عليها. ويتحمل كامل المسؤولية عن أي خلل أو انقطاع في أداء الخدمة.

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١١٠-١٣٠، جلسة ١٩٧٧/١٢/٣٠، ٢٧/٢٣، المجموعة، مرجع سابق، ص ٦٧٠.  
(٢) د/ على الخطار: مرجع سابق، ص ٥٨.



- ٢- الالتزام بتمويل إنشاء المشروع وتحمل نفقاته، وأعباء التشغيل والصيانة، سواء من موارده الذاتية أو التسهيلات المالية المعتمدة. ولا يجوز له التنازل للغير أو التعاقد من الباطن إلا بإذن مسبق من الإدارة.
- ٣- الالتزام بتحصيل الرسوم المقابل المالي من المنتفعين وفقاً للضوابط المحددة، نظير استخدام خدمات المرفق، تحت رقابة الجهة الإدارية.
- ٤- المحافظة على المال العام وملحقات المرفق؛ باعتباره مؤتمناً على عناصر المرفق ووسائله، وعليه استخدامها في الغرض المخصص لها.
- ٥- الالتزام بالامتثال لتعليمات وتوجيهات الجهة الإدارية في كل ما يخص سير المرفق، طالما لم تتعارض مع العقد أو القوانين المقررة.
- ٦- الوفاء بالضمانات المالية والتأمينية المقررة بالعقد، كخطاب الضمان، أو التأمينات ضد المخاطر، أو التعويض عن الأضرار.
- ٣/ ثالثاً- حقوق المنتفعين بخدمات المرفق العام محل الامتياز
- يعتبر المنتفعون الركيزة الأساسية في علاقة عقد الامتياز، والطرف غير المباشر المستفيد من تشغيل المرفق العام، ويتمتعون بالحقوق التالية:
- ١- الاستفادة من خدمات المرفق، وعدم الحرمان منها إلا بمبرر.
- ٢- المعاملة المتساوية في أداء الخدمة دون تمييز، إلا بنص قانوني.
- ٣- توفير بيئة تشغيل خدمية آمنة ومناسبة للمستخدمين في مرافق النقل أو المياه أو غيرها، ويتحمل الملتزم مسؤولية الأضرار التي تقع بسبب الإهمال أو التقصير في الأمن الصناعي والسلامة.

- ٤- حق المنتفعين في الشكوى والتظلم للجهة الإدارية المختصة أو للجهات الرقابية، حال التقصير أو المخالفة. وتلتزم الإدارة بالبحث والرد.
- ٥- حق المنتفعين في معرفة الأسعار وشروط الخدمة بطريقة واضحة، معلنة وشفافة. ويحظر على الملتزم تعديلها دون إذن الإدارة.

## المبحث الثاني

### عقد الأشغال العامة

أولاً: تعريف عقد الأشغال العامة وتمييزه عن غيره

يُعد من أقدم وأهم صور العقود الإدارية، ويُقصد به- وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري- ذلك العقد الذي تبرمه جهة إدارية مع فرد أو شركة بقصد تنفيذ أعمال بناء وإنشاء أو ترميم أو صيانة في عقار لحساب شخص معنوي عام، ويهدف لتحقيق مصلحة عامة، وذلك مقابل أجر أو ثمن متفق عليه سلفاً.

ويعرف فقهاً: اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات؛ للقيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقار مملوك لشخص معنوي عام، لتحقيق منفعة عامة، لقاء مقابل مادي، ووفقاً للشروط الواردة بالعقد<sup>(١)</sup>. وعرفته محكمة القضاء الإداري بأنه: "عقد مقاوله يبرم بين شخص من أشخاص القانون

---

(١) د/ سليمان محمد الطماوي: الأسس العامة للعقود، مرجع سابق، ص ١١٢ وما بعدها. د/ محمد سعيد أمين: دراسة وجيزة في فكرة العقود الإدارية وأحكام إبرامها، دار الثقافة الجامعية، ١٩٩٢، ص ١٧٤ وما بعدها. د/ علي عبد العال سيد أحمد: الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة، مؤسسة دار الكتب، الكويت، ط ٢، ١٩٩٨، ص ٣.

العام وفرد أو شركة، بمقتضاه يتعهد المقاول بتنفيذ عمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب الشخص المعنوي العام، وتحقيقاً لمصلحة عامة، مقابل ثمن يُحدّد بالعقد<sup>(١)</sup>.

وعرفه قسم الفتوى بأنه: (عقد يتعهد بمقتضاه مقاول بأن ينفذ عملاً معيناً لصالح الحكومة، تحت مسؤوليته، وتحت إشراف الإدارة، لقاء مقابل مالي يُدفع له وفق أسس متفق عليها. وهو عقد رضائي، لا يشترط فيه شكل معين، وينصب التراضي فيه على عنصرين اثنين: العمل المطلوب تأديته أو الشيء المراد تصنيعه، والأجر أو الثمن الذي يلزم به رب العمل، والأجر يعد ركناً أساسياً فيه ولا ينعقد بدونه)<sup>(٢)</sup>.

وعقد المقولة هو: "عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر، وهو يشتمل على نوعين من المعاملات؛ أولهما: صنع شيء، وهذا هو الاستصناع في الفقه، وهو يقوم على مستصنع وهو طالب الصنعة، وصانع وهو من يقوم بتحضير المادة الأولية ويتولى العمل، ومادة وهي محل العقد، وثمن وهو المال الذي يدفعه المستصنع نظير المطلوب صنعه، وهو قيمة المادة الأولية مع عمل الصانع"<sup>(٣)</sup>. المادة (٦٤٦) مدنى.

---

(١) حكمها في القضية رقم ٢٤٨ لسنة ٨ق، جلسة ٢٣ ديسمبر ١٩٥٦، مجموعة أحكام المحكمة، س ١١ق، ص ١٠٤.

(٢) الفتوى رقم ١١٠١ بتاريخ ١٩٨٩/١١/١٦، جلسة ١٩٨٩/١١/١، ٤٣، ٤٤/١٧٩/٤٧٩، المجموعة، مرجع سابق، ص ٦٨١ وما بعدها.

(٣) الفتوى رقم ٥٠٣ بتاريخ ٢٠٠٠/١٠/١، ملف رقم ٤٩/٢/٧٨. المستشار د/ محمد زعزع، موسوعة، مرجع سابق، ص ١٠٣.

ويختلف عقد الصيانة والإصلاح الإداري عن عقد الأشغال العامة، في أنه أحد صور العقود الإدارية المستحدثة التي ترد في الأصل على العمل، يراد به: عقد تبرمه الإدارة مع شخص طبيعي أو معنوي بمقتضاه يتعهد الأخير بصيانة آلة من الآلات الضرورية لتسيير المرفق العام أو إصلاحها نظير التزام المرفق بدفع الثمن المتفق عليه.

ويوجد فرق بين قيام المكاو؁ بالصيانة في عقار وبين إجراء الصيانة والإصلاح الإداري على الآلات الموجودة بالمرفق كأجهزة الكمبيوتر والأسانسير حيث يتم الاتفاق مع المتعاقد مع الإدارة "الصائن" على توريد بعض المواد أو قطع الغيار اللازمة لإنجاز أعمال الصيانة والإصلاح، فتجتمع أعمال التوريد والتركيب، أو ما يعرف بتقديم المادة والعمل معا. وهو بذلك يناظر عقد المكاولة في القانون المدني بحسبانه في الأصل من العقود التي ترد على العمل،.. بما لا يتعارض مع أحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو يتأبي وطبيعة العقود الإدارية"<sup>(١)</sup>.

ويختلف عن عقد العمل، في أن لكل منهما نظاما قانونيا خاصا، وآثارا مختلفة. فقد "أخذ المشرع بمعاير الخضوع لإرادة رب العمل وإشرافه للتمييز بينهما.."<sup>(٢)</sup>.

---

(١) الفتوى رقم ٧٣٠ بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٥، ملف رقم ٥٧٨٩/٢/٣٢. المستشار د/محمد زعزع، موسوعة، مرجع سابق، ص ١٠٦.  
(٢) الفتوى رقم ٢٠٠ بتاريخ ٢٠٠٦/٢/١٩، ملف رقم ٤٨٢/١/٥٤. المستشار د/محمد زعزع، موسوعة، مرجع سابق، ص ١٠٤ وما بعدها.

## ثانيًا: الطبيعة القانونية والأهمية الاقتصادية لعقد الأشغال العامة

رغم أن عقد الأشغال العامة في ظاهره يُشبه عقد المقاولة في القانون المدني، باعتباره عقد رضائي ذات وظيفة مزدوجة. إلا أنه يختلف في طبيعته، إذ يخضع لنظام قانوني خاص، يُضفي عليه الطابع الإداري متى توافرت فيه شروط العقد الإداري.

وقد اعتبره مجلس الدولة الفرنسي والمصري من العقود الإدارية بطبيعتها، دون حاجة إلى نص خاص.

وتبرز أهميته في كونه الوسيلة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ المشروعات الضخمة العملاقة، مشروعات البنية الأساسية، كشبكات الطرق، والمرافق، والمدارس، والمستشفيات. كما يعد أداة فاعلة لتحقيق التنمية العمرانية، وجذب استثمارات التشييد والبنية التحتية<sup>(١)</sup>.

## ثالثًا: عناصر وشروط عقد الأشغال العامة: يلزم توافر ما يلي:

١ - أن يرد موضوع العقد على عقار لا منقول، سواء أكان عقارًا بطبيعته (كالمباني، والطرق، والجسور والقناطر)، أو عقارًا بالتخصيص (كتركيب خطوط تليفونات أو مد أنابيب وكابلات وأسلاك تحت الماء). وقد توسّع القضاء الفرنسي في المفهوم ليشمل أعمال النظافة العامة من تنظيف وكنس ورش ماء بالطرق العامة، ونقل المواد اللازمة إذا كانت مرتبطة بتنفيذ مشروع إنشائي، واعتبارها من قبيل الأشغال العامة<sup>(٢)</sup>.

(١) د/ عمر حلمي وآخرون: المبادئ العامة، مرجع سابق، ص ١١٥ وما بعدها.

(٢) د/ جمال جبريل: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٣٦٢.

٢- أن تُنفَّذ الأشغال لحساب شخص معنوي عام: وهو شرط جوهري، ولا يشترط أن يكون العقار مملوكًا له، بل يكفي أن يكون العمل لحسابه. وقد فرّق مجلس الدولة الفرنسي بين حالتين:

**الأولى:** أن تُمارس الإدارة إشرافًا مباشرًا ورقابة فعالة على تنفيذ الأشغال محل الاتفاق. حيث توسع واعتبر من قبيل الأشغال العامة الاتفاق على نقل مواد، أو تقديم معونة مالية، أو عينية، أو إيجار الخدمات العامة<sup>(١)</sup>. **الثانية:** أن تؤول ملكية المشروع إلى الإدارة بعد إنشائه خلال مدة معينة. كما في طريقة شركات الاقتصاد المختلط، أو BOT.

٣- أن تستهدف الأشغال المقابلة محل العقد تحقيق منفعة عامة، متى كانت الأعمال المنفذة تُسهم في تحسين الخدمات، أو تطوير البنية التحتية، أو حماية الأمن العام.

### المبحث الثالث

#### عقد المساهمة في مشروع ذي نفع عام

**أولاً: تعريف عقد تقديم المعاونة أو المساهمة وأهميته**

هو ما يُعد من العقود الإدارية غير النمطية. إذ يقصد به: عقد إداري يلتزم بمقتضاه أحد أشخاص القانون الخاص أو العام بالمساهمة نقداً أو عينا في نفقات مرفق عام أو مشروع ذي نفع عام. وعرفته بأنه: "عقد

---

(١) د/ جمال جبريل: المرجع السابق، ص ٣٦٥ وما بعدها.

إداري يتعهد بموجبه شخص، برضائه واختياره، بالمساهمة نقدًا أو عينًا في مشروع من مشروعات الأشغال العامة أو المرافق العامة<sup>(١)</sup>. وترجع أهميته في أنه يمثل صورة متقدمة من الشراكة بين الأفراد والإدارة في خدمة المرافق العامة، إذ يؤكد على أن تحقيق المصلحة العامة لا يقتصر على الدولة فحسب، بل قد يتحقق بمساهمة طوعية مسئولة من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال دون الخروج على القانون.

**مثاله:** عرض أحد المواطنين أو الأشخاص اعتبارية المساهمة في تمويل إنشاء ورصف طريق يؤدي إلى ممتلكاته، أو أن تبدي إحدى الغرف التجارية استعدادها للمشاركة في تمويل إنشاء محطة قطار.

وقد تكون المساهمة إما مالية (نقدًا)، أو عينية (كالأراضي أو المعدات).

وقد قضت بأن: (ما يسمونه في فرنسا "Offre de Concours" أي عرض المساهمة في نفقات مشروع ذي نفع عام، هو عقد إداري يتعهد بمقتضاه شخص برضائه واختياره بأن يشترك في نفقات مشروع من مشروعات الأشغال العامة، أو المرافق العامة، وقد يصدر من أحد الأفراد كما في حالة هذه الدعوى، أو من أحد الأشخاص الإداريين كالهيئات الإقليمية أو المؤسسات العامة. وقد يكون المتعهد ذا مصلحة في تعهده أو غير ذي مصلحة فيه، وقد يكون بعوض أو يتمحض تبرعا، وقد يكون مبتدأ من تلقاء المتعهد أو مثارا بطلب من جانب الحكومة، كما لو عرضت

---

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣ لسنة ٣ق، بتاريخ ١٥ مارس ١٩٨٠.

عليه إحدى المدن إنشاء مدرسة بها بشرط مساهمتها في نفقاتها فساهمت فيها، وقد تكون المساهمة بمبلغ من المال أو بشيء عيني كأرض أو غيرها، وقد يكون التعهد منجزاً، وقد يكون مشروطاً. ويقوم عقد المساهمة على المساهمة الاختيارية في مشروع ذي نفع عام، مهما اختلفت صورته وأوصافه<sup>(١)</sup>.

### ثانياً: خصائص وطبيعة عقد المعاونة:

يتسم بخصائص العقد الإداري، بالإضافة إلى الخصائص التالية:

- ١- **يعد من العقود الإدارية؛** لكون الإدارة طرفاً فيه، ويرتبط بالمصلحة العامة، وتطبق عليه قواعد القانون العام لا المدني.
- ٢- **عقد ملزم لجانب واحد** يلتزم المتبرع به عند قبول الإدارة ولا تلتزم فيه الإدارة بشيء ما لم تقبل العرض.
- ٣- **عقد اختياري** يقوم على إرادة المتبرع الحرة في المساهمة الاختيارية في مرفق عام أو مشروع ذي نفع عام، حتى لو كانت بدعوى من الإدارة وبإغراء منها. ويمكن للمتطوع سحبه في أي وقت قبل قبول الإدارة له. وقد أفتت بعدم أحقية شركة "فاستر للمقاولات والتوريدات العامة" في الرجوع عن التبرع المقدم منها لصالح جهاز مدينة برج العرب الجديدة؛ على اعتبار أن التبرع هو في حقيقته عقد تقديم معاونة أو مساهمة في نفقات المرفق العام، وشأنه شأن سائر العقود ينعقد بإيجاب وقبول بين

---

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣ لسنة ٣٠ق، بتاريخ ١٥ مارس ١٩٨٠.



طرفيه وحيث إن الإيجاب المتمثل في طلب قبول التبرع، مرتبط بالمناقصة المحدودة ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة... وبات بعد ترسية المناقصة عليها جزءا لا يتجزأ من مشتملات العقد محل الأعمال موضوع المناقصة، ومتصلا بمدته، فلا تملك الرجوع عنه<sup>(١)</sup>.

٤- يتميز عن عقد الهبة في القانون المدني وغيرها، حيث لا يشترط فيه الشكل الرسمي<sup>(٢)</sup>، ولا يُفسر تضمنه لألفاظ التبرع أو التنازل بأنه هبة.

٥- غالبا ما يتعلق بتنفيذ عقود الأشغال العامة، ومشروعات البنية التحتية. وهو ما يعتبره مجلس الدولة الفرنسي عقدا إداريا باستمرار، فإذا فصل عنها صار عقدا إداريا أو مدنيا بحسب خصائصه الذاتية<sup>(٣)</sup>.

وقد قضت أنه: "عقد إداري وثيق الصلة بعقود الأشغال العامة يمتاز بخصائص العقود الإدارية التي تتأى عن القواعد المألوفة في مجالات القانون الخاص..."<sup>(٤)</sup>.

٦- لإدارة سلطة العدول عن قبول عقد المعاونة، متى رأت أنه لا يحقق المصلحة العامة، أو يترتب عليه أعباء غير مبررة.

---

(١) فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم (٥٩٦) في الملف رقم ٣٩١/١/٤٧، ورقم (٥٧٩) في الملف رقم ٣٩٠/١/٤٧ بتاريخ ٣٩٠/٤/١٨. المستشار د/ محمد زعزع، موسوعة، مرجع سابق، ص ١٠٨.

(٢) د/ داود عبد الرازق الباز: النظام القانوني لعقد المعاونة في تسخير المرافق العامة "تبرعات الأشخاص للدولة" - دراسة تحليلية مقارنة، دار الأزهر للطباعة، دمنهور، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م، ص ٤٦ وما بعدها.

(٣) د/ جمال جبريل، العقود، مرجع سابق، ص ٣٦٥.

(٤) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣ لسنة ٣ق، بتاريخ ١٥ مارس ١٩٨٠.

## المبحث الرابع

### عقد شغل الدومين العام والانتفاع بالأموال العامة

أولاً: مفهومه وشروط الانتفاع بالمال العام

يُقصد بعقد شغل الدومين العام والانتفاع بالأموال العامة: الاتفاق الذي يُبرم بين جهة إدارية أو أحد أشخاص القانون العام وبين فرد أو جهة خاصة، يُمنح الأخير بموجب عقد أو ترخيص، حق استخدام جزء محدد من المال العام استخدامًا خاصًا، وبشكل مؤقت، مع بقاء المال مخصصًا للنفع العام، واحتفاظ الإدارة بحقها في الإشراف والرقابة.

مثال: الترخيص بشغل جزء من الشارع العام لإقامة محل أو كشك، وإقامة كبائن الاستحمام أو منشآت ترفيهية على الشاطئ العام، وتأجير مساحات داخل محطات السكك الحديدية أو المطارات والموانئ العامة لاستخدامها في نشاطات خدمية أو تجارية، ومنح تراخيص للاستغلال.

ويشترط القانون لإضفاء وصف المال العام على المال توافر شرطان:

١- أن يكون المال عقارًا أو منقولًا مملوكًا للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، كالمحافظات أو المدن أو القرى.

٢- أن يكون المال مخصصًا **للمنفعة العامة** بالفعل، أو بمقتضى قانون، أو مرسوم، أو قرار من الوزير المختص.

وهي أدوات لا تصدر إلا عن الحكومة، مما يعنى انفراد الدولة بملكية الدومين العام، حتى ولو كانت تحت يد غيرها من الأشخاص الاعتبارية.

ومن ثم لا يعد نقل الانتفاع بالمال العام "الدومين العام" إلي أي من الأشخاص العامة من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها. ولا يخولها حق تقرير أو نقل أو إنهاء وجه المنفعة العامة للمال الخاضع لإشراف جهة عامة، أو تجاوز سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف المعقودة لجهة إدارية أخرى<sup>(١)</sup>.

ويُعد شرط التخصيص للمنفعة العامة هو الأساس الجوهري والحقيقي لفكرة الدومين العام؛ إذ يبرر إخضاع هذه الأموال لنظام قانوني متميز عن نظام الأموال الخاصة، وبالتالي حمايتها.

#### ثانيًا: الطبيعة القانونية لعقد شغل الدومين العام

تتسم يد الدولة على الأموال العامة بكونها يد أمانة ورعاية وحراسة، وليست يد ملكية مطلقة على غرار الملكية المدنية المشتملة على حق الانتفاع والاستغلال والتصرف مما يتمتع به المالك في ملكه، مما يستتبع خضوعها لنظام قانوني خاص يغل يدها، ويمنعها من التصرف فيها بالبيع أو الرهن، حفاظاً على الغرض المخصص لها.

وينشأ عقد شغل الدومين العام حين تُبرم الإدارة اتفاقاً مع أحد الأفراد أو الأشخاص الخاصة لاستعمال جزء من الأموال العامة استعمالاً خاصاً، دون أن يفقد المال صفته العامة، ودون أن تتحول العلاقة إلى ملكية خاصة. كما لو قامت إحدى الجهات الإدارية بتأجير لقطعة أرض من

---

(١) الفتوى رقم (٢٩٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٠، ملف رقم ٢٧١/٢/٧. المستشار د/ محمد زعزع، موسوعة، مرجع سابق، ص ٢٧١ وما بعدها.

أملكها الخاصة إلى أحد الأفراد لإقامة مصنع عليها فهذا لا يعتبر عقدا إداريا؛ إذ المعيار المميز للعقود الإدارية ليس هو صفة المتعاقد، بل موضوع العقد ذاته متى اتصل بالمرفق العام، وتضمن الشروط الاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص<sup>(١)</sup>.

وقد تباينت مواقف الفقه والقضاء في فرنسا ومصر بشأن تحديد الطبيعة القانونية لشغل المال العام؟ فاستقر **القضاء الإداري الفرنسي** على اعتبار الاتفاقات التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لشغل جزء من الدومين العام عقودا إدارية، كشغل جزء من شاطئ البحر، وتخصيص أجزاء من الأسواق للباعة، أو للجبانات والمقابر. أما في مصر، فقد نفت **محكمة النقض<sup>(٢)</sup>** الصفة التعاقدية عن الاتفاق على تأجير بوفيه محطة سكك حديد حلوان وملحقاتها، معتبرة إياه يتم بترخيص إداري. في حين اعتبرته المحكمة الإدارية العليا<sup>(٣)</sup> من العقود التي تخضع لأحكام القانون العام؛ لأنها توافق طبيعة المال العام، واتصالها الوثيق بمقتضيات النفع العام.

### **ثالثا: السلطة التقديرية للإدارة في تنظيم الانتفاع بالمال العام:**

للإدارة السلطة التقديرية في اختيار الإطار القانوني للانتفاع بالمال العام، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وطبيعة ونوع الدومين العام، الحكمي "الصناعي" أو الطبيعي، فسلطة الإدارة في تحديد الدومين

---

(١) حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم ١٢٣٥ لسنة ١٣ ق، جلسة ٢٢ مارس ١٩٦٠، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري، المكتب الفني، س١٤، من أول أكتوبر ١٩٥٩ إلى آخر سبتمبر ١٩٦٠، ص ٢٥٦.

(٢) حكمها الصادر بتاريخ ١٠ فبراير ١٩٥٥.

(٣) حكمها الصادر بجلسته ٣١ مارس ١٩٦٢ حكمها الصادر بجلسته ٣١ مارس ١٩٦٢.

الصناعي أوسع من سلطتها في تحديد الدومين العام الطبيعي كشواطئ البحار أو مجارى الأنهار.

وقد يكون الانتفاع بالمال العام عن طريق عقد إداري يتضمن التزامات متبادلة<sup>(١)</sup>، أو عن طريق ترخيص إداري منفرد تُصدره الإدارة بإرادتها المنفردة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. إلا أن نية الإدارة ينبغي أن تكون واضحة في أسلوب الترخيص<sup>(٢)</sup>.

وقد أفقت أنه يشترط للاستعمال الخاص للدومين العام "الحصول على رخصة مقدما، وألا يكون معطلا لانتفاع المجموع بالأموال العامة فيما أعدت له أصلا، وألا يكون في ذلك خطر أو ضرر على المال العام وحفظه... ومنح الترخيص أو رفضه أساسه المصلحة العامة، بعد تحصيل مقابل انتفاع من المرخص له،.. وأن يتحقق به وجه انتفاع عام، وإتاحة وجوه من الخدمات المكملة والمحسننة للمنفعة العامة، كأكشاك الخدمات في الطرق للمارة والمسافرين"<sup>(٣)</sup>.

رابعا: الضوابط والخصائص المميزة لعقد شغل الدومين العام: يشترط:

١- أن يكون المال محل الانتفاع من أموال الدومين العام مخصصا للنفع العام كالشوارع، والموانئ، والأسواق، والحدائق العامة.

---

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٤٩٨٥ لسنة ٤١ ق جلسة ٢٠٠١/٩/٤، المجموعة، س ٤٦، ج ٣، يونيو ٢٠٠١ إلى آخر سبتمبر ٢٠٠١، ص ٢٨٣٥.  
(٢) د/ سليمان الطماوى: الأسس العامة في العقود، مرجع سابق، ص ١٤٨ وما بعدها.  
ود/ عمر حلمي وآخرون، المبادئ العامة، مرجع سابق، ص ٢٠٣.  
(٣) الفتوى رقم (١١٠٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١١، ملف رقم ٣٥٨/٢/٧. المستشار د/محمد موسوعة، مرجع سابق، ص ٢٦٦ وما بعدها.

٢- أن يتم الانتفاع بموجب اتفاق تعاقدى، وموافقة متبادلة للطرفين، ولا يجوز إنهاؤه إلا طبقاً لشروط العقد أو لضرورة المصلحة العامة. وليس بمجرد ترخيص إداري فحسب. فالترخيص الإداري لا ينشئ علاقة تعاقدية، وإنما هو إجراء تنظيمي يخضع لسلطة الإدارة التقديرية.

٣- أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة، والتزامات إضافية.

٤- أن يكون للعقد صلة مباشرة بالمرافق العام أو بتحقيق غرض ذي نفع عام يخدم الصالح العام...

فإذا انتفت هذه الشروط أو خلا منها اعتبر من عقود القانون الخاص.

**خامساً: الآثار القانونية لعقد الانتفاع بالمال العام:**

يترتب عليه ما يلي:

أ- **حقوق والتزامات المنتفع من عقود الانتفاع بالمال العام:** تتمثل في:

- ١- التمتع بالانتفاع الهادئ بجزء المال العام المحدد طيلة مدة العقد.
- ٢- حماية مركزه القانوني واستقراره طيلة سريان العقد، ما لم تُنه الإدارة التعاقد انتهاء طبيعياً أو غير طبيعي، أو فسخه بقوة القانون.
- ٣- المطالبة بالتعويض في حال الإنهاء غير المشروع للعقد.

**أما التزامات المنتفع، فتتمثل في الآتي:**

- ١- سداد وأداء المقابل المالي أو الخدمة المطلوبة المتفق عليها.
- ٢- الالتزام بشروط وبنود العقد، وعدم تغيير طبيعة الانتفاع دون إذن.
- ٣- المحافظة على المال العام، وعدم إحداث تعطيل للانتفاع العام.

ب- سلطة الإدارة: تتمثل في الآتي:

- ١- الرقابة والإشراف الكامل على كيفية الانتفاع.
- ٢- الحق في إنهاء العقد أو تعديله أو إلغائه والرجوع فيه قبل آوانه.
- ٣- تحصيل مقابل الانتفاع، وعدم التصرف في المال العام بالمجان، أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل أو بالإيجار الفعلي.

## المبحث الخامس

### عقد التوريد

**مفهومه:** اتفاق تلتزم بموجبه إدارة عامة بالحصول على منقولات أو بضائع أو معدات من أحد الأفراد أو الشركات، مقابل ثمن محدد، ولمدة زمنية معينة؛ تحدد بمرة واحدة، أو مرات متتالية.

**وعرفته بأنه:** "اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة، يتعهد بمقتضاه الأخير بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي، لازمة لتسيير مرفق عام، مقابل ثمن معين يُحدد في العقد"<sup>(١)</sup>.

وتكتسب عقود التوريد أهمية عملية كبرى في الواقع الإداري، لا سيما في قطاعات التعليم، الصحة، والنقل والتموين وغيرها، حيث تطلب توريد أشياء منقولة كالבضائع أو المواد الغذائية كالدقيق والشعير والأرز، أو الأدوية، أو أدوات مكتبية، أو بطاطين، وغيرها.

---

(١) حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ٢ ديسمبر ١٩٥٢، مجموعة أحكام المجلس، س٧، ص٧٦.

## الطبيعة القانونية لعقد التوريد:

يُعد من العقود ذات الطبيعة المزدوجة، التي قد تكون إدارية أو مدنية وفقاً لخصائصها وطبيعتها الذاتية<sup>(١)</sup>.

يؤكد أنه أن محكمة القضاء الإداري في مصر كانت تعتمد في البداية في الكشف عن طبيعة عقد التوريد على مدى صلته وارتباطه بالمرفق العام، في حين تحرص الآن على إبراز شرط احتواء العقد على شروط استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص لتمييزه عن عقود القانون الخاص.

وقد قضت بأنه: (ومن حيث إن هذه المنازعة خاصة بعقد توريد، وهو من العقود الإدارية التي لا تخضع لأحكام القانون الخاص، وإنما يفصل فيها على مقتضى مبادئ القانون العام في شأن العقود الإدارية. ولما كانت هذه العقود تستهدف مصلحة عامة في تسيير المرافق العامة فإنه من أجل تحقيق هذا الهدف خولت جهة الإدارة سلطات استثنائية وحق تطبيق قواعد غير مألوفة في عقود القانون الخاص بقصد الوفاء بحاجة المرافق العامة، وهي أبرز الخصائص التي تميز نظام العقود الإدارية عن نظام العقود المدنية)<sup>(٢)</sup>.

ومن ثم اعترف القضاء الإداري لبعض عقود التوريد بالصفة الإدارية، مثل: الاتفاق على توريد شعير، وبطاطس، وكميات من الدقيق لوزارة التموين، والتصريح للأفراد باستيراد بعض صفقات من الصفيح بشروط

(١) د/ عمر حلمي وآخرون: المبادئ العامة، مرجع سابق، ص ١٨٣. د/ جمال جبريل، العقود، مرجع سابق، ص ٣٦٨.

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا السابق رقم ٧٦٣ - ١٢ق، الصادر في ١٦/١٢/١٩٥٦.



معينة<sup>(١)</sup>. وإذا ما اختلط عقد التوريد بعقد آخر - كما في حالات إصلاح الآلات، وتوريد وتركيب ما يلزم لها من قطع غيار جديدة ومستلزمات الإصلاح - فيطبق على كل من العقدين نظامه القانوني الخاص به. حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه: "عقد ينطوي على مزيج من مقاوله الأعمال والتوريد، وإذا ما انطوى العقد على مزيج من مقاوله الأعمال والتوريد فإنه يسرى في شأن كل منهما ما تنطبق عليه من أحكام"<sup>(٢)</sup>.

كما قضت بأن: "المشرع فرق عند فرضه لغرامة التأخير بين عقود المقاولات والأشغال العامة وبين عقود التوريد... بما يستتبع تطبيق أحكام متباينة على أجزاء العقد بحسب طبيعتها فيسري في شأن كل منها ما ينطبق عليه من أحكام، إلا أنه إذا كان من غير الممكن فصل أجزاء العقد عن بعضها كأن يختلط التوريد بالمقاوله بحيث لا يمكن فصل أي منهما، فلا مناص في هذه الحالة من تغليب أحدهما على الآخر.. بمراعاة الصفة الغالبة كمعيار لتطبيق الأحكام الخاصة بنوع العقد ذي الصفة الغالبة ليسري على كافة العملية"<sup>(٣)</sup>.

---

(١) د/ سليمان الطماوى، الأسس، مرجع سابق، ص ١٢٢. د/ جمال جبريل، العقود، مرجع سابق، ص ٣٦٨.

(٢) حكمها في الطعن رقم ٧٦٣، لسنة ١٢ق، الصادر في ١٦/١٢/١٩٥٦، ٢٩١/٣٨/١٤. المجموعة، سابق، ص ٧٢٣.

(٣) حكمها في الطعن رقم ٤٧٣٤ لسنة ٧ق. عليا، جلسة ١٨/١/٢٠٠٣. المستشار د/محمد علاء زعزع، موسوعة، مرجع سابق، ص ١٠٦ وما بعدها.

تميز عقد التوريد عن غيره: يختلف عقد التوريد عن عقد الأشغال العامة، فالأشغال يتعلق موضوعه بالعقارات، أما عقد التوريد فموضوعه تسليم منقولات أو بضائع أو مواد.

وقد تختلط عقود المقاوله بعقد التوريد؛ فإذا شمل العقد أعمال تصنيع أو تركيب، خُص كل جزء بنظامه القانوني الخاص به.

كما يختلف التوريد عن الاستيلاء الإداري، فالأول يتم بالتراضي والاتفاق، وبموجب عقد. أما الثاني يتم حبرا بموجب قرار إداري منفرد.

وقد تتشابه عقود التصنيع الحربي مع عقد التوريد، فتتفق عقود التوريد الصناعية مع عقود التوريد العادية في أن المورد يقوم على تصنيع المنقولات المنفق عليها وتوريدها للإدارة كعقود التصنيع الحربية. وتختلف عنها في أن المورد يلتزم بالتوريد بغض النظر عن مصدر الأشياء الموردة، وتمارس الإدارة سلطات رقابية واسعة على المورد أقرب من سلطاتها في عقود الأشغال العامة<sup>(١)</sup>. كما تختلف عقود تقديم الخدمات<sup>(٢)</sup> العامة عن عقد التوريد، في اختلاف محل وموضوع العقد.

---

(١) د/ جمال جبريل: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٣٧٠.  
(٢) يقصد بالخدمات وفقا لنص م(١) من قانون التعاقدات: "ما يكون التعاقد فيها على أساس أداء عمل مادي يمكن توصيفه، ومن ذلك: الصيانة، الأمن، النظافة، الخرائط، التصوير بالأقمار الصناعية، تطوير البرمجيات، وخدمات النقل".

## المبحث السادس

### عقد النقل

**تعريف عقد النقل:** هو: اتفاق بين أحد أشخاص القانون العام وناقل-فرد أو شركة- بمقتضاه يلتزم الناقل بنقل أشخاص أو منقولات لحساب الإدارة، أو بوضع وسيلة نقل-سيارة أو سفينة- تحت تصرفها مقابل أجر محدد يُتفق عليه سلفاً. قد يكون النقل مرة واحدة أو عدة مرات منتظمة.

### الطبيعة القانونية لعقد النقل وعلاقتها بعقد التوريد

تحدد طبيعة عقد النقل بحسب ما إذا اتبعت فيه الإدارة أسلوب القانون العام أو الخاص. فإذا لم يتضمن العقد شروطاً استثنائية، ولم يساهم الناقل في تشغيل المرفق العام بشكل مباشر يعد عقداً مدنياً تنطبق عليه أحكام القانون الخاص. والعكس؛ إذا ارتبطت وسائل النقل بالمرفق العام، وفرضت الإدارة رقابة واستمرارية تشغيل وسيلة النقل، وارتبط بتسيير مرفق عام- نقل الطلاب أو نقل المعدات لمرفق حكومي - ووجود شروط استثنائية -مثل الإشراف الإداري، وتدخل الإدارة في التشغيل، وأن يشترك الناقل في تسيير المرفق بتجهيز وسيلة النقل وخدمتها ومدها بالأفراد اللازمين لتشغيلها- فهذا يدخله ضمن نطاق العقد الإداري.

وتنطبق على عقد النقل ذات القواعد والأحكام المطبقة على عقد التوريد. حيث اعتبره مجلس الدولة الفرنسي نوعاً من عقود التوريد، وأجرى عليه

أحكامه القانونية<sup>(١)</sup>. كما لو وضع الناقل سفينته تحت تصرف الإدارة بنفس الشروط المألوفة في العقود التجارية، ودون أن يضمن عقده شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، ودون أن يساهم مباشرة في نشاط المرفق. بل شارك في تجهيزها وخدمتها ومدّها بالأفراد للتشغيل فقط<sup>(٢)</sup>.

لذا قضى بأن: (العقد المبرم بين مصلحة البريد وأحد الأفراد لنقل طرود من مصر إلى السودان لا يعتبر إداريا؛ إذ لا تتوافر فيه مقومات العقد الإداري... وإنما هو عقد مبرم لتحقيق مصلحة فردية خاصة هي نقل رسالة من مصر إلى السودان في مقابل أجر أو رسم فهو عقد من عقود النقل الخاص)<sup>(٣)</sup>. ويختلف عقد النقل عن عقد التوريد والامتياز حسب الموضوع والقانون.

---

(١) د/ عمر حلمي وآخرون: المبادئ، مرجع سابق، ص ١٨٩.

(٢) د/ جمال جبريل: العقود، مرجع سابق، ص ٣٧٢.

(٣) الحكم الصادر في ٢٤ فبراير ١٩٥٧، كإشارة د/ عمر حلمي، سابق، ص ١٩٠.

## الباب الثاني

### طرق إبرام العقود الإدارية

أهداف الباب الثاني: بنهاية الباب، يكون الطالب قادرًا على:

١- معرفة إبرام العقد بطريق المناقصات الأصلية وصورها الاستثنائية.

٢- معرفة إبرام العقد بطريق المزيادات الأصلية وصورها الاستثنائية.

٣- تحديد حالات إلغاء المناقصة والممارسة والمزايدة.

التطور التاريخي لطرق إبرام العقود الإدارية... وتقسيم:

أولى المشرع الفرنسي<sup>(١)</sup> والمصري اهتمامًا بالغًا بتنظيم طرق وأساليب إبرام العقود الإدارية؛ حيث نصت المادة (١٢) من قانون ٣١ يناير ١٨٣٣ الفرنسي: "تصدر أوامر ملكية لتنظيم أساليب العقود التي تبرمها الدولة". وتبعه المرسوم الصادر في ٤ ديسمبر ١٨٣٦، الذي كرس مبدأ التعاقد عن طريق المناقصة العامة، ثم توالى التعديلات؛ لتؤكد على إلزام الإدارة بالمناقصة العامة كأصل عام في اختيار المتعاقدين.

وقد اتبعت مصر نفس النهج، فنصت المادة الأولى من القانون رقم

٢٣٦ لسنة ١٩٥٤- كأول قانون للمناقصات والمزايدات- على أن:

"يكون شراء جميع الأصناف والمهمات اللازمة للوزارات والمصالح

العامة عن طريق مناقصات عامة يُعلن عنها". وهو ما رده القانون رقم

٩ لسنة ١٩٨٣، مع توسيع نطاقه ليشمل: شراء المنقولات، وتقديم

---

(١) د/ جمال جبريل، العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٥٧.

الخدمات، ومقاولات الأعمال، والنقل. ثم جاء القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ليؤسس قواعد أكثر مرونة، حيث أضاف إليها الممارسة العامة كطريق أصلي، وأجاز - استثناءً وبقرار مسبب - التعاقد بطرق أخرى كالمناقصة المحدودة، والمحلية، والممارسة المحدودة، والاتفاق المباشر. ويصدر **قانون تنظيم التعاقدات** تم استحداث قواعد متكاملة ومتعددة في التعاقد، تراعي طبيعة التعاقد واعتباراته الفنية والمالية؛ يؤكد نص المادة (٧) من القانون، والباب الرابع من اللائحة، على **تسعة طرق أصلية واستثنائية** لإبرام العقود، تشمل: (المناقصة العامة، المناقصة المحدودة، المناقصة ذات المرحلتين، المناقصة المحلية، الممارسة العامة، الممارسة المحدودة، الاتفاق المباشر، الاتفاقية الإطارية، أسلوب المسابقة).

كما خصّص الباب الخامس من اللائحة طرقاً خاصة لتصرف الإدارة في أموالها، كالمزايدات العلنية العامة، وبالمظاريف المغلقة، والمحدودة، والمحلية، والاتفاق المباشر. وتتناول **الباب السادس** منها التعاقدات ذات الطبيعة الخاصة، كما سبق. وهو ما نتناوله في فصلين:

**الفصل الأول:** إبرام العقد الإداري عن طريق المناقصات الأصلية والاستثنائية.

**الفصل الثاني:** إبرام العقد الإداري عن طريق المزايدات الأصلية والاستثنائية.

## الفصل الأول

### إبرام العقد الإداري عن طريق المناقصات الأصلية والاستثنائية

نظم المشرع وحدد طرق وإجراءات إبرام العقود الإدارية في كافة مراحلها؛ يؤكدده نص المادة (٧) من قانون التعاقدات: (يكون التعاقد وفق أحكام

هذا القانون في الحالات وبالطرق الآتية:

١- يكون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات، أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية عن طريق المناقصة العامة،

ويجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة التعاقدات إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية: (أ) الممارسة العامة. (ب) الممارسة المحدودة. (ج) المناقصة المحدودة. (د) المناقصة ذات المرحلتين. (هـ) المناقصة المحلية. (و) الاتفاق المباشر.

٢- يكون التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات ومن ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزيدة علنية عامة أو مزيدة بالمظاريف المغلقة،

ويجوز استثناء بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة التعاقدات إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية:

(أ) المزيدة المحدودة. (ب) المزيدة المحلية. (ج) الاتفاق المباشر.

ويجوز للجهة الإدارية التعاقد على احتياجاتها بإتباع أي من طرق التعاقد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة للوصول إلى إبرام اتفاق إطاري وفقا لحكم المادة (٦٥) من هذا القانون. ولا يجوز بأي حال تحويل أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في هذه المادة إلى طريق تعاقد آخر. وفي جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية).

وقد أفتت بأن: (المشرع في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ قرر سريان أحكامه على الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية، وحدد السبل التي يتعين على جهة الإدارة سلوكها قبل التعاقد على ما يلزمها من أعمال أو توريدات وهي المناقصات والممارسات بأنواعها والاتفاق المباشر، وفصل حالات وإجراءات كل سبيل على نحو يكفل حرية المنافسة ومبدأ المساواة بين الأشخاص والشركات)<sup>(١)</sup>. "ومن ثم يكون لكل من هذه الأساليب مجال إعماله الذي لا يجوز أن تختلط خلاله بغيره من الأساليب"<sup>(٢)</sup> دون مبرر قانوني. وهو ما يمكن دراسته في مبحثين:

---

(١) فتاوها رقم ١١١٦ بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٢١، ملف رقم ٦٤٩/١/٥٤، وفتاوها رقم ٩٦٤ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠، ملف ٦٥٣/١/٥٤، وفتاوها رقم ٩٦٣ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠، ملف رقم ٦٥٤/١/٥٤. د/ محمد علاء زعزع، موسوعة، مرجع سابق، ص ٢١١.

(٢) فتاوها رقم ٤٠٤ بتاريخ ١١/٤/١٩٩٠، بتاريخ ٢١/٣/١٩٩٠، ملف رقم ٤٣، ٤٤/٧١٣/٢٥٥، مجموعة المبادئ، مرجع سابق، المبدأ (٨٩)، ص ٢١١.



## المبحث الأول

### المناقصة العامة الطريق الأصلي للتعاقد الإداري

وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء تُعد المناقصة العامة الوسيلة الأصلية والأساسية التي تعتمد عليها الإدارة في اختيار المتعاقدين معها؛ نظرا لما توفره من تلبية الاحتياجات بأرخص الأسعار وأفضل المواصفات، نتيجة عرض عطاءاتهم بسعر أقل للمواصفات والشروط المطلوبة<sup>(١)</sup>.

وسوف نتناول أحكامها وإجراءاتها في المطالب الآتية:

## المطلب الأول

### مفهوم المناقصة وبيان أهميتها ونطاقها

بعيدا عن كونها لغة من صيغ المبالغة التي تقيد التكرار على وزن مفاعلة، ومشتقة من الفعل نقص ينقص نقصا ونقصانا فيراد بها: النقص والخط من الشيء والتقليل منه؛ بهدف المنافسة.

واصطلاحا، فيختلف التعريف بحسب رؤية كل فقيه، فقول: أولى طرق إبرام العقد الإداري<sup>(٢)</sup>، وتلتزم بمقتضاها الإدارة باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها شروطا، سواء من الناحية المالية أو الفنية، أو من ناحية الخدمة المطلوب أدائها<sup>(٣)</sup>. وهو ما اعترض عليه البعض<sup>(٤)</sup> لأن

(١) د/ إبراهيم محمد شاشو: أحكام المناقصة في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مج ٢٧، ع ٤٤، ٢٠١١، ص ٤٤٠. ونشرته دار المنظومة.

(٢) د/ أحمد سلامة بدر: العقود الإدارية وعقد البوت، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٣، ص ٧٤.

(٣) د/ سليمان الطماوي: الأسس العامة للعقود، مرجع سابق، ص ٢٢٦.

(٤) د/ رفيق يونس المصري: مناقصات العقود الإدارية- عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة، دار المكتبي، دمشق، ٢٠١٠، ص ٩ وما بعدها.

الأفضلية من ناحية الخدمة تعد مدخلا للتلاعب، ويجب قصرها على الناحية المالية فقط، على أساس أن العطاءات تتساوى من الناحية الفنية. وعرفها بأنها: "طريقة خاضعة لنظام محدد؛ لشراء سلعة أو خدمة تلتزم فيها الجهة الإدارية بدعوة المناقصين لتقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة الأجل للوصول إلى أرخص عطاء بافتراض تساوى العطاءات في سائر المواصفات والشروط".

ويتفق معه البعض، ويراه: "مجموعة من الإجراءات تهدف الإدارة من ورائها إلى اختيار المتعاقد الذي يتقدم بأرخص الأسعار، فالمناقصة تهدف أساساً إلى تحقيق المصلحة المالية"<sup>(١)</sup>. أو: "هي مجموعة من الإجراءات تلتزم الإدارة بمقتضاها باختيار أفضل المتقدمين شروطاً وأقلهم سعراً لإنجاز أعمال مطلوبة"<sup>(٢)</sup>. أو: الطريقة أو الأسلوب الأساسي لاختيار الإدارة المتعاقد معها، بأقل الأسعار وأحسن الشروط<sup>(٣)</sup>؛ إذ تلتزم بمقتضاه كأصل عام باختيار أفضل المتقدمين عطاء وفق الشروط المقررة قانوناً، من حيث الثمن والإمكانات المالية، والمواصفات والقدرات الفنية، وزمن التنفيذ، ونوع الخدمة المطلوب أدائها<sup>(٤)</sup>، وغيرها.

وأياً كانت التعريفات، فإن المناقصة العامة هي: أسلوب أو طريق أصلي للتعاقد، يُسمح فيه بالاشتراك لعدد غير محدود من أصحاب العطاءات

---

(١) المستشار د/ محمد ماهر أبو العينين: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٢٦٩.  
(٢) د/ عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون، مرجع سابق، ج ١، ص ٢٢٦.  
(٣) د/ محمد الشافعي أبو راس: العقود، مرجع سابق، ص ٧٥.  
(٤) د/ جمال جبريل: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٩٠.

-الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين-؛ بغرض التعاقد مع الجهة الإدارية الطالبة أو المستفيدة وفقا لأحكام القانون، وذلك بعد إعلانها عن رغبتها في التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية، لتقديم عروضهم الفنية والمالية في إطار من المساواة والمنافسة والشفافية، ما لم تكن طرق التعاقد الاستثنائية أكثر ملائمة.

### **معيار اختيار "الأقل عطاءً" وأهداف المناقصة العامة:**

تعد المناقصة النموذج الأمثل لإبرام العقد الإداري، والضامن لتحقيق أهداف المرفق والمصلحة العامة<sup>(١)</sup>، من خلال التعاقد مع أصحاب العطاءات الأيسر والأفضل شروطاً، والأقل سعراً، والقابلة للحد الأدنى. وكان معيار اختيار "الأقل عطاءً" أو اختيار الإدارة للمتعاقدين بأقل الأسعار وأحسن الشروط، وتنفيذ موضوع العقد بأقل مقابل تتحمله هو المعيار الرئيس المشهور والمتعارف عليه من قبل؛ لتحديد شخصية المتعاقد، بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى للسعر الأساسي المحدد من قبل الإدارة الطارحة. إلا أن هذا المبدأ قد تطور في الآونة الأخيرة، فلم يعد هو معيار الاختيار الأمثل، بل حل محله معيار "أفضل العطاءات" أو "الأفضل شروطاً وسعراً"، أو كما عرفته اللائحة التنفيذية العطاء الأفضل

---

(١) د/ السلال سعيد جمعة الهويدي: أسلوب المناقصة في إبرام العقود الادارية - دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة في الانظمة الادارية لدولة الامارات العربية والدول الاجنبية، مكتبة التبراة، الإمارات، ١٩٩٨، ص٥.

شروطا والأقل سعرا، أو الذي يتم ترجيحه وفقا لنظام النقاط<sup>(١)</sup>، والذي تم إخطاره بتزسية العملية عليه، واعتباره العطاء الفائز.

وغدا معيار المفاضلة يعتمد على الكثير من العناصر الأخرى، مثل: سابقة الأعمال، ونوعية الأداء، ومدة التنفيذ، والكفاءة المشهود بها في تنفيذ الأشغال العامة.. وغيرها<sup>(٢)</sup>.

بالإضافة إلى أولوية العطاء، بأن يقوم المتناقص صاحب العطاء بتقديم صورة صادقة لأسعاره دون مغالاة في أسعار الأعمال التي ينتظر زيادة حجمها أو كمياتها عند التنفيذ، وإنقاص الأعمال الأخرى نقصانا ينأى بها عن حقيقتها وصولا إلى التعاقد مع جهة الإدارة<sup>(٣)</sup> - مع مراعاة أنه لا محل لإعمال شرط أولوية العطاء على الأعمال الإضافية والمستجدة حال التعاقد بالاتفاق المباشر<sup>(٤)</sup> -؛ إذ قد أثبتت التجارب العملية أن معيار الأقل سعرا لم يعد الأنسب والأصلح دائما، بل قد يدفع المتعاقد إلى التلاعب والتزوير وغيره؛ ليحقق لنفسه الأرباح والتوازن المالي<sup>(٥)</sup>.

**وأيا كان، تُحقق المناقصة العامة عدة أهداف جوهرية، منها:**

**١- تحقيق الشفافية والعلانية في التعاقدات الحكومية.**

---

(١) المادة (٧٣) من قانون التعاقدات.  
(٢) المستشار د/ عبد الفتاح أبو الليل، أساليب، مرجع سابق، ١٩٩٤، ص ٤٢٤.  
(٣) فتوى الجمعية العمومية رقم (٧٦٩) بتاريخ ١٠/١١/٢٠٠٣، ملف رقم ٥٢/٢/٧٨.  
لدى المستشار د/ محمد علاء زعزع: موسوعة، مرجع سابق، ص ٦٧٥.  
(٤) فتوى الجمعية العمومية رقم (١٣٨٨) بتاريخ ١١/٦/٢٠٢٤، ملف رقم ٥٨١٣/٢/٣٢.  
لدى المستشار د/ محمد علاء زعزع: موسوعة، مرجع سابق، ص ٦٨٣.  
(٥) Francis-Paul Benoit. Le droit administratif Français, Paris- Librairie Dalloz, 1968. P.609 et Ss, art. 1080.

٢- ضمان المنافسة الحرة بين أكبر عدد ممكن من المتقدمين.

٣- اختيار أفضل العروض من حيث الجودة والسعر.

٤- تحقيق مصلحة الخزنة العامة للدولة، بتخفيض الأعباء والتكاليف.

### ثالثاً: نطاق تطبيق المناقصة العامة:

حدده المشرع في المادة (٧/ بند ١) من قانون التعاقدات وحصرها في:

١- شراء أو استئجار المنقولات: مثال إعلان وزارة التموين شراء

المنقولات: توفير ١٠٠٠٠٠٠٠ مليون جوال جوت اثنين ونصف لبرا، لزوم

استلام خام القمح. و ٤٥٠٠٠٠٠ كيس قطن هيشيان لتعبئة القطن الزهر.

أو توريد أحبار، وإعلان جهاز شئون البيئة عن المناقصة العامة لتأجير

عدد (١٠) خطوط لنقل السادة العاملين بفرعي القاهرة والاسكندرية

ومركز العوادم، أو شراء مستلزمات حاسب آلي، أو توريد أحبار.

٢- شراء أو استئجار العقارات.

٣- التعاقد على مقاولات الأعمال: كأعمال البناء والترميم والصيانة.

٤- تلقي الخدمات: مثال: إعلان نقل خام وتقاوي المحاصيل الشتوية

والصيفية ومستلزمات الانتاج من وإلى محطات الغربلة ومنافذ التوزيع

ونقل المحاصيل من المزارع إلى الصوامع. أو توفير عمالة لتقديم

خدمات أعمال تجهيز وإعداد تقاوي المحاصيل الخام وتحميلها وتغليفها

بمركز إعداد التقاوي لوحدة حسابات الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

٥- الأعمال الفنية.

ويكون التعاقد في الأعمال السابقة بطريق المناقصة العامة. وبذات الإجراءات المنظمة لمرحلة ما قبل الطرح، والطرح والترسية والتعاقد المقررة قانوناً م ١٢١ لائحة. الأمر الذي يلزم الإدارة اتباعه كقاعدة عامة وفقاً لركن الشكل، وإلا ترتب عليه بطلان العقد لمخالفته الشكليات والإجراءات الجوهرية المقررة.

ويجوز للإدارة على سبيل الاستثناء وفي حالات معينة وبضوابط خاصة إجراء التعاقد في الموضوعات السابقة بالطرق الاستثنائية، كما سنوضحه

## المطلب الثاني

### المبادئ القانونية الخاصة والحاكمة لأسلوب المناقصة العامة

إذا كان المشرع كنظيره الفرنسي<sup>(١)</sup> قد حرص صراحة على أن تخضع طرق التعاقد والإجراءات المقررة قانوناً - بشكل عام - لمبادئ الشفافية، وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص<sup>(٢)</sup> - كما سبق - فإن المناقصة تقوم بشكل خاص على أربعة مبادئ أساسية<sup>(٣)</sup> هي: العلانية، والمساواة، وحرية دخول المناقصات العامة، وحرية المنافسة. يؤكد نص المادتين (٤، ٩) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات: (تخضع إجراءات وطرق

---

(١) د/ جابر نصار: العقود، مرجع سابق، ص ١٣٨. حيث ذكر أن كافة عقود الدولة بمقتضى نص المادة (٨٥) من قانون العقود الفرنسي تخضع لمبدأ حرية المنافسة وغيره.  
(٢) المادة (٦) من قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.  
(٣) للتفصيل؛ يراجع: أحمد بن سليمان بن محمد الغابشي: المناقصة كطريق لإبرام العقود الإدارية في ظل القانون العماني - دراسة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق - جامعة السلطان قابوس، ٢٠١١، ص ٥٣ وما بعدها. ونشرتها دار المنظومة.

وأساليب التعاقد لمبادئ الشفافية، وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص....). وهو ما نوضحه فيما يلي:

### المبدأ الأول: مبدأ العلانية والنشر

ويقصد به: إلزام الإدارة بالإعلان والنشر؛ لإخبار ذوي الشأن من مجتمع الأعمال وفتح الباب وتوجيه الدعوة لهم في مرحلة طرح العطاء للتعاقد بأسلوب المناقصة، وإبلاغهم بشروطها العامة، وإجراءاتها، وكيفية الحصول على كراسة الشروط والمواصفات العامة، والأسعار، وذلك عبر وسائل النشر الرسمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين.

ويعتبر النشر والإعلان بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار عن العمليات التي يتم طرحها بجميع طرق التعاقد الواردة بالمادة (٧) من القانون على بوابة التعاقدات، عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي السرية وعدم النشر عنها، وفقا لما تقدره السلطة المختصة هو الوسيلة الرسمية المقررة قانوناً<sup>(١)</sup>. ويتم النشر وفقا للقواعد العامة المحددة قانوناً، شريطة أن يتضمن كل البيانات المطلوبة والمقررة قانوناً.

**أهمية الإعلان:** يُعد أحد المبادئ الرئيسية، والقيود الواردة في مرحلة الطرح، ومن الإجراءات الجوهرية والضرورية التي تقوم عليها المناقصة، إذ لا يتصور وجود مناقصة بدون إعلان<sup>(٢)</sup>. وإلا بطلت المناقصة

---

(١) المادة (٤/٩) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية.  
(٢) مصباح عمر النائب: الأسس التي تقوم عليها المناقصة، مجلة الحق، س١، ع١٤، فبراير ٢٠١٤، ص ١٥٦. ونشرته دار المنظومة. د/ مطيع علي حمود جبير: العقد الإداري بين التشريع والقضاء في اليمن- دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه- حقوق عين شمس، ٢٠٠٦. ص ٣٣١.

للإخلال بمبدأ العلانية. ويتم بموجبه إعلام وإبلاغ وتوجيه الدعوة لكل من يهمهم الرغبة والاشتراك في التعاقدات الحكومية، مع بيان شروط الموضوعية اللازمة للتقدم بالعروض إلى الجهة الإدارية<sup>(١)</sup> طالبة التعاقد. حسب الظروف والامكانيات، ونوع العقد.

كما يعد الإعلان ضماناً أساسية للراغبين في التعاقد مع الإدارة، لما يوفره من ضمان فرص متساوية لهم، وخلق نوع من التنافس بينهم، بشكل يؤدي إلى اختيار أحسن العطاءات المقدمة بما ينعكس بدوره على المصلحة العامة، ويجعل الإدارة بمنأى عن الشك والانتقاد من حيث قصر الاشتراك في التعاقد معها على فئة محددة من المتعاقدين<sup>(٢)</sup>.

#### **الإعلان دعوة على التعاقد فقط:**

الإعلان عن إجراء مناقصة، أو مزايمة، أو ممارسة؛ لتوريد أو بيع بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاء ليس إلا دعوة علي التعاقد، وأن التقدم بالعطاء وفقاً للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها هو الإيجاب الذي ينبغي أن يلتقي عنده قبول الإدارة لينعقد العقد.

ويرى بعض الفقه الإعلان ما هو إلا إخطار وإبلاغ لذوي الشأن عن المناقصة التي تجريها الإدارة، وكيفية الحصول على كراسة الشروط العامة والمواصفات وجدول الفئات؛ ليتسنى للراغبين في التعاقد مع

---

(1) Quancard (Michel) : L'adjudication des marchés publics de travaux et de fournitures, 1945, P.74 et S. et Le clère (Julien): Les Marchés publics et de travaux publics, 1949, P.64. ١٤٥. لدى د/ جابر نصار، العقود، مرجع سابق، ص ١٤٥. (٢) مال الله جعفر عبد الملك الحمادي: ضمانات العقد الإداري- الإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠٠٩م، ص ٨٠: ٨١.



الإدارة التقدم بطلباتهم مع بيان شروطهم، ونسبة التخفيض التي يتناقصون بها<sup>(١)</sup>. وقد نصت عليه صراحة المادتين (٨٤) و(٢٨٠) من قانون العقود العامة في فرنسا، وذلك بالنسبة لعقود الدولة، أو عقود المحليات<sup>(٢)</sup>. والمادتين (٢٠) من قانون التعاقدات، و(٣٧) من لائحته. وهو ما يتفق مع أهداف قانون التعاقدات ومنها تطبيق معايير العلانية.

### مضمون وبيانات الإعلان أو الدعوة للتعاقد

يجب فيه توافر البيانات الآتية<sup>(٣)</sup>:

- ١- اسم الجهة الإدارية الطارحة، وعنوان إدارة التعاقدات بها، ورقم التليفون والفاكس والبريد الإلكتروني للإدارة.
- ٢- اسم العملية، ورقمها، وطريق التعاقد.
- ٣- وصفا موجزا وواضحا لموضوع التعاقد.
- ٤- مكان ومواعيد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات وثمنها، والإشارة إلى إمكانية الاطلاع على بيانات العملية، ومستندات الطرح الخاصة بها على بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.
- ٥- موعد ومكان انعقاد جلسة الاستفسارات إن وجدت، وجلسة فتح المظاريف أو الممارسة أو جلسة المزايدة، بحسب الأحوال.
- ٦- مبلغ التأمين المؤقت ونسبة التأمين النهائي.

---

(١) د/ توفيق شحاته: مبادئ القانون الإداري، ج ١، ط ١، دار النشر للجامعة المصرية، القاهرة، ١٩٥٤، ص ٧٧٥.

(٢) د/ جمال جبريل: العقود، مرجع سابق، ص ٩٥. ود/ جابر نصار: العقود، مرجع سابق، ص ١٤٧.

(٣) المادة (٣٧) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

وبتعيين على إدارة التعاقدات إذا تقرر طرح أكثر من عملية في تاريخ واحد أو تواريخ متقاربة أن يراعى الإعلان عنها في إعلان واحد.

ووفقا للقواعد العامة إذا لم يتم الإعلان عن المناقصة أو الدعوة للتعاقد مع الإدارة، أو لم تتبع الإجراءات والشروط القانونية المقررة في الإعلان أو الدعوة فإن ذلك يعيب المناقصة، ويجوز لذوي الشأن والمصلحة الطعن في قرار إرسائها أمام القضاء الإداري.

ويجب الإعلان عند التعاقد عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة العامة الداخلية أو المزايدة العلنية العامة أو المزايدة بالمظاريف المغلقة مرة واحدة بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إذا كانت بالداخل.

ويكون الإعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الخارجية مرة واحدة بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وبإحدى الصحف الدولية وبالإعلان عنها من خلال السفارات والقنصليات.

### **حالات إعادة الإعلان عن المناقصة في فرنسا ومصر:**

يتم إعادة الإعلان عن المناقصات العامة، وفقا للقضاء الإداري الفرنسي<sup>(١)</sup>، وإلا كانت العملية باطلة في الحالات الآتية:

- ١- حالة عدم تقديم أي عطاءات أو نتائجها غير محققة للمصلحة العامة.
- ٢- حالة تعديل شروط المناقصة تعديلا جوهريا بعد الإعلان الأول.
- ٣- حالة تعديل كراسات الشروط بعد الإعلان الأول.

---

(١) المستشار د/ عبد الفتاح أبو الليل: أساليب التعاقد، مرجع سابق، ص ٢٢٧.

أما في مصر إنه وإن لم يوجد نصا صريحا في هذا الشأن، إلا أنه يمكن إعادة الإعلان عن المناقصة أو الدعوة للتعاقد في مصر كأمر طبيعي وتلقائي في الحالات التي تلغى فيها المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، وكذا المزايدة وجوبا، كما إذا استغنى عنها نهائيا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو في حالة عدم تفضيل المنتج الوطني المصري، والمنصوص عليها في المادة (١٢/١) من القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥. أما في الحالات الجوازية كحالة إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد فالأمر متوقف على سلطة الإدارة التقديرية، ورؤيتها من إعادة الإعلان والطرح من عدمه، ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة ترجى منه، وبشرط أن يكون العطاء مطابقا للشروط ومناسبا للقيمة التقديرية.

**المبدأ الثاني: مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية، وهو أساس عام، يحمل ثلاثة مبادئ في مبدأ واحد. أولها: مبدأ المساواة بين المتنافسين، ويوجب معاملة جميع المشاركين في المناقصة على قدم المساواة، من حيث الشروط والإجراءات دون أي تمييز بينهم<sup>(١)</sup> لأي سبب؛ باعتبار المساواة أولي الحقوق وأساسها<sup>(٢)</sup>. وإن كان هذا لا يمنعها من استبعاد البعض لأسباب قانونية. وثانيها: مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين: بقصد إتاحة الفرصة لجميع الأفراد والشركات المتقدمين**

---

(١) أحمد بن سليمان بن محمد الغابشي: المناقصة، مرجع سابق، ص ٦٤.  
(2) Villiers. M.; Dictionnaire de droit constitutionnel, A. Colin, Paris, 1999, p.91.

بعطاءاتهم، والمتساوين في التمتع بالحقوق والواجبات دون تمييز بينهم، بخلق وسائل قانونية أو واقعية تجعل بعض المتقدمين للمناقصة في وضع أفضل أو أسوأ من غيرهم<sup>(١)</sup>؛ باعتباره ضماناً هامة لمنع أي غش أو تحايل أو تواطؤ أو فساد أو اتفاق جانبي للإعفاء من دفع مبلغ التأمين، أو للتلاعب بالأسعار أو الأوراق، أو في المضاريف المغلقة الفنية والمالية للإضرار بالبعض، واستبعاده من ميدان المنافسة<sup>(٢)</sup>، وجعلها صورية.

وقد ألزم المشرع الجهة الإدارية وجوب اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تحقيق معايير ومبادئ تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة في المنافسة، ويتعين الالتزام<sup>(٣)</sup>:

١- إتاحة الفرصة لكافة الراغبين من المتعاملين المستوفين للشروط للمشاركة في المناقصات والممارسات، والمزايدات بأنواعها والاتفاق المباشر، وأن تستند الإجراءات على مبادئ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص، إعمالاً للمادة (٨٥)، الخاصة بإنشاء سجل لقيد المتعاملين.

٢- المساواة بين المتقدمين في المعاملة وعدم التحيز لأي منهم أو التمييز بينهم، وإفساح المجال للمنافسة بين من يتوافر فيهم الشروط المطلوبة المحددة مسبقاً بمستندات الطرح<sup>(٤)</sup>.....).

(١) د/ سعاد الشرقاوي: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٣٧٥.  
(٢) د/ عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، مرجع سابق، ص ٥٤٣.  
(٣) المادة (١/٩، ٢) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.  
(٤) يقصد بها: "ما تعده الجهة الإدارية من كراسة الشروط والمواصفات، طلب المعلومات، طلب إبداء الاهتمام، طلب التأهيل المسبق، وغير ذلك"، م (١) لائحة.

وقد قضت بأن: "قبول عطاء المطعون عليه بعد الميعاد إنما هو إخلال صريح بمبدأ المساواة بين المتناقصين بما يعد استثناء على خلاف الشروط المعلنة، وإخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص،.. ويحمل في طياته قرينة على علمه بما احتوته العطاءات المقدمة في الميعاد مما ينتقض من سرية المناقصة، وبالتالي يحقق الضرر بالمصلحة العامة"<sup>(١)</sup>.

وثالثها: الشفافية إداريا بين الراغبين في التعاقد: ويقصد بها: "المصادقية والإفصاح والوضوح والمشاركة بين جهة الإدارة والمتعاملين معها"<sup>(٢)</sup>.

أو هي: "المكاشفة والمصارحة والوضوح والإعلان المقدم إلى المتعاملين مع الإدارة بشأن المعلومات المتعلقة بالقرارات والعقود الإدارية،... وكل ما من شأنه إبعاد شبهة الفساد عن النشاط الإداري"<sup>(٣)</sup>. أو: "الوضوح والصدق والعلانية في اتخاذ القرارات الإدارية.. وغيرها من أعمال الإدارة"<sup>(٤)</sup>. وهوما يلزم الإدارة بالإفصاح الكامل عن موضوع المناقصة، وشروطها الفنية والمالية، ومعايير التقييم؛ لضمان بيئة تعاقدية نزيهة، وحتى لا تتهم الإدارة بالتحيز والمحاباة لأحد، أو القيام بأعمال صورية.

---

(١) حكمها السابق رقم ١٥٥٨ بجلسة ١١/٢٤/١٩٦٢.

(٢) فارس بن علوش السبيعي: دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية، رسالة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ٢٠١٠، ص ١٥.

(٣) د/ فرقد عبود العارضي: طرق إبرام العقود الإدارية في العراق، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون - جامعة القادسية، مج ١٦، ع ٥٤٤، ٢٠٢٣، ص ٣٤٤.

(٤) د/ عبد القادر الشخيلي: دور القانون في مكافحة الفساد الإداري والمالي، مؤتمر القيادة الإبداعية والتجديد في ظل النزاهة والشفافية، ونشرته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان النزاهة والشفافية والإدارة العربية، القاهرة، ٢٠٠٦م، ص ٣٥٧.

### المبدأ الثالث: حرية دخول المناقصات العامة (مبدأ حرية التعاقد)

وهو المبدأ التقليدي الرئيس والمكمل لمبدأ المساواة، الذي يحكم إبرام العقود الإدارية، فور الإعلان عن العملية، هدفه إيجاد التنافس الحر بين المتعاقدين، والوصول إلى أكبر قدر من المنافسة، وتوسيع قاعدتها للحصول على أحسن النتائج، واختيار أفضلها، وتحقيق المصالح الإدارية؛ للحيلولة بكافة الطرق من حدوث الاتفاقات غير المشروعة<sup>(١)</sup>.

وإذا كانت الإدارة حرة في اختيار المتعاقدين وفقا للقواعد المقررة قانونا مع التزامها بمبدأ الجدوى الاقتصادية واختيار الأفضل عطاء، فإنه بالمقابل كل متعاقد حر في إبداء رغبته وتلبية دعوة الإدارة بمحض اختياره وإرادته في الدخول في المناقصة العامة وغيرها من عدمه.

### المبدأ الرابع: مبدأ حرية المنافسة (المنافسة الحرة)

عرفته بأنه: "حق الأفراد في التقدم إلى المناقصة العامة دون منع الإدارة لأحد منهم أو حرمانه من حقه في التنافس للوصول إلى إرساء العطاء عليه"<sup>(٢)</sup>. إذ يُحظر تقييد المنافسة أو قصر التقديم على فئة معينة دون مبرر قانوني.

ويُعد أحد المبادئ الحاكمة لنظام المناقصات العامة<sup>(٣)</sup>، حيث يضمن وجود منافسة حرة وشريفة بين جميع المتقدمين، في ضوء إعلان إدارة

(١) المستشار د/ عبد الفتاح أبو الليل: أساليب التعاقد، مرجع سابق، ص ٤١٨: ٤٢٣.

(٢) حكمها في القضية رقم ٢٩٤٦ لسنة ٧ق، جلسة ١٩٥٧/٤/٢١، المجموعة، س ١١، ص ٣٦٩.

(3) Quancard (Michel) : L'adjudication des marchés publics., Op.cit., P.52 et Ss.

التعاقد، ووفق الشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط، وفي الحدود المقررة قانونا. إذ ما المبرر لدخول مناقصة معروف سلفا ترسيبتها على شركة أو مقاول بعينه، بغض النظر عن وجود ملفات الآخرين، ودون إبداء الرأي حولها. إلا أن هذا ليس معناه إطلاق كامل الحرية للمتقدمين، حيث منح القانون لجهة الإدارة سلطة تقديرية تستطيع بموجبها استبعاد بعض الأفراد أو الشركات من الدخول للمناقصة كجزء جنائي كما في حالات الغش والتلاعب، والإفلاس والإعسار، أو وقائي لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة دون إساءة استعمال السلطة<sup>(١)</sup>. كما قد ينص القانون في حالات محددة على الحرمان، كعقوبة تبعية<sup>(٢)</sup>.

**شروط تحقق مبدأ حرية المنافسة:** يشترط لتحقيقه توافر ما يلي:

١- أن يكون تنافسا حقيقيا لا صوريا؛ للشفافية وحماية للمال العام.

٢- وأن يكون التنافس صحيحا وسليما قانونا.

**نطاق مبدأ حرية المنافسة:**

يجب توافره في كافة صور المناقصة العامة على السواء. مع مراعاة أن المناقصة المحدودة تخضع لكافة القواعد الخاصة بالمناقصة العامة، عدا ما تعلق منها بمبدأ حرية الاشتراك فيها؛ فالاشتراك في المناقصة العامة المفتوحة مكفولا للجميع، بعكس المناقصة المحدودة أو المقيدة فيقتصر الاشتراك فيها على الأفراد أو المشروعات التي قررت الإدارة إدراج

---

(١) د/ أحمد عثمان عياد: مظاهر السلطة العامة، مرجع سابق، ص ١٤٩.  
(٢) د/ جابر جاد نصار: المناقصات العامة- دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٧، ص ١٧.

أسماءهم في كشف خاص<sup>(١)</sup>. بالإضافة إلى ضوابط أخرى كفترة التعاقد، أو تكاليف الطرح، أو إمكانية الاتفاق بين المتنافسين، واحتمالات الإلغاء، وإمكانية استكمال النقص في استيفاء اشتراطاتها<sup>(٢)</sup>.

وقد أفقت بأنه: (ومن حيث إنه متى كانت القاعدة في المناقصة العامة هي قيامها على أساس مبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة، فإنه مما يتعارض مع هذه المبادئ اجبار المتناقصين على الدخول في الممارسة بعد أن تعلقت حقوقهم بالمناقصة التي يجب أن تكون الأساس في اختيار العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا)<sup>(٣)</sup>.

٣- القيود التي ترد على مبدأ حرية المنافسة: يرد عليها بعض القيود، كالمعلقة بمصلحة المرفق، مثل: أهلية مقدم العطاء، وحسن سمعته، وكفايته الفنية، وملاءته المالية التي يلزم الإدارة بالتثبت منها من خلال إيداعه تأميناً مؤقتاً إذا ما نكل عن إجابته<sup>(٤)</sup>. ومنها ما يتصل بحماية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة<sup>(٥)</sup>.

---

(١) د/ فؤاد العطار: وسائل تعاقد الإدارة- نظرية المناقصة والممارسة، مجلة مجلس الدولة، س٥، يناير ١٩٥٤، ص ٢٧٣.

(٢) المستشار: حمدي ياسين عكاشة: موسوعة المشكلات العملية في منازعات العقود الإدارية، الكتاب الرابع، دار أبو المجد، القاهرة، ٢٠١٦، ص ٧٢١.

(٣) فتاها السابقة رقم ٤٠٤ بتاريخ ١١/٤/١٩٩٠، مجموعة، مرجع سابق، ص ٢١٣.

(٤) حكم المحكمة الإدارية العليا رقم ٢٨٨-٤، جلسة ١٩٥٩/٥/٩، ١٢٥٢/١٠٩/٤، مجموعة المبادئ، مرجع سابق، ص ٢٥٩.

(٥) المادة (٨) من قانون التعاقدات الحكومية.



### المطلب الثالث

#### حالات إلغاء المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها وسلطة الإدارة

توجد حالات وجوبية أو جوازية قد تدفع الجهة الإدارية إلى إلغاء المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها. م ٣٧ لائحة، ونوضحها فيما يلي:

١- وقت إلغاء المناقصة أو الممارسة: تلغى المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها قبل البت فيها، وذلك بقرار مسبب من السلطة المختصة.

#### ٢- حالات الإلغاء الوجوبي والجوازي للمنافسة أو الممارسة

ميز المشرع بينها، وإن سكت صراحة عن حالات الوجوب، وأفصح صراحة عن حالات الجواز؛ لقوله: "ويجوز الإلغاء في أي من الحالات الآتية:..."، مما يفهم معه أن المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها تلغى وجوبا في أي من الحالات الآتية: (١- إذا استغنى عنها نهائيا.

٢- أو اقتضت المصلحة العامة ذلك. مثال: ظهور ضرورة إدارية أو فنية لإعادة الطرح، ككون الشروط الواردة غير دقيقة، أو ظهور مستجدات تؤثر على موضوع التعاقد، وتلحق الضرر بالصالح العام.

٣- أو في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٢) من القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ المشار إليه.

ويصدر قرار إلغاء المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها من السلطة المختصة بالجهات التي تسري عليها أحكام قانون التعاقدات، سواء من تلقاء نفسها، أو بناءً على توصية لجنة البت أو الممارسة.

أما الحالات الجوازية لإلغاء المناقصة أو الممارسة: فتتمثل في:

١ - إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد؛ لعدم تقدم أحد بعرضه في الموعد المحدد. أو تقدموا ولم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد لا يحقق المنافسة المطلوبة، ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة ترجى من إعادته.

٢ - إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات. مثال: عدم مطابقة العروض للمواصفات الفنية، أو خالفت الشروط الجوهرية للمنافسة.

٣ - إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية، ما لم تبين دراسة لجنة البت أو لجنة الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه. مثال: حدوث تجاوز ومبالغة في الأسعار المُقدَّمة، وعدم تناسبها مع القيمة السوقية، أو الاعتماد المالي المحدد.

ويحقق إلغاء المناقصة بذلك ضمانات أكثر للمرفق، والصالح العام؛ لأن كل عمل مخالف لشروط المناقصة لا يعتد به ولا يترتب عليه أي أثر<sup>(١)</sup>.

٣ - مبررات إلغاء المناقصة أو الممارسة وسلطة الإدارة:

يكون الإلغاء بقرار مسبب من السلطة المختصة؛ إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار، أو إذا تبين وجود نقص أو خطأ في كراسة الشروط والمواصفات.

---

(١) حكمها السابق رقم ١٥٥٨، بتاريخ ١١/٢٤/١٩٦٩.

وتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في تقدير حرمان ومنع أحد الأشخاص أو الشركات من التقدم للمناقصات التي تجريها؛ نتيجة إخلاله بالتزاماته العقدية، واقتراف أخطاء منه عند تنفيذ عمليات سابقة، ومخالفته الاشتراطات والمواصفات المقررة بالعقد، أو استخدامه الغش، أو تقديمه رشوة بطريق، أو بآخر لأحد موظفي الإدارة ونحوه؛ بشرط علم المتعاقد بالغش، وقصده التلاعب والتحايل كمبرر للشطب من سجل المتعاقدين، لحرمانه جزائيا من التعاقد مع الإدارة وفقا لما قرره المشرع<sup>(١)</sup>.

ولذات العلة سوى المشرع بين متعاقد يغش أو يتلاعب وآخر يشرع في رشوة أحد الموظفين، أو يتواطأ معه إضرارا بها<sup>(٢)</sup>. إلا أنها سلطة مقيدة بالشروط المقررة قانونا وبشرط عدم إساءة استعمال السلطة. وقد يكون قرار الإدارة بالحرمان أو المنع مؤقتا، أو غير محدد المدة، وقد يكون مانعا للشخص من التقدم إلى جميع المناقصات والمزايدات العامة التي تجريها الإدارة مستقبلا، وقد يقتصر على بعضها<sup>(٣)</sup> فقط.

وقد يكون حرمانا جزائيا أو عقابيا بموجب نص قانوني، أو حرمانا وقائيا بموجب قرار إداري من الإدارة بما لها من سلطة تقديرية، أو بنص قانوني مانعا لتعارض وتضارب المصالح.

---

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا رقم ٩٢٩ لسنة ٩٩ق، جلسة ١٧ يونيو ١٩٦٧، المجموعة، س ١٢، ص ١١٩٢.

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا رقم ٨٦ - ١٢ق، بتاريخ ١٦/٥/١٩٨٠، ١٥/٥/٣٢٤، المجموعة، سابق، ص ٧٦٠.

(٣) د/ جابر نصار: العقود، مرجع سابق، ص ١٣٩.

وهو ما يترتب عليه عدم قبول العطاءات التي يتقدم بها الشخص المحروم، حتى ولو كانت هذه العطاءات مستوفاة لكافة الشروط التي حددتها الإدارة<sup>(١)</sup>. وتأكيذا له قضت بأن: "للإدارة حق أصيل في استبعاد من ترى استبعادهم من قائمة عملائها ممن لا يتمتعون بحسن السمعة، ولها مطلق التقدير في مباشرة هذا الحق لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة..."<sup>(٢)</sup>. وبأنه: "يجوز أيضا استبعاد بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم،.. وذلك كإجراء وقائي تمليه غير الإدارة توخيا للمصلحة العامة وحدها"<sup>(٣)</sup>.

#### ٤- دور لجنة البت قبل التوصية باتخاذ قرار الإلغاء:

يتعين على اللجنة قبل التوصية باتخاذ قرار الإلغاء لطريق المناقصة أو الممارسة أو المزايدة، وبعد مراعاة الحالة الواردة بالمادة (٣٧/ بند ٣) من القانون-حالة إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية- دراسة الآثار المترتبة عليه أخذاً في الاعتبار الضوابط الواردة بالمادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات. كجدوى إعادة الطرح من عدمه. وغير ذلك من اعتبارات تؤثر في قرار الإلغاء. -وعلى اللجنة أن تُضمن محضرها ما اتخذته من إجراءات وتوصيات إما باستكمال

(١) د/ أحمد عثمان عياد: مظاهر السلطة، مرجع سابق، ص ١٥١.  
(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا رقم ١٠٦٧-٥، جلسة ١٩٦٢/٢/١٧، ٣٣٤/٣٨/٧، المجموعة، مرجع سابق، ص ١٧١.  
(٣) حكمها رقم ١٦٥٤-٦، جلسة ١٩٦٢/١٢/٢٢، ٢٩٩/٢٨/٨، المجموعة، ص ١٧٣.

إجراءات الغاء العملية أو إرسائها. وترفع تقريرها للسلطة المختصة لاعتماد توصياتها أو تقرير ما تراه.

وبالرغم من توصيات اللجنة إلا أنه يمكن الطعن عليها مباشرة بالإلغاء، أو وقف التنفيذ بوصفها محل القرار الصادر من السلطة المختصة. ومن ثم فهي المجال الخصب لفكرة القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد<sup>(١)</sup>.

وتخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً عند عدم مشروعيتها.

#### ٥- آثار توافر إحدى حالات إلغاء المناقصة أو الممارسة:

- ١- يكون الإلغاء بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية اللجنة.
- ٢- يجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها.
- ٣- يخطر مقدمو العطاءات بقرار الإلغاء مسبباً بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس، بحسب الأحوال.
- ٤- يجب -في جميع حالات الإلغاء- رد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات عدا مقدمي العطاءات الذين تبين وجود تواطؤ بينهم أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار. بعكس الحال في لائحة قانون المناقصات الملغى.

---

(١) المستشار د/ محمد ماهر أبو العينين: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٣٨٤.

## المبحث الثاني

### إبرام العقد الإداري بغير طريق المناقصة العامة

وهو ما يمكن تناوله من خلال بيان الأحكام العامة للطرق الاستثنائية الست، كل على حدة، في المطالب الآتية:

## المطلب الأول

### الأحكام العامة للأخذ بالطرق الاستثنائية

#### ١ - الأساس القانوني للتعاقد الإداري بالطرق الاستثنائية وصورها:

أجاز المشرع للإدارة - على سبيل الاستثناء - في المادة (٧/ بند ٢) من قانون التعاقدات، وخولها سلطة تقديرية تمارسها بناءً على قرار مُسبب من السلطة المختصة، وبعد عرض إدارة التعاقدات، وفي حالات محددة وبضوابط خاصة، أن تبرم تعاقداتها المتعلقة في ذات موضوعات المناقصة بطرق استثنائية غير المناقصة العامة، التي تُعد الأصل العام. وتختلف الطرق الاستثنائية من حيث الأسس والضوابط والإجراءات عن تلك التي تحكم المناقصة العامة؛ إذ لا تعتمد بالضرورة على العلانية، أو على أوسع نطاق، وإنما تتيح للإدارة قدرًا من المرونة في الاختيار.

وكان يستخدم مصطلح "عقود التراضي"؛ للإشارة إلى العقود التي تبرمها الجهات الإدارية بغير طريق المناقصة، غير أن قانون العقود العامة الفرنسي الجديد استبدله بمصطلح "عقود التفاوض"؛ لإزالة

الغموض واللبس الذي قد يرد على تعبير "التراضي"، والتأكيد على أنه رغم مرونتها تظل عقودا خاضعة لضوابط المنافسة الحرة والعينية، واختيار الأصلح للإدارة<sup>(١)</sup>.

## ٢- سلطة الجهة الإدارية في التعاقد بالطرق الاستثنائية:

تتمتع جهة الإدارة في حالات التعاقد بإحدى الطرق الاستثنائية المناسبة خلافاً للمناقصة العامة بقدر من الحرية، تتسع وتضيق بما يتلاءم مع طبيعة العقد وظروفه، ووفقاً لما رسمه المشرع، متى توافرت الضوابط والشروط الموضوعية والشكلية التي تبرر العدول عن الأصل العام.

إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، بل تمارس في نطاق رقابي يبدأ من خلال إدارة التعاقدات المختصة داخل كل جهة إدارية، والتي تُنَاط بها مهام متابعة تنفيذ التعاقدات المبرمة، وإرسال وتلقي الإخطارات ذات الصلة، والتواصل مع الجهات الأخرى المعنية، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والمقررة قانوناً، وغيرها ما ورد بينود العقود.

ويمكن القول إن جهة الإدارة ليست ملزمة باتباع أسلوب تعاقدى بعينه في جميع الأحوال، وإنما تملك سلطة اختيار الوسيلة الأنسب لتحقيق المصلحة العامة، وحفاظاً على المال العام، ووفق المقرر قانوناً.

## ٣- قواعد عامة مشتركة بين طرق التعاقد الأصلية والاستثنائية:

توجد بعض القواعد العامة المشتركة لجميع طرق الإبرام، تتمثل في:

---

(١) د/ جمال جبريل: العقود، مرجع سابق، ص ١٦٤.

١ - الخضوع للمبادئ الدستورية والتنظيمية العامة، كالشفافية، وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وسلامة الإجراءات المتخذة وفقا لقانون التعاقدات ولأئحته التنفيذية، والقوانين ذات العلاقة.

٢ - سريان أحكام المناقصة العامة على بعض الوسائل الاستثنائية، كالمناقصات المحدودة، وذات المرحلتين، والمحلية، والممارسة العامة، والممارسة المحدودة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو اللائحة<sup>(١)</sup>، تأكيداً لوحدة المبادئ الإجرائية، وضماناً لسلامة التطبيق.

٣ - تطبيق القواعد الخاصة بشراء أو استئجار المنقولات على العقارات، وخضوعها لنفس الأحكام والقواعد المنظمة، وبما لا يتعارض مع الطبيعة القانونية والواقعية للعقار<sup>(٢)</sup>.

وقد قضت بأنه: "متى حدد المشرع طريقة معينة وإجراءات محددة لإبرام عقود الإدارة؛ فإن طريقة التعبير عن الإرادة تختلط حالتئذ بمشروعيتها، فلا تكون الإرادة صحيحة ومعتبرة إلا بإتباع هذه الطريقة"<sup>(٣)</sup>.

#### ٤ - الشروط العامة للأخذ بالأساليب الاستثنائية

الأصل العام أن يتم التعاقد عن طريق المناقصة في موضوعات الشراء أو الاستئجار، ومقاولات الأعمال، وغيرها مما حددته م ٧ قانون. إلا أنه

(١) م ٦٠ من قانون التعاقدات لعام ٢٠١٨، والمادة (١٣٠) من لائحته التنفيذية.

(٢) م ٦١ من قانون التعاقدات.

(٣) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١١٠٠٨ لسنة ٤٨ ق. عليا، جلسة ٢٠١١/٦/٢٢. وحكمها في الطعن رقم ٣٠٩٥٢، ٣١٣١٤ لسنة ٥٦ ق. عليا، جلسة ٢٠١٠/٩/١٤. وحكمها في الطعن رقم ٣٣٢٩٣ لسنة ٥٥ ق. عليا، جلسة ٢٠١٦/٦/٢٨.



يمكن اللجوء إلى غيرها من الطرق الاستثنائية على سبيل الاستثناء، ووفقاً للضوابط المقررة، ويتوافر شرطين أساسيين هما:

أولاً: توافر إحدى الحالات الاستثنائية القانونية التي تُجيز العدول عن أسلوب المناقصة العامة، وفقاً لطبيعة التعاقد أو ظروفه.

ثانياً: صدور قرار مسبب من السلطة المختصة؛ بناءً على عرض من إدارة التعاقدات يتضمن مبررات وأسباب الفنية العدول، وتحديد الملائم.

وتتطبق الشروط العامة على جميع طرق التعاقد الاستثنائية الست، مع وجوب مراعاة الحالات والشروط الخاصة المقررة قانوناً لكل حالة على حدة، سواء من حيث حدود القيمة المالية، أو طبيعة التعاقد، أو جهة الاعتماد، أو الإجراءات الفنية الواجب اتباعها، أو جواز طلب إبداء الاهتمام، أو طلب التأهيل المسبق.

## المطلب الثاني

### الممارسة العامة

أولاً: مفهوم الممارسة العامة:

تُعد الممارسة من الوسائل الاستثنائية، حيث تقوم على التفاوض مع عدد من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات في حالات محددة- لا يقل عن ثلاثة- للمفاضلة بين عروضهم المالية، وصولاً إلى أفضل عرض. وتعد هي الوسيلة الأكثر شيوعاً في إبرام عقود الدولة، أو عقود

المحليات في فرنسا<sup>(١)</sup>. ويُعرفها البعض بأنها: أسلوب مبسط لعملية التعاقد، يهدف إلى ضمان الشفافية والمنافسة من خلال تلقي عروض من عدة متنافسين والمفاضلة بينها، دون إجراءات المناقصة التقليدية<sup>(٢)</sup>. ويراهـا آخـر: وسيلة تعاقدية استثنائية تقوم على التفاوض المباشر بين الجهة الإدارية وعدد من المرشحين، دون التقيد بكافة إجراءات المناقصة العامة؛ لاختيار العرض الأنسب، وإبرام العقد على أساسها<sup>(٣)</sup>.

**مثالها:** إعلان جامعة القاهرة بشأن التعاقد مع شركات نظافة للمدن الجامعية للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤<sup>(٤)</sup>. وإعلان جامعة الأزهر - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن - عن طرح ممارسة عامة لتوريد مرواح حائط كهربائية للكلية وإدارات الجامعة، للعام المالي ٢٣/٢٤<sup>(٥)</sup>.

وتُتيح الممارسة للإدارة مرونة واسعة في التفاوض، خلافاً للمناقصة التي تقيدها بضوابط تتعلق بفتح المظاريف والتقييم والترسية. لذا يراها البعض تماثل المزايدة إلى حد كبير مع الفارق، نتيجة لاعتمادها على تقديم عروض متتالية تتناقص فيها الأسعار حتى تُرسى العملية على العرض الأقل من سابقه<sup>(٦)</sup>.

(١) المستشار د/ عبد الفتاح أبو الليل: أساليب، مرجع سابق، ص ٣٣١. ود/ جمال جبريل: العقود، مرجع سابق، ص ١٦٧.

(٢) حمدي ياسين عكاشة: موسوعة، الثاني، مرجع سابق، ص ٧٢٦.

(٣) المستشار د/ محمد أبو العينين: العقود، مرجع سابق، ص ٨٢٤.

(٤) جريدة الأهرام، ع ٤٩٩٨٣، س ١٤٨، بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣.

(٥) نشرت إلكترونياً بتاريخ <https://www.monaksaty.com/p/download-page.html> (5) ٢٠٢٣/١٠/٣م

(٦) حمدي ياسين عكاشة: موسوعة، الثاني، مرجع سابق، ص ٧٢٨.

## ثانيًا: الأساس القانوني للممارسة العامة

أوضحت المادتين (٥٤) من قانون التعاقدات، والمادة (١٢٢) من لائحته التنفيذية أحكام وشروط وحالات الممارسة العامة. حيث يشترط لاعتبار لجوء الإدارة إلى الممارسة العامة كطريق استثنائي صحيحًا ومشروعًا، أن يكون التعاقد بطريقها في الحالات التي تتوافر فيها الشروط الثلاثة - مجتمعة - الآتية:

١- أن يكون متاحا للجهة الإدارية وضع توصيف محدد ودقيق لموضوع التعاقد.

٢- أن يكون لموضوع التعاقد معايير قابلة للقياس الكمي والتي على أساسها يتم تحديد مدى استجابة العروض فنيا.

٣- أن يكون معلوما للجهة الإدارية وجود عدد كاف من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات للمشاركة في العملية لضمان تحقيق المنافسة الفعالة. وهنا يجوز للإدارة - إذا اقتضت طبيعة العملية - إصدار طلب لإبداء الاهتمام، أو طلب تأهيل مسبق<sup>(١)</sup>.

وأيا كان يشترط توافر الشروط الثلاثة السابقة مجتمعة. ويؤدي الإخلال بأي منها إلى بطلان التعاقد، باعتباره مخالفا لقواعد الشكل والإجراءات الجوهرية. وقد قضت بأنه: (كمبدأ أصيل يكون تعاقد الإدارة عن طريق المناقصة، والأخذ بأسلوب الممارسة لا يكون إلا في حالات معينة وفي

---

(١) يراجع تعريف كل منهما، م ١ من قانون التعاقدات.

أُضيق الحدود طبقاً للأوضاع والشروط المرسومة قانوناً...<sup>(١)</sup>. كما قضت: (إن مبدأ التعاقد في مجال العقد الإداري عن طريق الممارسة أو الاتفاق المباشر يخضع لقاعدة حرية الإدارة في اختيار المتعاقد، وإن كانت هذه الحرية في الاختيار لا يتنافى معها إخضاع عملية الممارسة لتنظيم قانوني معين... وبهذه الحقيقة تتميز طرق التعاقد عن طريق الممارسة عن طريق التعاقد عن طريق المناقصات العامة)<sup>(٢)</sup>.

#### رابعاً: الإعلان والعلانية في الممارسة العامة:

يجب الإعلان عن الممارسة العامة وفقاً لما يلي:

١- النشر على بوابة التعاقدات العامة.

٢- والإعلان في صحيفة يومية واسعة الانتشار -كجريدة الأهرام، أو الأخبار، أو الجمهورية ونحوها- على أن يكون ذلك قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف بعشرين يوماً على الأقل.

ويجوز تقصير مدة الإعلان إلى أربعة عشر يوماً في حالات الاستعجال، بموافقة السلطة المختصة. وتحتسب المدة من تاريخ الإعلان<sup>(٣)</sup>.

---

(١) حكمها السابق رقم ١٥٥٨، بتاريخ ١١/٢٤/١٩٦٩.  
(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا رقم ١٦٥٤-٦٦ق، جلسة ١٢/٢٢/١٩٦٢، ١٩٦٢/٢٨/٨. ٢٩٩.  
وحكمها رقم ١٦١-٩، جلسة ١٨/٣/١٩٦٧، ٧٦٩/٨٢/١٢، مجموعة، سابق، ص ٢٩٦.  
(٣) حددت جامعة القاهرة في إعلانها السابق جلسة استلام العطاءات وفتح المظاريف الفنية بمكتب مدير عام المدن الجامعية الخميس الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢٣، (١٢) ظهراً.

## المطلب الثالث

### الممارسة المحدودة

#### أولاً: تعريف الممارسة المحدودة

يقصد بها: أسلوب استثنائي للتعاقد الإداري، تتبعه الجهة الإدارية عند تعذر اتباع الطريق الأصلي "المناقصة" يقوم على التفاوض مع عدد محدد من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات المؤهلين، والمسجلين والمتخصصين في النشاط محل الطرح، دون طرح العملية للجمهور أو الإعلان عنها، وذلك في إطار قانوني منظم يلتزم بذات الإجراءات المقررة للممارسة العامة، ولكن في نطاق ضيق ومحكوم، يُراعى فيه طبيعة العملية التعاقدية وخصوصيتها، وتحقيق السرعة.

وهي بذلك تختلف عن الممارسة العامة في كونها تُوجّه لمجموعة مختارة من المتخصصين المسجلين بالنشاط محل الطرح، وفي قطاعات تخضع لضوابط السوق المحلي في حين تُعلن الممارسة العامة عبر بوابة التعاقدات العامة والصحف الرسمية لإتاحة أوسع نطاقاً من المنافسة.

**مثالها:** إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة لتوريد زيت خام محلي من زيت الصويا، وزيت العباد بالجنيه المصري لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع تحديد الأصناف والكميات وشروط التسليم والتقييم وبالشروط والمواصفات بكراسة الشروط<sup>(١)</sup>.

---

(١) الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠٢٣.

## ثانياً: حالات اللجوء إلى الممارسة المحدودة

حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة (٥٥) من القانون، وهي:

١- **الحالات والتعاقدات المتعلقة بالأصناف أو الخدمات الخاصة بسبب طبيعتها أو مصادرها:** كحالة الأصناف أو الخدمات المطلوب التعاقد عليها تُصنَّع أو تُستورد أو تُقدَّم حصرياً من قبل أشخاص أو كيانات محددة بذواتهم، أو تقتضي طبيعتها أو الغرض منها أن يتم شراؤها من أماكن إنتاجها مباشرة، بطريق الممارسة المحدودة.

مثال: الأجهزة أو المستلزمات الطبية أو التعويضية المُصممة بمواصفات خاصة للمرضى. ويجوز هنا أن تُصدر الجهة الإدارية "طلب إبداء الاهتمام" أو "طلب تأهيل مسبق"، بحسب طبيعة العملية، م ١٢٣ لائحة.

## ٢- **التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومي:**

وهي الحالات التي تتعلق بحسب طبيعتها بالأمن القومي، وتستلزم السرية، وتمنع الإعلان العام، كالعمليات الخاصة بوزارات الدفاع والداخلية والخارجية، أو تلك المرتبطة بالمرافق العامة ذات الطابع السيادي، وذلك حفاظاً على سريتها ودرءاً لأي مساس بالأمن القومي.

وقد استتثنتها المادة (١/٨٦) من القانون صراحة من النشر العلني، شريطة أن تُجرى بطريقة سرية وفقاً لما تقدره السلطة المختصة، مع إلزام الجهة الإدارية بالاحتفاظ بتفاصيل العملية في ملف خاص، وتوثيق أداء المتعاقد، بما يضمن جودة التنفيذ والانضباط الزمني.

كما أجازت المادة (٧٨) من ذات القانون للهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وجهاز المخابرات العامة التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بموافقة السلطة المختصة دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية المقررة، أو باستخدام طرق التعاقد الاستثنائية كالمناقصة المحدودة أو الممارسة المحدودة.

كما يجوز لأي منها أن تتوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، بشرط الالتزام بالقواعد السارية لدى الجهة طالبة التعاقد. ويُحظر - في هذا السياق - التنازل عن العقود المبرمة بينها لصالح أي جهة أخرى من غيرها.

**٣- التعاقدات والحالات المرتبطة بضرورة التوافق مع تجهيزات أو نظم قائمة بالفعل لدى الجهة الإدارية، وكان هذا التوافق ضرورياً بسبب غياب البدائل الفنية الحقيقية، مع وجود أكثر من مورد أو مصدر، جاز التعاقد بالممارسة المحدودة.**

**مثال:** حالة تحديث أو تطوير برمجيات أو نظم تشغيل حاسوبية متاحة بالفعل لدى الجهة الإدارية. أو عند تنفيذ أعمال تتطلب تكاملاً تشغيلياً أو فنياً مع معدات أو نظم قائمة، دون استبدالها أو تعديلها إلا بالتوافق. ويجب مراعاة حكمي الشرطين بالمادة (٥٤ / ١، ٢) من القانون بأن يكون في مقدور الجهة إعداد توصيف فني دقيق للموضوع، ووجود معايير فنية قابلة للقياس الكمي يمكن على أساسها التقييم.

ويجب التفرقة بين التنظيم القانوني للممارسة العامة والممارسة المحدودة من حيث الشروط، إذ يُشترط - وفق المادة (٥٤) من القانون - توافر جميع الشروط الثلاثة لإمكان اللجوء إلى الممارسة العامة، والإعلان عنها. بينما يكفي المشرّع - في المادة (٥٥) - بتوافر واحدة من الحالات المنصوص عليها فيها للجوء إلى الممارسة المحدودة، بشرط انطباق الشرطين الفنيين الواردين بالمادة (٥٤)، بدعوات مباشرة.

#### ثالثاً: النشر وتوجيه الدعوة في الممارسة المحدودة

أوجب المشرّع النشر عن الممارسة المحدودة على بوابة التعاقدات العامة، وتوجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المسجلين عليها، المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط موضوع الطرح، وذلك بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية. ويجوز بموافقة السلطة المختصة - في حالات الاستعجال - تقصير تلك المدة، بشرط ألا تقل عن عشرة أيام. وتحتسب المدة من تاريخ توجيه الدعوة؛ إذ الإعلان العام ليس بلازم، بل يتم التواصل المباشر مع المسجلين عليها، بما يحقق المنافسة الفعلية، والسرعة والمرونة المطلوبة.

#### رابعاً: آلية وإجراءات التمارس في الممارسة (العامة والمحدودة)

تُجري الممارسة بنوعيتها وفق آلية محددة، تبدأ من مقدمي العطاءات أصحاب العروض المقبولة فنياً، وتنتهي عند لجنة التمارس. كالاتي:



١- دور مقدمي العطاءات المقبولة فنياً: تقتصر المشاركة في جلسات التفاوض المالي (التمارس) المحددة على مقدمي العروض التي اجتازت التقييم الفني بنجاح دون غيرهم.

وقد تتضمن الجلسات جولة واحدة أو عدة جولات متتالية. يمنح خلالها كل عارض فرصة لتقديم عرضه المالي في ضوء العروض الأخرى، بقصد الوصول إلى أفضل الشروط التعاقدية، وأقل الأسعار الممكنة، ما لم يكن التقييم معتمداً على نظام النقاط الفنية والمالية.

## ٢- دور لجنة الممارسة:

تتولى لجنة الممارسة<sup>(١)</sup> المُشكّلة بقرار من السلطة المختصة- فتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنياً فقط، وممارسة مقدميها أو من يفوضونهم، في جولة أو عدة جولات في الجلسة المحددة؛ للوصول إلى أفضل الشروط وأقل الأسعار، أو الذي يتم ترجيحه وفقاً لنظام النقاط<sup>(٢)</sup> المحددة أسسه وعناصره والوزن النسبي بشروط الطرح، والحد الأدنى للقبول؛ وذلك بعد توحيد أساس المقارنة بين العروض من جميع النواحي الفنية والمالية. ويُراعى أن يكون التقييم المالي قائماً على أسس عادلة وموضوعية تضمن اختيار العرض الأكثر كفاءة والأقل تكلفة نسبياً، مع مراعاة خصوصية كل تعاقد وطبيعته الفنية والمالية.

---

(١) المادة (١/١٢٤) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات.  
(٢) هو: "أحد أساليب تقييم العطاءات، يتم فيه تطبيق معايير الجودة الفنية والسعر مجتمعين عن طريق تحديد أسس وعناصر التقييم، والوزن النسبي للجانب الفني أو الفني والمالي للعطاءات بحسب طبيعة العملية، والحد الأدنى للقبول وصولاً إلى درجات أو نسب إجمالية لكل عطاء، بما يكفل تحديد أولوية ترتيبه"، م ١ قانون التعاقدات.

## خامساً: الضوابط القانونية للتمارس - حظر الإعادة والترتيب

أحاط المشرع جلسات التمارس ببعض الضوابط لضمان النزاهة والشفافية، وردت في المادة (٢٤١/٢ و ٣) من اللائحة التنفيذية، كالتالي:

١- **حظر إعادة التمارس:** حيث يُحظر في جميع الحالات، إعادة فتح باب التمارس مرة أخرى لما تم الانتهاء إليه من تمارس. إذ الجولات التي تُعقد للتفاوض المالي نهائية، ولا يجوز الرجوع فيها.

٢- **حظر الترتيب بين الممارسين:** حيث يُحظر الترتيب بينهم قبل أو بعد تقديم عطاءاتهم، أو أثناء الجلسة؛ بهدف منع تحقيق غرض غير مشروع، وتجنب الإخلال بمبادئ المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية أو التواطؤ أو التلاعب بالأسعار، وتجزئة العقود.

وإذا ما ثبت وجود غش أو تلاعب أو تواطؤ أو احتيال من أحد المتعاقدين في التمارس، وجب على الجهة الإدارية فسخ العقد تلقائياً، وشطب اسمه من سجل المتعاملين مع الدولة بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. وإخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشرها قرار الشطب على البوابة. وبشرط تحقق إحدى الحالتين:

١- أن يتبين أن المتعاقد استعمل -بنفسه أو بواسطة غيره- الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية، أو في الحصول على العقد.

٢- وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو احتكار أو فساد تؤثر على عدالة الإجراءات ونزاهتها

## المطلب الرابع

### المناقصة المحدودة

#### أولاً: مفهوم المناقصة المحدودة

تعد أحد أساليب التعاقد الإداري الاستثنائية التي يقتصر فيها التنافس على عدد معين من الأفراد أو الشركات المتخصصة المؤهلين مسبقاً بما لديهم من كفاءة مالية وفنية، يتم اختيارهم من واقع القوائم المعدة سلفاً لدى الجهة الإدارية، وفقاً لطبيعة الأعمال، وبناءً على توافر شروط معينة، ويدعون لتقديم عروضهم بطرح المناقصة عليهم دون إعلان عام مفتوح للجمهور، للوصول إلى أفضل عطاء<sup>(١)</sup>.

أو هي: وسيلة استثنائية من وسائل التعاقد تمنح الإدارة سلطات واسعة إزاء بعض العقود التي تتطلب كفاءات فنية خاصة، حيث يكون لها أن تضع مقدماً قائمة بأسماء الأشخاص الذين لهم فقط حق التقدم للمناقصة<sup>(٢)</sup>. أو هي: وسيلة شراء، يدعى للاشتراك فيها الموردون المعتمد التعامل معهم من الجهة إدارية، بالنظر إلى كفاءاتهم وتخصصهم في موضوع المناقصة المطروحة، ووفقاً للضوابط والشروط والحالات المقررة قانوناً. وتُعرف بأسماء أخرى مثل: المناقصة الانتقائية أو المناقصة من القائمة؛ تتم في إطار قائمة مغلقة من المتناقصين

(١) المستشار: حمدي ياسين عكاشة: موسوعة المشكلات العملية في منازعات العقود الإدارية، الكتاب الثاني، دار أبو المجد، القاهرة، ٢٠١٦، ص ٧١٠ وما بعدها. د/ نواف كنعان: مبادئ القانون الإداري، جامعة الشارقة، ٢٠٠١، ص ٢٦١.

(٢) د/محمد على الخلايلة: القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص ٢٩٤.

المحليين أو الدوليين<sup>(١)</sup>، يكون قد جرى تأهيلهم أو انتقاؤهم مسبقاً من قبل الجهة الإدارية، باعتبارهم ذوي كفاءة وخبرة في موضوع العقد.

**ومن أمثلتها:** إعلان الهيئة العامة للخدمات الحكومية طرح شراء أجهزة حاسب آلي hp وطابعات بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٣ مع غلق باب التقديم واستقبال العطاءات في ١٧/٩/٢٠٢٣ الساعة ١٢ ظهراً. وإعلان شراء بطاريات. وإعلان الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن طرح مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروع شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد لمدينة ناصر بمحافظة بنى سويف، بنظام المظروفين الفني والمالي.

وقد يلجأ إليها أحياناً لتوريد كميات صغيرة من مستلزمات محددة، أو شراء آلات ومعدات ذات طبيعة تخصصية، كأجهزة صيانة الطرق أو الآلات الزراعية، وتوريد الكميات الصغيرة<sup>(٢)</sup>. أو لاستكمال أسطول تقني موجود. أو إنشاء ميناء، أو محطة أقمار صناعية، أو مصنع أجهزة إلكترونية وغيره مما يحتاج إلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة<sup>(٣)</sup>.

**ثانياً: خصائص المناقصة المحدودة:** تتميز بعدد من السمات تجعلها وسطاً بين المناقصة العامة والممارسة<sup>(٤)</sup>:

---

(١) نعيم عطية: التعاقد الدولي وتجهيز مشروعات التنمية - اختيار المتعاقد، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة، ص ٢٣ وما بعدها.  
(٢) حمدي ياسين، موسوعة، الثاني، سابق، ص ٨٠٠ وما بعدها.  
(٣) د/ نواف كنعان، مرجع سابق، ص ٢٦٣.  
(٤) للتفصيل؛ يراجع: نواف نواف نواف أبو زيد: المناقصة المحدودة "المفاوضة والتلزم" كأحد طرق التعاقد الإداري - دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والإماراتي، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا - جامعة مؤتة، ٢٠٢٣، ص ٢٢ وما بعدها. دار المنظومة

١ - خضوعها لأحكام المناقصة العامة: فهي مناقصة بالمعنى الفني الكامل- وإن اختلفت كأسلوب استثنائي، وتوجيه الدعوة- حيث تخضع لذات القواعد والإجراءات المقررة قانوناً، وتسري عليها الأحكام الخاصة بالمناقصة العامة فيما لم يرد في شأنه نص خاص. م(٦٠) قانون.

٢ - انتقائية المشاركة: حيث يتم توجيه الدعوة فيها لمتعاقدين معتمدين تم تأهيلهم أو قبولهم مسبقاً، مما يسمح للإدارة بتقييد دائرة المنافسة، وضمان التعامل مع جهات موثوقة ومجربة، بعكس المناقصة العامة.

٣ - تقليل التكلفة والوقت واختصار الإجراءات<sup>(١)</sup>: حيث تمتاز المناقصة المحدودة بالاقتصاد في الوقت والتكلفة، مع ضمان مستوى جودة أعلى في التنفيذ، بسبب اختيار متعاقدين ذوي كفاءة.

#### سلطة الإدارة التقديرية في المناقصة المحدودة:

سلطة الإدارة التقديرية فيها مقيدة، تستطيع من خلالها اختيار بعض الأشخاص، للتعاقد معها، تقديراً لكفايته وخبراته الفنية<sup>(٢)</sup>. من واقع قوائم مسبقة، أو إجراءات تأهيل محددة سلفاً. وإن تميزت بالمرونة في اختيار المتعاقد القادر على التنفيذ في الأوقات الحرجة، أو في مجالات ذات طبيعة خاصة، وإتاحة الفرصة لتقديم عروض أكثر واقعية وجدية.

وقد تُثير سلطة الإدارة عدداً من الإشكالات، كاحتمال تقييد حرية المنافسة، وعدم إتاحة الفرص أمام الشركات المتخصصة، واستغلالها

---

(١) عاصم بن سعود السباط: آلية إبرام العقود الإدارية والأسباب المؤدية إلى بطلانها، مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد، ع٥٩، أغسطس ٢٠١٦، ص٣٠٩.  
(٢) د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة: الأسس العامة، مرجع سابق، ص١٤٣.

أحياناً لتكريس المحاباة أو المجاملة الشخصية، باقتصار الدعوة على شركات بعينها، أو نتيجة وجود تفاهمات مسبقة بين المدعويين للتلاعب بالأسعار، ورفع التكلفة نظير مصالح متبادلة<sup>(١)</sup>.

**ثالثاً: حالات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة:** يكون التعاقد بها في أي من الحالات الآتية<sup>(٢)</sup>:

- ١- العمليات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو فنيين أو استشاريين أو خبراء بذاتهم داخل مصر أو خارجها.
- ٢- العمليات التي اتخذت الجهة الإدارية إجراءات تأهيل مسبق في شأنها، ويجوز حينئذ دعوة من تم تأهيلهم فقط للمشاركة.
- ٣- التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومي، والتي تستوجب السرية أو التعامل مع جهات بعينها.
- ٤- حالات توفير المستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية والعلاجية والأدوية، وغيرها مما يتعلق بالمحافظة على الحياة والصحة العامة.
- ٥- إذا كان الوقت أو التكلفة اللازمان للطرح بطريقة المناقصة العامة لا يتناسبان مع قيمة التعاقد، بما لا يُبرر الإجراءات المطوّلة والعلنية.
- ٦- إذا سبق طرح العملية في مناقصة عامة دون تقديم عروض مناسبة، أو ثبت عزوف المتنافسين، وارتأت الجهة الإدارية أن تغيير وسيلة الطرح إلى المناقصة المحدودة أنسب لتحقيق المصلحة العامة.

---

(١) حمدي ياسين عكاشة: موسوعة، مرجع سابق، ص ٧١١.  
(٢) المادة (٥٧) من قانون التعاقدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

#### رابعاً: النشر وتوجيه الدعوة في المناقصة المحدودة

ألزمت المادة (١٢٥) من اللائحة الجهة الإدارية بوجوب النشر عن المناقصة المحدودة على بوابة التعاقدات العامة، وتوجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المسجلين عليها، المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط موضوع الطرح، وذلك بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية.

وبجوز بموافقة السلطة المختصة في حالة الاستعجال تقصير مدة توجيه الدعوة، بحيث لا تقل عن عشرة أيام، وتحتسب من تاريخ توجيه الدعوة.

#### المطلب الخامس

##### المناقصة ذات المرحلتين

تعرف بأنها: أسلوب استثنائي مستحدث من أساليب التعاقد الإداري، إذ لم ينص عليه المشرع من قبل في قانون المناقصات الملغي.

وتلجأ إليه الجهة الإدارية عندما لا تستطيع تحديد المواصفات الفنية للعملية بشكل دقيق ومسبق عند الإعلان عن التعاقد؛ باعتبارها ذات مواصفات فنية مركبة، أو أن الجهة الإدارية لم تصل إلى قرار نهائي بشأن المواصفات الفنية، وترغب في الأخذ في الاعتبار مختلف الحلول الفنية أو التعاقدية، أو عندما لا تتوافر تفاصيل المواصفات الفنية الدقيقة

عند البدء في إجراءات الطرح<sup>(١)</sup>. أو تلجأ إليها عندما تكون العملية معقدة، أو ذات تقنية عالية، بشكل يحتاج معه إلى فنيين متخصصين، وإجراءات مرنة منظمة وحالات محددة قانوناً. لذا يطلق عليها المناقصة العامة بطريقة التأهيل الفني<sup>(٢)</sup>.

مثال: شراء نظام تكنولوجي متطور، أو تصميم مبانٍ ذات طبيعة خاصة بالمدن الجديدة، وإعداد برامج أو شعارات أو حلول هندسية يصعب توصيفها بداية.

وتتميز المناقصة ذات المرحلتين في أنها: تمنح الجهة الإدارية فرصة لفهم احتياجاتها الفنية بدقة قبل الالتزام المالي. وتسمح بمشاركة خبرات متعددة؛ للوصول إلى أفضل حل فني قبل التعاقد.

ثانياً: حالات اللجوء إلى المناقصة ذات المرحلتين وأساسها القانوني أجاز المشرع اللجوء إليها في الحالات التي يتعذر فيها وضع مواصفات فنية دقيقة ونهائية للعملية محل التعاقد في بداية الطرح، بما يحول دون استخدام المناقصة العامة؛ بشرط توافر أي من الحالات المقررة قانوناً، حالات التقنية أو التعاقدية<sup>(٣)</sup>. ومن أبرزها:

١ - التعاقدات ذات المواصفات الفنية المعقدة أو المركبة التي تتطلب دراسة متعددة الجوانب قبل اعتماد مواصفات نهائية لإنشاء منشآت متخصصة ذات طبيعة متطورة كمستشفيات ذكية أو ببنية تحتية ذكية.

(١) المستشار د/ محمد علاء زعزع: موسوعة، مرجع سابق، ص ٨٤٩ وما بعدها.

(٢) د/ فرقد عبود العارضي: طرق إبرام العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٣٤٢.

(٣) المادة (٥٨) من قانون التعاقدات العامة والمادة (١٢٦) من اللائحة التنفيذية.



٢- رغبة الجهة الإدارية في دراسة مختلف الحلول الفنية أو التعاقدية المتعددة، بما يسمح لها بالمفاضلة بين المزايا النسبية لكل عرض أو حل مقترح قبل الاستقرار على الصيغة النهائية.

٣- عدم توافر توصيف تفصيلي للمواصفات الفنية الدقيقة موضوع التعاقد أو خصائصه في بداية الطرح، بما يستدعي المرور بمرحلة أولى لجمع البيانات وتحليل العروض الفنية الأولية.

ثالثاً: النشر والإعلان والدعوة في المناقصة ذات المرحلتين:

قرر المشرع الالتزام بمبادئ العلانية، واستخدام الوسائل الثلاثة<sup>(١)</sup>:

١- النشر على بوابة التعاقدات العامة في حال كان النشاط محل الطرح يتسم بالشيع أو الانفتاح السوقي.

٢- الإعلان في صحيفة يومية واسعة الانتشار لتعزيز الوصول إلى أكبر شريحة من مقدمي العروض المؤهلين.

٣- توجيه الدعوة إلى المسجلين على بوابة التعاقدات، من المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط موضوع الطرح.

ويجب ألا تقل مدة الإعلان أو توجيه الدعوة عن عشرين يوماً قبل الموعد المحدد لتقديم العروض الفنية الأولية. ويجوز تقصيرها إلى أربعة عشر يوماً بموافقة السلطة المختصة في حالة الاستعجال، على ألا تقل عن عشرة أيام إذا تم الاكتفاء بتوجيه الدعوة.

---

(١) المادة (٥٨) من قانون التعاقدات، والمادة (١٢٦) من لائحته التنفيذية.

رابعاً: إجراءات المناقصة ذات المرحلتين: تُقسم إلى مرحلتين:  
المرحلة الأولى: لا تُطلب فيها عروض أسعار، ويُطلب فقط عروض  
فنية أولية من المتقدمين، ويتم مناقشتها وتقييمها، ثم تُحدد الجهة  
الإدارية، بناءً عليها، المواصفات الفنية النهائية التي تحتاجها.  
والمرحلة الثانية: يُطلب من المتنافسين المقبولين تقديم عروضهم  
النهائية (الفنية والمالية) طبقاً للمواصفات التي تم الاتفاق عليها في  
المرحلة الأولى، ثم يتم اختيار العرض الأنسب ويبرم العقد.  
وتمر في المرحلتين بعدة إجراءات، يسبقها إجراءات ما قبل الطرح.  
-إجراءات ما قبل الطرح: تتمثل في الآتي:

- ١- تشكيل لجنة متخصصة بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر  
فنية ومالية وقانونية، تتولى إعداد كراسة الشروط الأولية.  
وتتضمن كراسة الشروط الأولية العناصر الست الآتية: (الغرض من  
التعاقد- الأداء المتوقع- المواصفات الفنية أو التشغيلية المطلوبة-  
المؤهلات المهنية أو الفنية اللازمة لتنفيذ العقد- محددات التعامل مع  
الأمر المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية- أي بيانات ومعلومات وشروط).
- ٢- إمكانية إجراء طلب تأهيل مسبق لمقدمي العروض قبل الطرح،  
وهو أمر جوازي، وفقاً لما تراه الجهة الإدارية مناسباً لطبيعة العملية.

-إجراءات المرحلة الأولى من المناقصة ذات المرحلتين: تتمثل في:

١ - اتباع ذات الإجراءات المعتادة لتشكيل اللجان-لجنة إعداد القيمة التقديرية، ولجنة الرد على الاستفسارات، ولجنة فتح المظاريف- وتحديد التأمين المؤقت وفقا لما هو مقرر قانونا.

٢ - جواز استقبال الاستفسارات في الموعد المحدد، ومناقشة مقدمي العروض فنياً لتوضيح ما يلزم بشأن العملية محل التعاقد، وتوثيق كافة الاستفسارات والمناقشات والردود وتوثيقها وحفظها في ملف العملية.

٣ - تشكيل لجنة لدراسة العروض الفنية الأولية بعد تلقيها، وتقديم تقرير شامل للسلطة المختصة، متضمناً التوصية بأحد القرارات التالية:  
أ- تكليف اللجنة الفنية -المعدة لكراسة الشروط الأولية- بإعداد كراسة الشروط النهائية استناداً للنتائج الفنية التي تم التوصل إليها، وتدقيق المواصفات الفنية، ومعايير التقييم وشروط العقد.

ب-إلغاء إجراءات الطرح حال الحاجة إلى المزيد من التخطيط ودراسة السوق أو تعديل نطاق العملية بعد المراجعة الفنية.

ج-استبعاد العروض الفنية غير المستجيبة للمتطلبات الأساسية.

إجراءات المرحلة الثانية من المناقصة ذات المرحلتين: تتمثل في:

أ- بعد إعداد كراسة الشروط النهائية، يجب التأكد من الآتي: (١-توافر الاعتماد المالي اللازم للعملية. ٢-تدقيق القيمة التقديرية ومبلغ التأمين

المؤقت في ضوء الشروط النهائية. ٣- التأكد من اكتمال كافة المتطلبات التعاقدية بعد استيعابها).

ب- توجيه إخطار من إدارة التعاقدات في المرحلة الثانية لكافة المتقدمين المستجيبين العروض المقبولين في المرحلة الأولى للتقدم بعطاءات فنية ومالية نهائية طبقاً لكراسة الشروط النهائية المدققة.

ج- فتح المظاريف ودراسة وتقييم العروض والعطاءات والبت فيها، وإعلان النتائج بذات الإجراءات القانونية المقررة والمحددة في اللائحة.

### المطلب السادس

#### المناقصة المحلية كأحد أساليب التعاقد الإداري الاستثنائية

##### أولاً: مفهوم المناقصة المحلية

مناقصة يقتصر التقدم فيها الأشخاص المحليين، أو من يسمح لهم القانون بالاشتراك فيها. أو على المسجلين عليها المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بنوع النشاط المزمع طرحه، والذين يقع نشاطهم داخل نطاق المحافظة التي يتم فيها تنفيذ موضوع التعاقد.

أو: تلك المناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها الأفراد أو الشركات المحليين، المقيمين في الدولة، والذين يقع نشاطهم داخل نطاق المحافظة التي يجري فيها تنفيذ موضوع التعاقد، دون غيرهم، بما فيها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة.

وقد تكون المناقصة العامة محلية أو دولية، بحسب نطاق الدعوة والمشاركة. إلا أن المناقصة المحلية الداخلية تختلف عن المناقصة الدولية الخارجية في أن الأخيرة يُتاح الاشتراك فيها للأجانب المصرح لهم بمزاولة النشاط التجاري سواء داخل الدولة أو خارجها، بما يشمل الشركات والمؤسسات العالمية أو الإقليمية.

**مثالها:** إعلان ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية للوزارة بالمحافظات بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٣ طرح مناقصة محلية لشراء منقولات تتمثل في طلب شراء علب مناديل ورقية جيدة ٥٥٠ مناديل، بكمية ٣٠٠٠ علبة، وصابون وجه ١٢٥ جم نوعية جيدة، بكمية ٢٠٠٠ صابونة، فوط صفراء، بكمية ٥٠٠ فوطة، معطر جو نوعية جيدة، بكمية ١٠٠٠ معطر، باسكيت بلاستيك نوعية جيدة، بكمية ٧٥٠ باسكيت.

### **ثانيًا: الأساس القانوني للمناقصة المحلية**

نصت المادة (٥٩) من قانون التعاقدات على أن: يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على أربعة ملايين جنيه، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والأعمال الفنية والاستشاريين المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائلتها تنفيذ موضوع التعاقد ومن بينهم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

كما نظمت المادة (١٢٩) من اللائحة أحكامها، وأكدت اختصاص الجهة الإدارية بتوجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المسجلين بالنشاط محل التعاقد داخل نطاق المحافظة.

### ثالثاً: الأحكام القانونية للمناقصة المحلية

#### ١- نطاق الأشخاص المخاطبين بالمناقصة المحلية:

يقتصر الاشتراك فيها على الموردين، والمقاولين، والاستشاريين، ومقدمي الخدمات والأعمال الفنية الذين يباشرون نشاطهم داخل المحافظة التي سيتم تنفيذ موضوع التعاقد فيها، ويشمل ذلك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقاً للمقرر بالمادة (١/٥٩) من القانون.

ويجوز للجهة الإدارية -في حال عدم تقدم أي من الأشخاص المحليين- عند إعادة الطرح توسيع نطاق الدعوة؛ لتشمل غيرهم، دون الإخلال بالقواعد العامة. ولا يجوز الاستثناء من شرط التأمين المؤقت إلا في حالة قصر التعاقد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيما لا يتجاوز مليوني جنيه، وفقاً للمادة (٣/٥٩) من القانون.

٢- التزام إدارة التعاقدات بإنشاء وتحديث قاعدة بيانات بالمهتمين بالدخول في المناقصات المحلية: تلتزم إدارة التعاقدات، قبل عرض مذكرة الطرح على السلطة المختصة، بمخاطبة فرع جهاز تنمية

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر<sup>(١)</sup> بالمحافظة محل التنفيذ، وإخطار أصحاب تلك المشروعات لتسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة التعاقدات العامة.

ويتعين على الجهاز تزويد الجهة الإدارية بأسماء وبيانات المهتمين منهم بالدخول في العملية محل الطرح والراغبين في الاشتراك في المناقصة، لدعوتهم خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار<sup>(٢)</sup>.

#### رابعاً: حالات اللجوء إلى المناقصة المحلية

لا يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحلية إلا في حالة وحيدة نص عليها القانون، وهي إذا لم تتجاوز قيمة التعاقد أربعة ملايين جنيه، وذلك وفقاً لما قرره المشرع في المادة (٥٩ / ١) من قانون تنظيم التعاقدات.

**حالة التعاقد بطريق المناقصة المحلية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:** يجوز بموافقة السلطة المختصة قصر الطرح والتعاقد بطريق المناقصة المحلية - متى كانت قيمته لا تتجاوز مليوني جنيه - على المشروعات الصغيرة<sup>(٣)</sup>، والمتوسطة<sup>(٤)</sup>، ومتناهية

---

(١) أنشئ الجهاز، وتم منحه الشخصية الاعتبارية العامة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠١٧؛ بهدف تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، لشباب الخريجين، وأصحاب الخبرة من المهنيين والحرفيين. وأصحاب المشروعات الصغيرة والراغبين في تطوير مشروعاتهم. والفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة. وكان يتبع وزارة الصناعة والتجارة، ثم نقلت تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٧٠ لسنة ٢٠١٨.

(٢) م ٤/٥٩ من قانون التعاقدات، والمادة (٤/١٢٩) من لائحته التنفيذية.

(٣) هي: "كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن ٥٠ مليون جنيه، طبقاً للقوائم المالية المعتمدة لآخر سنة. مثال: طلب تمويل شراء الآلات والمعدات، أو تمويل وسائل النقل. م (١) من القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ قانون تنمية المشروعات.

(٤) "كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي ٥٠ مليون جنيه ولا يتجاوز ٢٠٠ مليون جنيه، طبقاً للقوائم المالية المعتمدة لآخر سنة.

الصغر<sup>(١)</sup>، التي يقع نشاطها في نطاق المحافظة محل التنفيذ، والتي يتم بدائلتها تنفيذ موضوع التعاقد.

ويجوز للجهة الإدارية في هذه الحالة وبموافقة السلطة المختصة التعامل مع صاحب العطاء الفائز بالتسهيلات التالية<sup>(٢)</sup>:

١-الاكتفاء بتقديم إقرار بديل عن التأمين المؤقت، يفيد التزام المتقدم بالسير في إجراءات الطرح.

٢- إدراج نموذج هذا الإقرار ضمن كراسة الشروط، موقعا عليه من صاحب العطاء، وإرفاقه بمظروفه الفني.

٣- صرف دفعة مقدمة بنسبة لا تتجاوز ٥٠٪ من قيمة التعاقد، مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد، وبشرط النص عليه في شروط الطرح<sup>(٣)</sup>.

وتُعد هذه التيسيرات آلية تشجيعية لدعم تلك المشروعات، بما يتسق مع أهداف قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.

### جزاء تقاعس صاحب العطاء الفائز عن سداد التأمين النهائي

يجوز للجهة الإدارية حال إخلال صاحب العطاء الفائز في المناقصة المحلية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتزاماته، وسداد التأمين النهائي-بالرغم من كل تسهيلات الإدارة- اتخاذ التالي<sup>(٤)</sup>:

(١) هي: كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه. أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن ٥٠ ألف جنيه. مثال: تمويل المشروعات المتخصصة، كالإقراض الجماعي للسيدات، ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة، ودعم المرأة المعيلة لهم، والتنمية الريفية والزراعية.

(٢) م ٢/٥٩ من قانون التعاقدات. م ٢/١٢٩، ٣ من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

(٣) المادة (٣/١٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

(٤) م ٢/١٢٩ من اللائحة التنفيذية.



- ١- خصم قيمة التأمين المؤقت من مستحقاته لديها، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى.
  - ٢- إلغاء التعاقد، أو إسناد التنفيذ لصاحب العطاء التالي، بحسب ترتيب أولويتها. وهو أمر جوازي للجهة الإدارية.
  - ٣- خصم قيمة أي خسائر لحقت بالإدارة نتيجة الإخلال، دون الإخلال بحقها في المطالبة القضائية.
  - ٤- إخطار جهاز تنمية المشروعات بعدم التزام المتعاقد بسداد التأمين النهائي، لاتخاذ ما يلزم، وأخذه في الاعتبار مستقبلاً.
- خامساً: النشر وتوجيه الدعوة في المناقصة المحلية**
- يتعين النشر عنها في بوابة التعاقدات العامة، وتوجيه الدعوات لأكبر عدد ممكن من المسجلين عليها، المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط المزمع طرحه، والذين يقع نشاطهم داخل نطاق المحافظة التي يتم فيها تنفيذ موضوع التعاقد، وذلك قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بأربعة عشر يوماً على الأقل.
- ويجوز تقصير هذه المدة إلى عشرة أيام بموافقة السلطة المختصة في حالة الاستعجال. وتحتسب المدة من تاريخ توجيه الدعوة<sup>(١)</sup>.

---

(١) المادة ١/١٢٩ اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م.

## المطلب السابع

### الاتفاق المباشر

أولاً: مفهوم الاتفاق المباشر وخصائصه

يُقصد به: أسلوب استثنائي تلجأ فيه الجهة الإدارية إلى إبرام العقد مع جهة معينة أو شخص بعينه، دون اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة، ودون دعوة عامة أو محددة للمتنافسين، ويبرره حالات وظروف معينة أو غير متوقعة<sup>(١)</sup>.

وقد عرفته الجمعية العمومية بأنه: "تعاقد الإدارة مباشرة مع المتعاقد الذي وقع اختيارها عليه دونما مناقصة أو مزيدة أو ممارسة، متحللة من ضوابط وأحكام وقواعد المناقصة بصورها العامة والمحدودة والمحلية، وطريق الممارسة بصورتها العامة والمحدودة"<sup>(٢)</sup>؛ لتمكينها من إبرام عقودها بسرعة ومرونة.

**مثال:** إعلان ديوان عام وزارة العدل بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٣ طرح شراء منقولات بطريق الاتفاق المباشر تتمثل في اسناد أعمال الصيانة لماكينة التصوير وفق البرنامج الزمني المتوقع بالإعلان.

ويُطلق عليه عدة تسميات، مثل: "الإسناد المباشر، أو المناقصة وحيدة المصدر، والتزويد المباشر، والتكليف المباشر، والأمر المباشر"<sup>(٣)</sup>، إلا

---

(١) د/ أحمد محمود جمعة: العقود الإدارية، ص ٣٦٩.  
(٢) المستشار د/ محمد ماهر أبو العينين: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ١٢٩.  
(٣) ابتسام بنت سعيد بن خلفان الرامية: التعاقد بالإسناد المباشر في قانون المناقصات العماني - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق - جامعة السلطان قابوس، ٢٠١٥، ص ٧٦. دار المنظومة.

أن تسمية الاتفاق المباشر تعد الأقرب إلى الصواب؛ إذ تقوم فيه الإدارة بالاتفاق مباشرة مع من تختاره للقيام بالعمل المراد تنفيذه، بإيجاب وقبول، دون المرور بالإجراءات التي تمر بها المناقصة أو طرق التعاقد الأخرى. وأما باقي التسميات فتفترض وجود مجموعة من الإجراءات، ووجود طرف قوى وآخر ضعيف، وهو ما يستحيل تصوره، فالإدارة وإن كانت حرة في اختيار الشخص المتعاقد معها، إلا أنه لا بد من قبول الطرف الآخر، ووجود ضوابط معينة، تحكم الإدارة، وتجعلها تتأى بنفسها عن التعسف في استعمال صلاحياتها، بما يحافظ على المال العام، ويبعد عنه خطر الضياع والتعدي عليه<sup>(١)</sup>.

**خصائص الاتفاق المباشر:** يتسم بعدة خصائص، من أهمها:

١- **أحد الطرق الاستثنائية لإبرام العقود الإدارية، بل ومن أكثرها استعمالاً<sup>(٢)</sup>.** وهو ما يترتب عليه النتائج التالية:

- أ- عدم جواز اللجوء إليه إلا في حال عدم جدوى اتباع الطريق الأصلي.
- ب- عدم جواز اللجوء إليه إلا في حالات محددة، ومقررة قانوناً.
- ج- عدم تأثير مخالفة الإدارة لضوابطه وحالاته على صحة العقد.

٢- **تحلل الإدارة من الضوابط الحاكمة للتعاقد بنظام المناقصات والممارسات بصورها المتعددة<sup>(٣)</sup>.** وهو ما يترتب عليه نتيجتان:

---

(١) د/ محمود عاطف البنا: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ١٥٥.  
(٢) د/ محمد فؤاد عبد الباسط: القانون الإداري، مرجع سابق، ص ٥٣٦.  
(٣) ريم على إحسان محمد العزاوي: وسائل إبرام العقود الإدارية وصورها - دراسة مقارنة، ص ٢٠٠.

أ- حرية الإدارة الواسعة في اختيار المتعاقد معها دون اتباع إجراءات<sup>(١)</sup>.  
ب- عدم جواز الطعن على ما اتخذته الجهة الإدارية من إجراءات،  
لكونها قواعد مصلحة داخلية وضعت لصالح الإدارة فقط<sup>(٢)</sup>، إلا فيما  
يتعلق باستيفاء قواعد الاختصاص والشكل والانحراف بالسلطة<sup>(٣)</sup>.

وقد قضى: (إن مبدأ التعاقد في مجال العقد الإداري عن طريق  
الممارسة أو الاتفاق المباشر "de gré a gré" يخضع لقاعدة حرية الإدارة في  
اختيار المتعاقد وإن كانت هذه الحرية في الاختيار لا يتنافى معها  
إخضاع عملية الممارسة لتنظيم قانوني معين... ليس من طريقة واحدة  
تلزم جهة الإدارة على اختيار متعاقد معين)<sup>(٤)</sup>.

ثانياً: الأساس القانوني للجوء إلى الاتفاق المباشر وحالاته وضوابطه  
نظم المشرع المصري أحكام الاتفاق المباشر في المواد من (٦٢ : ٦٤)  
من قانون التعاقدات، والمواد (١٣٢ : ١٣٦) من لائحته التنفيذية.

### ثالثاً - حالات اللجوء إلى الاتفاق المباشر

يجوز التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في أي من الحالات الآتية<sup>(٥)</sup>:

١ - الحالات الطارئة الناجمة عن الظروف الفجائية التي لم يكن في  
الإمكان توقعها أو التنبؤ بها. وهي: حالات الضرورة القصوى التي لا  
تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة - مثل الكوارث الطبيعية،

(١) ابتسام بنت سعيد بن خلفان الربامية: التعاقد بالإسناد المباشر، مرجع سابق، ص ٨٣.

(٢) د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة: الأسس العامة للعقود، مرجع سابق ص ١٦٢.

(٣) د/ حمد محمد حمد الشلحاني: امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري، ص ٧٤.

(٤) الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٦ق، بتاريخ ١٢/٢٢/١٩٦٢، المكتب الفني ٨، ص ٢٩٩.

(٥) المادة ٦٢ من قانون التعاقدات الحكومية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

والحوادث المفاجئة، والأعطال الجسيمة، والطوارئ الصحية. أو الحالات التي تتطلب الضرورة التعامل معها بشكل فوري -التنفيذ الفوري-، ولا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما.

٢- وجود مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية، أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد، أو لديه الحق الحصري أو الاحتكاري لموضوع التعاقد، "جهة تخصص معينة". بمعنى آخر، حالة الانفراد الفني أو الاحتكار التجاري، كأن توجد جهة وحيدة تقدم منتجاً أو خدمة معينة، أو تملك حقاً حصرياً بشأنه، ولا يقدمها سواها، محلياً أو دولياً.

٣- تحقيق أغراض التكامل مع ما هو موجود، ولا يوجد له سوى مصدر واحد. مثال: يمكن لجهة الإدارة التعاقد مباشرة مع مقاول سبق له العمل في نفس المشروع، وأثبت كفاءته، فيمكن للإدارة التعاقد معه مباشرة لتنفيذ الجزء المتبقي بغرض التكامل بدلاً من طرح مناقصة جديدة.

٤- عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول في عقد قائم، وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ. مثال: تعاقد الجهة الإدارية لتوريد وتركيب نظام تكييف مركزي في مبنى جديد، وخلال التنفيذ يتبين الحاجة لتعديل في نظام التهوية بحيث يتكامل مع نظام التكييف، فيتم التعاقد معه مباشرة؛ باعتباره الوحيد القادر على إجراء التعديل بسبب معرفته بتفاصيل النظام وتكامله مع التكييف.

٥- الحالات العاجلة التي يكون التعاقد فيها خلال مدة زمنية لا تسمح باتخاذ إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما، لاعتبارات الأمن القومي ومقتضيات السياسة العامة، أو المصلحة الاقتصادية، وذلك لضمان السرية، وسلامة وكفالة سير العمل بالجهات الإدارية.

وبعد من أمثلة الحالات العاجلة: حالات الطوارئ والكوارث: مثل الحرائق، الفيضانات، الزلازل، أو أي كارثة طبيعية تتطلب استجابة سريعة لتوفير الإغاثة والمساعدات.

والأمن القومي: مثل التعاقد على شراء معدات أو خدمات ضرورية للحفاظ على أمن الدولة وحماية حدودها.

المصالح الاقتصادية الملحة: مثل التعاقد على توفير سلع أو خدمات ضرورية لتأمين إمدادات حيوية للبلاد، أو لتنفيذ مشاريع ذات أهمية اقتصادية قصوى.

الأحداث الاستثنائية أو الفجائية: كالأحداث التي تتطلب استجابة فورية دون إمكانية التخطيط المسبق، مثل اندلاع أزمة صحية عامة تتطلب توفير معدات طبية أو خدمات صحية عاجلة.

ويشترط للتعاقد بالاتفاق المباشر على الحالات العاجلة أن تكون الحالة عاجلة بالفعل، ولا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة. مع وجود مبرر قوي وواضح مرتبط بالأمن القومي أو السياسة العامة أو المصلحة الاقتصادية. ويتم توثيق الإجراءات المتخذة.

٦- حالة التوحيد القياسي لمواصفات صنف معين وفقاً لمواصفات الشراء الموحد مع ما هو قائم بالفعل في السوق أو مع ما هو متوفر لدى جهة بعينها. مثال: قيام وزارة الصحة بتوحيد مواصفات الأجهزة الطبية التي تحتاجها، ثم تقوم بالبحث عن الشركات التي تقدمها وفقاً لمواصفات الشراء الموحد، وتقوم بالتعاقد المباشر معها بدلاً من طرح مناقصة عامة لكل جهاز على حدة.

٧- حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تتبناها الدولة، من خلال: إعطاء الأفضلية للمشاريع التي تخدم أهدافاً اجتماعية أو بيئية، وتوجيه التعاقدات نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة والمحلية. رابعا- ضوابط وقيود التعاقد بالاتفاق المباشر:

أحاطه المشرع بقيود وضوابط صارمة؛ لضمان الشفافية، ومن أبرزها: ١- وجوب تبرير قرار اللجوء إليه، وتوافر إحدى حالاته المقررة قانون بمذكرة تفصيلية فنية قانونية مسببة ومعتمدة.

٢- ضرورة موافقة السلطة المختصة؛ لاعتماد التعاقد بما يضمن الرقابة الرئاسية على قرار التعاقد بالاتفاق المباشر.

٣- يتعين الحصول على عروض أسعار عند التعاقد بالاتفاق المباشر في الحالات المبينة قرين البنود (٥، ٦، ٧). الخاصة بالحالات العاجلة، والتوحيد القياسي، وحالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية.

وتقوم إدارة التعاقدات بطلب عرض أو عروض أسعار-وفقا للبيانات الواجب توافرها فيه والمحددة باللائحة- من المشتغلين بنوع النشاط المطلوب التعاقد عليه بالاتفاق المباشر، وينشر على بوابة التعاقدات.

٤- أن ترفق صورة من خطة الاحتياجات، فيما عدا الحالات المبينة قرين البنود (١)، و(٤)، و(٥) من المادة (٦٢). وهي الحالات الطارئة، موضوع التعاقد غير مشمول في عقد قائم، الحالات العاجلة.

٥- عدم تجزئة الأعمال أو التحايل لتفادي الحدود المالية، والتهرب من تطبيق الإجراءات المقررة التي تستوجب اللجوء للمناقصة أو الممارسة.

٦- التأكد من توافر الاعتماد المالي اللازم لإبرام العقد. وتحديد سعر عادل من خلال لجنة فنية متخصصة أو مراجع أسعار السوق.

٧- توثيق مبررات إتباع طريق الاتفاق المباشر، والإجراءات المتخذة بالكامل وإخضاعها للمراجعة اللاحقة من الجهات الرقابية المختصة، كالجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.

٨- يجوز إعداد كراسة للشروط والمواصفات لمحل التعاقد في طريق التعاقد بالاتفاق المباشر؛ إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك.

إلا أن الجمعية العمومية خلصت إلى: "أنه في حالات التعاقد بالاتفاق المباشر التي تتطلب بحسب طبيعتها إعداد كراسة شروط ومواصفات، ولم تتضمن نصا يُجيز الترخيص في صرف دفعة مقدمة، فإذا اشترط المتعاقد بعطائه صرف دفعة مقدمة في حدود النسب المقررة قانونا،



مقابل تقديمه خطاب ضمان بنكي غير مقيد أو مشروط، ووافقت الجهة الإدارية على صرفها له، فإنه يتعين إعمال هذا الشرط باعتباره أضحي جزءاً لا يتجزأ من شروط التعاقد، لا يجوز للجهة الإدارية التحلل أو التنصل منه...<sup>(١)</sup>.

٩- **أجاز المشرع** - في المادتين (٦٤) من قانون التعاقدات والمادة (١٣٦) من اللائحة التنفيذية- للجهة الإدارية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات بطريق الاتفاق المباشر؛ وذلك في الحالات الطارئة، أو في الحالات العاجلة، أو لدواعي المصلحة العامة؛ وذلك باتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (١٣٢) من اللائحة.

١٠- **يعد قرار التعاقد بطريق المباشر قراراً إدارياً منفصلاً عن العملية العقدية ذاتها وليس متصلاً بها<sup>(٢)</sup>**؛ من حيث كونه إذناً بالتعاقد ويجوز الطعن عليه استقلالاً. يؤكد ما قضت به: "إن التعاقد بطريق الاتفاق المباشر يعتبر قراراً إدارياً من حيث كونه إذناً بالتعاقد،.. وهو بهذه المثابة كالقرار الصادر بإرساء المناقصة أو المزايدة من حيث انفصاله عن العملية العقدية ذاتها...<sup>(٣)</sup>.

١١- **تخضع قرارات اللجنة لرقابة القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً، مثلها مثل أي قرار إداري غير مشروع.**

(١) فتاها في الملف رقم ٦٩٠/١/٥٤، بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٢.

(٢) د/ محمد السناري: مرجع سابق، ص ٦٠.

(٣) حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٣٢٩ لسنة ١٤٠٤، جلسة ٢٠١٩/٤/١٩٦٣، المجموعة.

## خامسا- سلطات الترخيص بالتعاقد بالاتفاق المباشر

أناط المشرع التعاقد بالاتفاق المباشر بناء على ترخيص يصدر من بعض الأشخاص المختصين، المحددين على سبيل الحصر، وهم:

١- **رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق، فيما لا تجاوز قيمته مليون جنية بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات، أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية، أو الدراسات الاستشارية، وخمسة ملايين جنية لمقاولات الأعمال.** وقد أفتت الجمعية العمومية بعدم تمتع رؤساء مديريات الخدمات بسلطات رئيس المصلحة،... **وتبعا له لا يجوز لهم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر؛ إذ لا يدخلون في مفهوم السلطات المختصة، ولا يعينون بقرار جمهوري، كما أن مديريات الخدمات بالمحافظات هي تقسيمات إدارية بالمحافظات، وليست مصالح<sup>(١)</sup>.**

٢- **الوزير ومن له سلطاته، أو المحافظ، فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنية بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات، أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية، أو الدراسات الاستشارية، وعشرين مليون جنية بالنسبة لمقاولات الأعمال.**

**سلطة مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى: لمجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى أن يأذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر، وذلك**

---

(١) بتصرف فتاوها السابقة في الملف رقم ٦٢٤/١/٥٤ بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠.

فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (٢). وقد أنيط الأمر بمجلس الوزراء ورئيسه باعتباره قمة الجهاز الإداري في الدولة.

٣- **الوزير المختص بالصحة** بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الإستراتيجية وألبان الأطفال، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

**ضوابط تعاقد وزير الصحة بالاتفاق المباشر:** تتمثل في الآتي<sup>(١)</sup>:  
أعطى المشرع لوزير الصحة سلطة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الإستراتيجية وألبان الأطفال، وفقا للضوابط والشروط الآتية:

١- تعد إدارة التعاقدات بوزارة الصحة دليل إجرائي بذلك تعتمده الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

٢- يشكل وزير الصحة لجنة متخصصة -على غرار لجنة الاتفاق المباشر- تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتولى مباشرة إجراءات التعاقد، ويقع على عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة الأصناف من حيث النوع والمواصفات والشروط، وأن الأسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض متى توافرت.

٣- ترفع اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة تقريراً بنتائج أعمالها للوزير تضمنه كافة ما قامت به من إجراءات وما انتهت إليه من توصيات.

---

(١) المادة (١٣٤) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

## سادسا: التفويض في الاختصاص للسلطات المختصة وضوابطه

الأصل أنه وفقا لنص م ٦٣ من قانون التعاقدات لعام ٢٠١٨ لا يجوز لأي من السلطات المختصة أو سلطات الترخيص التفويض في الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بطريق الاتفاق المباشر.

باستثناء حالة وحيدة فقط هي حالة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو الأعمال أو تلقي الخدمات منخفضة القيمة، والتي لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف جنيه في المرة الواحدة، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه خلال السنة المالية لذات العملية موضوع التعاقد وذلك بمراعاة تجانسها وبعد موافقة السلطة المختصة، حيث يجوز للسلطة المختصة التفويض في اختصاصاتها في هذه الحالة فقط.

### ضوابط التفويض في التعاقد بطريق الاتفاق المباشر:

- يجب مراعاة الضوابط العامة، والضوابط والإجراءات الخاصة الآتية<sup>(١)</sup>:
- أ- يجوز للسلطة المختصة أن تفوض في أي من اختصاصاتها لشاغلي الوظائف القيادية المحددة بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ خدمة مدنية.
  - ب- يكون التفويض لمن يشهد لهم بالكفاءة والخبرة والتمتع بصفات النزاهة والأمانة وحسن السمعة والخبرة اللازمة لممارسة التفويض.
  - ج- يشترط صدور قرار التفويض من السلطة المختصة، يتضمن اسم المفوض، ووظيفته، وموضوع التفويض، ومدته، وشروطه، ومتطلباته.

---

(١) المادة (١٦٦) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

د- ينتهي التفويض بإلغاء القرار الصادر بشأنه أو انتهاء مدته أو الغرض منه.

وتطبيقا له يجوز تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لرئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بطريق الاتفاق المباشر<sup>(١)</sup>.

كما يجوز تفويض سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المصالح والوحدات المحلية كل في نطاق اختصاصه، ووفقا لشروط وضوابط التفويض؛ باعتبارها من الوظيفة الأدنى مباشرة في حالة عدم وجود وظيفة نائب محافظ<sup>(٢)</sup>.

ولا يجوز توقيع رئيس الوحدة المحلية للمدينة على عقد بيع الوحدة السكنية وعقود مماثلة إلا بتفويض خاص من المحافظ المختص. في حين يجوز لرئيس الجامعة تفويض أي من اختصاصاته المقررة قانونا إلى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالنسبة للمسائل المتعلقة بالمستشفيات، ويكون لرئيس مجلس إدارة تلك المستشفيات سلطات رئيس المصلحة فيما يتعلق بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر<sup>(٣)</sup>.

---

(١) فتوى الجمعية العمومية في الملف رقم ٧٠٤/١/٥٤، جلسة ٢٠٠٣/٤/٢، لدى حمدي ياسين، الكتاب الثالث، سابق، ص ٢٣٢.

(٢) فتوى الجمعية العمومية في الملف رقم ٣٦٥/١/٥٤، جلسة ٢٠٠٠/١/١٩، السابق، ص ٢٣٧.

(٣) فتوى الجمعية العمومية في الملف رقم ٢١٥ في ٢٠٠٠/٥/٣، جلسة ٢٠٠٠/٢/٢، ملف رقم ٣٥٧/١/٥٤، لدى عكاشة، المرجع السابق، ص ٢٤٧.

سابعاً - التعريف بلجنة الاتفاق المباشر واختصاصاتها وواجباتها  
يقصد بها: اللجنة التي تشكل بقرار من السلطة المختصة من أهل الخبرة  
من بينهم عناصر فنية، ومالية، وقانونية، وعضو من إدارة التعاقدات.  
وللجنة أن تستعين برأي من تراه من أهل الخبرة بموضوع الطلب. ويجوز  
لها الاستعانة بمن تراه من الجهات الإدارية الأخرى؛ وفقاً لأهمية التعاقد  
وطبيعته في حال عدم توافر أهل الخبرة. ويكون اعتمادها في كل  
الأحوال من السلطة المختصة دون غيرها. وتتمثل اختصاصها في<sup>(١)</sup>:  
١- تتولى إجراءات التعاقد بالطريق المباشر في أي من الحالات المقررة  
قانوناً. ويقع على عاتقها مسئولية التحقق من ذلك.  
٢- التحقق من مطابقة موضوع التعاقد من النواحي الفنية المطلوبة.  
٣- مناسبة الأسعار مقارنة بأسعار السوق السائدة وقت التعاقد أو  
لتحديد أقل العروض سعراً من واقع عروض الأسعار.  
٤- مناسبة أسس اختيار المتعاقد مع الإدارة.  
وقد حددت المادة ١٢٣/٥ من لائحته التنفيذية دور ومسئولية اللجنة،  
ودور إدارة التعاقدات في نشر نتيجة التعاقد بالطريق المباشر فور  
اعتماده على بوابة التعاقدات، واستكمال باقي الإجراءات وتوثيقها.

---

(١) المادة (٣٠) من قانون التعاقدات، والفقرة الأخيرة من المادة ١٣٥ من اللائحة التنفيذية.

## الفصل الثاني

### إبرام العقد الإداري عن طريق المزايدات الأصلية والاستثنائية

نظم المشرع طرق إبرام العقود الإدارية، وجاءت أحكام قانون تنظيم التعاقدات، ولائحته التنفيذية متضمنة تحديد هذه الطرق<sup>(١)</sup>. حيث نصت المادة (٧/ بند ٢) منه: على أن: (يكون التعاقد وفق أحكام هذا القانون في الحالات وبالطرق الآتية:...

٢- يكون التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات ومن ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة.

وبجوز استثناء بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة التعاقدات إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية:

(أ) المزايدة المحدودة.

(ب) المزايدة المحلية.

(ج) الاتفاق المباشر (...).

وهو ما يمكن دراسته في بحثين:

المبحث الأول: المزايدة العامة الطريق الأصلي لإبرام العقد الإداري.

المبحث الثاني: إبرام العقد الإداري بغير طريق المزايدة العامة.

---

(١) فتوى الجمعية العمومية رقم ٢٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٨. ملف رقم ٦٨٥/١/٥٤ المستشار د/محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٢٦٥.

## المبحث الأول

### المزايدة العامة الطريق الأصلي لإبرام العقد الإداري

#### أولاً: مفهوم المزايدة العامة

تقوم فكرة المزايدة على طرح الجهة الإدارية بيع شيء مستعمل -كالأثاث والأدوات والسيارات والكمبيوترات وغيرها- بقصد الحصول على أفضل عائد مالي ممكن، ويتنافس فيه الأفراد بعروض سعرية متزايدة.

وتُعد المزايدة العامة من العقود الشائعة، وأحد الوسائل الأصلية التي تعتمد عليها الإدارة، لا سيما تلك التي يكون محلها بيع أو تأجير ممتلكات عامة من المنقولات أو العقارات، أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات ومن ذلك المنشآت السياحية والمقاصف التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

ويحظى عقد بيع المزايدة، أو ما يعرف ببيع من يزيد، وبيع المزاد العلني، وبيع الدلالة وغيره<sup>(١)</sup>، بكثير من اهتمام رجال الفقه الشرعي والقانوني، وتناولوه بالتنظيم؛ باعتباره عرفاً سائداً، وأحد وسائل التسويق والعرض.

وتتنوع صورها، فقد تكون المزايدة اختيارية، وهذا هو الأصل. أو إجبارية، أو علنية أو سرية. بينما يقسمها رجال القانون بحسب طريقة العمل بها إلى مزايدة علنية عامة، يتم فيها التزايد شفاهاً بين المتقدمين

---

(١) عبد السلام أحمد فيغو: عقد بيع المزايدة، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، الإصدار ٣٩، المغرب، ٢٠١٦، ص ١٢١. ونشرته دار المنظومة.



من خلال جولة أو عدة جولات حتى الترسية على أعلى سعر. أو مزايمة سرية تتم من خلال المظاريف المغلقة<sup>(١)</sup>، وتعد الشكل العكسي للمناقصة، وتتم فيها الترسية على أعلى عطاء مستوف للشروط<sup>(٢)</sup>.

### ثانيًا: الفرق بين المزايمة والمناقصة

رغم الاتفاق بينهما من حيث كونهما أحد الأساليب الأصلية لإبرام العقد الإداري، إلا أن بينهما فروقًا جوهرية، منها:

١- **موضوع التعاقد:** موضوع المناقصة شراء أو استئجار أو تلقي خدمات، أو الأعمال الفنية. أما المزايمة فموضوعها بيع أو تأجير للمنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف.

**مثال:** إعلان جهاز مدينة الشيخ زايد عن طرح بيع عدد ١٣ محلا تجاريا بمساحات تتراوح من ٢١٨م الي ٢٩٠م أسفل العمارات السكنية بالحي ١٣ بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، "مزايمة عامة" بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٣.

٢- **الهدف ومعيار الترسية:** تُرسى العطاءات في المناقصة على العرض الأقل سعرًا أو الأفضل فنيًا وماليًا؛ إذ تهدف الإدارة إلى اختيار متعاقد بأقل عطاء. وقد أفتت بأن: (تجرى المفاضلة والمقارنة بين

---

(١) خالد بن عبد العزيز السعيد: أحكام بيع المزايمة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة بالنظام، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠، ونشرتها دار الميمان للطباعة والنشر - الرياض، منشورة على شبكة الإنترنت بنظام Pdf، ص ٦٢ وما بعدها.

(٢) المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٥٠٤.

المتناقصين لتحديد صاحب العطاء الأقل على أساس موضوعي بما يحقق المساواة بين المتناقصين؛ للوصول إلى صاحب أقل عطاء، وترتيب أولويته بين العطاء تبعا لذلك<sup>(١)</sup>...).

أما في المزايدة فترسّى العطاءات على العرض الأعلى سعرا؛ إذ تهدف الإدارة إلى اختيار متعاقد يتقدم بأفضل وأعلى عطاء. لذا قضت بأنه: (إذا رأت الجهة الإدارية المختصة إبرام العقد فإنه يتعين أن تتعاقد مع صاحب أفضل عطاء الذي عينته اللجنة المختصة بالبت في المزايدة، ولا تملك أن تستبدل به غيره ولو كان منصوصا في الشروط..)<sup>(٢)</sup>.

٣- طبيعة العائد: فالإدارة ملتزمة في المناقصة بدفع المقابل النقدي من المال من الميزانية المقررة، مقابل عقد الأشغال العامة، أو عقد التوريد<sup>(٣)</sup>، أو شراء أو استئجار أو تلقى خدمات، أو الأعمال الفنية. بعكس الحال في المزايدة فالإدارة تتلقّى المال، أو تقبض المقابل المالي من المتعاقد وتقوم بتوريده للخزانة العامة، مقابل ما تقوم ببيعه أو تأجيره، أو ترخيصها بالانتفاع أو باستغلال المشروعات السياحية كمنطقة الأهرامات بالجيزة، أو منطقة المنتزه السياحية<sup>(٤)</sup> بالإسكندرية وغيره.

(١) فتوى رقم ٦٤ في ١٢/١/١٩٨٨ جلسة ٩/١٢/١٩٨٧، ٤١، ٤٢/٢١٠/٥٨٨، المجموعة، مرجع سابق، ص ٢٦٢ وما بعدها.

(٢) حكمها رقم ٨١٢ - ١٣٠، بتاريخ ١/٢/١٩٦٩، ١٤/٤١/٣١٣، المجموعة، مرجع سابق، ص ٢٥٧.

(٣) د/ جمال جبريل: العقود، مرجع سابق، ص ٩٠. وحوله: د/ عمر حلمي وآخرون: المبادئ، مرجع سابق، ص ٢٠٨.

(٤) قضت بأن: "جهة الإدارة منحت الشركة حق استغلال منطقة المنتزه لاستعمالها كمركز سياحي - اتصال العقد بنشاط مرفقين عامين هما: مرفق الإنشاء والتعمير، ومرفق السياحة وأعطيت الشركة حق إدارته واستغلاله تحت إشراف الإدارة". الطعن رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٠، بتاريخ ٢٠/٢/١٩٩٠، مكتب فنى ٣٥، ص ١١٣٣.

### ثالثاً: الطبيعة القانونية للمزايدة العامة

تتميّز المزايدة بطابعها التنافسي المفتوح، القائم على المفاضلة بين العروض الأعلى سعراً، بما يُعبّر عن التقاء إرادتين. وهو ما يُستمد من قواعد القانون العام، في ضوء المبادئ العامة والخاصة الحاكمة للتعاقد. وبعيد حق الدولة على أملاكها الخاصة حق ملكية شأنها شأن الأفراد، لا تجبر على بيعها، وإنما تخضع لمحض سلطتها التقديرية، وأن مجرد تقديم طلب لشراء ملك الدولة ودفع ثمنه لا يكسب صاحبه صفة المالك، أو ينشئ له مركزاً قانونياً يلزم جهة الإدارة بإتمام إجراءات البيع<sup>(١)</sup>. لذا قضت: (ومن حيث إن المشرع.. اتخذ من المزايدة العلنية العامة أو المحلية والمظاريف المغلقة سبيلاً أصلياً لبيع وتأجير العقارات المملوكة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون؛ بحسبان أن المزايدة والمظاريف المغلقة تقومان على المساواة وتجسدان مبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن تحقيق المصلحة العامة، حيث يطرح العقار المطلوب بيعه أو تأجيره على الكافة، ومن ثم يتقدم الراغبون بعروضهم، وفي سبيل الفوز به يتنافس المتنافسون.. وتجرى المزايدة ويتم فتح المظاريف المغلقة على رموس الأشهاد، ويتم الاختيار لأفضل الشروط والأسعار، ومن ثم تجنى المصلحة ثمرة ذلك بالوصول إلى أعلى الأسعار...)<sup>(٢)</sup>.

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٤٦٠٧ لسنة ٤٩ ق. ع، جلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٦.

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الأولى، في الطعن رقم ٣٤١٨١ لسنة ٦٢ بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٧. الموسوعة القانونية لوزارة العدل بجمهورية مصر العربية. ويراجع حكمها في الطعنين رقمي (٣٠٩٥٢ و ٣١٣١٤ لسنة ٥٦ ق. ع، بـجلسة ٢٠١٠/٩/١٤.

رابعاً: الأحكام القانونية للمزايدة في قانون التعاقدات ولائحته التنفيذية

#### ١ - موضوع ونطاق المزايدات العامة وصورها

حدده المشرع في المادة (٧/بند ٢) من قانون التعاقدات ببيع أو تأجير المنقولات- بيع أو تأجير العقارات- بيع أو تأجير المشروعات التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية- الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال. ويجوز للإدارة في حالات معينة، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، بناء على عرض إدارة التعاقدات إتباع طرقاً استثنائية أخرى؛ للتعاقد بشأن البيع والتأجير، تتمثل في: (المزايدة العلنية العامة- المزايدة بالمظاريف المغلقة- المزايدة المحدودة- المزايدة المحلية- البيع بالاتفاق المباشر)، إذا توافرت مبررات لذلك.

صور المزايدات: تنقسم المزايدة من حيث أسلوب إجرائها إلى صورتين: المزايدة العلنية العامة، والمزايدة السرية بالمظاريف.

#### أ- الأحكام القانونية للمزايدة العلنية العامة:

يكون التعاقد بطريق المزايدة العلنية العامة لبيع أو تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها شخصية اعتبارية، وكذلك الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال، ويشمل ذلك المنشآت السياحية والمقاصف<sup>(١)</sup>. وتُطبق عليها ذات الإجراءات المنظمة لمراحل ما قبل الطرح، والطرح، والترسية، والتعاقد المقررة في اللائحة. كما تسري ذات

---

(١) المادة (١٤١) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

إجراءات المزايدة العلنية العامة على المزايدة المحدودة والمحلية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص ينظمها. مادة ١٤٢ من اللائحة.

**مثالها:** إعلان ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن - بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٣ عن ثلاث عمليات بيع أشجار خشبية بغابة الحبيل بمحافظة الأقصر، وغابة أولاد عزاز بمحافظة سوهاج، وغابة عرب المدابغ بمحافظة أسيوط التابعة للإدارة المركزية للتشجير والبيئة بطريق المزايدة العلنية العامة، وأن آخر تاريخ لاستقبال العطاءات يوم ٢/١١/٢٠٢٣ م. والعملية وحدة واحدة لا تتجزأ في كل منها، والمحدد لها جلسة يوم الأحد الموافق ٥/١١/٢٠٢٣ الساعة ١٢ ظهراً، والعملية تخضع لقانون التعاقدات، على أن تكون الشركات المتقدمة مسجلة بالبوابة، ومنظومة التعاقدات الإلكترونية<sup>(١)</sup>.

### **آلية وإجراءات المزايدة العلنية العامة:**

يتعين على لجنة المزايدة إتباع الآلية والإجراءات التالية<sup>(٢)</sup>:

- ١- **الإعلان للمتزايدين:** وهو ما يكون في بداية جلسة المزايدة العلنية العامة، فتعلن عن البيانات والمواصفات الكافية عن موضوع البيع، أو التأجير، أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال دون ذكر الثمن الأساسي.
- ٢- **تتولي إجراءات التزايد مع المتزايدين:** في جولة واحدة أو عدة جولات بذات الجلسة؛ للوصول لأعلى سعر مستوفي للشروط. ويجوز

---

(١) جريدة الأخبار، العدد ٢٢٣٢٥، السنة ٧٢، بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣.  
(٢) المادة (١٤٣) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

استثناء أن تكون جلسة التزايد على أكثر من يوم لكل مجموعة أو أكثر على حدة؛ بشرط أن تتضمن شروط الطرح ذلك، وأن تكون لكل مجموعة ثمن أساسي منفصل في ظروف مغلقة.

٣- **حظر إعادة فتح باب التزايد:** حيث يحظر في جميع الحالات إعادة فتحه مرة أخرى؛ لما تم الانتهاء من التزايد عليه.

٤- **حظر الاتفاق بين المتزايدين والترتيب بينهم قبل أو أثناء جلسة المزايدة؛** لتحقيق غرض غير مشروع، بما في ذلك التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على تصرفات طرف آخر. وفي حالة ثبوته يتم الفسخ الوجوبي للعقد تلقائياً، وشطب المتعاقد من سجل المتعاقدين.

٥- **ترسية المزايدة على أعلى سعر مستوفي للشروط ؛** بشرط ألا يقل عن الثمن الأساسي للعملية محل التعاقد، وفقاً لما تحدده لجنة المزايدة المشكلة، لدراسة السوق ووضع القيمة التقديرية، وتحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد بدراسة السوق، وتعاقدات الإدارة السابقة، أو غيرها إن وجدت. وتحرر اللجنة محضراً بإجراءاتها، وتعتمد قراراتها وتوصياتها من السلطة المختصة بعد التوقيع عليها.

ب- **الأحكام القانونية للمزايدة السرية بالمظاريف المغلقة:** وهي ما تتم بذات الشروط والقواعد والإجراءات المقررة قانوناً في طريق المناقصات العامة الأصلي، مع مراعاة طبيعة محل التعاقد، من بيع أو تأجير أو ترخيص، وبما لا يتعارض معه. ونحيل إليها؛ منعاً من التكرار.

## المبحث الثاني

### إبرام العقد الإداري بغير طريق المزايدة العامة

تملك الإدارة حرية اختيار وسيلة التعاقد مع الغير بطريق آخر استثنائي غير المزايدة العلنية العامة كالمزايدة المحدودة، والمزايدة المحلية، والاتفاق المباشر. وسوف نعرض لكل منها في مطلب مستقل:

### المطلب الأول

#### المزايدة المحدودة

#### أولاً - مفهوم المزايدة المحدودة وأساسها القانوني

تعتبر إحدى طرق التعاقد الاستثنائية التي أجاز المشرع للجهات الإدارية اللجوء إليها، عند توفر مبررات تبرر العدول عن الطريق الأصلي، حسب طبيعة العملية، أو الظروف المحيطة بها الانتقاء المسبق للمشاركين، وقصر المنافسة على عدد معين من المتزايدين الذين تتوافر فيهم معايير موضوعية، وشروط فنية أو مالية محددة سلفاً، تحت إشراف السلطة المختصة وإدارة التعاقدات.

ونظمت أحكامها المادتين (٦٨) قانون التعاقدات، و(١٤٥) لائحته.

**مثالها:** إعلان جامعة الأزهر عن طرح مزايدة محدودة لعملية حق انتفاع أرض العنب بمزرعة كلية الزراعة فرع السادات، بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٤. وإعلان ديوان عام محافظة البحيرة عن طرح مزايدة محدودة لبيع

الاصناف المطروحة من الكهنة والخردة والمخلفات والرواكد المتواجدة بناء عن كشوف التصنيف المعدة بديوان عام محافظة البحيرة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمشروعات، بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣.

**ثانيا: شروط المزايدة المحدودة وخصائصها:** يجب توافر شرطين:

- ١- صدور قرار مسبب من السلطة المختصة، يوضح أسباب العدول.
- ٢- توافر حالات ومبررات فنية أو موضوعية تجعل من غير الملائم طرح العملية في مزايدة عامة للمحدودية، أو سرية البيانات، أو السرعة. وتتسم المزايدة المحدودة بعدة خصائص، تميزها عن غيرها، أبرزها:
  - ١- قصر المشاركة فيها على من يتم توجيه الدعوة إليهم دون غيرهم.
  - ٢- إعداد قائمة مختارة للمترشحين، بناءً على دراسات السوق وبياناتهم.
  - ٣- توافر شروط فنية ومالية مسبقة يتم تحديدها في مستندات الطرح.
  - ٤- الخضوع لأحكام الشفافية والمنافسة والمبادئ الحاكمة للتعاقد.

### ثالثا - حالات المزايدة المحدودة

يكون التعاقد بطريق المزايدة المحدودة في أي من الحالات الآتية<sup>(١)</sup>:

- ١ - أصناف يخشى عليها من التلف بقاء تخزينها.
- ٢ - أصناف تتطلب طبيعتها قصر بيعها على أشخاص مرخص لهم.
- ٣ - الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة العلنية العامة، أو بالمظاريف المغلقة.

---

(١) المادة ٦٨ من قانون تنظيم التعاقدات.



٤- الحالات التي سبق عرضها في مزيدة علنية عامة أو مزيدة بالمظاريف المغلقة لأكثر من مرة، ولم تقدم عنها أي عروض، أو لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي، وانتهت دراسة الجهة الإدارية إلى مناسبة تغيير طريقة الطرح.

#### رابعاً - إجراءات النشر وتوجيه الدعوة عن المزيدة المحدودة

يجب النشر عنها على بوابة التعاقدات العامة، وتوجيه الدعوات لأكثر عدد من المسجلين عليها، المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بنوع النشاط المزمع طرحه، بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً قبل الموعد المحدد لجلسة المزيدة.

ويجوز في حالة الاستعجال وبموافقة السلطة المختصة تقصير مدة توجيه الدعوة بحيث لا تقل عن عشرة أيام.  
تحتسب من تاريخ توجيه الدعوة<sup>(١)</sup>. على أن تتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها في الإعلان عن المزيدة العامة.

---

(١) المادة (١٤٥) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م.

## المطلب الثاني

### المزايدة المحلية

أولاً: مفهوم المزايدة المحلية وتمييزها عن غيرها ومبررات الأخذ بها  
تعتبر إحدى صور التعاقد الإداري الاستثنائية، المقررة قانوناً للجهة  
الإدارية؛ بهدف اختيار المتعاقد معها في حالات الضرورة، وبضوابط  
وشروط وإجراءات خاصة وفقاً لموضوع المزايدة.

وبقتصر الاشتراك فيها على المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطهم داخل  
نطاق المحافظة التي ينفذ بدائلتها موضوع التعاقد، سواء كانوا من  
المقيدين في سجل الموردين لدى الجهة، أو من المقيمين في نطاق  
جغرافي معين، أو ممن تم توجيه الدعوة لهم، وذلك حين لا تقتضي  
طبيعة العملية أو ظروفها التوسع في الإعلان أو طرحها على مستوى  
عام. ونظمت أحكامها المادتين (٦٩) قانون التعاقدات، م (١٤٦) لائحة.

**مثالها:** إعلان جامعة الأزهر عن طرح مزايدة محلية لعملية حق انتفاع  
مساحة ٢٦ فدان بمزرعة كلية الزراعة بنين بمدينة السادات، بتاريخ  
٢٠٢٣/١٠/٤.

وأما عن موقف الجهة الإدارية حال عدم اشتراك المتزايدين المحليين في  
المزايدة المحلية فلا شيء عليها، ولا تتخذ أي إجراء حيال ذلك، إذ  
يحظر في جميع الحالات إعادة فتح باب التزايد مرة أخرى؛ لما تم  
الانتهاء من التزايد عليه. بعكس الحال في المناقصة فيكون للجهة

الإدارية إعادة الطرح، وتوجيه الدعوة لهم ولغيرهم في حالة عدم تقدم أو اشتراك أي من الموردين، والمقاولين، ومقدمي الخدمات.

وتشترك المزايدة المحلية مع المزايدة العامة في كونها تقوم على تنافس المتزايدين لعرض أعلى الأسعار، إلا أن المزايدة المحلية تتميز بكونها محددة النطاق جغرافياً أو بشرياً، وتتم دون إعلان على المستوى القومي، بحسب طبيعة العملية أو الظروف المحيطة بها وتستوجب هذا القيد، بغرض تحقيق الكفاءة دون تحميل الإدارة أية أعباء. بعكس المزايدة العامة فالباب فيها مفتوح لكل المتزايدين لتحقيق أعلى سعر.

**مبررات الأخذ بطريق المزايدة المحلية:** يعتبر من مبررات الأخذ بها:

١- **تقليل التكاليف المرتبطة بالإعلان والتنظيم.**  
٢- **توفير الوقت والجهد في التعامل مع عمليات ذات طابع محلي أو محدود القيمة.**

٣- **تمكين الإدارة من التصرف في الأموال التي لا تستدعي طرحاً عاماً.**

٤- **تحقيق التنمية المحلية بإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين.**

٥- **ملاءمة طبيعة الأصل المطروح. كالأراضي الزراعية الصغيرة.**

**ثانياً: حالات التعاقد بطريق المزايدة المحلية:** يكون التعاقد بطريق المزايدة المحلية فيما لا يجاوز ثمنه الأساسي ستمائة ألف جنيه<sup>(١)</sup>، وفق ما نصت عليه م(٦٩) من قانون التعاقدات.

---

(١) المادة (٦٩) من قانون التعاقدات ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، ويقابلها م١٤٦ من اللائحة.

### ثالثاً: النشر وتوجيه الدعوة عن المزايدة المحلية

يجب النشر عنها على بوابة التعاقدات، وتوجيه الدعوة لأكبر عدد من المسجلين عليها، المتخصصين، أو المؤهلين المشتغلين بنوع النشاط المزمع طرحه، والذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائلتها تنفيذ موضوع البيع أو التأجير أو الترخيص، وذلك بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً قبل الموعد المحدد لجلسة المزايدة. ويجوز بموافقة السلطة المختصة في حالة الاستعجال تقصير مدة توجيه الدعوة بحيث لا تقل عن عشرة أيام. وتحتسب المدة من تاريخ توجيه الدعوة<sup>(١)</sup>. ويجب أن تتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها في الإعلان.

- دور إدارة التعاقدات قبل عرض مذكرة الطرح على السلطة المختصة  
يجوز لها قبل عرض مذكرة الطرح إخطار<sup>(٢)</sup> فرع جهاز تنمية المشروعات الواقع بالمحافظة التي يتم بدائلتها موضوع المزايدة المحلية؛ لحث أصحاب المشروعات المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بنوع النشاط المزمع طرحه لتسجيل بياناتهم أو تحديثها على البوابة، على أن يقوم الجهاز بموافاة الجهة الإدارية بأسماء وبيانات المهتمين منهم بالدخول في المزايدة لدعوتهم، خلال موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ تسلمه إخطارها<sup>(٣)</sup>.

---

(١) المادة (١٤٦) من اللائحة التنفيذية.  
(٢) إدارة التعاقدات في المناقصة المحلية ملزمة بمخاطبة الفرع وإنشاء قاعدة بيانات وتحديثها، وهنا يجوز لها إخطارها فقط، وأمر تسجيل البيانات وتحديثها اختياري.  
(٣) المادة (١٤٦) من اللائحة التنفيذية.

## - سريان أحكام الشراء في المناقصة على البيع في المزايدة:

تسري ذات ونفس القواعد والإجراءات المنظمة لشراء المنقولات، أو استئجارها على بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص أو الاستغلال. المادتين (١٣٦، ١٤٧) من اللائحة.

## رابعاً: حالات إلغاء المزايدة بجميع صورها وسلطة الإدارة

الأصل في الإجراءات التعاقدية أن تسير نحو غايتها النهائية وهي الترسية وإبرام العقد، إلا أن المشرّع أجاز - بل أوجب أحياناً - للإدارة إلغاء المزايدة في بعض الحالات.

وهو ما نظمت أحكامه م (٣٨) من قانون التعاقدات، والمادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية. ووفق ما سبق ذكره من حيث وقت الإلغاء، والسلطة المختصة، وحالات الإلغاء، ويجب أن يشتمل قرار إلغاء المزايدة على الأسباب التي بني عليها. فنحيل إليه منعاً للتكرار.

ويترتب على قرار الإلغاء انتهاء إجراءات التزايد دون اختيار أي من المتزايدين. وإخطارهم بذلك، مع جواز إعادة الطرح من جديد، إما بنفس الشروط أو بشروط معدلة، إذا ارتأت الجهة الإدارية جدوى ذلك. لذا قضت بأنه: "إذا رأت لجنة البت أن أعلى العطاءات سعراً في المزايدة

يقل عن أسعار السوق مما يستوجب إلغاء المزايدة واعتمدت توصياتها من السلطة المختصة ولم يثبت ثمة انحراف بالسلطة فإن القرار الصادر بالإلغاء يكون صحيحاً؛ لأن المشرع استهدف من إلغاء المزايدة في مثل هذه الحالات تحقيق مصلحة الخزنة العامة<sup>(١)</sup>.

وبعد قرار الإلغاء من القرارات المنفصلة، ويخضع في كل الأحوال للرقابة القضائية، لوجود انحراف في استعمال السلطة أو غيره. وترفع لجنة المزايدة محضراً متضمناً قراراتها وتوصياتها للسلطة المختصة للاعتماد، أو تقرير ما تراه. وأن تُضمنه ما اتخذته من إجراءات وتوصيات، إما باستكمال إجراءات الغاء العملية أو إرسائها.

### المطلب الثالث

#### الاتفاق المباشر

#### أولاً- الأساس القانوني للبيع بالاتفاق المباشر

نظمت أحكامه المادة (٧١) من قانون التعاقدات، وبإتباع الإجراءات ذاتها المنصوص عليها بالمادة (١٣٢) من اللائحة التنفيذية، وبما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص. وأيضاً المادة (١٤٨) من اللائحة. ويشترط في جميع حالات الاتفاق المباشر ألا تقل قيمة سعر البيع أو التأجير أو الترخيص عن الثمن الأساسي التي قدرتها لجنة وضع الثمن الأساسي، مع وجوب توثيق المبررات لدى إدارة التعاقدات.

---

(١) الطعن رقم ١٥٠٥ لسنة ٢٩ق، بتاريخ ١١/٢٩/١٩٨٦، مكتب فنى ٣٢، ص ٢٨٦.

ثانيا: حالات وإجراءات وشروط التعاقد على البيع بالاتفاق المباشر  
يجوز للجهة الإدارية التعاقد على البيع بطريق الاتفاق المباشر في  
الحالات الطارئة أو العاجلة التي لا تحتل إتباع إجراءات المزايدة بجميع  
أنواعها المحدودة أو المحلية على عمليات البيع أو التأجير أو الترخيص.  
ويكون بذات الإجراءات المنصوص عليها م(١٣٢) من اللائحة التنفيذية  
لقانون التعاقدات، والمنظمة للتعاقد بالاتفاق المباشر في موضوعات  
المناقصة وبما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص.  
ويشترط في جميع الحالات ألا تقل قيمة البيع، أو التأجير، أو الترخيص  
عن الثمن الأساسي التي قدرتها لجنة وضع الثمن الأساسي.

#### **سلطات الترخيص بالتعاقد على البيع بالاتفاق المباشر**

يكون التعاقد على البيع بطريق الاتفاق المباشر من خلال اللجنة المشكلة  
لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة من أهل الخبرة من بينهم  
عناصر فنية ومالية وقانونية، وفقا لأهمية التعاقد وطبيعته وإجراءاته.

وقد أناط المشرع في المادة (٧١) بأن يكون التعاقد على البيع به بناء

على ترخيص يصدر من بعض الأشخاص المختصين، وحصرهم في:

١- رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات  
الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسمائة  
ألف جنيه.

٢- الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه

٣- استثناءات من أحكام المادة (٧١ / ١) من قانون التعاقدات، وبموافقة الوزير المختص بالجهة الإدارية، في الحالات التي سبق عرضها في مزيدة علنية عامة، أو بالمظاريف المغلقة لأكثر من مرة، ولم تقدم عنها عروض أو لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي أن يتم البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال بالاتفاق المباشر، وذلك على النحو الآتي:

١- العقارات التي لا تجاوز قيمتها مليوني جنيه، يتم إعلان الثمن الأساسي، وبشرط ألا يقل سعر البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال عنه.

٢- بيع المنقولات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، أو تأجيرها أو الترخيص بالانتفاع بالمشروعات أو استغلالها بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، بحسب الأحوال، التي لا تجاوز قيمتها مليون جنيه بشرط ألا يقل الثمن عن الثمن أو القيمة الأساسية. بشرط أن يتم التعاقد مع مقدم العرض الأفضل شروطاً والأعلى سعراً. حيث يشترط في جميع الحالات ألا تقل القيمة عن الثمن الأساسي التي قدرته لجنة أوضاع الثمن الأساسي.

**جواز التصرف في العقارات بالاتفاق المباشر:** يجوز للجهات الإدارية في حالات الضرورة واعتبارات المصلحة العامة التصرف في العقارات والتعامل معها بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالبيع أو التأجير أو



الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط الصادرة بقرار مجلس الوزراء؛ وذلك لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة<sup>(١)</sup>.

ويجب وضع وصف دقيق لموضوع التعاقد، ومراعاة أهمية وتميز موقع محل التعاقد، ومساحته، وحالته، وعمره، وتكلفة إنشائه، واستهلاكاته، واسم الشهرة إن وجد<sup>(٢)</sup>.

**حظر التفويض للسلطات المختصة بالتعاقد على البيع بالاتفاق المباشر**  
لا يجوز لأي من السلطات المختصة أو سلطات الترخيص رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق، أو الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ التفويض في الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد على البيع بطريق الاتفاق المباشر. وتطبق ذات الأحكام السابقة من ذات المؤلف، فنحيل إليها منعا للتكرار.

### ثالثا: لجنة تسليم الأصناف المباعة بعد المزايدة

يكون تسليم الأصناف أو المنقولات المباعة بطريق المزايدة بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار من السلطة المختصة يرأسها موظف مسئول، وعضوية أمين المخزن المختص، وعضو يندبه مدير المخازن من غير أمناء المخازن، بالإضافة لمن ترى السلطة المختصة أهمية ضمهم لعضوية اللجنة. وعليها مراعاة أن يكون التسليم حسب التقسيم الذي أجرته لجنة

(١) المادة (١٣٦) من اللائحة التنفيذية.

(٢) م ٢٦ من اللائحة التنفيذية، والخاصة بتوصيف العقارات والمشروعات.

التصنيف من حيث الكمية والمواصفات وما أسفرت عنه القرارات. وأما تسليم محل المزايدة بالنسبة لغير المنقولات فيكون بمعرفة اللجنة. وعليها التحقق من تنفيذ ما أسفرت عنه قرارات البيع أو التأجير أو الترخيص<sup>(١)</sup>.

#### رابعاً: المدة القانونية المقررة للتأجير أو الترخيص

الأصل أنه يجب في جميع الحالات ألا تتجاوز المدة القانونية المقررة للتعاقد بطريق المزايدة للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال عن ثلاث سنوات.

وقد أطلق المشرع عبارة "المدة الاقتصادية للتعاقد" في م(١٥٠) من اللائحة التنفيذية دون أن يوضح تفاصيل المدد.

واستثناء منه، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة يجوز التعاقد بطريق المزايدة للتأجير أو الترخيص لمدة تتجاوز الثلاث سنوات، بناءً على ترخيص من السلطات المختصة:

١- الوزير المختص: فيما يزيد على ثلاث سنوات، ولا يتجاوز خمسا وعشرين سنة.

٢- وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص: فيما يزيد على خمس وعشرين سنة، ولا يتجاوز خمسا وسبعين سنة، بالنسبة إلى المشروعات ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب استثمارات ضخمة لإنجازها. ويراعى في هاتين الحالتين أن تتضمن شروط التعاقد زيادة المقابل سنوياً بنسبة

---

(١) المادة (١٤٩) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

مئوية من قيمته. ويجوز أن تتضمن شروط الطرح تقديم تسهيلات وبما يتفق مع محل العقد، وتحقيقا لاقتصاديات المشروع.

ويجب في جميع الأحوال تضمين الشروط تحديد المدة التي يتم التعاقد على أساسها، وطبيعة النشاط الذي يمكن مزاولته أو المصرح به بشكل محدد مدد السداد وجزاء عدم الالتزام بها، حظر التعاقد من الباطن، أو التنازل عن حق الانتفاع للغير والنص على التزام المتعاقد وعلى نفقته بإجراء ما يلزم من تجهيزات وأعمال تطوير وصيانة مستمرة لمحل التعاقد ضمانا لإعادته للجهة المالكة بحالة جيدة في نهاية المدة.

ويتعين قبل نهاية مدة التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال اتخاذ إجراءات الطرح من جديد بإحدى الطرق، وفي حدود القواعد والإجراءات المقررة قانونا، وأن تقوم الجهة الإدارية بحصر ما تم من تجهيزات وغيرها في نهاية كل مدة وقبل إعادة الطرح، وأخذه في الاعتبار عند تحديد القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع.

وتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في قبول التجديد أو رفضه؛ طبقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة؛ على اعتبار أن مناط تجديد العقد الإداري هو موافقة طرفيه<sup>(١)</sup>.

---

(١) الطعن رقم ٢٥٣ لسنة ٣١ق، بتاريخ ١٩٨٦/٢/٨، مكتب فنى ٣١، ص ١١١٤.

## الباب الثالث

### المراحل والإجراءات المنظمة لإبرام العقد الإداري

أهداف الباب الثالث: بنهاية الباب، يكون الطالب قادراً على:

- ١- تحديد قيود وإجراءات مرحلة ما قبل الدعوة للتعاقد.
- ٢- معرفة قيود وإجراءات مرحلة الطرح وأهم الأحكام بشأنها.
- ٣- معرفة قيود وإجراءات مرحلة الترسية وأهم الأحكام بشأنها.

تقسيم: يشمل هذا الباب ثلاثة فصول، على النحو التالي:

الفصل الأول: القيود والإجراءات السابقة علي مرحلة ما قبل الدعوة إلي التعاقد.

الفصل الثاني: القيود والإجراءات الخاصة بمرحلة الطرح والإعلان عن التعاقد.

الفصل الثالث: القيود والإجراءات المقررة بمرحلة الترسية وإبرام العقد الإداري.

## الفصل الأول

### القيود والإجراءات المقررة في مرحلة ما قبل الدعوة إلى التعاقد

وهي ما تتمثل في القيود السابقة التالية:

١- تبني الجهة الإدارية سياسات التعاقد المستدام، ووجوب مراعاته؛ باعتباره أحد أهداف قانون التعاقدات، واعتبارات الجودة والتكلفة، وغيرها من الشروط والمعايير اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة<sup>(١)</sup>.

٢- تخطيط الاحتياجات، وهو ما يلزم الجهة الإدارية مخاطبة كافة قطاعاتها وإداراتها ووحداتها؛ لحصر احتياجاتها المطلوبة للسنة المالية التالية وفقا للنماذج المعدة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والتأكد من أنها فعلية وضرورية لسير العمل بناء على دراسات واقعية وموضوعية، قبل مشروع الموازنة، ونشرها على بوابة التعاقدات<sup>(٢)</sup>.

٣- وجوب توافر الاعتمادات المالية، وسنفردها له مبحثا مستقلا لأهميته.

٤- طلب الحصول على معلومات أو مقترحات أو مواصفات، وهو أمر جوازي للجهة الإدارية؛ يسمح لإدارة التعاقدات أن تصدر طلبا مجانيا؛ للحصول على المعلومات، أو المقترحات، أو المواصفات المستجدة في السوق، أو غيرها؛ بما يمكنها من اتخاذ القرار المناسب.

وقد نظمت أحكامه المادتين (١٢) من قانون التعاقدات، و(١٧) لائحته التنفيذية.

---

(١) المادة (٨) من قانون التعاقدات. والمادة (١٢) من اللائحة التنفيذية.  
(٢) م ١٣ من اللائحة التنفيذية.

٥- طلب إبداء الاهتمام: إجراء وجوبى تتخذه الجهة الإدارية، وتعلن عنه في العمليات التي تتطلب معرفة مسبقة للمشغلين بنشاط معين والوقوف على قدراتهم وخبراتهم بهدف الوصول إلى قائمة مختصرة منهم، أو معرفة مدى اهتمامهم بالمشاركة في العملية المقترح طرحها<sup>(١)</sup>. ويتم نشر نتيجته على بوابة التعاقدات، مع إخطار المشاركين بالنتيجة. وقد نظمت أحكامه المادتين (١٣) من قانون التعاقدات، (١٨) لائحته. ويتم إبداء الاهتمام في مرحلة ما قبل الطرح، بعكس التأهيل المسبق فيكون في مرحلة الطرح.

٦- إعداد المواصفات الفنية، فيشترط أن يكون طرح العملية على أساس مواصفات، ورسومات فنية دقيقة ومفصلة، أو معايير أداء عامة وكافية<sup>(٢)</sup>. وهو ما قرره المشرع في اللائحة التنفيذية، ونظم أحكامه في المواد (١٩ : ٢٦)، وميز بين مواصفات عقود المناقصات والمزايدات.

٧- دراسة وضع السوق ومعايير وضع القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي، وهو من القيود السابقة على إبرام العقود الإدارية. وقد نظمت أحكامه المواد (١٥) من قانون التعاقدات، والمواد (٢٧ : ٢٩) لائحته .

٨- قيام السلطة المختصة بتحديد مبلغ التأمين المؤقت ضمن شروط الطرح، سنفرد له مبحثا مستقلا لأهميته.

٩- إعداد كراسة الشروط والمواصفات. وسنفرد له مبحثا مستقلا.

(١) م ١ من قانون التعاقدات.  
(٢) م ١٤ من قانون التعاقدات.

وإذا ما توافرت القيود السابقة في مرحلة ما قبل الطرح للتعاقد قامت إدارة التعاقدات بعد التأكد من الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد وفق الإجراءات المقررة قانوناً، بإعداد مذكرة الإجراءات والطرح؛ تمهيداً للعرض على السلطة المختصة، متضمنة بيان موضوع وطريق التعاقد المناسب، والإدارة الطالبة أو المستفيدة منه، والإجراءات السابق اتخاذها للإعداد للعملية محل الطرح؛ للموافقة على اتخاذ إجراءات الطرح، وفقاً لما حددته بوضوح المادتين ١٧ من قانون التعاقدات، و(٣٢) من لائحته التنفيذية. وغيرها من بيانات تراها إدارة التعاقدات يلزم عرضها على السلطة المختصة. وعلى أن ترفق بمذكرة الطرح صورة من نموذج خطة الاحتياجات المعتمدة، والمتضمنة العملية محل الطرح. وصورة الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بالعملية محل الطرح. ونسخة من تقرير لجنة إعداد المواصفات الفنية. ونسخة من مستندات الطرح، وصيغة الإعلان أو خطابات الدعوة.

وأياً كان، سوف نتناول أهم القيود السابقة في المباحث التالية:

## المبحث الأول

### وجوب توافر الاعتمادات المالية

يعد من أهم القيود السابقة لتعاقد الجهات الإدارية؛ إذ يجب على الجهة الإدارية قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح التحقق من توافر الاعتمادات المالية المخصصة لديها لتنفيذ موضوع التعاقد على أن تتضمن شروط الطرح ما يفيد ذلك، ويكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية. م (١١ / ١) من قانون التعاقدات.

وقد عرفه المشرع بأنه: "المبلغ المخصص للجهة الإدارية الطالبة أو المستفيدة من وزارة المالية، والمدرج بموازنتها؛ لتوفير احتياجاتها" (١).

ولما كان إبرام العقود الإدارية يترتب عليه التزام مالي والتزام تعاقدية، فإن المنطق القانوني والمالي يقتضي أن يستند الالتزام على اعتماد مالي مسبق، مرصود في الموازنة العامة للدولة، أو الموازنة الخاصة بالجهة الإدارية ذاتها، أم الموازنة الخاصة بكل وحدة محلية (٢)، بحسب طبيعتها، ونوع العقد.

ومن ثم حظر المشرع على الجهات الإدارية الإعلان أو توجيه الدعوات أو نشر أي عملية تعاقدية عبر بوابة التعاقدات الحكومية ما لم يكن لها اعتماد مالي (٣). ونتناول أحكامه فيما يلي:

---

(١) الاعتماد المالي، م ١ من اللائحة التنفيذية. ويقصد بالجهة الطالبة أو المستفيدة: "الإدارة المسؤولة عن تحديد المتطلبات بمحل التعاقد طبقاً لمهامها أو احتياجاتها".

(٢) د/ رمضان بطيخ: قيود إبرام العقد، مرجع سابق، ص ١٧.

(٣) م ١٥ من اللائحة التنفيذية.



## أولاً: الطبيعة القانونية للاعتماد المالي

يُعد الاعتماد المالي قيداً جوهرياً في تنفيذ أعمال المرفق العام الذي خصص له، ولا يجوز استخدامه إلا في حدود القيمة المالية المخصصة فقط دون غيرها، وأثناء المدة الزمنية المحددة عادة بسنة مالية<sup>(١)</sup>. فالاعتماد المالي ليس مجرد قيد محاسبي، بل هو إذن وترخيص قانوني عام يُمنح من قبل السلطة المختصة -عادة البرلمان- ويُمكن الإدارة من القيام بتصرفات قانونية تُرتب التزامات مالية على عاتق الدولة وجهاتها الإدارية، وفي مقدمتها العقود الإدارية.

ويعد الاعتماد المالي شرطاً أساسياً لمشروعية العقد الإداري، فحيث يشترطه المشرع فإنه يجب الالتزام به، وإلا كان باطلاً بطلاناً مطلقاً<sup>(٢)</sup> لمخالفته شرطاً جوهرياً لازماً. ويفهم منه أن:

- ١- الاعتماد لا يستخدم إلا في الغرض المخصص له تحديداً.
- ٢- لا يجوز تجاوز القيمة المالية المرصودة له.
- ٣- لا يمتد أثره إلى السنة المالية التالية ما لم يُجدد أو يُمدد قانوناً.

### ثانياً: واجبات الجهة الإدارية لتوفير الاعتماد المالي:

يجب عليها قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح التحقق من توافر الاعتمادات المالية المخصصة لديها؛ لتنفيذ موضوع التعاقد<sup>(٣)</sup>.

وهذا مقيد بأمرين:

---

(١) د/ رمضان بطيخ: قیوم إبرام العقد، مرجع سابق، ص ١٧.  
(٢) د/ رمضان بطيخ: قیود الإبرام، المرجع السابق، ص ٢١.  
(٣) المادة (١١) من قانون التعاقدات.

١- أن تتضمن شروط ووثائق الطرح ما يفيد توافر الاعتماد المالي.

٢- وأن يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية.

ويُستثنى من هذا الالتزام الحالات الطارئة أو العاجلة أو التكاليف التي تقتضيها المصلحة العامة، إذ يجوز حينها أن تُجري التعاقدات ذات الصلة بالتنسيق أولاً مع وزارة المالية أو التخطيط بحسب الأحوال، والتأكد من توافر التمويل اللازم<sup>(١)</sup>.

ثالثاً: أثر غياب الاعتماد المالي على مشروعية العقد الإداري

استقر الرأي الراجح فقها وقضاء، وأجمع<sup>(٢)</sup> على أن مخالفة قواعد القانون المالي بعدم توافر الاعتماد المالي لا تؤثر في صحة العقد الإداري ذاته، بل يظل العقد صحيحاً وناظراً في مواجهة الإدارة، ولا يُعتد بغيبابه كسبب لبطلانه. فإذا ما تعاقدت الإدارة على عقد ما دون وجود اعتمادات مالية له، أو له اعتماد ولكنه غير كاف، أو يتجاوز المبلغ المعتمد زيادته فإن العقد يكون سليماً ومشروعاً وملزماً للإدارة في مواجهة الأفراد، ولا يمكن لها أن تتملص من دفع المبالغ المالية الناجمة عنه<sup>(٣)</sup>.

فالقانون المالي فرع مستقل له ذاتيته الخاصة، وله قواعده وتفسيراته، وأهدافه التي تختلف عن أساليب وتفسيرات وأهداف القوانين الأخرى كالقانون الإداري. إلا أن مخالفة قواعد القانون المالي ليس لها من نتائج أو جزاءات أو عدم مشروعية إلا في إطار ونطاق القانون المالي فقط.

(١) م ٢/١٥ من اللائحة التنفيذية.

(٢) د/ رمضان بطيخ: قيود إبرام العقد، مرجع سابق، ص ١٩.

(٣) د/ رمضان بطيخ: قيود إبرام العقد، المرجع السابق، ذات الصفحة.

وهو ما يترتب عليه نتيجة عامة مؤداها: أن مخالفة الإدارة للقواعد الخاصة بالاعتماد المالي لا يترتب عليها بطلان التصرف الإداري. يؤكد قضاؤها أن: "..... الثابت في فقه القانون الإداري أن العقد الذي تبرمه الإدارة مع الغير كعقد من عقود الأشغال العامة أو التوريد مثلاً، ينعقد صحيحاً، وينتج آثاره حتى ولو لم يكن البرلمان قد اعتمد المال اللازم لهذه الأشغال أو حتى لو تجاوزت الإدارة حدود الاعتماد أو لو خالفت الغرض المقصود منه أو لو فات الوقت المحدد لاستخدامه، فمثل هذه المخالفات -ولو وجدت من جانب الإدارة- لا تمس صحة العقد ولا نفاذه، وإنما تستوجب المسؤولية السياسية. ... العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة مع الغير هي روابط فردية ذاتية، وليست تنظيمية عامة، ويجب من ناحية حماية هذا الغير، ومن ناحية أخرى عدم زعزعة الثقة في الإدارة، فليس في مقدور الفرد الذي يتعاقد معها أن يعرف مقدماً ما إذا كان قد صدر اعتماد أو لم يصدر، وما إذا كان يسمح بإبرام العقد أو لا يسمح، وما إذا كان العقد في حدود الغرض المخصص له الاعتماد أو ليس في حدود هذا الغرض، كل أولئك من الدقائق التي يتعذر على الفرد العادي بل الحريص التعرف عليها. ولو جاز جعل صحة العقود الإدارية أو نفاذها رهناً بذلك لما جازف أحد بالتعاقد مع الإدارة، ولتعطل سير المرافق العامة<sup>(١)</sup>".

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٧٥ لسنة ١٩٥٦/١١/١١، بتاريخ ١١/١١/١٩٥٦، مكتب فني ١، ص ٤٩١.

كما أفقت: ( إن عدم توافر المصرف المالي لا يصلح سنداً للتقاعس عن الوفاء بما التزمت به الجهة الإدارية، وأن امتناعها عن الوفاء بما التزمت به بدعوى عدم كفاية الاعتمادات المالية يعد إخلالاً من جانبها بما التزمت به، وحق عليها أن تقوم بتنفيذه طبقاً لشروط العقد... وأنه يجوز إعادة النظر في الأسعار المتعاقد عليها بسبب توقف العمل لعدم توافر الاعتماد المالي، وذلك حتى لا تختل اقتصاديات العقد لسبب لا دخل للمتعاقد فيه<sup>(١)</sup>.

**ومن ثم يحق للمتعاقد مع الإدارة المضرور ما يلي:**

- ١- حق المطالبة القضائية بقيمة الأعمال المنفذة أو التعويض عنها.
  - ٢- التمسك بتطبيق نظرية الإثراء بلا سبب في مواجهة الإدارة.
  - ٣- المطالبة بفسخ العقد والتعويض عند الاقتضاء.
- وقد أعطى مجلس الدولة الفرنسي للمتعاقد في هذه الحالة حق اللجوء للقضاء أو التسوية، وغالبا ما يلجأ إلى طريق التسوية<sup>(٢)</sup>.

**رابعا: فتح الاعتماد المالي بالموازنة لا يترتب إلزاماً بالتعاقد**

فتح الاعتماد المالي في الموازنة لا يلزم الجهة الإدارية بالتعاقد، إذ تخضع تصرفاتها دوماً للمصلحة العامة، فقد ترى إرجاء المشروع، أو العدول عنه لظهور أمور طرأت تحتم إلغائه واستبداله بأعمال أخرى، دون أن يُعد ذلك مخالفة قانونية، فمجرد وجود الاعتماد المالي أو فتحه

---

(١) فتوى رقم ٥٤١ في ١٩٩٣/٧/٨، ملف رقم ٢٦/٢/٧٨.  
(٢) د/ رمضان بطيخ: قيود إبرام العقد، مرجع سابق، ص ٢٠.

لا يترتب بذاته التزاماً في ذمة الإدارة، وإنما يوجد الالتزام حين تتدخل الإدارة، وتعتبر عن إرادتها، باستخدامه في تحقيق الغرض المرصود من أجله، ولا يترتب حقاً للأفراد في ضرورة استعماله من جهة الإدارة.

#### خامساً: استثناءات ومحظورات قانونية مرتبطة بالاعتماد المالي:

١- يجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية، بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في سنة التعاقد<sup>(١)</sup>.

٢- يكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة علي أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة<sup>(٢)</sup>.

وأما المحظورات، فتتمثل في أنه حماية للمال العام والاعتمادات المالية، يحظر على إدارة التعاقد<sup>(٣)</sup>: التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية. أو التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية، إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل، وبموافقة السلطة المختصة. كالحالات الطارئة أو العاجلة بشرط استكمال إجراءات تعاقدتها قبل انتهاء السنة المالية<sup>(٤)</sup>. والتعاقدات الممولة من الاتفاقيات الدولية من وزير المالية.

(١) المادة ٣/١٥ من اللائحة التنفيذية.

(٢) المادة ٤/١٥ من اللائحة التنفيذية.

(٣) م ١١ من قانون التعاقدات. ويقابلها المادة (٤/١٥) من اللائحة: (ويحظر اتخاذ أي من إجراءات التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية، إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل، وبموافقة السلطة المختصة).

(٤) المادة ٢/١٥ من اللائحة التنفيذية.

## المبحث الثاني

### التأمين المؤقت

#### أولاً: مفهوم وطبيعة التأمين المؤقت

التأمين المؤقت هو: ضمان ابتدائي منفصل، ذو طبيعة خاصة ترتبط بطبيعة العقد الإداري، يسدده مقدم العطاء في المناقصة أو المزايدة، بهدف إثبات جديته ورغبته في التعاقد مع الإدارة، وتقادي التلاعب، وبظل تحت يد الجهة الإدارية طوال المدة المحددة لسريان العطاءات، وبانتهاء المدة يجب رده<sup>(١)</sup>. ويُرد في حال عدم إرساء العطاء عليه.

يؤكد ما قضت به، بأنه: "من المقرر في العقود الإدارية -التي هي من مجالات القانون العام التي تختلف عن مجالات القانون الخاص- أن التأمين الابتدائي ضمان لتنفيذ التعاقد على النحو المتفق عليه في الشروط الخاصة بالمناقصة وليست له صفة العيرون المنصوص عليه بالمادة ١٠٢ من القانون المدني"<sup>(٢)</sup>.

ويعد من أبرز الضمانات التي تشترطها الإدارة قبل الدخول في مراحل التعاقد النهائي، بل ومن القيود الإجرائية والشروط الجوهرية السابقة لإبرام العقود الإدارية، والنظر في العطاءات؛ حيث ألزم المشرع السلطة المختصة بأن تحدد مبلغ التأمين المؤقت ضمن شروط الطرح، ويجب تقديره دون مبالغة وبما لا يجاوز النسبة المنصوص عليها وفقاً لطبيعة

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعين رقمي ٣٤٤ و ٩٦٧ لسنة ٥٠ ق.ع، جلسة ٢٠٠٥/٦/٢٨. المستشار محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٣٢٩ وما بعدها.

(٢) حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم ٧٣٥ لسنة ١١، جلسة ١٩٥٩/١/١١.

كل عملية<sup>(١)</sup>. وقد قضت بأن: "إيداع التأمين المؤقت من مقدم العطاء في الوقت المحدد شرط أساسي للنظر في عطائه سواء أكان هذا التأمين نقداً أم سندات أم كفالة مصرفية، وهذا الشرط مقرر للصالح العام دون ترتيب جزاء البطلان على مخالفته إذا ما اطمأنت الإدارة إلى ملاءة مقدم العطاء"<sup>(٢)</sup>.

### ثانياً - الجهة المختصة بتحديد مبلغ التأمين المؤقت

يُعد تحديد مبلغ التأمين المؤقت اختصاصاً أصيلاً للسلطة المختصة بالتعاقد؛ لأن العقد الإداري لا ينشأ ولا يعدل إلا بإرادة صحيحة، صادرة ممن يملك التعبير عنها، وهو ما لا يتأتى إلا من السلطة المختصة<sup>(٣)</sup>. كما يجوز للجنة إعداد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي بحسب الأحوال اقتراح مبلغ التأمين المؤقت بكتاب مستقل موقع من رئيسها وأعضاءها، يرفق بتقريرها.

وبعد أن يتم تحديده منها، واعتماده من السلطة المختصة يخطر به مدير إدارة التعاقدات؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن يتضمن مستندات الطرح مبلغ التأمين المؤقت<sup>(٤)</sup>، ويدرج ضمن شروط الطرح.

(١) المادة ١٦ من قانون التعاقدات.

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٣٨٦، لسنة ٨ق، جلسة ١٤/٣/١٩٦٤، مكتب فني ٩، ص ٧٩٨.

(٣) حكمها في الطعن رقم ٨٤٥، لسنة ١٩، بتاريخ ٢٢/١١/١٩٨٠، مكتب فني ٢٦، ص ٦٨.

(٤) المادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

ثالثاً: تقدير مبلغ التأمين المؤقت في عقود المناقصات والمزايدات:

يجب تقدير مبلغ التأمين المؤقت<sup>(١)</sup> من السلطة المختصة دون مبالغة،

لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركة، وبما يتناسب وطبيعة العملية:

١- يقدر مبلغ التأمين المؤقت في عمليات شراء أو استئجار المنقولات

والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية والدراسات

الاستشارية بأي قيمة وبما يتماشى مع طبيعة العملية وحجمها؛ شريطة

ألا يصل الحد الأقصى له ما يجاوز نسبة (١.٥ %) من القيمة

التقديرية. وبحسب التأمين المؤقت في حالة الطرح في مجموعات

متجانسة لكل مجموعة بذات النسبة المقررة (١.٥ %).

٢- يقدر مبلغ التأمين المؤقت في عمليات شراء أو استئجار العقارات

بأي قيمة شريطة ألا يصل الحد الأقصى له ما يجاوز نسبة (٠.٥ %)

من القيمة التقديرية للعملية المطروحة.

٣- يتم تحديد مبلغ التأمين المؤقت في عمليات بيع وتأجير المنقولات

والعقارات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات التي

ليس لها الشخصية الاعتبارية حسب طبيعة وأهمية المزايدة.

ومخالفة شروط تقديم التأمين الابتدائي للنظر في العطاءات يعد إخلالاً

بواجبات الوظيفة يستوجب المساءلة<sup>(٢)</sup>.

(١) المادتين ١٦ من قانون التعاقدات، و ٣٠ من لائحته التنفيذية.

(٢) حكمها في الطعن رقم ٣١٧٤ لسنة ٢٩ق، جلسة ٣١/٣/١٩٩٠، س ٣٠، مبدأ

١٤٠، ص ١٤٩٤. مجموعة الأربعين عاماً، مبدأ ١٠١، ص ٢٢٨. المستشار د/ محمد

أبو العينين، العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٨٥٨.



#### رابعاً: مدة سريان التأمين المؤقت:

يجب في جميع الأحوال أن يكون التأمين المؤقت سارياً لمدة ثلاثين يوماً، تبدأ بعد تاريخ انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء، أو تاريخ انتهاء مدة مدّ صلاحيته - بحسب الأحوال - ويُعد ذلك من قبيل الضمانات القانونية التي تحول دون تلاعب المتقدمين أو تراجعهم المفاجئ.

#### خامساً: صور أداء التأمين المؤقت

حددت اللائحة التنفيذية وسائل سداد التأمين المؤقت، بواحد من ثلاثة:

##### الصورة الأولى: صورة خطابات الضمان

وهي أكثر الصور شيوعاً، إذ هو تعهد نهائي يصدر عن البنك بناء على طلب عميله بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد خلال مدة محددة<sup>(١)</sup>.

وبشترط فيه: أن يصدر من بنك محلي معتمد، وألا يقترن بأي قيد أو شرط، وأن يقر فيه البنك بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب. وهو ما ينشئ بذاته في ذمة البنك التزاماً أصلياً مباشراً بأداء قيمته للمستفيد الجهة الإدارية متى طلب ذلك خلال المدة المبينة فيه وعن العملية المعتمدة في الخطاب دون غيرها<sup>(٢)</sup>. ويتعين على الجهة الإدارية أن تتحقق من أن المصرف أو الفرع قد أعطى إقراراً على

---

(١) حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٤٥٢ لسنة ٧٢ ق، جلسة ٢٧/٤/٢٠٠٤. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٣٣٥ وما بعدها.

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٣٩٧٥ لسنة ٤٩ ق. عليا، جلسة ٢٨/٤/٢٠١٥. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٣٣٧ وما بعدها.

خطابات الضمان بأنه لم يجاوز الحد الأقصى المعين لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف في إصدارها. فإذا تبين عند مراجعة الإخطارات لدى البنك المركزي أن المصرف قد تعدى الحد الأقصى المحدد له أخطرت الجهة الإدارية فوراً لمطالبة المصرف بأن يؤدي إليها في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل قيمة خطاب الضمان.

كما تقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المحلية المعتمدة على أن يتعهد المصرف المحلى بأن يدفع للجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب، وأنه ملتزم بأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفات إلى أي معارضة من صاحب العطاء.

#### الطبيعة القانونية لخطاب الضمان

يعتبر أداة ضمان لا وفاء، ولا يجوز الحجز على قيمة خطاب الضمان. وقد قضت بأن: "خطاب الضمان المقدم من أحد البنوك للجهة الإدارية ضماناً لالتزامات المقاول ليس مثل الشيك أداة وفاء وإنما هو أداة ضمان، فطبيعة خطاب الضمان تختلف عن طبيعة الشيك، إذ أن خطاب الضمان شخصي ولا يجوز للمستفيد تظهيره إلى غيره أو التنازل

عنه بأي طريق وبالتالي فليست له قيمة ذاتية إلا لشخص المستفيد<sup>(١)</sup>.  
ومن ثم لا يسوغ الحجز على قيمة خطابي الضمان المشار إليهما<sup>(٢)</sup>.  
وتعتبر الجمعية العمومية خطاب الضمان في إطار التعاقدات الإدارية  
.... هو كفالة شخصية من مصدره "المتعاقد" لصالح الدائن "الجهة  
الإدارية"، ومن محررات ضمان الغير؛ شرع من أجل تأمين وفاء المتعاقد  
بالتزامه وفقا للمواصفات وفي المواعيد المتفق عليها<sup>(٣)</sup>.

### الصورة الثانية: صورة الخصم من المستحقات

وفيها يجوز لصاحب العطاء سداد مبلغ التأمين المؤقت خصما من  
مستحقاته التي تقر الجهة العامة صلاحيتها للصرف من عمليات أخرى  
في ذات الجهة الإدارية وفي تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية.

**الصورة الثالثة: صورة الاستبدال:** وهي صورة جوازية، حيث يمكن  
استبدال مبلغ التأمين المؤقت بأي صورة أخرى؛ بالشروط التالية:

- ١- موافقة السلطة المختصة، بناء على طلب صاحب العطاء للاستبدال.
- ٢- وألا تنقطع مدة سريان التأمين.
- ٣- عدم إخلال صاحب العطاء بمسئوليته طبقا للغرض المقدم عنه  
التأمين، أو جلسة المزايدة بناء على الطلب المقدم منه.

---

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٨٩٧ لسنة ٩٩ق، جلسة ١٩٦٣/٧/٢٠،  
المجموعة، مرجع سابق، ص ٤٤٢.  
(٢) طعن رقم ١٣٢٦ لسنة ٣٣ق، جلسة ١٩٩٥/١/٢٤، اللجنة الثالثة فتوى رقم ١٩٧٨  
في ١٩٥٩/٥/٢٣.  
(٣) فتاها رقم ٥١٥ بتاريخ ٢٠١٧/٣/١١، ملف رقم ٤١٨٦/٢/٢٢. المستشار د/محمد  
علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٣٣٨ وما بعدها.

## سادسا: حالات رد التأمين المؤقت

يتم رده في الحالات المقررة بذات الوسيلة التي تم أدائه بها، ويجب تضمين شروط الطرح صور السداد والرد بشكل صريح. **والحالات هي:**

١- رد التأمين للمتقدمين غير المقبولين فنياً، وهو ما يتم دون طلب، فور انتهاء مرحلة البت الفني.

٢- رد التأمين للمتزايدين غير الفائزين، وهو ما يتم فور انتهاء المزايدة، ودون طلب.

٣- في حالات التأخير في الرد، حيث تلتزم الجهة الإدارية برد قيمة المظاريف البنكية لتجديد خطاب الضمان، وسداد الفوائد القانونية، مع إحالة المتسبب للتحقيق.

وقد قضت ببطلان المزايدة وإعادة التأمين المؤقت؛ لوجود معوقات - ظاهرة وغير ظاهرة - تحول دون الانتفاع بالأرض محل المزايدة، وتنفيذ العملية، ويعد ذلك من قبيل الغلط الجوهري لوقوعه في صفة جوهريّة في محل العقد<sup>(١)</sup>.

---

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٤٦٧٣٢ لسنة ٦٨ ق.ع، جلسة ٢٠٢٤/٣/٢٦. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٥٠٥ وما بعدها.

## المبحث الثالث

### إعداد كراسة الشروط والمواصفات

أولاً: تعريف كراسة الشروط والمواصفات أو دفاتر الشروط وضوابطها يقصد بها: الوثيقة أو مجموعة من الوثائق أو النماذج، الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والتي تُعدها الجهة الإدارية منفردة قبل التعاقد، بغرض حصول الراغب في التعاقد مع الإدارة من الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالمشروع من كافة الجوانب الفنية، والمالية، والإدارية، والقانونية، وطريقة التعاقد، والشروط والمواصفات الفنية لموضوع التعاقد، وشروط الطرح العامة والخاصة، ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه متضمناً حقوق والتزامات طرفي التعاقد<sup>(١)</sup>.

ويلزم مراعاة الضوابط والاعتبارات الخاصة بإعداد الكراسة من حيث الشفافية والوضوح والحيادية، وخلوها من الغموض، أو التمييز، والمرونة في التعديل قبل الطرح. وتضمنها آليات الشكوى والتظلم من قرارات الاستبعاد ونحوه، حتى تكون ملزمة لكافة المتنافسين والمتعاقد النهائي، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من العقد.

### الجهة المختصة بإعداد كراسة الشروط والمواصفات وواجباتها

الأصل العام أن تستأثر وتستقل الجهة الإدارية وحدها بإعدادها دون حاجة لاستشارة الأفراد بما يخدم الصالح العام، ويحافظ على سير

---

(١) فتوى الجمعية العمومية رقم ١٦٥٢ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١. ملف رقم ٦٥٩/١/٥٤ المستشار د/محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٣٥٤.

المرافق العام بانتظام واضطراد، وتصدر بقرار وزاري<sup>(١)</sup>. وتلتزم بإعدادها قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك في جميع طرق التعاقد الواردة بقانون التعاقد، بما فيها طريقة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك، ويجب عليها التقيد به<sup>(٢)</sup>، وتتضمن الإحالة إلى جميع القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المقررة قانوناً، بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يتطلبها القانون.

وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في إعداد الكراسة محددة فيها شروطها التعاقدية، وبما يخدم صالح المرفق ما لم تتضمن ما يخالف أي أحكام أمرة لا يجوز الاتفاق على ما مخالفتها، أو رتب المشرع جزاء البطلان على مخالفتها<sup>(٣)</sup>. وليس لمن يريد التعاقد إلا أن يقبل هذه الشروط أو يرفضها، فإذا أراد الخروج في عطائه على هذه الشروط فإن الأصل أن يستبعد هذا العطاء<sup>(٤)</sup>.

وتعد قيوداً وشرطاً شكلياً جوهرياً سابقاً، لا بد من الالتزام به وإلا بطل العقد؛ لكونه من الإجراءات الشكلية الجوهرية المقررة بنص قانوني في المواد (١٩) من قانون التعاقدات، ٣٣: ٣٦ من لائحته.

---

(١) د/ عمر حلمي وآخرون: المبادئ، مرجع سابق، ص ٢٧١.  
(٢) المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية، ومن قبلها المادة (٩) من ذات اللائحة.  
(٣) فتوى الجمعية العمومية رقم ٤٨١ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦. ملف رقم ٦٩١/١/٥٤.  
المستشار د/محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٣٥٧.  
(٤) حكمها في الطعن رقم ٣٣٣ لسنة ١٠٠، بتاريخ ١٩٦٧/١٢/٢، مكتب فني ١٣، ص ١٦٦.

ويتعين على الجهة الإدارية وإدارة التعاقد في كل الأحوال ما يلي:

١- الالتزام بالنماذج والأنماط الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية أيا كانت نماذج كراسات الشروط والمواصفات، وأنماط العقود النموذجية والأدلة الإرشادية، وغيرها.

٢- أن تتخذ ما يلزم بشأن تضمين كراسة الشروط النموذجية المواصفات الفنية والتوصيف الفني الكافي لموضوع التعاقد وأي اشتراطات إضافية أخرى، ونموذج العقد بما يتناسب مع طبيعة العملية محل الطرح.

٣- تحديد ثمن شراء كراسة الشروط والمواصفات وفقا للشرائح المحددة باللائحة التنفيذية.

٤- ترجمة كراسة الشروط والقوائم والمواصفات والتوصيف الفني بحسب الأحوال في حال الطرح في الخارج، مع ذكر أن النص العربي هو النص المعول عليه في حالة الخلاف أو الالتباس في مضمونها.

٥- يتم نشر صورة كاملة ومطابقة من كراسة الشروط والمواصفات على بوابة التعاقدات العامة. عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي عدم النشر عنها وفقا لما تقدره السلطة المختصة.

٦- تلتزم إدارة التعاقدات بإخطار أو موافاة -بحسب الأحوال- لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بنسخة من شروط ومواصفات الطرح أو العقود، وذلك في عقود المنقولات، وعقود مقاولات الأعمال فقط، طبقا للإجراءات المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة (١٩) من القانون.

## أهمية وخصائص كراسة الشروط والمواصفات

تعد من أهم الوثائق القانونية التي تُعدّها الجهة الإدارية في مرحلة ما قبل التعاقد، ومن أهم ما يميزها عن غيرها الخصائص والمزايا التالية<sup>(١)</sup>:

١- ضمان تكافؤ الفرص والشفافية في التعاقد، وتمكين الراغبين في التعاقد من معرفة كل تفاصيل العملية التعاقدية وحقوقهم والتزاماتهم.

٢- تتسم بطابع الديمومة والاستمرارية.

٣- بساطة وسهولة عملية إعداد العقد، حيث لا يبقى أمام الموظفين المكلفين بإعدادها، إلا تقرير شروطها الخاصة، وتحديد محل العقد.

٤- تسهيل عملية التقييم والاختيار الموضوعي.

٥- حماية الإدارة من المنازعات المستقبلية عبر توثيق الشروط.

٦- ضبط العلاقة القانونية والمالية والفنية مع المتعاقد.

## ثانياً: أنواع كراسة الشروط والمواصفات في فرنسا ومصر

يتسم النظام الفرنسي بتقسيم دقيق لأنواع كراسة الشروط<sup>(٢)</sup>، فقسمها إلى:

١ - كراسة الشروط العامة: وهي وثيقة تنظيمية تصدرها السلطة العامة،

تتضمن قواعد لائحية، وأخرى عامة ومجردة. وتطبق على عقود معينة-

كعقود الأشغال العامة، والتوريدات، والعقود الصناعية وغيرها- بصرف

النظر عن الجهة المتعاقدة. وتنقسم إلى كراسة أو دفاتر الشروط العامة

الإدارية والمالية، ودفاتر الشروط العامة الفنية أو التقنية.

---

(١) د/ رمضان بطيخ: قيود إبرام العقد، مرجع سابق، ص ٢٨.  
(٢) د/ رمضان بطيخ: قيود إبرام العقد، المرجع سابق، ص ٢٨ وما بعدها.



٢- **كراسة الشروط الخاصة:** وهي ما تتضمن شروطاً خاصة، تخص عقداً بعينه، أو تتعلق بكل حالة عقدية على حدة، حيث يتمثل دورها في إكمال ما لم يرد بدفتر الشروط العامة من اشتراطات ومواصفات. وتنقسم إلى دفاتر الشروط الخاصة المالية والإدارية، ودفاتر الشروط الخاصة الفنية أو التقنية.

**أما الوضع في مصر:** فلا يوجد فيها تقسيم لكراسة الشروط إلى عامة وخاصة. وإن رأى بعض الفقه أن الأحكام العامة الواردة في القسم الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات الملغي، والتي اشتملت على أحكام عامة في تنفيذ العقود، وشروطاً أخرى عامة لتنفيذ عقود الأشغال أو مقاولات الأعمال، وثالثة لتنفيذ عقود التوريد وغيرها، تصلح مقابلاً لتلك الدفاتر والكراسات، وإن كانت لا تسد الفراغ المتعلق بالشروط التقنية العامة التي يجب أن توجد كنموذج يحتذى من جانب الإدارة المتعاقدة من جهة بنود العقد الفنية<sup>(١)</sup>.

وبقابلها في قانون التعاقدات الحالي الشروط العامة الواجب توافرها في كراسة الشروط والمواصفات، بالإضافة إلى الشروط الخاصة والتي تختلف حسب مضمون ومحتوى وطبيعة ونوع العقد، وما إذا كانت كراسة خاصة بعقود المناقصات والمزايدات حسب موضوعات كل منها. وتعلق بشكل أساسي بالشروط المالية والإدارية دون الشروط الفنية أو التقنية،

---

(١) د/ رمضان بطيخ: قيود إبرام العقد، مرجع سابق، ص ٣٠.

وبالتالي لا تتطابق مع دفاتر الشروط العامة في فرنسا إلا من زاوية واحدة، الأمر الذي يتطلب أن توجد أحكام وبنود أخرى ذات طبيعة فنية أو تقنية تأخذ شكل نموذج يحتذى به من جانب الإدارة المتعاقدة<sup>(١)</sup>.

ويجوز في فرنسا ومصر مخالفة الشروط الخاصة الواردة بكراسة الشروط أيا كان نوعها، بشرط أن يُشار صراحة إلى ما يخالف، وإلا يُعتبر غير نافذ؛ استنادا إلى مبدأ الحرية التعاقدية، الذي يسمح للأطراف أن يضمنوا العقد كل ما يرونه ملائماً لطبيعة الرابطة التعاقدية.

وقد قضت بأنه: (...ومن حيث إنه إذا تضمنت الشروط الخاصة الملحقة بالشروط العامة أحكاماً خاصة لمواجهة تقصير المتعاقد في التوريد فإنها تكون هي الواجبة التطبيق دون النص اللائحي أو النص العام؛ إذ أن من المبادئ المسلم بها أن الخاص يقيد العام...) <sup>(٢)</sup>. شريطة أن ينص في العقد صراحة على هذه المخالفة، وألا تكون المخالفة متعلقة بقاعدة من قواعد النظام العام.

### ثالثاً: محتويات ومواصفات وضوابط كراسة الشروط والمواصفات

يجب أن تتضمن كراسة الشروط على وجه الخصوص طريقة التعاقد، والمواصفات والأطر الفنية لموضوع التعاقد ومكان التنفيذ، والبرنامج الزمني المتوقع للإجراءات ومواعيد ومكان انعقاد الجلسات، وشروط الطرح العامة والخاصة، والتأمينات، وطريقة السداد، وتوقيتات تقديم

---

(١) د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص ٣٠.  
(٢) حكمها السابق في الطعن رقم ٢٨٧ بتاريخ ١٩٧٤/٦/٢٩.

الشكاوى، وأسلوب التقييم، وشروط فسخ العقد، والجزاءات والغرامات، ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه متضمنا حقوق والتزامات طرفي التعاقد، وأي بيانات أخرى بحسب طبيعة العملية<sup>(١)</sup>.

ثم أتت اللائحة التنفيذية<sup>(٢)</sup> لتبين البيانات الواجب أن تلتزم بها إدارة التعاقدات وتضمنها كراسة الشروط والمواصفات في عمليات وعقود شراء أو استئجار المنقولات والعقارات، والتعاقد على مقاولات الأعمال، وتلقى الخدمات والأعمال الفنية بحسب الأحوال. والبيانات الواجب أن تلتزم بها في عمليات وعقود بيع وتأجير المنقولات والعقارات، والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف<sup>(٣)</sup>.

**والخلاصة،** تحتوى كراسة الشروط على ستة عناصر أساسية، هي:

١ - **البيانات التعريفية:** مثل: اسم الجهة المتعاقدة، رقم العملية أو المناقصة أو المزايدة، وصف موجز لطبيعة التعاقد.

٢ - **الاشتراطات الإدارية العامة للتعاقد:** وتشمل الشروط القانونية للمشاركة، وطريقة التعاقد، مواعيد التقديم، وفتح المظاريف، كيفية الاستعلام وتقديم التظلمات.

---

(١) المادة (٢/١٩) من قانون التعاقدات.  
(٢) المادة (٣٤) من اللائحة التنفيذية. وحددت ١٨ بيانا، وغيره، حسب طبيعة العملية.  
(٣) المادة (٣٥) من اللائحة التنفيذية. وحددت ٨ بيانات، وغيره مما تراه حسب طبيعة العملية. مع بيان شرائح تحديد ثمن كراسة الشروط والمواصفات.

٣- **الاشتراطات الفنية:** وتشمل المواصفات الفنية التفصيلية، وطريقة التنفيذ ومراحل الإنجاز، وشروط الجودة والاعتماد، وشروط تقديم العينات أو الرسومات أو النماذج.

٤- **الاشتراطات المالية:** وتشمل قيمة التأمين الابتدائي والنهائي، كيفية احتساب الأسعار، شروط السداد والدفع، وأسلوب تسوية الفروق المالية أو فروق الأسعار.

٥- **معايير التقييم والترسية:** وتشمل نسب التقييم الفني والمالي (مثال: ٧٠٪ فني - ٣٠٪ مالي)، وأسس التقييم التفصيلية، وضوابط فض العروض وتشكيل اللجان.

٦- **نموذج العقد الابتدائي:** يُرفق نموذج للعقد المقترح، يُشار فيه إلى الالتزامات المتبادلة، يُنص فيه على جزاءات التأخير أو الفسخ وغيره.

رابعاً: **جواز إدخال تعديلات وإضافات على كراسة الشروط وضوابطه:**  
يجوز للجهة الإدارية إدخال تعديلات على كراسة الشروط والمواصفات؛ إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على جلسة الاستفسارات، بشرط أن يتم اعتماد تلك التعديلات من السلطة المختصة. وإخطار من قاموا بشراء الكراسة ومقدمي الاستفسارات بتلك التعديلات دون الإفصاح عن مقدميها، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات<sup>(١)</sup>، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إجراء التعديلات أو جلسة الاستفسارات.

---

(١) المادة ٥/٩ من اللائحة التنفيذية.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة بين الإخطار بهذه التعديلات والموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية عن سبعة أيام.

وبتعيين الرد عليه كتابة بكتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات.

ولا يجوز التعديل في الكراسة بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية<sup>(١)</sup>. كما لا يجوز تعديل الشروط الواردة بكراسة الشروط والتي تم الطرح العملية عليها بعد إبرام العقد بناء على مزايدة؛ باعتبار هذه الاشتراطات هي قانون التعاقد الذي يتعين الالتزام به<sup>(٢)</sup>.

ويجوز أن تتضمن كراسة الشروط شروطاً خاصة إضافية عما ورد بالنموذج والنمط الصادر عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية بما يخدم العمليات المطروحة ومصالحة المرفق، ولا يخالف سياق ما ورد بقانون التعاقدات ولائحته التنفيذية.

يؤكدده فتاها الخاصة بمديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية من أن البند (١١) من الكراسة، والذي نص على أن يكون للمديرية في حالة الضرورة تكليف أي مقال آخر بأمر كتابي بتنفيذ أي أعمال تطلب منه في أي موقع، وبأي حي من أحياء المحافظة دون التقيد بمنطقة التعاقد ودون اعتراض من المقال الأصلي أو الوافد من حي آخر، ويتم

(١) المادة (١٩ / ٣) من قانون التعاقدات.  
(٢) فتوى الجمعية العمومية رقم ٩٩٥ بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٩. ملف رقم ٦٩١/١/٥٤. المستشار د/محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٣٦١ وما بعدها.

احتساب السعر الأقل لصالح الخزانة العامة طبقاً لأولوية العطاء إجمالياً... باعتباره يدخل ضمن إطار سلطة جهة الإدارية التقديرية في إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات المعروضة، محددة فيها شروطها التعاقدية مسبقاً بما يخدم صالح المرفق الذي تقوم على إدارته،... ما دامت تلك الشروط لا تخالف أي أحكام أمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، أو رتب المشرع جزاء البطلان على مخالفتها، فضلاً عن كونه مقررراً لمصلحة جهة الإدارة لمجابهة حالة الضرورة القصوى أو الطارئة التي يستلزم التعامل معها أقصى درجات الاستعجال، بالإضافة إلى أن نطاق تطبيقه يقتصر على الحالات الاستثنائية الواردة به، وبشرط المحاسبة على السعر الأقل لصالح الخزانة العامة طبقاً لأولوية العطاء إجمالياً، كما أن كافة المقاولين سيكونون على علم ودراية بهذا الشرط قبل تقديم عروضهم.."<sup>(١)</sup>.

### **الرقابة على كراسة الشروط والمواصفات وحالات رد ثمنها**

تخضع كراسة الشروط بعد إعدادها لمراجعة الإدارة القانونية، والجهة الفنية المختصة مالياً وتقنياً، وقد تستوجب أحياناً مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حسب طبيعة العملية. كما قرر المشرع في قانون التعاقدات بأن تتولى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة مراجعة مشروعات العقود التي تكون الجهة الإدارية طرفاً

---

(١) فتاها السابقة في الملف رقم ٥٤ / ١ / ٦٩١، الصادرة بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٣.

فيها، ونماذج كراسات الشروط، وأنماط العقود النموذجية والأدلة الإرشادية وغيرها<sup>(١)</sup> إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أما إذا زادت على ذلك أو كانت غير محددة القيمة فتلتزم إدارة الفتوى بإحالاته إلى اللجنة المختصة بحسبان الاختصاص بمراجعته ينعقد إلى لجنة الفتوى المختصة إعمالاً للمادة (٦١/ب) من قانون المجلس<sup>(٢)</sup>.

كما يجوز للمتافسين التظلم إدارياً وقضائياً من بنود وشروط الكراسة. أما عن حالات رد ثمن كراسة الشروط والمواصفات: فيرد ثمن الكراسة لمن قام بشرائها متى توافرت حالة من حالات إلغاء العملية- المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها قبل البت فيها- المنصوص عليها بالمادة (٣٧) من القانون الوجوبية والجوازية، والسابق ذكرها؛ شريطة إعادتها للجهة الإدارية كاملة<sup>(٣)</sup>. باستثناء الحالات التي يتبين فيها وجود تواطؤ بينهم، أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار فلا يرد الثمن.

ويعد عدم استيفاء المستندات المطلوبة بكراسة الشروط في مرحلة البت الفني من قبل الموظف المختص نتيجة إهماله وتقاعسه مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته تأديبياً؛ لأنه أخطأ في تطبيق القانون، وأوقع اللجان في قبول عروض من شركات بالمخالفة لكراسة الشروط<sup>(٤)</sup>.

---

(١) المادة (٩٠) من قانون التعاقدات.  
(٢) فتوى الجمعية العمومية رقم ٧٩٥ بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٠. ملف رقم ٦١٨/١/٥٤.  
المستشار د/محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٣٥٨.  
(٣) م ٣٧ من قانون التعاقدات، والمادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية. ونحيل إليها.  
(٤) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٣٩٢٦ لسنة ٦٤ ق. عليا، جلسة ٢٠١٩/٣/١٦. د/محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ١٠٨٤. وعاقبته بغرامة تعادل الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته، لعدم تقديم استمارة ٤ للأخبار المستوردة.

## الفصل الثاني

### القيود والإجراءات المقررة في مرحلة الطرح والإعلان عن التعاقد

تعتبر مرحلة الطرح للتعاقد من أهم مراحل إبرام العقد الإداري. وقد نظم المشرع أحكامها، وفصل إجراءاتها في قانون التعاقدات ولائحته التنفيذية. وهو ما سوف نتناوله في المباحث الآتية:

## المبحث الأول

### الاستشارات السابقة على التعاقد

أولاً: تعريف الاستشارات السابقة على التعاقد وتمييزها وأهميتها

تُعد مرحلة ما قبل الطرح إحدى المراحل الجوهرية، بل الحيوية المؤثرة في صحة وسلامة العقد الإداري؛ إذ تتطلب قدرًا عاليًا من التحضير الفني والقانوني لضمان سلامة إجراءات الطرح وفعالية التعاقد.

ومن أبرز آليات التحضير المسبق، أو متطلبات ما قبل التعاقد إجراء الاستشارات الفنية والقانونية والمالية قبل الطرح، التي تُقيد الإدارة خاصة في العقود المعقدة، أو الخاصة بالبنية التحتية القومية، أو التي تمثل قيمة مالية كبيرة، أو ترتب التزامات استراتيجية على جهة التعاقد، أو العقود ذات الطابع السيادي، أو المرتبطة بالتزامات دولية، أو التعاقدات الممولة بقروض، أو منح خارجية.

وتلعب دورا كبيرا في الرقابة وحماية المال العام وضمان الشفافية.



ويراد بالرأي الاستشاري في مجال إبرام العقود الإدارية: إجراء شكلي تحصل جهة الإدارة المختصة بمقتضاه وقبل إبرام العقد على رأى معين بشأنه من خلال المشورة والنصيحة والرأي القانوني من هيئة أو إدارة أخرى، تعرف عادة بالهيئة الاستشارية أو الإدارة الاستشارية.

وقد يقصد به: رأي أو دراسة فنية أو مالية وفق طبيعة موضوع العقد وقيمته، أو قانونية تخص الصياغة القانونية للعقد، أو تمكن جهة الوصاية من ممارسة حقها في الرقابة السابقة<sup>(١)</sup> تجريبها الإدارة، أو تكلف بها الجهات المختصة، قبل الدخول في مرحلة الإعلان أو التفاوض أو الترسية؛ بهدف التأكد من جدوى التعاقد، وتحديد مواصفاته.

بعكس الدراسات الاستشارية أحد موضوعات العقد الإداري، التي تبرم عن طريق المناقصة. وعرفها المشرع: "ما يغلب عليه الطابع الفكري أو الإرشادي، ومن ذلك: الدراسات الهندسية أو المهنية أو الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القانونية، بما في ذلك مهام الإعداد أو التصميم أو الإشراف على التنفيذ أو التقييم أو الاستلام"<sup>(٢)</sup>.

## ثانيا- صور تقديم الاستشارات السابقة على التعاقد

تتخذ صوراً متعددة، بحسب طبيعتها، والغرض منها -قانوني، أو فني، أو مالي، أو اجتماعي- وما إذا كانت إلزامية إجبارية، أو اختيارية تلقائية، أو مقيدة. فالاستشارات القانونية: هدفها التأكد من صحة التكيف

(١) د/ جابر نصار: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ١٢٦. وأيضاً: د/ عمر حلمي وآخرون: المبادئ العامة، مرجع سابق، ص ٢٦٦.  
(٢) م ١ من قانون التعاقدات.

القانوني للعقد، ومدى مشروعيته، واختيار طريقة التعاقد المناسبة، أو الحلول البديلة، ومدى التزام الجهة بالضوابط القانونية، وبالأخص العقود ذات الطابع الدولي أو السيادي.

وعادة ما تختص الإدارات القانونية الداخلية بالإدارة، أو إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بها، بناء على نص فرضه القانون فتكون استشارة إلزامية. **مثال:** نص المادة (٥٨) من قانون مجلس الدولة: "...لا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة....".

**أما الاستشارات الفنية التقنية:** فعادة ما تستخدم من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة، والجامعات أو المراكز البحثية في حالات التخصص الدقيق من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة، والجامعات أو المراكز البحثية في حالات التخصص الدقيق لتحديد المواصفات الفنية الدقيقة للسلعة أو الخدمة محل التعاقد. كإعداد دراسات الجدوى الفنية، ورسومات المشروعات، ووصف الأعمال المطلوبة.

**مثال:** يتعين على جميع الجهات الحكومية أو القطاع العام التي ترغب في شراء أو تأجير أو استخدام الحاسبات الإلكترونية وحزم البرامج الجاهزة اللازمة لها استشارة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في جميع مراحل دراسة الجدوى، والاستخدام والتعاقد على الأنظمة المذكورة

وعرض النتيجة على الوزير الذي تتبعه الجهة الطالبة لتقرير ما تراه<sup>(١)</sup>.  
والاستشارة هنا إلزامية إجبارية، فرضها القانون على الإدارة.

وأما الاستشارات المالية والاقتصادية: فتشمل التأكد من وجود اعتماد مالي كافٍ، وتقدير التكلفة الإجمالية للتعاقد، وتحديد التقديرات المالية الأولية، ومقارنة التكلفة بالعائد، وتحليل العروض المتوقعة. وقد تشمل تحليل السوق ومؤشر الأسعار.

ويكون من خلال الإدارة المالية، أو وزارة المالية، أو لجنة التخطيط والموازنة داخل الجهة. والاستشارة هنا قد تكون إلزامية أو اختيارية حسب طبيعة العقد وموضوعه.

وأما الاستشارات البيئية والاجتماعية: وعادة ما تكون عند الطلب في المشروعات ذات الأثر البيئي، والتي تشترط دراسة تقييم الأثر البيئي قبل الطرح وفقاً لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته. وهي هنا اختيارية حسب طبيعة العقد، ورغبة الإدارة وتعرف بالاستشارة الحرة.

### ثالثاً: الطبيعة القانونية للاستشارات السابقة وجزاء مخالفتها

يوجد خلاف فقهي حول تحديد طبيعتها القانونية على رأيين: الأول: ويعتبرها من قبيل الإجراءات التمهيدية أو التحضيرية، التي لا تلزم الإدارة قانوناً، ولا ترقى إلى مرتبة القرار لكونها اختيارية، ما لم يرد بها نص واضح صريح يلزم الإدارة باتباعها.

---

(١) المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٢ بشأن استخدام الأجهزة الحكومية والقطاع العام للحاسبات الإلكترونية.

أما الرأي الثاني والراجح، فبراها إجراءات وجوبية إذا نص عليها القانون أو اللائحة، وإلا اعتبر التعاقد معيباً شكلياً، قد يُبطل أو يوقف تنفيذه.  
وإن كان طلب الرأي أو الاستشارة يجب الحصول عليه قبل إبرام العقد، أو قبل توقيعه إلا أن جهة الإدارة لا تكون ملزمة في جميع الأحوال باتباع ما قرره الفتوى في موضوع العقد، على اعتبار أن رأي الفتوى استشاري غير ملزم، حتى وإن اشترطها المشرع، وطلب أخذ إدارة الفتوى مسبقاً بشكل ملزم<sup>(١)</sup>.

ويترتب على مخالفة شرط الاستشارة الإلزامية قبل إبرام العقد بطلان القرار الصادر من الإدارة، حتى ولو كانت الاستشارة في موضوعها غير ملزمة. وإذا تم إبرام العقد فإنه يكون قد اكتمل من حيث الوجود القانوني مما يمتنع معه إثارة أية نقاط تعاقدية قد تكون في غير صالح الإدارة المتعاقدة من جانب مجلس الدولة لاحقاً؛ لأن الرجوع عن بعض المسائل التي يحكمها العقد بعد إبرامه قد يأخذ حكم النكول عن الالتزامات العقدية، مما يثير المسؤولية التعاقدية للإدارة<sup>(٢)</sup>.

**خامساً: مدى استشارة مجلس الدولة بعد إبرام العقد الإداري:** يعتبر مجلس الدولة - وفقاً لنص المادة (١٩٠) من دستور ٢٠١٤ - جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه،.. ويتولى.. ومراجعة

(١) د/ جابر نصار: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ١٢٧.

(٢) د/ رمضان بطيخ: قيود إبرام العقد، مرجع سابق، ص ٤.

مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها..".

أما بالنسبة لطلب أخذ رأي مجلس الدولة أو استشارته بعد إبرام العقد وقبل أخذ الرأي أو الإجراء الاستشاري من الإدارة المختصة-وفقاً لما أفتت به في بادئ الأمر- يؤدي إلى بطلان العقد؛ لمخالفته لصريح النص القانوني. مما سيؤدي إلى زعزعة الثقة بالإدارة، بشكل ينعكس سلباً على سير المرفق العام<sup>(١)</sup> بانتظام واطراد.

وهو ما استدركته الجمعية العمومية لاحقاً فأفتت: (أن البطلان الذي يصيب العقد الإداري في الحالة السابقة لا يتقرر إذا تم إبرام العقد في الأحوال الاستثنائية وفي حالات الضرورة، ولم يكن في مخالفة هذا الإجراء فوات لمصلحة عامة كبرى... كما اقتضت ظروف طارئة إبرام عقد في بلد أجنبي، وكانت الظروف لا تسمح بالرجوع إلى المجلس وكانت المصلحة العامة تقتضي عدم فوات فرصة إبرام العقد، فإن مثل هذه الضرورة يكون لها وزنها بحيث يعتبر إبرام العقد في هذه الظروف أمراً استثنائياً... ومن ثم ليس هناك ما يمنع من إبرامه على مسئولية موقعة، ويكون في هذه الحالة عقداً صحيحاً).

وإنه وإن كان رأي الفقه واستدراك الجمعية العمومية ينطويان في واقع الأمر على وجهة ومنطقية، إلا أنهما يصطدمان مع صراحة النص

---

(١) د/ رمضان بطيخ ، مرجع سابق، ص ٥.

الملزم بهذه الاستشارة والذي لم يستثن أي نمط من العقود من حكمه، وبالتالي فإن القول بصحة العقد رغم عدم استفتاء مجلس الدولة تذرعا بحالات الضرورة وعدم فوات مصلحة عامة كبرى سوف يؤدي إلى إفراغ نص المادة (٥٨) من قانون مجلس الدولة من غايته ومحتواه، وخصوصا في ظل غياب أي معيار للفرقة بين المصلحة العامة الكبرى وغيرها. لذا يرى بعض الفقه-ونحن معه- ضرورة تعديل النص بما يجعله محققاً للتوازن أو التلاؤم بين المصلحة العامة وبين تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً<sup>(١)</sup>.

ولكن، هل يلتزم مجلس الدولة بمراجعة العقد الإداري بعد إبرامه أم لا؟ يجب الفرقة بين حالتين طلب المراجعة بعد الإبرام وقبل تنفيذ العقد، وطلبها أثناء تنفيذه<sup>(٢)</sup>.

أما الحالة الأولى: ففيها نفرق بين أمرين:

الأول: إذا كان الطرفان قد اتفقا في العقد على قبول أية تعديلات يرى مجلس الدولة إدخالها عليه فحينئذ يجوز امتثالاً للضرورات العملية مراجعة العقد من الناحية القانونية؛ لأن الضرورات العملية تقدر بقدرها ويترك تقديرها لجهة الاختصاص بمجلس الدولة.

يؤكدته فتواها: " الأصل أن مراجعة مجلس الدولة هي مراجعة قانونية فقط قبل التعهد أو الالتزام، لا تمتد إلى التقدير والملائمة في العقد محل

---

(١) د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص ٥٥.  
(٢) للمزيد: د/ رمضان بطيخ: المرجع السابق، ص ٦.

المراجعة،... ومن حيث إنه في الحالة المعروضة اقتضى الأمر سرعة توقيع العقد في الخارج ولم تتراخ الإدارة في عرض الأمر على إدارة الفتوى فإنه والحالة هذه يجوز مراجعة العقد من الناحية القانونية مع ملاحظة أن هذه المراجعة لا تضي على إجراءات وبنود العقد الشرعية والصحة إذا كانت قد فقدتها، ولا تظهره من المخالفات التي شابت إبرامه أو بنوده أو تجبرها، إنما تكشف عنها وتضعها تحت بصر الجهة الإدارية، وبما يستتجبه ذلك من إعادة النظر في العقد بالتحلل منه كله أو بعضه على ضوء ما أسفرت عنه هذه المراجعة<sup>(١)</sup>.

**والأمر الثاني:** إذا كان الطرفان لم يتفقا في العقد على قبول أية تعديلات يرى مجلس الدولة إدخالها - فهذا يغدو من غير الملائم مراجعة العقد. كما يجب التفرقة أيضا بين أمرين في الحالة الثانية:

الأول: أن العقد قد انقضى بتمام تنفيذه، مما يفقد جدواه من المراجعة؛ لنفاذ الغرض منها، وهو أن تقف جهة الإدارة على حكم القانون قبل التعهد أو الالتزام، أما وأنها قد تعاقدت والتزمت وانقضى العقد بتمام تنفيذه فلا يكون من وجه لطلب مراجعة العقد. وقد أفتت: "...ومن المقرر في إفتاء الجمعية العمومية أن اكتمال تنفيذ العقد يجعل من غير الملائم مراجعة العقد<sup>(٢)</sup>". كما أن عدم وجود موافقة من المتعاقد مع الجهة الإدارية على قبول ما يدخله مجلس الدولة وتعديلاته على العقد يجعل

(١) فتوى الجمعية العمومية الصادرة في جلسة ١٩٩٨/١/٢١، السابق الإشارة إليها.  
(٢) فتوى رقم ١١٩ في ١٩٩٢/١/٢٧، ملف رقم ٢٩٢/١/٥٤، المستشار د/ محمد أبو العينين، مرجع سابق، ص ٧٩١.

من غير الملأئم مراجعته<sup>(١)</sup>. ومن ثم يجب النص في العقد على العمل بالتعديلات التي يدخلها مجلس الدولة. وأنه المختص بأية منازعات تنشأ عن تنفيذه<sup>(٢)</sup>.

الأمر الثاني: أن العقد قد بدئ في تنفيذه دون تمامه: فهذا يجب على إدارة الفتوى بمجلس الدولة- وإن أصبح إبرام العقد أمراً واقعاً- أن تراجع من الناحية القانونية؛ لإبداء ما عساه يوجد فيه من ملاحظات، والجهة المتعاقدة وشأنها في تدارك ذلك إن أمكن مع الطرف الآخر من عدمه.

## المبحث الثاني

### الإعلان أو الدعوة للتعاقد

يجب النشر -وفقاً لمبدأ العلانية والنشر السابق ذكره- عن العمليات التي يتم طرحها بجميع طرق التعاقد المقررة بالمادة (٧) من القانون على بوابة التعاقدات العامة، عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي عدم النشر عنها وفقاً لما تقرر السلطة المختصة. وقد نظم المشرع أحكام وإجراءات الطرح الإعلان أو الدعوة في م ٢٠ من قانون التعاقدات، وم ٣٧ من لائحته التنفيذية. واستلزم أن يتضمن النشر طريقة التعاقد ومبرراتها، وشروطه، وغيره مما فصلت فيه اللائحة وبينت محتويات الإعلان أو الدعوة. سبق عرضه ونحيل إليه منعاً للتكرار.

---

(١) فتوى رقم ٤٩١ في ١٦/٧/١٩٩٤، جلسة ١٦/٧/١٩٩٤، ملف رقم ٣٢٤/١/٥٤، المستشار د/ محمد أبو العينين، المرجع السابق، ص ٧٩١.  
(٢) فتوى الجمعية العمومية رقم ٤٩٠ في ٣٠/١٠/١٩٩٥، السابق، ص ٨٠٢.



وإذا لم يتم الإعلان عن المناقصة أو الدعوة للتعاقد مع الإدارة، أو لم تتبع الإجراءات والشروط القانونية المقررة في الإعلان أو النشر أو الدعوة فإن ذلك يعيب المناقصة، ويجوز لذوي الشأن الطعن في قرار الترسية أمام القضاء الإداري، على اعتبار أن قضاء العقود الإدارية ينتمي أساساً إلى القضاء الكامل، ويكون للمحكمة أن تنظر ما يكون قد صدر بشأنها من إجراءات وقرارات، باعتبارها من العناصر المتنازعة الأصلية في حدود اختصاصها الكامل<sup>(١)</sup>.

### المبحث الثالث

#### التأهيل المسبق ومعرفة قدرات المتعاقد مع الإدارة

هو: "إجراء جوازي تتخذه الجهة الإدارية، وتعلن عنه؛ للتأكد من توافر القدرات الفنية والإمكانات المالية والإدارية والبشرية وغيرها لدى الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أو الاستشاريين، للقيام بتنفيذ أحد العقود بالكفاءة المطلوبة قبل دعوتهم لتقديم العطاءات، وذلك وفقاً لمتطلبات ومعايير التقييم المحددة بمستندات طلب التأهيل المسبق<sup>(٢)</sup>.

ويتم الإعلان عنه على بوابة التعاقدات، وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار. وقد نظمت أحكامه م ٢١ من القانون، وبينت اللائحة قواعده وبياناته، واللجنة، ومعاييره للعمليات ودراسة طلبات التأهيل المسبق<sup>(٣)</sup>.

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا ١٣٢٦-٣٣، جلسة ١٩٩٥/١/٢٤، ٤٠، مجموعة المبادئ، مرجع سابق، ص ١٢٥.

(٢) م ١ من قانون التعاقدات.

(٣) المواد (٣٨: ٤١) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

## المبحث الرابع

### آلية تقديم العطاءات

"تقدم العطاءات في مظاروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، وتلتزم الجهة الإدارية بالحصول على إقرار من مقدم العطاء<sup>(١)</sup> يضمنه بمظروفه الفني يفيد التزامه بالتأمين على العمالة وفقا لقوانين التأمينات السائدة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك. وقد أوضح المشرع في القانون واللائحة الأحكام المتعلقة بتقديم العطاءات، من حيث إعدادها وحفظها، ومن الذي يتحملها، وتسليمها، ومدتها، وتعديل مدة تقديم العطاءات، وحفظ العطاءات والعينات<sup>(٢)</sup>.

كما تناول بالقسم الخامس الأحكام الخاصة بحظر التقدم بأكثر من عطاء، وحظر تعديله، والفصل في الخلاف بين أعضاء اللجنة، وإيضاح أسباب عدم قبول بعض العطاءات<sup>(٣)</sup>.

وأما عن أهم الأحكام القانونية المتعلقة بالعطاءات: فتتمثل في الآتي:

١- يتحمل صاحب العطاء<sup>(٤)</sup> وحده دون مسئولية الجهة الإدارية أية تكاليف؛ لإعداد وتقديم عطاءه، وكل ما يتعلق به من مهام، بغض النظر عن نتيجة العملية.

---

(١) المادة (٢٣) من قانون التعاقدات. وعرفت م ١ منه مقدم العطاء بأنه: صاحب العطاء ذاته، أو من يفوضه في تقديم عطاءه للجهة الإدارية الطارحة.  
(٢) المواد (٤٤ : ٤٨) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.  
(٣) المواد (٨٣ : ٨٦) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.  
(٤) هو كل شخص طبيعي أو معنوي، يقدم عرضا بغرض التعاقد مع الجهة الإدارية الطارحة وفقا لأحكام قانون التعاقدات ولائحته التنفيذية.

٢- طريقة وشروط تقديم العطاءات، تتلخص في الآتي<sup>(١)</sup>:

٢/١- تقدم العطاءات موقعة من صاحبها وفقا للشروط المحددة بمستندات الطرح.

٢/٢- يجوز التفويض في تقديم العطاءات، ويشترط تقديم التفويض أو التوكيل الدال على ذلك.

٢/٣- يجب أن يكون صاحب العطاء أو المتزايد من المصرح لهم بالعمل وفقا للقوانين المصرية، أو له ممثل رسمي فيها لديه كافة الإمكانات، وقادر على تنفيذ كافة التزاماته الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وعنوان مخاطبته وإعلامه.

٢/٤- يجب تقديم العطاءات على نموذج العطاء المدرج بكراسة الشروط.

٣- تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين، للعرض الفني، والآخر للعرض المالي.

٣/١- يجب أن يثبت على كل من مظروفي العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج.

٣/٢- يوضع المظروفان داخل ظرف مغلق بطريقة محكمة.

٣/٣- يوضح على المظروف بيانات: اسم الجهة الإدارية، وعنوان إدارة التعاقدات وما يفيد أن ما بداخله المظروف الفني والمالي، ويذكر اسم العملية ورقمها وتاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية واسم صاحب العطاء.

---

(١) المادتين (٢٣) من قانون التعاقدات، و(٤٤) من اللائحة التنفيذية. وغيرها مما سبق.

٣/٤- تلتزم الجهة الإدارية بالحصول على إقرار من مقدم العطاء يضمنه بمظروفه الفني يفيد التزامه بالتأمين على العمالة وفقا لقوانين التأمينات حسب طبيعة العملية<sup>(١)</sup>.

٣/٥- تسلم العطاءات من صاحبها، أو من يفوضه، قبل التاريخ، أو الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية في الجلسة العلنية العامة إما باليد مع توقيع إدارة التعاقدات على إيصال يفيد الاستلام يحدد به موعد وتاريخ استلام العطاءات. أو عن طريق البريد السريع من خلال الهيئة القومية للبريد، أو عن طريق الوسائل الإلكترونية إذا ما سمحت بذلك شروط العملية، مع توقيع موظف الإدارة على إيصال الهيئة بالاستلام والاحتفاظ بصورة منه.

٣/٦- يتم تحديد مدة تقديم العطاءات حسب طريقة التعاقد الأصلية أو الاستثنائية. مع إعطاء الوقت الكافي لأصحاب العطاءات لدراستهم لكراسة الشروط والمواصفات، واستيفاء المستندات اللازمة لتقديم عطاءاتهم ووفقا لطبيعة وحجم العملية محل الطرح.

ويجوز لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية، أو جلسة المزايدة بثلاثة أيام على الأقل أن يتقدم لإدارة التعاقدات بطلب كتابي مسبب لمد مدة تقديم العطاءات، على أن تعرض إدارة التعاقدات على السلطة المختصة نتيجة دراستها والحصول

---

(١) م ٢٣ من قانون التعاقدات.

على موافقتها حال اقتراح مد المدة، وتأجيل موعد فتح المظاريف أو المزايدة بحسب الأحوال، أو الأسباب التي تراها مناسبة لعدم التأجيل. ويجوز للجهة الإدارية إذا ارتأت ضرورة، أن تقوم بتأجيل أو مد موعد تاريخ فتح المظاريف أو المزايدة ، بحسب الأحوال. بشرط موافقة السلطة المختصة، وإعادة النشر على بوابة التعاقدات، والاعلان أو توجيه الدعوات بحسب الأحوال. على ألا تقل مدة التأجيل أو المد عن نصف المدة المحددة مسبقا لفتح المظاريف الفنية من تاريخ الإعلان أو الدعوة. ويعد تقاعس وإهمال الموظف المختص عن عدم طلب مد مدة صلاحية سريان العطاءات مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته بالجزاء المناسب<sup>(١)</sup>.

ولا يجوز لصاحب العطاء أو من يمثله بعد تسليم العطاء شطب أي بند من بنود العطاء، أو من المواصفات الفنية، أو إجراء تعديل فيه، مهما كان نوعه. وإذا ما رغب في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فعليه أن يثبتها في كتاب مستقل، ويسلمها لإدارة التعاقدات قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية.

ويبقى العطاء نافذ المفعول، وغير جائز الرجوع فيه من وقت تسليمه بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجهة الإدارية، وحتى نهاية مدة سريان العطاءات. ومن ثم حظر المشرع تعديل العطاء بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية.

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٧٥٥٧ لسنة ٥٦ ق. عليا، جلسة ٢٠١٣/٢/١٨. المستشار د/محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ١٠٨٣.

٤- تأكد إدارة التعاقدات من أن جميع العطاءات والعينات المستلمة محفوظة بطريقة آمنة لا تسمح بالاطلاع على مضمونها أو فتحها، ولو بطريق الخطأ.

ويحظر فتحها قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف. ولا يجوز الكشف عن عددها، أو أية معلومات بشأن أصحابها قبل انعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية.

ويتعين على مدير إدارة التعاقدات تسليم العينات لإدارة المخازن لحفظها، بشرط التعامل معها بطريقة سرية ومضمونة لا تؤدي إلى الكشف عن خصائصها قبل فتح المظاريف.

### المبحث الخامس

أحكام الوفاة والتعاقد من الباطن والفئات المحظور تعاملها

أولاً: الأحكام القانونية الخاصة بوفاء صاحب العطاء

قد يحدث أثناء تنفيذ إجراءات مرحلة الطرح وفاة صاحب العطاء، عندئذ أجاز المشرع<sup>(١)</sup> للسلطة المختصة بعد عرض إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية اتخاذ قرار بواحد مما يلي:

١- استبعاد العطاء المقدم من صاحب العطاء المتوفي ورد التأمين.

٢- أو السماح للورثة بالاستمرار في الإجراءات؛ بشرط أن يعينوا عنهم وكيلًا بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه، وتوافق عليه السلطة.

---

(١) المادتين ٢٤ من قانون التعاقدات، والمادة ٥٥ من لائحته التنفيذية.

ويظل الوكيل دون غيره هو المسؤول أمام الجهة الإدارية عن تنفيذ الإجراءات؛ استنادا إلى أن فكرة الاعتبار الشخصي تعد أحد العناصر الجوهرية في مجال العقد الإداري كغيره، حيث إن لشخصية المتعاقد مع الإدارة بذاته أو بصفته محل اعتبار عند التعاقد، أو عند تنفيذ العقد<sup>(١)</sup>.

### ١/أولا- وفاة المتعاقد أثناء تنفيذ العقد

يحق للجهة الإدارية في حالة وفاة المتعاقد أثناء تنفيذ العقد إنهاء العقد، ورد التأمين النهائي للورثة ما لم يكن لها مطالبات قبل المتعاقد، ويجوز السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد<sup>(٢)</sup>، وفق الأحكام التالية:

١- تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لحصر الأعمال المنجزة بعد وفاة المتعاقد، وتحديد تكلفتها والمبالغ المنصرفة حتى تاريخ الوفاة، والمبالغ المتبقية له والأعمال المتبقية في العقد، ويدعى لحضور أعمال اللجنة ممثل عن ورثة المتوفى.

٢- السماح للورثة أو ممثلهم حال تقديمه طلب بالاستمرار في تنفيذ العقد، بشرط توافر المقدرة الفنية والمالية للاستمرار بذات الشروط والمواصفات المحددة به، وأن يعينوا عنهم وكيلًا خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الوفاة لإتمام غير المنفذ من الأعمال.

---

(١) أحمد محمد هزاع: الاعتبار الشخصي وأثره في تنفيذ العقد الإداري، مجلة القراءة والمعرفة، مصر، ع ١٣٤، ديسمبر ٢٠١٢م، ص ١٤٧.

(٢) المادة (٥٢) من قانون التعاقدات، المادة (١٠٣) من اللائحة التنفيذية.

وفي حالة عدم مقدرتهم أو عدم رغبتهم في إتمام العقد يتم محاسبتهم وتنفيذ الجزء المتبقى عن طريق طرح عملية أخرى وفقا للمقرر قانونا<sup>(١)</sup>.

## ٢/أولا-حكم التعاقد مع أكثر من متعاقد وتوفي أحدهم:

إذا كان العقد مبرما مع أكثر من متعاقد كشريك وتوفي أحدهم<sup>(٢)</sup>، جاز للجهة الإدارية إنهاء العقد مع رد التأمين النهائي ما لم يكن لها مطالبات أو السماح لبقية المتعاقدين الشركاء بتنفيذ بنود العقد.

ويحصل الإنهاء في جميع الحالات السابقة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى أو اللجوء إلى القضاء.

## ثانيا: الأحكام القانونية الخاصة بالتعاقد من الباطن

يقصد به: "كل من يعهد إليهم صاحب العطاء، وتحت مسؤوليته ببعض بنود العملية محل التعاقد، على أن يتضمن عطائه بياناتهم وخبراتهم، شريطة موافقة الجهة الإدارية عليهم وفقا للمحددات والاشتراطات والنسب الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك في كافة أنواع العقود المنصوص عليها في القانون"<sup>(٣)</sup>.

وقد أجاز المشرع<sup>(٤)</sup> التعاقد من الباطن وأذن للجهة الإدارية بأن تسمح لصاحب العطاء أن يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيره من الباطن، على ألا تمثل تلك البنود الجانب الأكبر أو الجوهري من

(١) المادة (١٠٣) من اللائحة التنفيذية.

(٢) حذفت عبارة: "وكانت له حصة تسمح بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بتنفيذ العقد" من نص اللائحة.

(٣) المادة (١) من اللائحة التنفيذية.

(٤) المادتين ٢٥ من قانون التعاقدات، والمادة ٥٦ من لائحته التنفيذية.



العملية، وذلك بناء على دراسة موثقة تعدها إدارة التعاقدات من واقع دراستها للسوق، ووفقا لطبيعة العملية وتعتمدها السلطة المختصة ضمن إجراءات العملية، على أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات بيان تلك البنود، وأية محددات واشتراطات<sup>(١)</sup> ذات صلة وردت باللائحة.

ويلتزم المتعاقد الأصلي باطلاع من أسند بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد. ويظل المتعاقد -دون غيره- مسئولا وحده أمام الجهة الإدارية المتعاقدة عن أية أفعال أو أعمال أو أخطاء في تنفيذ العقد. وترجع مسؤوليته استنادا على فكرة الاعتبار الشخصي؛ إذ يعتبر من الأخطاء العقدية إخلال المتعاقد الشخصي في تنفيذ العقد الإداري<sup>(٢)</sup>، بإحلاله آخر محله في أداء وتنفيذ التزاماته العقدية، واكتساب حقوقه الناشئة عن العقد المبرم بينه وبين جهة الإدارة<sup>(٣)</sup>، كلية دون موافقة الإدارة، وهو ما يعرف بالتنازل عن العقد.

أو أن يقوم المتعاقد الأصلي بالتعاقد مع الغير من الباطن؛ بقصد تنفيذ جزء من محل العقد. مما يعد إخلالا بأحد العناصر الجوهرية، وأحد المبادئ المستقرة فقها وقضاء لعدم جوازه دون الحصول على ترخيص

---

(١) المادة ٥٧ من اللائحة التنفيذية.

(٢) إبراهيم الشارف الطاهر تفوقه: الصعوبات التي تواجه تنفيذ العقد الإداري - دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ٢٠١١، ص ٩٥ - ١١٤.

(٣) د/ محمد سعيد حسين أمين: الأسس العامة للالتزامات وحقوق المتعاقدين مع الإدارة في تنفيذ العقد الإداري، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية حقوق عين شمس، ١٩٨٣، القاهرة، ص ١٥٨.

مسبق من الإدارة<sup>(١)</sup>، وهما للاعتبارات والصفات الشخصية الخاصة بخبرة المتعاقد، وكفاءته الفنية، وملاءته المالية، وحسن سمعته، وسيرته. وقد قضت بأنه: (... من المسلمات أن يقوم المتعاقد بنفسه بالتنفيذ فالتزامات المتعاقد مع الإدارة التزامات شخصية لا يجوز له أن يحل غيره فيها أو أن يتعاقد بشأنها مع الغير من الباطن إلا بموافقة الإدارة، فإذا حصل التنازل عن العقد بدون موافقة الإدارة،... فإن التنازل يعتبر باطلاً ولا يحتج به في مواجهة الإدارة فلا تنشأ بين المتعاقد من الباطن وبين الإدارة أي علاقة- ويبقى المتعاقد الأصلي مسؤولاً في مواجهة الإدارة في كلتا الحالتين)<sup>(٢)</sup>.

### ثالثاً: الفئات المحظور عليها التعاقد والتقدم بعطاءات

حرصاً من المشرع على تحقيق أهداف قانون التعاقدات، والحفاظ على المال العام، ومصلحة المرفق والصالح العام، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، وتجنب تعارض المصالح، وعدم التزحيز من الوظيفة العامة، والإثراء بلا سبب، وعدم استغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استعمال السلطة لتحقيق أهداف ومآرب شخصية خاصة، واحترام أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في

---

(١) د/ عبد المجيد فياض: نظرية الجزاءات في العقد الإداري، مرجع سابق، ص ١٢٦.  
(٢) حكمها في الطعن رقم ١١٠٩ لسنة ٨ق، جلسة ١٩٦٣/١٢/٢٨، مكتب فنى ٢٩/٩، ص ٣٢٤، مجموعة المبادئ، مرجع سابق، ص ٣٢٠.

الدولة<sup>(١)</sup>، والقواعد الحاكمة للسلوك الوظيفي والمهني، حدد في المادة (٢٦) من قانون التعاقدات بعض الفئات المحظور عليها التقدم بعطاءات، وحصرهم في فئة الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون التعاقدات، فحظر عليهم التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات، أو عروض لذات الجهات التي يعملون بها. بل ولا يجوز شراء أصناف منهم، أو تكليفهم بأعمال.

كما يحظر عليهم الدخول بالذات أو بالواسطة في المزايدات بأنواعها، إلا إذا كانت الأصناف المشتراة لاستعمالهم الخاص، وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات إدارية أخرى غير جهة عملهم، ولا تخضع لإشراف هذه الجهة.

واستثناء لا يسري حظر التعاقد مع أحد الموظفين أو العاملين بالجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون التعاقدات ولائحته التنفيذية في مجال المؤلفات العلمية والأعمال الفنية، حيث يجوز التعاقد معهم على شراء كتب من تأليفهم، أو تكليفهم بأعمال فنية، أو شرائها منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية، وسريان العطاءات عليهم.

---

(١) الجريدة الرسمية، العدد ٤٥ مكرر (أ)، في ١٣ نوفمبر سنة ٢٠١٣. ويقصد بالمسئول الحكومي: "كل شخص يشغل أحد المناصب أو الوظائف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين". أما الشخص المرتبط فهو: "كل شخص تربطه بالمسئول الحكومي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، والشركات التي يساهمون فيها أو يديرونها".

ويتعين عند التعاقد مع أحدهم مراعاة الحدود والضوابط التالية<sup>(١)</sup>:

- ١- إتاحة الفرصة لموظفي الإدارة وغيرهم لتقديم عروضهم.
- ٢- أن تكون المؤلفات العلمية والأعمال الفنية المطلوبة ذات صلة بالأعمال المصلحية.
- ٣- عدم وجود من يمكنه أداء العمل المطلوب من بين الموظفين أو العاملين ويدخل في نطاق أعماله الوظيفية.
- ٤- ألا يدخل العمل المطلوب ضمن الاختصاص الوظيفي للموظف أو العامل ولا يعتبر امتدادا له.
- ٥- ألا يشاركوا بأي صورة من الصورة في إجراءات قرار الشراء أو التكليف وأن يتم كل منهما في الحدود والقواعد والإجراءات المقررة قانونا.
- ٦- الحصول على الموافقة اللازمة من السلطة المختصة فيما لا يجاوز عشرين ألف جنيه، وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للخدمات فيما يزيد. وبالنسبة للكتب الدراسية فيكون لوزير التربية والتعليم سلطة الموافقة على شرائها طبقا لأحكام اللائحة، ما لم يكن الموظف أو العامل قد باع حق الطبع والنشر إلى مكتبة أو فرد بعقد ثابت التاريخ قبل الشراء بستة أشهر على الأقل.

شروط شراء حق المؤلف أو الطبع أو النشر من موظفي الإدارة<sup>(٢)</sup>:

- ١- أن يكون المؤلف وثيق الصلة بأعمال الجهة الإدارية.

---

(١) المادة (٢٦) من قانون التعاقدات، والمادة (٥٨) من لائحته التنفيذية.  
(٢) المادة (٥٨) من لائحته التنفيذية.

- ٢- وأن تكون الحاجة ماسة إلى الحصول عليه.
- ٣- وألا تقل النسخ اللازمة منه عن ثلاثة آلاف نسخة- ما لم يكن المؤلف قد وضع خصيصة بناء على طلب الجهة الإدارية فيجوز عند الضرورة أن يقل العدد عن ذلك.
- ٤- يشترط قيام لجنة تشكل من اخصائيين في المادة التي تناولها المؤلف بفحص الكتاب وتقدير قيمته العلمية واقتراح المبلغ الذي تقدره مقابل هذا الشراء على أن يراعي عدد النسخ المطلوبة، ومدة الانتفاع.
- ٥- يصدر بالشراء قرار من السلطة المختصة فيما لا يجاوز عشرين ألف جنيه وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للخدمات فيما يزيد على ذلك.
- ٦- يكون شراء حق التأليف أو الترجمة أو الطبع أو النشر بالنسبة إلى الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

## الفصل الثالث

### القيود والإجراءات المقررة في مرحلة الترسية وإبرام العقد الإداري

تعد مرحلة الترسية من أهم مراحل إبرام العقد الإداري، حيث يعلن فيها صاحب العطاء الفائز؛ باعتباره العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً، أو العطاء الذي يتم ترجيحه وفقاً لنظام النقاط المحددة أسسه وعناصره والوزن النسبي بشروط الطرح، والذي تم إخطاره بترسية العملية عليه. وانتقل بعدها إلى صفة المتعاقد، وتبعاً له يقوم بسداد التأمين النهائي<sup>(١)</sup>. ويسبق هذا الإعلان أن تتحقق الجهة الإدارية من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة فيمن يتم التعامل معهم، وغيرها من المعايير الموضوعية<sup>(٢)</sup>، وأن تتخذ إجراءات البت الفني، بفتح المظاريف الفنية، وآلية التعامل مع العطاء المتأخر، والتعامل مع العينات، والفحص الشكلي وتفرغ العروض الفنية، ودراساتها، واستيفاءها والاستيضاح بشأنها. والبت الفني، وإعلان نتائجه<sup>(٣)</sup>.

كما تقوم بإجراءات البت المالي، بفتح المظاريف المالية لأصحاب العطاءات المقبولة عروضهم الفنية، وتفرغ ومراجعة العروض المالية، ودراساتها وتقييمها، واستيفاءها والاستيضاح بشأنها، والتقييم بنظام النقاط،

---

(١) المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.  
(٢) المادة (٣٢) من قانون التعاقدات.  
(٣) المواد (٦٢: ٦٩) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

ومقارنة العطاءات بالقيمة التقديرية، وحكم العرض المالي منخفض القيمة، ودراسة قرار الإلغاء أو الترسية، وإعلان نتائج البت المالي<sup>(١)</sup>. وتأتي مرحلة الترسية بعدها، واختيار صاحب العطاء الفائز. ومطالبته بسداد التأمين النهائي وأثر عدم سداد، وبيان صور التأمين النهائي وأدائه واستبداله، ويتبعه حظر التقدم بأكثر من عطاء، وحظر تعديل العطاء، والفصل في الخلاف بين أعضاء اللجنة، وإيضاح أسباب قبول بعض العطاءات<sup>(٢)</sup>.

وتعد الكتابة والعلانية في إجراءات البت الفني والمالي أحد الضمانات اللازمة، لنزاهة عملية البت في المناقصة أو المزايدة بجميع صورها، وعدم التلاعب فيها<sup>(٣)</sup>.

وأيا كان، سوف نتناول أهم تلك الأحكام في المباحث التالية:

---

(١) المواد (٧٠: ٧٨) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.  
(٢) المواد (٧٩: ٨٦) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.  
(٣) د/ جابر نصار، العقود، مرجع سابق، ص ١٥٨.

## المبحث الأول

### قيود وإجراءات فتح مظاريف العطاءات

يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيا فقط دون غيرها. حيث يقوم مدير إدارة التعاقدات بتسليمها لرئيس لجنة فتح المظاريف المالية بعد التحقق من سلامتها، ووجود رقم العطاء، وتوقيع أعضاء اللجنة السابق إثباته على كل مظاروف بجلسة فتح المظاريف الفنية.

ويكون الفتح في الوقت والمكان المحددين بكراسة الشروط والمواصفات، وفي جلسة علنية عامة، بحضور من يرغب من مقدمي العطاءات. ويجوز لمقدمي العطاءات تفويض من يرونه؛ لحضور جلسة فتح المظاريف، شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك.

وتقوم لجنة فتح المظاريف المالية بإعمال دورها وفق الإجراءات المقررة بالمادة (٢/٧٠) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات. مثل: فتحها بالتتابع، وكل مظاروف يفتح يثبت رئيس اللجنة عدد أوراقه التي بداخله. والتوقيع من رئيس اللجنة وأعضائها على كل ورقة بداخل المظاروف المالي. والتأشير بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح أو تحشير في الأرقام أو الإجماليات الواردة بالمظاروف المالي، والتوقيع بجانبه من رئيس اللجنة وأعضائها على هذه التأشيرات. وقراءة اسم صاحب العطاء ومحتويات المظاروف المالي على الحاضرين من أصحاب العطاءات أو



من يفوضونهم، وإرفاق المظاريف المالية وجميع الأوراق المقدمة بها بمحضر اللجنة وتسليمها لمدير إدارة التعاقدات وذلك لحفظها لديه..... وغيرها من الإجراءات.

ويكلف رئيس لجنة البت اثنين من أعضائها لمراجعة العروض المالية

بعد تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية والتوقيع عليها بما يفيد المراجعة.

وتكون نتيجة هذه المراجعة هي الأساس الذي يعول عليه في تحديد سعر العطاء، وإذا تبين وجود أخطاء حسابية فيجب تصحيحها وفقا لكل حالة. ويتعين على لجنة البت التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة، وفقا لشروط الكراسة وطبيعة العملية.

**أولاً- محتويات المظروف الفني والضوابط الواجب مراعاتها:**

يجب أن يحتوي المظروف الفني في عمليات شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية على ما يفيد سداد التأمين المؤقت المطلوب. بالإضافة إلى البيانات والمستندات المنصوص عليها بكراسة الشروط والمواصفات، وبحسب طبيعة العملية<sup>(١)</sup>.

وهو ما يختلف عن محتويات المظروف الفني المقدم في عمليات شراء أو استئجار العقارات<sup>(٢)</sup>، والمظروف الفني في عمليات الدراسات الاستشارية<sup>(٣)</sup>.

---

(١) المادة (٤٩) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.  
(٢) المادة (٥٠) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.  
(٣) المادة (١٥٧) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

**الضوابط الواجب مراعاتها عند دراسة العروض الفنية:**

يجب مراعاة كل ما ورد بكراسة الشروط، ومن أبرزها مراعاة:

(أ) مدى قدرة صاحب العطاء على الالتزام بالتوريد أو التنفيذ بالمواعيد المحددة بشروط الطرح.

(ب) الالتزام بمدة سريان العطاءات المنصوص عليها بشروط الطرح.

(ج) مدى تلبية العطاءات للمواصفات الفنية الجوهرية أو لمعايير الأداء المحددة بشروط الطرح.

(د) الالتزام بالبنود التي يجوز لصاحب العطاء أن يعهد بها إلى غيره من الباطن، وكذا المحددات والاشتراطات الأخرى ذات الصلة.

ويتعين على اللجنة في جميع الحالات أن تستطلع رأى الجهات الإدارية السابق تعاملهم معها، وإجراء الزيارات الميدانية إذا تطلب الأمر ذلك؛ للوقوف على قدرة وكفاءة أصحاب العطاءات المقدمة، وبما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

**ثانياً - محتويات المظروف المالي والضوابط الواجب مراعاتها:**

يجب أن يحتوي المظروف المالي في عمليات شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات والأعمال الفنية على ما قرره المادتين (٥٢، ٥٣) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات. والمادة (١٥٨) بشأن عمليات الدراسات الاستشارية. ويجب على صاحب العطاء عند إعدادة لقائمة الأسعار، وجدول الفئات

الخاصة بعمليات الشراء من الداخل أو الخارج مراعاة الاشتراطات المقررة قانونا في إعداد المظروف المالي، ككتابة الأسعار رقما وحروفا باللغة العربية، ومؤرخة، وموقعة من صاحب العطاء. مع عدم الكشط أو المحو أو التحوير في جدول الفئات، وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع بجانبه.

وإذا سكت صاحب العطاء في عرضه المالي عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول فيه. وغيرها. المادتين (٥٣، ٥٤) لائحة.

### ثالثا - حظر التقدم بأكثر من عطاء وجزاء مخالفته

يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة، ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء.

### ويجب على الجهة الإدارية حال مخالفة الحظر:

- أ- استبعاد العطاءات المخالفة، وأيلولة التأمين المؤقت للجهة الإدارية.
- ب- أو فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب، وأيلولة التأمين النهائي، وتحميل المتعاقد بأي خسارة تلحق بها إذا تبين لها المخالفة بعد التعاقد.
- ج- إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأي مخالفة لأحكام القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥. مع بيان المخالفة، وما يدعمها من أدلة إن وجدت، وكامل مستندات العملية.

#### رابعاً - النظام القانوني للعطاءات المتأخرة وحالات الغش أو التلاعب

يجب تقديم أي عطاء يرد بعد موعد فتح المظاريف الفنية المحدد بكراسة الشروط والمواصفات فور وروده إلى رئيس لجنة فتح المظاريف للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده دون فتحه ثم يدرج في كشف العطاءات المتأخرة، ويتم ترقيمه على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات المتأخرة.

وتستبعد لجنة البت العطاءات المتأخرة ويتم ردها إلى أصحابها بمعرفة إدارة التعاقدات خلال مدة لا تجاوز يومين من قرار اللجنة<sup>(١)</sup>.

#### الغش أو التلاعب من صاحب العطاء للحصول على العقد

يجب على لجنة البت إذا ما تبين أن صاحب العطاء قد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية للحصول على العقد<sup>(٢)</sup> اتخاذ ما يلي:

١- استبعاد عطائه.

٢- ويصبح التأمين المؤقت عند الاستبعاد من حق الجهة الإدارية.

٣- ويتم شطب اسمه من سجل المتعاملين بعد أخذ رأى إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.

٤- وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة.

---

(١) المادة (٦٣) من اللائحة التنفيذية.  
(٢) المادة (٦٦) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

## خامسا- التظلم الإداري من قرار الاستبعاد

تستبعد العطاءات من قبل لجنة البت؛ إما لعيب، أو نقص، أو قصور أصاب العطاء ذاته، أو أحد مرفقاته، أو ترجع إلى أسباب متعلقة بصاحب العطاء ذاته.

ويعد من أهم هذه الحالات: حالة العطاء المقدم ممن لم يشتروا كراسة الشروط والمواصفات، أو العطاء المقدم من أحد الأشخاص ممنوعين من التعامل، أو تقديم عطاء غير مصحوب بالتأمين المؤقت الابتدائي كاملا، أو إذا قدم العطاء متأخرا وغير مستوف لشروط قبول العطاء المتأخر، أو إذا كان العطاء مقدما من شركة باطلة غير مشهورة وفقا لأحكام القانون، أو العطاء المقدم من شخصين لا تجمعهما رابطة قانونية<sup>(١)</sup>. أو أن صاحب العطاء ليس له خبرة سابقة بالأعمال موضوع المناقصة، أو كان غير كفء ماليا وفنيا<sup>(٢)</sup>. وأيضا كان يحق لأصحاب العطاءات المستبعدة سواء في مرحلة البت الفني، أو المالي، والممنوعين من التعامل مع الجهة الإدارية التقدم بشكاوهم كتابة، سواء عن طريق الجهة الإدارية، أو مكتب شكاوى التعاقدات العمومية<sup>(٣)</sup>، والتظلم من قرار

(١) فتوى إدارة الفتوى للأزهر رقم ٩٨٧ في ١٠/١٠/١٩٩٨، ملف ٢٠/١/٦٧، المستشار د/محمد أبو العينين، العقود الادارية، مرجع سابق، ص ٣٩١.

(٢) فتوى الجمعية بجلسة ١٩٨٥/٣/٢٠، ملف رقم ٢٥٢/١/٥٤. وفتوى رقم ٣٧٣ في ١٩٨٥/٣/٣١، ص ٢٩، ٤٠، ٢٧٩.

(٣) المادة (٧٩) من اللائحة التنفيذية. وقد أضيفت فقرة ثانية لها بموجب قرار وزير المالية رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠٢١، نصها: "وتتولى إدارة التعاقدات فور اعتماد السلطة المختصة نشر البيانات المنصوص عليها في البند (١) من الفقرة الأولى من المادة (٤٩) من هذه اللائحة المتعلقة ببيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء الفائز والمستفيد الحقيقي منه، وذلك على بوابة التعاقدات العامة".

الإدارة باستبعادهم بناء على توصية لجنة البت خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرار<sup>(١)</sup>. ويتم نشر النتيجة فور إرسال الإخطارات في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض، ولمدة سبعة أيام. وعلى بوابة التعاقدات.

وبعد انقضاء ومرور السبعة أيام الخاصة بمدة النشر يتم إخطار أصحاب العطاءات المقبولة فنيا بموعد ومكان جلسة فتح المظاريف المالية، ما لم يكن هناك شكوى محل دراسة<sup>(٢)</sup>.

ويجب على مدير إدارة التعاقدات عقد اجتماع لمن يطلب من أصحاب العطاءات غير المقبولة بعد انتهاء أعمال لجنة البت؛ لإيضاح أسباب عدم قبولهم، وبغرض تلافيفهم الأسباب التي أدت إلى ذلك، وتحسين أدائهم في العمليات اللاحقة<sup>(٣)</sup>.

وتطبيقاً له قضت بأنه: (من المسلمات أنه كما يجوز إصدار قرارات الاستبعاد بالنسبة للمتعهدين والمقاولين كجزء بسبب العجز في تنفيذ التزام سابق يجوز أيضاً استبعاد بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم، بما يتجمع لدى الإدارة من تقدير عام عن كفاية هؤلاء وقدرتهم دون أن يسبق ذلك ارتباطهم مع جهة الإدارة في عمل ما، وذلك كإجراء وقائي تمليه غيره الإدارة توكياً للمصلحة العامة وحدها)<sup>(٤)</sup>.

(١) م ١/٦٩ من اللائحة التنفيذية.

(٢) م ٢/٦٩ من اللائحة التنفيذية.

(٣) المادة (٨٦) من اللائحة التنفيذية.

(٤) الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٦ق، بتاريخ ١٩٦٢/١٢/٢٢، سابق الإشارة إليه.

ويُفرق بعض الفقه بين قرار الاستبعاد وقرار الحرمان، فالأول إجراء موضوعي فردي يتعلق بأحد العطاءات، واستبعاده من دخول مناقصة معينة لشخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين. أما قرار الحرمان فإجراء عام يتعلق بالشخص الطبيعي أو المعنوي يهدف إلى حرمانه لفترة محدودة أو غير محدودة، وقد يكون قرار الاستبعاد نتيجة لتطبيق قرارات الحرمان الواقعة على ذات المتعاقد<sup>(١)</sup>.

سادسا - دور إدارة التعاقدات بعد إعلان نتائج البت المالي والإخطار بعد التأكد من عدم وجود أية شكاوى لم يفصل فيها، سواء عن طريق جهة الإدارة، أو مكتب شكاوى التعاقدات<sup>(٢)</sup>، ترفع لجنة البت محضرا بتوصياتها النهائية للسلطة المختصة بإرساء العملية على صاحب العطاء الفائز للاعتماد، أو تقرير ما تراه. ويتعين على إدارة التعاقدات إخطار مقدمي العطاءات بنتائج قرارات اللجان بالقبول، أو أسباب الاستبعاد، أو الإلغاء بخطابات ترسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه بالبريد الإلكتروني، أو الفاكس، بحسب الأحوال، وفقا لعناوينهم وبياناتهم، فور اعتماد السلطة المختصة لمحضر لجنة البت، وبعد انقضاء السبعة أيام المقررة<sup>(٣)</sup>. وخلال مدة لا تتجاوز يومين إخطار الفائز بترسية العملية عليه، وأصحاب العطاءات بذلك<sup>(٤)</sup>.

(١) د/ أحمد عثمان عباد: مظاهر السلطة، مرجع سابق، ص ١١٢.

(٢) المادة (٧٩) من اللائحة التنفيذية.

(٣) بالمادتين (٣٩) من قانون التعاقدات، والمادة (٦٩) من لائحته التنفيذية.

(٤) المادة (٨٠) من اللائحة التنفيذية.

## المبحث الثاني

### إصدار قرار الترسية وآثاره القانونية

#### أولاً- مضمون وبيانات إخطار الترسية

يخطر صاحب العطاء الفائز بترسية العملية عليه. بشرط أن يشتمل قرار الترسية على الأسباب التي بنى عليها. ثم ترفع لجنة البت محضرا بتوصياتها النهائية للسلطة المختصة للاعتماد أو تقرير ما تراه. وبعد إخطار الترسية إجراء تمهيدي أو عمل تحضيري لإبرام العقد الإداري، إذ لا يتم أو يكتمل إلا بعد الانتهاء من كل المراحل السابقة. ويجب أن يتضمن إخطار الترسية على البيانات الآتية:

١- طريقة التعاقد ورقم واسم العملية.

٢- تاريخ فتح المظاريف الفنية.

٣- اسم صاحب العطاء الفائز وعنوانه.

٤- قيمة الترسية.

٥- التأمين النهائي المطلوب سداذه.

ويلاحظ أنه بمجرد اعتماد نتيجة البت من السلطة المختصة، وإخطار صاحب العطاء الفائز يكون التعاقد قد تم. يؤكد حكمها بأنه: ( لكي ينتج القبول أثره وبالتالي يعتبر التعاقد تاما يتعين أن يعلم الموجب بقبول إيجابه باعتبار أن القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يتحقق وجوده القانوني ولا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه وأن العلم الذي



يعتد به في هذا الشأن هو العلم الذي يتم طبقاً للقانون أو لاتفاق الطرفين وهو في العقود الإدارية يتم بإبلاغ هذا القبول كتابة إلى صاحب العطاء-الفائز - متضمناً اعتماد عطائه وتكليفه بالتنفيذ..(١).

**ثانياً: التزام صاحب العطاء الفائز بسداد قيمة التأمين النهائي وآثاره**  
يترتب على صدور قرار الترسية إبرام العقد الإداري مع صاحب العطاء الفائز، والذي يقع عليه عبء سداد قيمة التأمين النهائي خلال المدة المحددة لذلك، وفور سداده يتم إخطاره بأمر التوريد، أو أمر الإسناد بحسب الأحوال، والموعد المحدد للتوقيع على العقد(٢).

### **مفهوم التأمين النهائي:**

عرفته المحكمة الإدارية العليا بأنه: ما يكون ضماناً لجهة الإدارة، يؤمنها الأخطاء التي قد تصدر من المتعاقد معها- كتحويل الإدارة غرامات التأخير منه، والتعويضات والمبالغ المستحقة عليه نتيجة لتقصيره أو إخلاله بتنفيذ التزامات العقد- حين يباشر تنفيذ شروط العقد الإداري. كما يضمن ملاءمة المتعاقد معها عند مواجهة المسؤوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري(٣).

ولما كان التأمين النهائي ضماناً لتنفيذ العقد، فإنه يتم الاحتفاظ به إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان طبقاً

---

(١) حكمها في الطعن رقم ١٢٤٢ لسنة ٤٥ق، جلسة ٢٠٠١/١/٩، الدائرة السادسة، المستشار د/ محمد أبو العينين، العقود، مرجع سابق، ص ٨١٨.

(٢) المادة (٨٠) من اللائحة التنفيذية.

(٣) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٨ق، بتاريخ ١٩٦٥/١/٢، مكتب فني ١٠، ص ٣١٤.

للشروط<sup>(١)</sup>. لذا قضت بأنه: "لا يمكن لجهة الإدارة أن تتجاوز عن التأمين حرصاً على مصلحة المرفق العام وانتظام سيره،... وإذا كان التأمين في حقيقته هو ضمان لتنفيذ العقد الإداري على النحو المذكور، فلا يمكن تصور قيام هذا الضمان، ما لم يكن للإدارة حق مصادرة التأمين عند وقوع الإخلال دون حاجة لإثبات ركن الضرر<sup>(٢)</sup>، أي اقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء، في حالة عدم التنفيذ، سواء نص أم لم ينص في الشروط على هذا الحق، وإلا لما كان هناك محل أصلاً لاشتراط إيداع التأمين مع العطاء.

وإذا كان التأمين ضماناً لجهة الإدارة شرع لمصلحتها، ولحمايتها، فلا يتصور منطقاً أن يكون التأمين قيداً عليها، أو ضاراً بحقوقها، أو معوقاً لجبرها ومانعاً لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للأضرار الأخرى التي تكون قد لحقتها من جراء إخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد الإداري...."<sup>(٣)</sup>.

ويتم سداد التأمين النهائي-كما سبق بالتأمين المؤقت- بأي وسيلة يصدر بشأنها قرار من وزير المالية، ومنها: وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أو بغيرها:

---

(١) المادة (١/٨٢) من اللائحة التنفيذية.  
(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٧٧٢، لسنة ٢٩ق، بتاريخ ١٩٨٥/٢/٥، مكتب فني ٣٠، ص ٥٥٩.  
(٣) حكمها السابق في الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٨ق، بتاريخ ١٩٦٥/١/٢.

١- بموجب خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة،  
وإلا يقترن بقيد أو شرط، وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر  
الجهة الإدارية مبلغا يوازي التأمين المطلوب.

وعندما يرد لإحدى الجهات الإدارية خطابات ضمان عن التأمين  
المستحق من أحد المصارف المرخص لها أو أحد فروعها إصدارها  
عليها أن تتحقق من أن المصرف أو الفرع قد أعطى إقرارا على خطابات  
الضمان بأنه لم يجاوز الحد الأقصى المعين لمجموع خطابات الضمان  
المرخص للمصرف في إصدارها.

فإذا تبين عند مراجعة الإخطارات لدى البنك المركزي أن المصرف قد  
تعدى الحد الأقصى المحدد له أخطرت الجهة الإدارية فورا لمطالبة  
المصرف بأن يؤدي إليها في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل قيمة  
خطاب الضمان.

وتقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها  
بالقبول من أحد المصارف المحلية المعتمدة على أن يتعهد المصرف  
المحلى بأن يدفع للجهة الإدارية مبلغا يوازي التأمين المطلوب وأنه ملتزم  
بأدائه بأكمله دون الالتفات إلى أي معارضة من صاحب العطاء.

٢- يجوز سداد التأمين النهائي خصما من مستحقاته الصالحة للصرف  
من عمليات أخرى في ذات الجهة الإدارية، وفي الوقت المحدد للسداد

ويكون التأمين النهائي ساريا لمدة تبدأ من وقت إصداره الى ما بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر إلا إذا اتفق على غير ذلك.

٣- ويجوز بموافقة السلطة المختصة وبناء على طلب صاحب العطاء الفائز استبدال التأمين المسدد منه بأحد صور السداد الأخرى المنصوص عليها بهذه المادة-م ٨٢ لائحة- بشرط ألا تنقطع مدة سريان التأمين، وعدم الإخلال بمسئوليته طبقا للغرض المقدم عنه التأمين. ويتم رد التأمين النهائي في الحالات المقررة قانونا بذات الوسيلة التي تم سدادها بها. وإن كان يجوز أدائه بصورة أخرى غير واردة بما يتفق عليه الجهتين، باعتبار أن صور سداد التأمين النهائي من قبيل الحالات المالية التي لا تقيد التعاقدات الخاصة، كما أن التأمين النهائي ضمان وضامن لجهة الإدارة لتنفيذ عقودها، فمن ثم تكون العلة من تقييد سداده بصورة معينة بين الجهات الإدارية قد انتقت<sup>(١)</sup>.

ويجب أن تتضمن مستندات الطرح صور سداد ورد التأمين النهائي.

### جزاء إخلال صاحب العطاء الفائز بسداد التأمين النهائي

يتعين على إدارة التعاقدات في حال عدم الالتزام بأداء التأمين النهائي خلال المدة المحددة لسدادها- بالنسبة لعقود شراء أو استئجار المنقولات، أو العقارات، أو التعاقد على مقاولات الأعمال، أو تلقي الخدمات، أو الأعمال الفنية، أو الدراسات الاستشارية عنها- ما يلي:

---

(١) فتوى الجمعية العمومية رقم ٢٠٠ بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٧، ملف رقم ٧٠٦/١/٥٤. لدى المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٥٧٢ وما بعدها.

١- إعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة باقتراح منح صاحب  
العطاء الفائز مهلة إضافية بما لا يجاوز عشرة أيام عمل<sup>(١)</sup>.  
٢- كما يتعين عليها وبما يحقق مصلحة الجهة الإدارية اتخاذ أحد  
الإجراءات<sup>(٢)</sup>:

١- إلغاء العقد.  
٢- أو التنفيذ بواسطة أحد العطاءات التالية له في الترتيب، بشرط أن  
يكون في حدود القيمة التقديرية.  
ويكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية في جميع حالات عدم  
سداد التأمين النهائي، كما يكون لها أن تخصم قيمة أية خسائر فعلية  
تلقق بها تسبب فيها صاحب العطاء الفائز.  
وفي حالة عدم كفايتها لديها؛ يتم خصمها لدى أي جهة إدارية أخرى مع  
عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه  
من حقوق بالطريق الإداري.

---

(١) المادة (١/٨١) من اللائحة التنفيذية.  
(٢) المادة (٢/٨١، ٣) من اللائحة التنفيذية.

## المبحث الثالث

### الموافقات والتصاريح اللازمة للموافقة على التعاقد

مفهومه: يقصد بالإذن والموافقات والتصاريح اللازمة ذات الصلة بموضوع الطرح: الترخيص الرسمي من السلطة المختصة أو من تفوضه، أو من الجهات المعنية وفقا للقوانين والقرارات التي تقضى بذلك<sup>(١)</sup>، باتخاذ إجراءات التعاقد نيابة عن الجهة الإدارية، بموجب قرار إداري يخول جهة إدارية معينة الحق في الشروع في التعاقد مع الغير على عملية ما، بحسب نوع الجهة، وطبيعة العقد، وقيمتها المالية، ووفقا لاحتياجات الإدارة وأولوياتها، وبعد التحقق من توافر الاعتمادات المالية، والشروط والمواصفات الفنية والقانونية وغيرها من قيود وإجراءات.

### ويشمل مضمون الإذن والموافقة والتصريح ما يلي:

- ١- الموافقة على الإجراء التعاقدي من حيث المبدأ.
  - ٢- الموافقة على المستندات الفنية والقانونية للطرح.
  - ٣- إقرار قيمة التعاقد، وتحديد وسيلة التعاقد الأصلية أو الاستثنائية.
  - ٤- إجازة تشكيل لجان الفحص والترسية، وما انتهت إليه.
- مثال: يتعين الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التعاقد وفقا للشروط والقواعد التي يعتمدها بناء على اقتراح الوزير المختص بالجهة الإدارية<sup>(٢)</sup>. وموافقة وزير الصحة للأموال واللقاحات.

---

(١) المادة (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.  
(٢) المادة (٧٢) من قانون التعاقدات.

وبعد أخذ الموافقات والتصاريح اللازمة قبل وبعد الطرح من أهم القيود الإجرائية التي يُشترط استيفائها قبل مباشرة إجراءات إبرام العقد الإداري، وأحد أبرز القيود القانونية اللازمة في مرحلة الإعداد للتعاقد، ووسيلة لضمان الرقابة المسبقة.

وبتقارب الوضع بين مصر وفرنسا مع اختلاف طفيف<sup>(١)</sup>؛ حيث لا تملك الجهات الإدارية حرية مطلقة في مباشرة إجراءات التعاقد، بل قد تُقيد بالحصول على إذن أو تصريح مسبق من الجهات المعنية المقررة قانونا قبل الشروع في إجراءات التعاقد.

كما يتعين عليها في جميع حالات الإعلان أو الدعوة أو النشر للتعاقد الحصول على موافقة السلطة المختصة، ويجوز بموافقتها الإعلان في أكثر من صحيفة مصرية أو دولية تبعا لأهمية وطبيعة العقد<sup>(٢)</sup>. بل يتعين لتعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال<sup>(٣)</sup>...الخ.

أما عن شروط صحة الموافقات والتصاريح اللازمة للعقد الإداري فتختلف بحسب موضوع وطبيعة العقد؛ باعتبارها قيد قانوني سابق، يتطلب موافقات خاصة مقررة قانونا. ويشترط لصحة الموافقات ما يلي:

- ١- أن تصدر من السلطة المختصة قانونًا.
- ٢- أن تكون مكتوبة في صورة قرار إداري، صريحة في مضمونها.

---

(١) د/ سليمان الطماوي: الأسس العامة، مرجع سابق، ص ٣٤٢.  
(٢) المادة (٢٠) من قانون التعاقدات.  
(٣) المادة (٤٦) من قانون التعاقدات.

٣- تُحدد بوضوح موضوع العقد، وطريقة إبرامه، وقيمته، ومبرراته.

٤- تستند إلى إجراءات ومستندات ودراسات تم إعدادها مسبقاً.

٥- تتم بعد التحقق من توافر الاعتمادات المالية الكافية.

٦- تقيد بمدة زمنية محددة لإتمام إجراءات الطرح والتعاقد.

### **الطبيعة القانونية لموافقات وتصاريح التعاقد:**

يعتبر أخذ الموافقات والتصاريح اللازمة إجراء تحضيرياً، وعملاً إدارياً تمهيدياً، سابقاً على التعاقد. وشرطاً جوهرياً في مشروعية الإجراءات المتخذة؛ إذ قرره المشرع بنص واضح وصريح في القانون ولائحته وإلا بطل العقد. فعدم التوقيع على العقد من السلطة المختصة يجعل الرابطة العقدية معدومة مهما سبقها من مقدمات ما لم يكن قد تم بينهما وعد بالتعاقد.

ويجمع الفقه والقضاء على أن القواعد الخاصة بالتصريح أو الإذن المسبق تعد من النظام العام؛ لقيامها على أسباب جهرية تتصل بالصالح العام اتصالاً وثيقاً، ويؤدي تخلفها إلى بطلان العقد بطلاناً مطلقاً<sup>(١)</sup>. وإلى بطلان لاحق في الإجراءات التالية، حتى وإن تم التعاقد فعلياً. إذ لا تغني الموافقة اللاحقة عن الموافقة المسبقة، وفقاً للمقرر قانوناً؛ لمخالفته أحد الإجراءات الشكلية الجوهرية. وهذا البطلان لا تصححه الإجازة حتى ولو كانت بقانون.

---

(١) د/ عمر حلمي وآخرون: المبادئ العامة، مرجع سابق، ص ٢٦٥.



وقد أفتت بأنه: (..) فإذا كانت السلطة التشريعية وهي سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية لم تعبر عن رأيها، فإن إرادة الدولة لا تكون حينئذ معيبة فحسب، وإنما تكون منعدمة إطلاقاً، إذ أن أفراد السلطة التنفيذية الممثلة في مجلس الوزراء بالتعبير عن إرادة الدولة في عقد التبرع، يعتبر منها طغياناً على السلطة التشريعية بعدم إرادة الدولة - ومتى انعدمت الإرادة التي تعتبر العنصر الأساسي في تكوين العقد كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا وجود له في نظر القانون، وإنما هو واقعة مادية بحتة، وبالتالي يسقط هذا العقد مع ما يترتب على ذلك من آثار<sup>(١)</sup>.

وتطبق عليه حينئذ أحكام السحب والإلغاء. سحب القرار بأن تزول كافة آثاره بالنسبة للماضي والمستقبل، وتعتبر كأن لم تكن، وإعادة أطراف العقد إلى مركزهم القانوني الذي كانوا يوجدون فيه قبل إبرامه.

وإلغاء القرار بأن توقف آثاره بالنسبة للمستقبل فقط دون الماضي، وعدم المساس بالآثار الماضية؛ تأسيساً على حسن نية الطرف الآخر، وعدم مسئوليته عن خطأ الدولة. وقد أفتت بأن: (...القانون الصادر من البرلمان متضمناً الإذن أو الترخيص، وإن كان شرطاً لإبرام العقد، إلا أنه غير ملزم للسلطة المختصة بالمنح، فيبقى لهذه السلطة دائماً أن تترخص في تقدير ملاءمة منح الترخيص من عدمه بما لها من حق الإشراف والرقابة على حسن استغلال موارد الثروة الطبيعية في

---

(١) الفتوى السابقة الصادرة في ٢٢ سبتمبر ١٩٥٤، ص ٢٢٦.

البلاد<sup>(١)</sup>. وتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في إبرام عقودها، فاختيار لجنة البت لأحد المتناقصين لا يلزم الإدارة بالتعاقد معه.

ويكون لذوى الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من السلطة المختصة بعدم إبرام العقد، باعتباره قرارا منفصلا، وبشكل مستقل إذا شابه عيب من عيوب عدم المشروعية، والمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، إما على أساس الخطأ، أو على أساس الإثراء بلا سبب.

### نطاق الإلزام بالحصول على الإذن أو التصريح والموافقة

حدده المشرع في قانون التعاقدات، ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين ذات العلاقة بنصوص واضحة، حيث أوجب ضرورة الحصول على موافقات صريحة قبل الطرح والإسناد، بحسب نوع الجهة، وطبيعة التعاقد، وقيمه المالية. على النحو التالي:

#### ١ - موافقة رئيس الجمهورية على العقد الإداري:

وتكون في صورة مرسوم، أو قرار جمهوري تبعا لنظام الحكم. ومن أبرزها: إبرام عقد التزام أو امتياز مرفق عام. حيث تتم منح الالتزامات بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس النواب، باستثناء الامتياز باستغلال موارد الثروة المائية ومناطق صيد الطيور التابعة لوزارة الحربية فتتم بقرار من وزير الحربية لمدة أقصاها خمس سنوات.

---

(١) فتوى ٢٢ سبتمبر ١٩٥٤، مجموعة فتاوى المجلس، السنة الثامنة ومنتصف التاسعة، مرجع سابق، ص ٢٢٦ وما بعدها.

٢- موافقة البرلمان على العقد الإداري: وتأخذ صورة صدور قانون عن السلطة التشريعية المختصة خاص بعقد معين.

مثال: ما نصت عليه المادة (٣٢ / ٣، ٤، ٥) من دستور ٢٠١٤ من: (... ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما.

ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك).

ومثال العقود التي تتجاوز حدًا ماليًا معينًا يُحدده القانون أو اللائحة، أو العقود المرتبطة بالمشروعات القومية أو الإستراتيجية، أو التي تنطوي على بيع أو استغلال أصول الدولة من عقارات ومشروعات عامة، أو التعاقد بالاتفاق المباشر.

٣- موافقة مجلس الوزراء على العقد الإداري:

يكون لمجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى أن يأذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر، وذلك فيما يجاوز الحدود المقررة في المادة (٦٣ / بند ٢) قانون التعاقدات. ومثال ما اشترطته القوانين الصادرة في شأن منح التزامات محطات الكهرباء، ومنح التزامات الطرق العامة، ومنح التزامات

المطارات من أن يتم منح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

وما تطلبه القانون الخاص بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء من ضرورة موافقة مجلس الوزراء عند إبرام التعاقد مع الجهات الأجنبية والا كان العقد باطلا.

#### ٤ - موافقة الوزير المختص أو الوزارة على العقد الإداري:

تأخذ صورة صدور قرار وزاري من الوزير المختص، كوزير الصحة مثلا. والذي له حق التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالنسبة للأعمال واللقاءات والعقاقات الطبية ذات الطبيعة الإستراتيجية وألبان الأطفال.

وقد يستلزم التعاقد موافقة إحدى الوزارات المختصة وليس الوزير فحسب، كموافقة وزارة التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة بالموازنة لوسائل الانتقال، وعلى شراء سيارات الركوب الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أي كان الغرض منها<sup>(١)</sup>، أو موافقة وزارة المالية؛ للتأكد من توافر الاعتمادات.

وقد يمتد الأمر ليشمل أحيانا ضرورة أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، كالجهاز المركزي للمحاسبات، أو هيئة الرقابة الإدارية، أو المخابرات والأمن.

---

(١) د/ رمضان بطيخ: قيود إبرام العقد ، مرجع سابق، ص ١٣.

٥- موافقة المحافظ على العقد الإداري: وتأخذ صورة صدور قرار من المحافظ، بالنسبة لعقود الوحدات والإدارات المحلية والتي تبرم في إطار اللامركزية الإدارية المحلية أو المصلحية، دون عقود الدولة. حيث يجوز للمحافظ التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية، وعشرين مليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.

إذ الولاية العامة في إبرام عقود الوحدات الإدارية المحلية تنصرف إلى المحافظ، باعتباره يتولى جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية<sup>(١)</sup>.

ويتناقض هذا الاختصاص مع فلسفة الإدارة المحلية ذاتها؛ ويجعل السلطة المركزية طرفاً في كل عقود الوحدات والإدارات المحلية بشكل يؤدي إلى إلغاء الإرادة الشعبية التي تمثلها المجالس الشعبية المحلية باختلاف درجاتها<sup>(٢)</sup>.

وتتصرف الولاية العامة فيما يتعلق بإبرام عقود الهيئات العامة-خدمية أو اقتصادية- إلى رئيس مجلس إدارتها؛ باعتباره السلطة المختصة بإبرام تلك العقود.

---

(١) م(٢٧) من قانون الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩.  
(٢) د/ رمضان بطيخ: مرجع سابق، ص ١٤.

## موافقات خاصة لبعض عقود الوحدات الإدارية المحلية

تستلزم بعض عقود الوحدات المحلية قبل إبرامها ضرورة الحصول على تصريح أو إذن أو ترخيص سابق من:

أ- البرلمان: فلا يجوز لوحدة الإدارة المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة<sup>(١)</sup> إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس الشعب-النواب حالياً.

ب- مجلس الوزراء: بالنسبة للعقود التي تبرمها المجالس الشعبية المحلية للمحافظات أو المراكز أو المدن بقصد التأجير بإيجار أسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، إذا كانت قيمته تزيد على خمسين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام.

ج- رئيس مجلس الوزراء: بالنسبة للعقود إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة، ولغرض ذي نفع عام، وعقد القرض الذي يبرمه مجلس شعبي محلي المحافظة وذلك إذا تم الاقتراض من جهة أجنبية، أو إذا زاد حد المديونية الناجمة عن القرض نسبة ٤٠٪ من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها هذه المشروعات<sup>(٢)</sup>.

(١) م (١٢٩) قانون الإدارة المحلية.  
(٢) م ١٥ من قانون الإدارة المحلية.

د- الوزير المختص بالإدارة المحلية: بالنسبة للعقود التي يبرمها المجلس الشعبي المحلي للمدينة للتصرف بالمجان أو التأجير بإيجار أسمى أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، أو لجهة أجنبية لغرض ذي نفع عام وكان ذلك في حدود عشرين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة.

هـ- المجلس الشعبي المحلي للمحافظة: بالنسبة للعقود التي تبرمها المجالس الشعبية المحلية للمدينة بقصد التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمى أو بأقل من أجر المثل لتحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام<sup>(١)</sup>.

كما يستلزم المشرع ضرورة قيام مجلس إدارة الهيئة العامة بإبلاغ الوزير المختص بكافة القرارات، ومن بينها قرارات إبرام، أو عدم إبرام العقود لاعتمادها<sup>(٢)</sup>.

٦- موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو الصندوق على العقد الإداري: وتأخذ صورة صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو الصندوق، أو من يعادلهم من سلطات، بالنسبة للعقود التي تبرم في إطار اللامركزية المصلحية أو المرفقية. حيث يكون لرئيس الهيئة، أو

(١) م ١/٥٠ من قانون الإدارة المحلية.  
(٢) القانون ٦١ لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة.

رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، وذلك فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية، وخمسة ملايين جنيه بالنسبة للمقاولات.

### تفويض السلطة المختصة

سبق القول إن التفويض استثناء ولا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. وأنه يحظر علي السلطة المختصة التفويض في مباشرة اختصاصاتها في بعض الحالات.

وقد حدد المشرع في المادة (١٦٦) من لائحة ضوابط وإجراءات التفويض، كالتالي:

أ- يجوز للسلطة المختصة- بعد مراعاة الحالات التي حظر القانون ولائحته التنفيذية التفويض فيها<sup>(١)</sup>- أن تفوض في أي من اختصاصاتها لشاغلي الوظائف القيادية المحددة بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ قانون الخدمة المدنية أو غيره.

ب- يكون التفويض لمن يشهد لهم بالكفاءة والخبرة والتمتع بصفات النزاهة والأمانة وحسن السمعة والخبرة اللازمة لممارسة الاختصاصات المفوضة لهم.

---

(١) مثال ما ورد بالمادة (٦٣) من قانون التعاقدات: (ولا يجوز لأي من هذه السلطات التفويض في الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بهذا الطريق).



- ج- يشترط صدر قرار التفويض من السلطة المختصة، يتضمن اسم المفوض، ووظيفته، وموضوع التفويض، ومدته، وشروطه، ومتطلباته.
- د- ينتهي التفويض بإلغاء القرار الصادر بشأنه أو انتهاء مدته أو الغرض منه.

ويجب على المفوض إعداد تقارير يعرضها على السلطة المختصة بشأن ما اتخذ من إجراءات مفوض فيها. وبالمقابل يجب على السلطة المختصة الأصلية مراجعة نتائج أعمال المفوضين بشكل دائم للوقوف على مستوى أدائهم لاتخاذ ما يلزم بشأنهم. وتعتمد نتائج أعمال المفوض من السلطة المختصة الأصلية دون غيرها.

## الباب الرابع

الآثار المترتبة على انعقاد العقد الإداري وتنفيذه

أهداف الباب الرابع: بنهاية الباب، يكون الطالب قادرًا على:

١- تحديد التزامات وحقوق المتعاقد.

٢- معرفة سلطات والتزامات الإدارة.

٣- معرفة نهاية العقد الإداري وتسوية منازعاته.

تقسيم: يشمل هذا الباب ثلاثة فصول:

الفصل الأول: التزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة.

الفصل الثاني: سلطات والتزامات الإدارة تجاه المتعاقد.

الفصل الثالث: انتهاء العقد الإداري وتسوية منازعاته.

## الفصل الأول

التزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة

وهو ما يمكن تناوله من خلال مبحثين:

المبحث الأول : التزامات المتعاقد مع الإدارة .

المبحث الثاني : حقوق المتعاقد مع الإدارة .

## المبحث الأول

### التزامات المتعاقد مع الإدارة

يلتزم المتعاقد مع الإدارة وفي مواجهتها بعدة التزامات من أهمها: تنفيذ محل العقد وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، في المواعيد والمدد المحددة قانوناً، وبحسن نية، واستكمال الأعمال المطلوبة، وضمانها ونحوه. وهو ما تناولت أحكامه القانونية المادة (١٠٥) وغيرها من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م بشكل يحدد به التزامات المتعاقد مع الإدارة. وهو ما سنتناوله في المطالب التالية:

### المطلب الأول

#### التزام المتعاقد بالتنفيذ الشخصي والتعديلات في المواعيد المحددة

مفاده: أن يلتزم المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ محل العقد شخصياً في الميعاد، أو المواعيد المحددة بأمر التوريد أو الإسناد، ووفقاً للشروط الفنية والمالية المحددة في العقد، والمواصفات الملحقه به في بنوده وكراسة الشروط، وذلك بحسن نية، وما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته الخاصة والعامة.

وهو ما يعد من القواعد العامة، ويترتب عليه التنفيذ خلال المدة المحددة قانوناً، واحترام المواصفات الفنية التفصيلية، وعدم الإخلال بجودة الأعمال، وتنفيذ الأعمال تحت رقابة الإدارة وبناءً على تعليماتها.

وتعتبر فكرة حسن النية واحترام المتعاقد لجميع التزاماته الناشئة عن العقد، وتنفيذه محل العقد بطريقة سليمة تتفق مع الشروط والمواصفات المقررة من الأمور الموضوعية التي تخضع لرقابة قاضى الموضوع، وعليه أن يقدرها محاطة بكل الظروف والملابسات التي تصادف العقد أثناء تنفيذه، وتبعا لموقف الإدارة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، بل قد تمتد رقابته في بعض الحالات لتشمل تقدير مسلك الإدارة على ضوء الظروف التي تواجه العقد عند تنفيذه، وينعت هذا المسلك بسوء النية من جانب الإدارة<sup>(١)</sup>.

وهو ما يترتب عليه عدم جواز دفع المتعاقد بعدم التنفيذ بحجة تقاعس الإدارة ونحوه.

**والتزام المتعاقد هنا هو التزام بتحقيق نتيجة، بأن يبذل أقصى جهد** للالتزام بتنفيذ كل التزاماته التعاقدية في موضوع العقد، ووفقا لما اشتمل عليه<sup>(٢)</sup>. ووفقا لطبيعته، وعدم تعرض سير المرفق العام للخطر، وليس ببذل عناية<sup>(٣)</sup>، ولا تبرأ ذمته إلا بالوفاء بالعمل في موضوع التعاقد<sup>(٤)</sup>.

---

(١) د/ إبراهيم محمد علي: آثار العقود الإدارية وفقا للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، ط٢، دار النهضة العربية، ٢٠٠٣، ص ١٥٥.

(٢) المادة (١٠١) من اللائحة التنفيذية.

(٣) للتفصيل: د/ أسامة أحمد بدر: الالتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق نتيجة بين المسئولين الشخصية والموضوعية - دراسة تحليلية قضائية في القانونين الفرنسي والمصري، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، حقوق الإسكندرية، ٢٤، ٢٠٠٩م، ص ٢٧١، وقارن ص ٢٧٧، ٣٠٧.

(٤) د/ هارون عبد العزيز الجمل: النظام القانوني للجزاءات في عقد الأشغال العامة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية حقوق عين شمس، ١٩٧٩، ص ٣٧٢ وما بعدها.

كما أنه التزام مركب ومزدوج يمتد أثره، ويقتضى من المتعاقد التزامه  
تنفيذ أمرين:

**الأول: التزام المتعاقد الشخصي بتنفيذ العمل المتفق عليه بنفسه:** إذ  
يعد من المسلمات أن يقوم المتعاقد بنفسه وشخصه بالتنفيذ.

وبصير محل اعتبار في أغلب العقود في جميع مراحلها؛ لما لها من أثر  
ملموس وأهمية بالغة في نظرية العقد بصفة عامة<sup>(١)</sup>. وإن تفاوتت درجة  
الأهمية في بعض العقود وفقا لدرجة اتصاله بالمرفق العام، أو النفع  
العام تضيق وتقتصر علي عقود الامتياز أو تتسع فتشمل غيره حسب  
طبيعة ونوع العقد وأهميته؛ باعتبار الاعتبار الشخصي وسيلة لضمان  
تنفيذ العقد الإداري، وليست هدفا في حد ذاته<sup>(٢)</sup>. وتحديدًا لمسئولية  
المتعاقد الشخصية عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن العقد الإداري<sup>(٣)</sup>.

**ويقصد بالاعتبار الشخصي في العقد الإداري:** "أن تكون شخصية  
المتعاقد مع الإدارة بذاتها، أو صفة جوهرية من صفاته عنصرا جوهريا  
في التعاقد"<sup>(٤)</sup>. أو: "أن تكون شخصية أحد المتعاقدين أو كليهما عنصرا  
جوهريا في التعاقد"<sup>(٥)</sup> بشكل رضائي، لا يصل إلى حد التضحية بحقوق

---

(١) أحمد محمد هزاع: الاعتبار الشخصي وأثره في تنفيذ العقد الإداري، مجلة القراءة  
والمعرفة، مصر، ع ١٣٤، ديسمبر ٢٠١٢م، ص ١٤٧.

(٢) يراجع الخلاف: أحمد هزاع: الاعتبار الشخصي، مرجع سابق، ص ١٤ وما بعدها.  
(٣) د/ محمد سعيد حسين أمين: الأسس العامة لالتزامات وحقوق المتعاقدين، مرجع  
سابق، ٥٢.

(٤) عادل عبد الرحمن خليل: عقود الإدارة الإدارية والمدنية، مطبعة الإيمان، بدون، ص  
١١٣. لدى المرجع السابق، ص ١٤٧.

(٥) د/ محمد سعيد حسين أمين: المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، مطبعة جامعة  
عين شمس، القاهرة، ٢٠٠٤، ص ٥٦ وما بعدها.

المتعاقد مع الإدارة، وحرمانه من المقابل المالي وكافة حقوقه، وإلا لأحجم الأشخاص والشركات عن التعاقد مع الإدارة، والمساهمة في تسيير المرفق العام بانتظام واطراد.

وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن: "العقد المبرم بين المدعى والحكومة هو من العقود الإدارية، التي تحكمها قواعد عامة تطبق عليها جميعا، ولو لم ينص عليه العقد، ومنها أن التزامات المتعاقد مع الإدارة التزامات شخصية. أي أن المتعاقد يجب أن ينفذها شخصيا وبنفسه... وأنه مسئول مسؤولية شخصية في تنفيذ التزاماته التي تضمنها العقد"<sup>(١)</sup>. وقضت المحكمة الإدارية العليا: (تقديرًا من المشرع لطبيعة العقود الإدارية وصلتها بالمرفق العام تم التركيز على الجانب الشخصي للمتعاقد مع الإدارة، وحسن سمعته، ومقدارته الفنية والمالية..)<sup>(٢)</sup>.

ويتبع هذا الالتزام ويلحق به التزام المتعاقد بتنفيذ موضوع العقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة؛ إذ لا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا التنازل أو النزول عن العقد. وهو ما نصت عليه المادة (٩٢) من قانون التعاقدات، والمستبدلة بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٠<sup>(٣)</sup>. وإن

(١) حكمها الصادر في ١٩٥٧/١/٢٧.

(٢) حكمها في الطعن رقم ٣٥٩٦ لسنة ٣٦ ق. ع، جلسة ١٩٩٧/١١/٢٥. لدى المستشار د/ محمد أبو العينين: العقود، مرجع سابق، ص ٨٣١. د/ مفتاح خليفة عبد الحميد: إنهاء العقد الإداري في التشريع الليبي - دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٧، ص ٢٤٥ وما بعدها.

(٣) الجريدة الرسمية، ع ٣٦٦ مكرر (ب)، في ٥ سبتمبر ٢٠٢٠. وكان النص القديم: (لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك، ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسؤولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق).

أجازت المادة (٢٥) منه التعاقد من الباطن، ووضعت له حكماً قانونياً  
خاصاً، سبق ذكره. ولا يجوز للمتعاقد تغيير أي منهم دون موافقة الجهة  
الإدارية المتعاقدة. وبطل المتعاقد دون غيره مسئولاً أمام الإدارة عن تنفيذ  
العقد. وقد أفنت بأن استعانة المتعاقد بغيره في العقد لا يعد تنازلاً عن  
العقد<sup>(١)</sup>.

**الأمر الثاني: الخضوع لسلطة الإدارة والالتزام بتنفيذ الأعمال الإضافية  
والتعديلات المطلوبة:**

يلتزم المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ الأعمال الإضافية أو المطلوب تعديلها،  
وذلك وفق النسب المحددة والمقررة فنياً وقانوناً؛ إذ يمتد تنفيذ العقد  
ليتناول كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون، والعرف، والعدالة بحسب  
طبيعة الالتزام. وهو من المبادئ المسلمة في مجال روابط القانون العام  
والخاص على السواء طبقاً لما تقضى به المادة (١٤٨) من القانون  
المدني<sup>(٢)</sup>.

وقد أوضحت المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات أحكام  
وضوابط تعديل حجم العقد، بأنه: (يجب على الجهة الإدارية تحديد  
احتياجاتها الفعلية والضرورية لسير العمل على أساس دراسة واقعية  
وموضوعية، ومع ذلك إذا استجد أثناء التنفيذ ما يوجب تعديل العقد فيتم

---

(١) فتوى الجمعية العمومية رقم ١٤٩٢ بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٥، ملف رقم  
٤٠٨٢/٢/٣٢. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٤١٥ وما بعدها.  
(٢) الطعن رقم ٩٥٤، س ١٢، بتاريخ ١٩٦٩/٤/١١، ٤٣/١٥، ص ٢٦٤. المجموعة،  
مرجع سابق، ص ٣٠٧.

التعديل بما لا يجاوز (٢٥ %) من كمية كل بند لعقود المقاولات، وبما لا يجاوز (١٥ %) من كمية كل بند لباقي العقود مع تضمين شروط الطرح مضمون ذلك مع تعديل المدة المناسبة أو البرنامج الزمني، بحسب الأحوال، للتوريد، أو التنفيذ وبما يتناسب مع حجم التعديل، على أن تراعى إدارة التعاقدات الآتي:

- ١- وجود ضرورة وأسباب داعمة لتلك التعديلات.
  - ٢- الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو مجلس الوزراء- بحسب الأحوال- على التعديل.
  - ٣- أن تكون تلك التعديلات على بنود العقد الأصلي ذاته بالشروط والمواصفات ذاتها والأسعار المتعاقد عليها.
  - ٤- إعداد ملحق للعقد متضمنا تلك التعديلات.
  - ٥- الحصول من الإدارة المالية على سماح البند في حالة التعديل بالزيادة.
  - ٦- أن يكون التعديل خلال مدة تنفيذ العقد، ولا يدخل فيها مدة الضمان.
  - ٧- ألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه.
- على أن تتولى إدارة التعاقدات توثيق تلك التعديلات والمستندات المؤيدة لها وحفظها بملف العملية، ويتم النشر عن القيمة النهائية للعقد بعد التعديل على بوابة التعاقدات.



## المطلب الثاني

### الالتزام بالقوانين واللوائح وحفظ النظام في موقع العمل

يلتزم المتعاقد بإتباع جميع الأحكام القانونية الواردة في قانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية، وغيره من القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد. بالإضافة إلى الشروط التعاقدية واللائحية والبند الواردة بكراسة الشروط والمواصفات.

وهو التزام أساسي يقع على أطراف العقد، ويجب توافره في كل مراحل تنفيذ العقد، يتفق ومبدأ المشروعية وسيادة القانون ووجوب خضوع الإدارة للقانون. فمثلاً إذا كان التزام المتعاقد السابق هو تنفيذ العقد في الميعاد أو المواعيد المحددة فإن المشرع قد حدد في اللائحة التنفيذية الشروط العامة لتنفيذ العقود وفق المدد المحددة للتوريد أو التنفيذ، وتبدأ من التواريخ التالية:

١- تبدأ المدة المحددة لتنفيذ التوريد في عقود التوريدات من اليوم التالي لإخطار المورد، سواء أكان بالداخل أو الخارج، بموجب أمر التوريد إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. على أن يتضمن أمر التوريد الأصناف والكميات والفئات ومكان التسليم، ومواعيد بدء التوريد وانتهائه<sup>(١)</sup>.

٢- تبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الأعمال من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع بموجب محضر خالياً من الموانع إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

---

(١) المادة (١/١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

وفى حال عدم حضور المفاوض يحضر بذلك، ويعتبر هذا التاريخ موعداً لبدء تنفيذ الأعمال.

٣- تبدأ المدة المحددة لتنفيذ لباقي عمليات العقود الأخرى وفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات، والعقد المبرم بين الطرفين<sup>(١)</sup>. ويلتزم بباقي الأحكام المنظمة لموضوع عقده بقانون التعاقدات وغيره مما ورد بكافة القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذه. ويستتبع وجوب احترام المتعاقد مع الإدارة للقوانين واللوائح مسئوليته عما يلي:

أ- ضمان الجودة والصيانة، واستمرار انتظام المرفق العام، وعدم توقفه عن العمل.

ب- الحفاظ على المال العام، وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.

ج- أن يتحرى بنفسه في عقود المقاولات طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وجسات وغيرها؛ للتأكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة<sup>(٢)</sup>.

وعليه إخطار الجهة الإدارية -إدارة التعاقدات- في الوقت المناسب بملاحظته عليها، ويكون مسئولاً تبعاً لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه.

---

(١) المادة (٣/١٠٥) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.  
(٢) المادتين (١٠٥) و(١١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للجهة الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون واللائحة.

د- أن يتحرى المقاول بنفسه عن صلاحية المقادير والأوزان<sup>(١)</sup>.

هـ- حفظ النظام بموقع العمل.

و- تنفيذ أوامر الجهة الإدارية بإبعاد كل من يهمل، أو يرفض تنفيذ التعليمات، أو يحاول الغش أو يخالف ذلك.

ز- اتخاذ كل ما يكفل للحفاظ على السلامة المهنية، ومنع الإصابات، أو حوادث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر، أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد.

وتعتبر مسؤوليته مسؤولية مباشرة دون تدخل للإدارة.

ويكون للجهة الإدارية في حالة إخلاله بذلك الحق في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون واللائحة.

---

(١) المادة (٢/١١٧) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

### المطلب الثالث

#### الالتزام بسلامة التنفيذ للأعمال وحماية العمال والغير

مفاده: ضمان المتعاقد سلامة التنفيذ لكل الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها وفقاً للشروط والمواصفات والجودة، وضمان ما يحدث من تدهم كلي أو جزئي لما أنشأه من مباني وغيرها من أعمال، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ الاستلام المؤقت، وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني -عشر سنوات- أو أي قانون آخر، والمقررة من تاريخ تسليمه إياه للجهة الحكومية تسليمًا نهائياً.

ويكون المتعاقد مسؤولاً عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد، فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته، وإذا قصر في إجراء ذلك فللجهة الإدارية أن تجريه على نفقته وتحت مسؤوليته<sup>(١)</sup>. ووفقاً لأحكام القانون.

ويتعين على المتعاقد قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب أن يخطر الجهة الإدارية كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة.

ومتى تبين أن الأعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسليمها نهائياً، بموجب محضر من أصل وأربع نسخ يوقعه كل من مندوبي الجهة الإدارية، والمتعاقد، أو من يفوضه.

---

(١) المادة (١١٩) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

ويسلم الأصل للإدارة المالية، وتسلم نسخة للمتعاقد، ونسخة لإدارة التعاقدات لحفظها بملف العملية، ونسخة للإدارة المشرفة على التنفيذ<sup>(١)</sup>. وإذا ظهر من المعاينة أن المتعاقد لم يقيم ببعض الالتزامات فيؤجل الاستلام النهائي لحين قيامه باستكمال التزاماته - وإجراءات التعديلات والإضافات المطلوبة - هذا مع عدم الإخلال بمسئوليته طبقاً لأحكام القانون المدني أو أي قانون آخر. وقد قضت: "أن الإدارة تتمتع بامتياز في مجال العقد الإداري من مقتضاه أنها تستقل دون ما حاجة إلى الالتجاء للقضاء بالحكم على مدى مطابقة تنفيذ الموقولة لأصول الصناعة ولمواصفات العقد وشروطه"<sup>(٢)</sup>.

كما يتعين على المتعاقد الحفاظ على السلامة المهنية للعمال والغير وحمايتهم، باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات، أو حوادث الوفاة للعمال، أو أي شخص آخر، أو الإضرار بممتلكات الحكومة، أو الأفراد. وتعتبر مسئوليته مسؤولية مباشرة دون تدخل للجهة الإدارية. لذا تلزم الجهات الخاضعة لأحكام قانون التعاقدات بالحصول على إقرار من مقدم العطاء بالتزامه بالتأمين على العمالة وفقاً لقوانين التأمينات السائدة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك. أما عمليات الأمن والحراسة للمنشآت ونقل الأموال فلا تخضع لنظام تأمين المقاولات بل تخضع لنظام التأمين النمطي<sup>(٣)</sup>.

---

(١) المادة (١٢٠) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.  
(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٩٩٤ لسنة ٢٤ق، جلسة ١٩٨٢/١/٢٣.  
(٣) فتوى الجمعية العمومية رقم ١٧٩ بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٥، ملف رقم ٥٦٨٢/٢/٣٢. لدى المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٣٨٦ وما بعدها.

## المطلب الرابع

### التزام المتعاقد بمواعيد التسليم الابتدائي والنهائي للعقد الإداري

يتعين على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلى الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وأن يمهدده، وأن يسلم الموقع أو العمل خال من العوائق تسليماً مؤقتاً أو ابتدائياً، وإلا كان للجهة الإدارية الحق بعد إخطاره في تنفيذ ذلك على حسابه، ويخطر عندئذ بالموعد الذي حدد لإجراء المعاينة<sup>(١)</sup>.

ويحرر محضر الاستلام المؤقت بعد إتمام المعاينة، ويوقعه كل من المتعاقد أو من يفوضه بذلك بتوكيل مصدق عليه، ومسئول إدارة العقد من الجهة الإدارية أو مندوبيها، بحسب الأحوال، الذين يُخطر المقاول بأسمائهم. ويكون هذا المحضر من أصل وأربع نسخ يسلم الأصل للإدارة المالية، ونسخة لإدارة التعاقدات لحفظها بملف العملية، ونسخة للإدارة الطالبة أو المستفيدة، ونسخة للإدارة المشرفة على التنفيذ، وتسلم نسخة للمتعاقد. وفي حالة عدم حضوره هو أو من يفوضه في الميعاد المحدد تتم المعاينة، ويوقع المحضر من مندوبي الجهة الإدارية وحدهم.

وإذا تبين من المعاينة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إخطار المتعاقد للجهة الإدارية باستعداده للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل، وبدء مدة الضمان.

---

(١) المادة (١١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

أما إذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل فيثبت هذا في المحضر، ويؤجل الاستلام إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط والمواصفات مع عدم الإخلال بمسئولية المتعاقد طبقاً لأحكام القانون المدني، وتبدأ من تاريخ المعاينة الأخيرة مدة الضمان. وبعد إتمام الاستلام المؤقت يرد للمتعاقد إذا لم توجد قبله مطالبات للجهة المتعاقدة، أو لأية جهة إدارية أخرى ما زاد من قيمة التأمين النهائي على النسبة المحددة من قيمة الأعمال التي تمت فعلاً، وتحفظ الجهة المتعاقدة بهذه النسبة لحين انتهاء مدة الضمان، وإتمام الاستلام النهائي<sup>(١)</sup>.

وبالمقابل تلتزم الإدارة بعمل التسهيلات اللازمة للمتعاقد بتسليمه الموقع أو المواد والأدوات والأصناف المتفق عليها حسب طبيعة كل عقد، ومعاونته في الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.

### الاستلام النهائي واستكمال الأعمال المطلوبة

يقصد به: إجراء إداري بمقتضاه تعلن الإدارة الطارحة قبول الأعمال المزمع تنفيذها، والواردة بمحل العقد بشكل نهائي، بعد انتهاء مدة الضمان، وذلك بموجب محضر من أصل وأربع نسخ يوقعه كل من مندوبي الجهة الإدارية، والمتعاقد أو من يفوضه. ويسلم الأصل للإدارة المالية، ونسخة تعطى للمتعاقد، ونسخة منه للإدارة المشرفة على التنفيذ.

---

(١) المادة (١١٨) الخاصة بالاستلام المؤقت من اللائحة التنفيذية.

وتسليم المبنى تسليماً نهائياً يكون بنقله إلى حوزة صاحب العمل أو الإدارة، وبأن يحظى بقبوله ورضاه<sup>(١)</sup>.

وسبق القول إنه يتعين على المتعاقد قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب أن يخطر الجهة الإدارية كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة، فإذا كانت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسلمها نهائياً، وإلا تم تأجيل الاستلام النهائي لحين قيامه باستكمال التزاماته، مع عدم الإخلال بمسؤوليته وفقاً للقانون المدني أو أي قانون آخر.

وعند إتمام الاستلام النهائي يدفع للمتعاقد ما قد يكون مستحقاً له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائي أو ما تبقى منه<sup>(٢)</sup>.

ويكون للجهة الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون واللائحة جزاء إخلال المتعاقد بالالتزامات السابقة، على نحو ما سنوضحه لاحقاً.

---

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣٠٠٦ لسنة ٤٢ق، جلسة ١٨/٥/١٩٩٩ لدى حمدي ياسين، سابق، ص ٣٤.  
(٢) المادة (١٢٠) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.



## المبحث الثاني

### حقوق المتعاقد مع الإدارة

تتمثل في عدة حقوق، نوضحها في المطالب التالية:

#### المطلب الأول

##### حق المتعاقد في الحصول على المقابل المالي المتفق عليه

يعد من أهم الحقوق للمتعاقد مع جهة الإدارة حقه في الحصول على المقابل المالي؛ إذ لم يُقدم المتعاقد على التعاقد مع الإدارة إلا من أجل الحصول على المقابل المالي المتفق عليه في العقد، نظير ما يقوم به من أعمال. لكنه يختلف باختلاف موضوع العقد الإداري، وطبيعته. وتصرف مستحقات المتعاقد على دفعات طبقاً لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمد عليها الجهة الحكومية.

وإن كان يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة بموافقة السلطة المختصة صرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد دون أي قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتهما، بشرط تضمين كراسة الشروط والمواصفات نسبة الدفعة، وطلب تحديد أوجه صرفها، ويتم استئصال قيمة الدفعة المقدمة مما يتم صرفه للمتعاقد مقابل تخفيض قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة بالنسبة ذاتها<sup>(١)</sup>. وإلا اعتبر ذلك عزوفاً منها عن

---

(١) المادة ٤٤ من قانون التعاقدات.

مبدأ إقرارها. وقد حدد القانون في المادتين (٤٤، ٤٥) قانون التعاقدات، والمادتين (٩٢، ٩٣) من لائحته التنفيذية نسب وإجراءات صرف الدفعة المقدمة للمتعاقد، وتتراوح بين (٢٥% و ٥٠%)، ويجوز تجاوز تلك النسب بموافقة وزير المالية، بحسب نوع وطبيعة العقد، وطريقة التعاقد.

ويتعين على أصحاب العطاءات عدم تجاوز تلك النسبة المقررة، ويستبعد كل عطاء يخالف ذلك، فإذا ما ثبت أثناء التنفيذ عدم الالتزام بأوجه الصرف المحددة للدفعة المقدمة يتم تسيل خطاب الضمان مقابل الدفعة المقدمة. ويراعى في مقاولات الأعمال عدم صرف فروق الأسعار لما يتم شراؤه من قيمة الدفعة المقدمة في العقود التي تتطلب ذلك، وفي الحالات التي يكون فيها بداية العقد معلقة على تحقق أكثر من واقعة من بينها صرف الدفعة المقدمة فيراعى ألا يتم صرفها إلا بعد تحقق جميع الوقائع الأخرى.

ويجب في جميع الحالات أن تكون الدفعة المقدمة في حدود الاعتمادات المدرجة بموازنة الجهة الإدارية عن السنة المالية التي يتم فيها التعاقد، وعليها التأكد من ذلك مسبقا وقبل الطرح.

ويجوز للمقاول في حالة رفض الجهة الإدارية استلام المستخلص المستوفي لشروط التعاقد والوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقد في المواعيد المحددة إرساله مرفقا به كافة المستندات المبينة بشروط التعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، على

أن يكون تاريخ استلام الجهة الإدارية للمستخلص بالبريد هو بداية المدة اللازمة للبدء في إجراءات الصرف.

وفي جميع الأحوال، إذا لم يتم الوفاء له بالمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة تلتزم الجهة الإدارية بأن تؤدي للمتعاقد ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة؛ شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به، ويحال المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك<sup>(١)</sup>.

## المطلب الثاني

### حق المتعاقد في اللجوء إلى القضاء أو التحكيم

يتمتع المتعاقد مع الإدارة بالحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، سواء أمام محاكم مجلس الدولة بوصفها صاحبة الولاية العامة في منازعات العقد الإداري، أو أمام هيئات التحكيم إذا ما نُص على ذلك صراحة في العقد. ويشمل حقه في المطالبة بالمستحقات المالية، والتعويض عن الأضرار الناتجة عن إخلال الإدارة بالتزاماتها.

وهو ما يُعد أحد المظاهر الجوهرية لمبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون، حيث يخضع العقد الإداري لرقابة القضاء الإداري، المتمثل في

---

(١) المادة (٤٥) من قانون التعاقدات.

قضاء الإلغاء، وقضاء التعويض، وقضاء العقود، وهو ما يُعرف بالقضاء الكامل، الذي يتصدى للفصل في أصل الحق وما يترتب عليه. وتكون المنازعة شخصية أو ذاتية متى تعلقت بحقوق شخصية نابعة من مركز قانوني فردي أو ذاتي لرافع الدعوى<sup>(١)</sup>.

وقد أكدته المادة (٩١) من قانون التعاقدات، بنصها على أنه: (... كما يجوز للمتعاقد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار نتيجة إخلال الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها، ما لم يوافق الوزير المختص بالجهة الإدارية على اللجوء إلى التحكيم وتتضمنه شروط العقد،...).

### اختصاص القضاء الإداري بمنازعات العقد الإداري

كان اختصاص القضاء الإداري، في بدايته، مقصوراً على الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية المتصلة والمنفصلة وغيرها، إلا أن تطور القضاء الإداري المصري أدى إلى أن امتد الاختصاص إلي كل ما يتعلق بعملية إبرام العقد الإداري، اختصاصاً مطلقاً وشاملاً لأصل تلك المنازعات العقدية وما يتفرع عنها، من نشأة العقد وحتى نهايته، بما في ذلك مراحل التنفيذ والتصفية<sup>(٢)</sup>. يؤكد ما قرره: "يعتبر مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.. ويتولى الإفتاء في المسائل

(١) د/ عبد الغنى بسيوني: ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة - قضاء الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٨٣، ص ١٣.

(٢) المستشار د/ محمد أبو العينين: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ١٠٧.

القانونية للجهات التي يحددها القانون،... ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها..<sup>(١)</sup>. وتطبيقاً له قضت: ( إن العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً ومتصلاً بمرفق عام ومتضمناً شروطاً غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، فإذا تضمن عقد هذه الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص به القضاء الإداري بحسب ولايته المحددة... ومن ثم يكون العقد موضوع الدعوى قد تكاملت له العناصر الثلاثة المشار إليها باعتباره عقداً إدارياً مما يختص بنظره القضاء الإداري...)<sup>(٢)</sup>.

كما يختص القضاء الإداري بالفصل في الأمور المستعجلة المنبثقة عن منازعات العقود الإدارية، ما دام القانون لم يسلبه ولاية الفصل في الأمور المستعجلة التي تنثيرها تلك المنازعات ويعهد بها إلى أخرى<sup>(٣)</sup>. "ولا تقل سلطة القاضي في تبيان الخطأ الذي وقع في العقد عن سلطته في فسخه أو تعديله فله أن يتحرى الإرادة الظاهرة للمتعاقدين؛ للوقوف على الخطأ الذي شابها من واقع الظروف والملايسات، فإذا استبان له وجود خطأ قام بتصحيحه بما يتحقق معه التعبير الصحيح للإرادة"<sup>(٤)</sup>.

---

(١) المادة (١٩٠) من دستور ٢٠١٤.  
(٢) الطعن رقم ١٨٨٩ لسنة ٦ق، بتاريخ ١٩٦٢/٣/٣١، مكتب فني ٧، ص ٥٢٧.  
(٣) من الطعن رقم ٨٩٧ لسنة ٩ق، جلسة ١٩٦٣/٧/٢٠، المستشار د/ محمد أبو العينين، العقود، مرجع سابق، ص ١١٣.  
(٤) الإدارية العليا في الطعن رقم ١٣٤٢، بتاريخ ١٩٦٢/٥/٥، لسنة (٦)، المكتب الفني، س ٧، ص ٧٧٩.

## آليات تسوية الخلافات والمنازعات قبل اللجوء إلى القضاء

حدد المشرع في المادة (٩١) من قانون التعاقدات، والمادة (١٨٠) من لائحته التنفيذية آليات تسوية الخلافات الناشئة عن تنفيذ العقد الإداري بين أطرافه. بأنه يجوز لطرفي العقد في حالة حدوث خلاف أثناء تنفيذه، وقبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم بحسب الأحوال، الاتفاق على تسويته عن طريق التوفيق أو الوساطة، وذلك إذا تضمنت شروط الطرح أو العقد جواز ذلك، وبموافقة السلطة المختصة مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد.

كما يتعين على طرفي العقد بذل أقصى جهد للالتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ما يوجبه حسن النية.

**وهو ما يفهم منه أن طرق حل المنازعات العقدية ثلاثة، هي:**

**الأول:** ودي من خلال: التوفيق أو الوساطة، حسب ما يتوصل إليه الخصوم، بتنازلهم عن بعض مطالبهم، بشرط أن تتضمن شروط الطرح أو العقد ذلك، وأن تتم بموافقة السلطة المختصة.

**وقد عرفت التسوية الودية بقولها:** "من المقرر أن مفهوم التسوية الودية بعيدا عن ساحات القضاء أو التحكيم الدولي هو: أن يتم تنازل كل طرف عن بعض حقوقه للطرف الآخر، حتى تقترب شقة الخلاف دون الدخول في تفاصيل الخلاف وحجج الطرفين ومستنداتهم ودفاعهم ودفعهم وأرقام المطالبات والطلبات المضادة من النواحي الفنية

والهندسية والعقدية فإنها بذلك تخرج عن مفهوم التسوية الودية<sup>(١)</sup>.

**والثاني: رسمي:** وهو إنهاء المنازعة عن طريق القضاء المختص.

**والثالث: اللجوء للتحكيم،** ويتم فيه نظر المنازعة والفصل فيها، بتولية

المتنازعين حكماً يرتضيانه ليحكم بينهما.

الإجراءات الواجب اتخاذها من جهة الإدارة للتسوية الودية:

يتعين على الجهة الإدارية لحل النزاع ودياً وقبل مباشرة إجراءات فسخ

العقد مع المتعاقد اتخاذ الإجراءات التالية:

١- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة.

٢- قيام إدارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأى

فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة، ويجوز لها الاستعانة باستشاري

متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وتقديم الرأى.

٣- تسوية الخلافات التي نشأت بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق

والالتزامات طرفي العقد، وإذا ترتب على التسوية الودية أي أعباء مالية

فيجب الاتفاق عليها وعرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد

تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.

٤- يتم توجيه الدعوة للمتعاقد لعقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد أو

ممثل الجهة الإدارية بحسب الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوماً من

تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته.

---

(١) فتوى إدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت بتاريخ ١٣/١١/١٩٩٤، لدى ياسين، سابق، ص ٦٣٨.

٥- إذا لما يتم التواصل إلى اتفاق يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم بحسب ما تنص عليه شروط التعاقد.

### مدى فعالية التحكيم في مجال منازعات العقد الإداري:

على الرغم من أن الأصل هو اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الناشئة عن العقد الإداري، فإن المشرع أجاز، كاستثناء، اللجوء إلى التحكيم بشرط موافقة الوزير المختص، وتضمن شرط التحكيم في العقد، وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.

وتظهر أهمية التحكيم في العقود الإدارية الدولية، أو تلك التي تتعلق بمنح امتيازات اقتصادية كبيرة، حيث يوفر التحكيم وسيلة إجرائية سريعة، ومحايدة لفض النزاعات، والتخصص في المنازعات الفنية؛ شريطة الالتزام بالضوابط القانونية والإجرائية التي حددها المشرع.

ويدور التحكيم في العقود الإدارية ما بين مؤيد ومعارض؛ إذ وفقاً للأصل العام لا يجوز للجهات الحكومية العمل بالتحكيم في مجال منازعات العقد الإداري كوسيلة لفض المنازعات التي قد تنشأ بينها وبين أي فرد أو شركة أو هيئة خاصة. فقد حظر المشرع على جميع الجهات الإدارية ألا تبرم عقداً أو تقبل تحكيماً أو صلحاً فيما تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الفتوى الخاصة بمجلس الدولة. وهو لم يفرض عبثاً وإنما من أجل تجنب الإدارة مواطن الخطأ وأن يكفل لها من أسباب السلامة في إبرام عقودها ما تتحقق به المصلحة العامة.



وبستثنى، الحالات التي تمنح فيها الدولة امتيازاً هاماً، وتتضمن شرط التحكيم؛ بشرط موافقة الوزير المختص بالجهة الإدارية على اللجوء إليه، وأن تتضمنه شروط العقد، ويتفق عليه الطرفان وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة بقانون التحكيم، إذ يتعين على طرفي العقد بذل أقصى جهد للالتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ما يوجبه حسن النية، ويجب أن تتضمن شروط الطرح والعقد مراحل وآليات تسوية الخلافات والمنازعات بين طرفيه.

### التحكيم في الفقه الإسلامي:

يعرف بأنه: (اتفاق بين الجهة الإدارية أو أحد الأشخاص المعنوية العامة مع المتعاقد معهما لفض النزاع الناشئ بينهما بشأن العقد المبرم بينهما من غير طريق القضاء ملزم لهما باختيارهما بما لا يخالف الشرع)<sup>(١)</sup>. واصطلاحاً: الفصل في أي نزاع عقدي يحصل أو حصل بين إحدى الجهات الإدارية أو أحد الأشخاص المعنوية العامة مع غيرهم عن طريق من يرتضيانه ليحكم بينهما وفقاً للشرع والقانون تحت إشراف إدارة الفتوى بمجلس الدولة، ولا ينفذ إلا بعد مراجعته من إدارة الفتوى والموافقة عليه من الوزير المختص واعتماده من السلطة المختصة في ضوء ما اتفق عليه مسبقاً عند إبرام العقد.

---

(١) د/ خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير: التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة مع دراسة تطبيقية للنظام السعودي، رسالة مقدمة إلى قسم السياسة الشرعية بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ص ٣٣٦. ونشرتها مطابع الحميضى، السعودية، ٢٠١١. د/ محمد رفعت عبد الوهاب: التحكيم في العقود الإدارية، مجلة حقوق الإسكندرية للبحوث القانونية والاقتصادية، ع ٢٤، ٢٠١٠، ص ٤٦٣ وما بعدها.

وبعد التحكيم في الفقه الإسلامي من الأمور المشروعة والجائزة في جميع الدعاوى، والتي منها منازعات العقد الإداري، وليس هناك ما يخرجها عن هذا الأصل. استنادا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). فاتفاق جهة الإدارة مع المتعاقد معها على التحكيم لحل المنازعات الناشئة عن العقد يدخل في عموم الآية.

وقد أخذ القانون المصري بهذا الأصل، مع إخضاع التحكيم لإشراف الدولة عبر إدارة الفتوى بمجلس الدولة وموافقة السلطة المختصة.

### المطلب الثالث

#### حق المتعاقد في المطالبة بالتعويض واسترداد التأمين النهائي

يعد من حقوق المتعاقد مع الإدارة حقه في الحصول على التعويض المناسب متى أخلت الإدارة معه بالتزاماتها العقدية، أو مارست أحد امتيازاتها دون مبرر مشروع وأدى ذلك إلى إلحاق ضرر به، في حالة تأخيرها في تسليم الموقع أو دفع الدفعات، وتعديلها شروط العقد منها بشكل منفرد دون مبرر، وإنهاء العقد دون سبب قانوني. وذلك عن طريق الإدارة ذاتها بتظلم إداري أمامها أو أمام اللجان المختصة. أو اللجوء إلى القضاء الإداري المختص. المادة (٢/٩١) من قانون التعاقدات.

يؤكدته فتاها أن: "الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد، سواء كان ذلك عن عمد أو إهماله، أو عن فعله دون

عمد أو إهمال - عدم قيام الجهة الإدارية بتسليم المقاول الموقع المحدد للتنفيذ خاليا من الموانع لتنفيذ التزاماته - يوجب مسئوليتها عن تعويض الأضرار التي قد تلحق المقاول - مبلغ التعويض يجب أن يكون جابرا لجميع الأضرار، وأن يكون متكافئا مع الضرر فلا يزيد عليه أو يكون دونه<sup>(١)</sup>.

كما قضت بأن: "ما يصدر عن مجلس الوزراء بتعويض المقاولين لا يعدو أن يكون توجيهها أو توصية، ولا يرقى إلى مصاف القواعد القانونية الملزمة لهذه الجهات؛ باعتبارها قرارات استرشادية، غير ملزمة للسلطة المختصة - كما أنه لا ينال من الإرادة المشتركة للمتعاقدين"<sup>(٢)</sup>.

وأفتت أنه وبمجرد انتهاء العقد بتنفيذه كاملا، ينقضي العقد كليا ويتحلل المتعاقد مع جهة الإدارة من جميع التزاماته، كما يعود إليه حقه في استرداد التأمين النهائي، ويقع علي جهة الإدارة الالتزام برده له بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية، ما دام ما تم تنفيذه موافقا للشروط والمواصفات المتفق عليها<sup>(٣)</sup>.

---

(١) فتوى الجمعية العمومية رقم ٧٧١ بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢٠، ملف رقم ٣٩١٨/٢/٢٢. لدى المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٤٢ وما بعدها.  
(٢) حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم ٦٦٣٩٦ لسنة ٦٧ ق. عليا، جلسة ٢٠٢٣٨/٨/٣١. لدى المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٧٢١.  
(٣) فتوى الجمعية العمومية رقم ٥١٩ بتاريخ ٣/٤/٢٠٢٤، ملف رقم ٤٨٤١/٢/٣٢. وفتاها رقم ١٤١٧ بتاريخ ١٦/٩/٢٠٢١ ملف رقم ٥٤٢٧/٢/٣٢. لدى المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٥٤٥.

## المطلب الرابع

### الحق في إعادة التوازن المالي

إذا طرأت ظروف استثنائية لم يكن في الحسبان حدوثها عند التعاقد، وأدت إلى اختلال التوازن المالي للعقد، فإن للمتعاقد الحق في المطالبة بإعادة التوازن المالي العادل للعقد للتوازن بين التزاماته وحقوقه، من خلال ما يعرف بمثلث نظريات إعادة التوازن المالي وهي: نظرية فعل الأمير. ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة. ونظرية الظروف الطارئة. وسوف نتناول أحكام كل منها في فرع مستقل.

## الفرع الأول

### نظرية فعل الأمير أو أعمال السلطة

ويراد بها: "كل إجراء عام أو خاص يصدر من جانب الجهة الإدارية المتعاقدة، لم يكن متوقعا وقت التعاقد، قد يترتب عليه ضرر خاص بالمتعاقدين معها، لا يشاركه فيه سائر من يمسمهم الإجراء"<sup>(١)</sup>.

أو هي: كل إجراء تقدم عليه السلطة الإدارية ويكون من شأنه زيادة الأعباء المالية علي كاهل المتعاقد مع الإدارة أو زيادة الالتزامات التي ينص عليها العقد<sup>(٢)</sup>. أو هي: "عمل يصدر من سلطة عامة دون خطأ من جانبها، ينجم عنه أن يسوء مركز المتعاقد في عقد إداري، ويؤدي

---

(١) فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المصرية رقم ٢٩٧ في ١١/٣/١٩٦٥، ملف ١٩٦٥/٢/٢، س ٣، ص ٣٩.

(٢) د/ فؤاد النادي، مبادئ القانون الإداري، سابق، ص ٥١٧.

إلى التزام الإدارة المتعاقدة بتعويض المتعاقد المضرور عن كافة الأضرار التي تلحق به من جراء ذلك بما يعيد التوازن المالي<sup>(١)</sup>.

وتسمى بنظرية المخاطر الإدارية أو أعمال السلطة أو أعمال الحاكم أو فعل الأمير. وهي من أولى النظريات التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي؛ بغية إقامة التوازن المالي الشريف والعادل نسبيا في العقد الإداري بين التزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة<sup>(٢)</sup>.

والإجراءات التي تصدر من السلطة العامة قد تصدر من الجهة الإدارية المتعاقدة نفسها، أو في صورة قرار فردي خاص، أو تصدر بموجب قواعد تنظيمية عامة<sup>(٣)</sup>.

وإنه وإن نص المشرع في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات، على أنه مع مراعاة أحكام المادة (٩٧) من اللائحة - الخاصة بمعادلة تغير الأسعار في عقود مقاولات الأعمال واشتراطات تطبيقها -، يعتبر سعر العقد ثابتا طوال مدة تنفيذه.

إلا أنه نص في المادة (٩١) منها على أنه: (في حال حدوث تغيير في التعريف الجمركية، أو الرسوم، أو الضرائب الأخرى التي تحصل عن الأصناف الموردة وفقا للعقد في المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر

---

(١) د/ سليمان الطماوي: الأسس العامة للعقود، مرجع سابق، ٥٦٧.  
(2) Saroit Badaoui: Le Fait du prince dans les contrats adminostratif en droit francais et en droit egyptien, Paris, L.G.D 1955. كإشارة د/ جابر نصار: العقود، مرجع سابق، ص ٣٠٤.  
(٣) فتوى الجمعية العمومية الصادرة بتاريخ ١١/٢٨/١٩٦٤، س ١٩، ص ٥١. المجموعة.

موعد للتوريد، وكان التوريد قد تم في غضون المدة المحددة له فيسوى الفرق تبعا لذلك بشرط أن يثبت المورد أنه أدى الرسوم والضرائب على الأصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزيادة، أما في حالة ما إذا كان التعديل بالنقص فتخصم قيمة الفرق من العقد إلا إذا أثبت المورد أنه أدى الرسوم على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل.

وقد أفنت بأن طلب المتعاقد تعديل الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف -تقدير قيمة التعويض يكون وفقا لأحكام قانون التعويضات<sup>(١)</sup>. وأنه: "... ومن ثم يتعين تطبيق معاملات تغيير الأسعار، نتيجة زيادة أسعار الوقود "السولار"، وصرف فروق الأسعار عن البند المذكور للشركة المتعاقدة، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك في ترتيب أولوية الشركة في ترتيب عطاءتها، بما مفاده ضرورة بقاء عطاء هذه الشركة أقل العطاءات سعرا بعد تطبيق معاملات التغير على باقي العطاءات الأخرى....

لذلك انتهت إلى أحقية شركة "طريق الرحمن للمقاولات" في صروف فروق الأسعار نتيجة زيادة أسعار الوقود "السولار" لعملية تالف الرصف بحي الوايلي للعام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ بمراعاة أعمال شروط أولوية العطاء"<sup>(٢)</sup>.

---

(١) فتاها رقم ٨٣٩ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٦ في الملف رقم ٦٩٣/١/٥٤. وفتاها رقم ٥٩٤ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨ ملف رقم ٦٨٠/١/٥٤. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٥٣ وما بعدها.  
(٢) فتاها في الملف رقم ٧٨ / ٢ / ١٨١ بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٢٢. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، المرجع السابق.

## شروط التعويض عن نظرية فعل الأمير

يشترط لتطبيقها وقيام دعوى التعويض لصالح المتعاقد على أساسها:

١- صدور الإجراء الفردي الخاص عن جهة الإدارة المتعاقدة، وبسبب العقد الإداري؛ إذ لا تسري النظرية على عقود الإدارة التي لا تتوافر فيها صفة العقد الإداري، والتي تتصرف فيها كالأفراد كعقد الإيجار المبرم بينها والغير ونحوه.

٢- مشروعية الإجراء المتخذ، وعدم توقع حدوثه، بل فرضته ظروف ومستجدات خارجة عن الطرفين كارتفاع غلاء الأسعار، أو أزمة مالية أو اقتصادية دفعت الإدارة لرفع الأسعار أو عدلت في الرسوم الجمركية.

٣- وأن يلحق بالمتعاقد مع الإدارة ضرراً خاصاً، لا يشاركه فيه سائر من يمسّه القرار العام، يترتب عليه زيادة في الأعباء المالية له. ولا يشترط فيه درجة معينة من الجسامة.

٤- وعدم انطوائه على خطأ ينسب للإدارة حين اتخذت عملها الضار، فمسئوليتها عقدية بلا خطأ؛ إذ لو كان تدخل الإدارة أساسه تصحيح خطأ من جانبها فلا تنطبق هذه النظرية، وكان للمتعاقد طلب الفسخ مع التعويض. أما لو كان الخطأ مشتركاً بينهما فالأمر متروك للقاضي لتحديد وتقدير نصيب كل منهما في التعويض<sup>(١)</sup>.

٥- أن يكون الإجراء الصادر من الإدارة غير متوقع.

---

(١) د/ فؤاد النادي: مبادئ القانون الإداري، ج ٢، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م، مطابع الدار الهندسية، القاهرة، ص ٢٠٧.

وإذا ما تحققت نظرية فعل الأمير بكل شروطها فإنه يتعين على الإدارة تحقيق التوازن المالي للمشروع بتعويضه تعويضاً كاملاً عن الأضرار. وهو تعويض شامل غير جزئي بعكس التعويض في نظرية الظروف الطارئة<sup>(١)</sup>. كما يحق له أن يطلب فسخ العقد إذا ما تبين له صعوبة الاستمرار في تنفيذه.

وبالإضافة إلى التعويض يترتب على نظرية فعل الأمير الآثار التالية<sup>(٢)</sup>:  
أ- أن يتحلل المتعاقد من التزامه بتنفيذ العقد عند استحالة التنفيذ من جراء الإجراء الصادر من السلطة العامة، مثال أن تصدر قرارها بإلغاء استيراد سلعة معينة يتعهد المتعاقد بتوريدها.

ب- طلب فسخ العقد مع التعويض عند استحالة التنفيذ، لأن الخطأ من جانب الإدارة.

ج- أن يطلب من الإدارة المتعاقد معها أن تعذره أو تعطيه مهلة حال تأخره في التنفيذ.

أما إذا كان الضرر الذي لحق المتعاقد قد تحقق علي أساس خطئه وخطأ الإدارة فللقاضي أن يقدر نصيب كل من الطرفين عن الخطأ في تقدير التعويض<sup>(٣)</sup>. يؤكد حكمها أن: "طلب الشركة التعويض على أساس المسؤولية العقدية لاستحالة تنفيذ العقد- وإن كان عدم تنفيذها

---

(١) حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٩٨٣ لسنة ٩٩، جلسة ١٩٥٧/٦/٣٠، س ١١، المجموعة، ص ٦٠٧.

(٢) د/ جابر نصار، العقود، مرجع سابق، ص ٣١٨.

(٣) د/ فؤاد النادي : مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص ٢١٨.



التزاماتها يرجع إلى الموانع المادية والقانونية بموقع العمل، ومن ثم تكون  
الجهة الإدارية قد أخلت بالتزاماتها- إلا أنه يوجد خطأ مشترك بين  
الشركة لعدم وفائها بالتزامها القانوني بصفتها مقاول العملية؛ بأن تتحري  
طبيعة الأعمال، وإجراء كل ما يلزم..- ومن ثم فإنها تقف على مسافة  
متساوية من الخطأ مع الجهة الإدارية- خاصة في ضوء أن المشروع  
من المشروعات الكبرى التي لا تقوم بها إلا الشركات ذات الخبرة، ولا  
ينال من ذلك ما ورد بتقرير الخبير<sup>(١)</sup>.

مما يفهم منه أنه لكي تطبق نظرية فعل الأمير فلا بد من توافر كل  
شروطها، وإلا فلا لتخلف شروطها.

## الفرع الثاني

### نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

قد يواجه المتعاقد مع الإدارة أثناء تنفيذ العقد الإداري صعوبات مادية  
طارئة، لم يكن في وسعه ولا في وسع جهة الإدارة توقعها عند التعاقد،  
رغم ما اتخذته من حيلة وحذر، وما قام به من التحري عن طبيعة العمل  
والظروف المحيطة به، تؤدي في النهاية إلى زيادة التكاليف والإخلال  
بالتوازن المالي للعقد<sup>(٢)</sup>. ومجال تطبيقها عقود الأشغال العامة.

---

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٣٩٥ لسنة ٥٩ ق. عليا، جلسة  
٢٨/١١/٢٠٢٣. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٦١٤ وما بعدها.  
(٢) د/ علي شفيق: الرقابة على أعمال الإدارة، مطبعة معهد الإدارة العامة،  
١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م، ص ٢٦١.

## شروط التعويض عن نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

يشترط لتطبيقها وقيام دعوى التعويض على أساسها ما يلي:

- ١- أن تكون الصعوبة مادية وغير عادية أو استثنائية.
- ٢- وعدم توقعها وقت التعاقد، باعتبارها طارئة غير متوقعة، أو مما لا يمكن توقعه، أو ليس في الوسع توقعه.
- ٣- وأن تصيب المتعاقد بضرر بسيطاً كان أو جسيماً، بأن يترتب على التنفيذ تكبده خسار ونفقات تجاوز الأسعار المتفق عليها وتزيد من أعبائه.

وبتوافر هذه الشروط وقيامها تلتزم الإدارة بإعادة التوازن المالي للمتعاقد معها، بأن تساهم معه في تحمل الصعوبات المادية غير المتوقعة، التي تسببت في خسارته بأي شكل كان بسيطاً أو جسيماً، وأرهفته مالياً، وتحول في الوقت ذاته بينه وبين تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقه من جراء هذا العقد تلك الظروف الطارئة.

ويختلف تحقق شرط الصعوبة غير العادية أو الاستثنائية باختلاف كل حالة على حدة. فقد أفتت بأن: "مقتضى تطبيق النظرية هو مشاركة الإدارة للمتعاقد في الخسارة التي لحقته بالفعل وليس طلب زيادة الأسعار المتعاقد عليها، وثبوت حدوث الخسارة الاستثنائية"<sup>(١)</sup>.

---

(١) فتوى الجمعية العمومية رقم ١٤١٧ بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٢، ملف رقم ٦٧٧/١/٥٤. وفتاها رقم ١٦٤٥ بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٢، ملف رقم ٦٧٨/١/٥٤. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٥٠ وما بعدها.

كما قضت بأنه: "يشترط بين ما يشترط في الصعوبات المادية أن تكون طارئة غير متوقعة، أو مما لا يمكن توقعه، أو ليس في الوسع توقعه، وهذا الشرط ينطوي إلى حد كبير على معنى المفاجأة في صورة معينة كأن يجد المتعاقد مع الإدارة نفسه في حالة لم يتوقع حدوثها لا بناء على دفتر الشروط ولا من دراسته الأولية للمشروع، أو بالرغم مما نبه إليه، أو ما اتخذ من حيلة لا تفوت على الشخص البصير بالأمور قبل الإقدام على المساهمة في تسيير المرفق العام والتعاقد بشأنه"<sup>(١)</sup>.

### الفرع الثالث

#### نظرية الظروف الطارئة

عرفتها المحكمة الإدارية العليا بأنه: (إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث غير متوقعة عند إبرام العقد قلبت اقتصادياته، وكأن من شأنها أن تجعل تنفيذ العقد أكثر عبئا، وكانت الخسارة الناجمة عنها تجاوز الخسارة المألوفة، فيحق للمتعاقد أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في هذه الخسارة- مقتضاها أن يدفع الدائن للمدين تعويضا لكفالة تنفيذ العقد متى كان من شأن الظروف غير المتوقعة أن تثقل كاهل المدين بخسارة تقلب اقتصاديات العقد)<sup>(٢)</sup>.

---

(١) د/ علي شفيق، مرجع سابق، ١٤٢٢، ص ٢٦٢. وحكم محكمة القضاء الإداري، جلسة ١٩٥٧/١/٢٠، س ١١، المجموعة ص ١٥٢.

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقمي ٥٢٥٦٠ و ٥٢٤٣ لسنة ٦٧ ق. عليا، جلسة ٢٠٢٣/٣/٢٨. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٤٨ وما بعدها.

وتقوم هذه النظرية على فكرة العدالة المجردة، وهدفها تحقيق المصلحة العامة، وضمان تنفيذ العقد.

وبعد من الأسباب الطارئة التي تؤدي إلى تغيير في التعريف الجمركية تقلب سعر السوق وسعر العملة وتعديل الضرائب والرسوم الجمركية. وفرقت المحكمة بينهما؛ باعتبارها ليست ظرفاً طارئاً وكان بوسع المتعاقد توقعها عند التعاقد. أما لو كان السبب راجعاً إلى تعديل في الضرائب والرسوم الجمركية التزمت الإدارة بالزيادة أو النقصان. ويستوى أن يكون السبب المؤثر قد طرأ قبل أو بعد إتمام إجراءات التعاقد<sup>(١)</sup>.

### شروط التعويض عن نظرية الظروف الطارئة

يشترط لتطبيقها وقيام دعوى التعويض على أساسها ما يلي:

١ - **عدم توقع حدوثها بالمرّة** لكونها مفاجئة وطارئة، كحدوث حرب أو فتنة أو إضراب، أو قطع العلاقة بين بلدين أدى إلى قلب الأوضاع الاقتصادية.

٢ - **واستقلالها عن إرادة طرفي العقد**، باعتبارها ظرفاً طارئاً أجنبياً عن المتعاقد مع الإدارة، والإدارة ذاتها.

٣ - **وأن يؤدي الظرف الطارئ إلى إرهاب مالي وقلب اقتصاديات العقد الإداري من جراء ما لحق بالمتعاقد من خسائر فادحة واستثنائية**<sup>(٢)</sup>. ونتيجة لهذا الإخلال بالتوازن المالي للمشروع كان التنفيذ مرهقاً وصعباً.

---

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١١٨٦ لسنة ١٠٠٠، جلسة ١٩٦٧/١١/٢٥، ١٢١/١٩/١٣.

(٢) بتوسع: العجمي، مرجع سابق، ١٤٣٢، ص ١٧٦.

٤- وأن يستمر المتعاقد مع الإدارة في الوفاء بتنفيذ التزاماته.

بالإضافة إلى أنه يجب أن يطرأ الحادث الطارئ خلال مدة تنفيذ العقد وليس بعدها، ويتوافر هذه الشروط وقيامها تلتزم الإدارة بإعادة التوازن المالي للمتعاقد معها، وأن ترده إلي الحد المعقول، بأن تساهم معه في تحمل أعباءها، التي تسببت في خسارته خسارة فادحة، وأرهقته ماليا.

أما إذا لم يترتب على الظرف الطارئ خسارة، أو كانت في حدود الخسارة العادية المألوفة في التعامل، أو اقتصر الأمر على تفويت الربح على المتعاقد بإنقاص أرباحه، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال نظرية الظروف الطارئة<sup>(١)</sup>.

وإذا ما وقع الحادث الطارئ خلال فترة امتداد مدة تنفيذ العقد المتفق عليه فإنه يأخذ حكم المدة الأصلية المحددة في العقد، طالما وافقت الإدارة وسمحت له بالتمديد.

**تمييز نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة عن غيرها**

يتضح من الأحكام المتعلقة بكل نظرية على حدة وجود فروق بينهم. يوضحه ما قضت به، بأن: "مقتضى النظرية المعروفة بنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة هي من النظريات التي ابتكرها الفقه والقضاء الإداري-أنه عند تنفيذ العقد الإداري- وبخاصة عقود الأشغال العامة قد تطرأ صعوبات مادية استثنائية لم تدخل في حساب طرفي

---

(١) فتوى الجمعية العمومية رقم ٥٩٤ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨، ملف رقم ٦٨٠/١/٥٤. وفتاها رقم ٨٣٩ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٣، ملف رقم ٦٩٣/١/٥٤. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٤٩ وما بعدها.

العقد وتقديرهما عند التعاقد وتجعل التنفيذ أشد وطأة على المتعاقد مع الإدارة وأكثر كلفة، فيجب- من باب العدالة- تعويضه عن ذلك بزيادة الأسعار المتفق عليها في العقد زيادة تغطي جميع الأعباء والتكاليف التي تحملها اعتبارا بأن الأسعار المتفق عليها في العقد لا تسرى إلا على الأعمال العادية المتوقعة فقط.

وأن هذه نية الطرفين المشتركة، والتعويض هنا لا يتمثل في معاونة مالية جزئية تمنحها جهة الإدارة للمتعاقد معها، بل يكون تعويضا كاملا عن جميع الأضرار التي يتحملها المقاول بدفع مبلغ إضافي له على الأسعار المتفق عليها.

**وبذلك تختلف هذه النظرية من حيث سببها، والنتائج المترتبة عليها عن نظرية الظروف الطارئة التي تطبق بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ينشأ عنها قلب اقتصاديات العقد أو اختلال توازنه المالي، ويقتصر التعويض فيها على قدر محدود تساهم فيه جهة الإدارة. كما تختلف أيضا عن حالة القوة القاهرة في أنه يكفي في حالة الصعوبات المادية غير المتوقعة أن يصبح التنفيذ مستحيلا، كما أنه يترتب على القوة القاهرة إما وقف التنفيذ أو فسخ العقد، أما في حالة الصعوبات المادية غير المتوقعة فإنه يفترض- على العكس- الاستمرار في التنفيذ<sup>(١)</sup>.**

---

(١) حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٧٨٩٢ لسنة ٨ق، جلسة ١٩٥٧/١١/١٧، ١٠٧/١١، المجموعة، سابق، ص ١٥٢. وذكره عكاشة، الكتاب الثالث، سابق، ص ٥٠٦.

## الفصل الثاني

### سلطات والتزامات الجهة الإدارية تجاه المتعاقد

يتميز العقد الإداري عن غيره من العقود المدنية بطبيعة أطرافه، وأهدافه، ونظامه القانوني الخاص الذي يضفي على الإدارة سلطات استثنائية غير مألوفة في العلاقات التعاقدية العادية؛ لحماية الصالح العام، والمرفق العام، ودون إخلال بحقوق الطرف الآخر، أو إساءة استعمال السلطة. وهو ما سوف نتناوله في مبحثين:

### المبحث الأول

#### سلطات الجهة الإدارية مع المتعاقد

تتمتع الإدارة في العقد الإداري ببعض الامتيازات والسلطات الاستثنائية التي لا يتمتع بها الطرف الآخر؛ باعتبارها وسيلة وليست غاية لتحقيق ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وحماية المصلحة العامة، وتحقيق التوازن مع حقوق المتعاقد. إذ لا يُتصور قيام علاقة تعاقدية مستقرة دون احترام جهة الإدارة لالتزاماتها، وممارستها لسلطاتها في نطاق ما يتيح القانون دون تجاوز؛ فهي وإن تساوت مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود، إلا أنها مقيدة بوجوب الالتزام بالإجراءات التي قررها المشرع بالقوانين واللوائح<sup>(١)</sup>. وتتمثل سلطاتها في:

---

(١) فتوى الجمعية العمومية رقم ٨٠ بتاريخ ٢١/١/٢٠٠٢، ملف رقم ٥٦/٢/٧٨. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٧.

## المطلب الأول

### سلطة الإدارة في التوجيه والإشراف والرقابة على تنفيذ العقد

تمارس الإدارة سلطتها في التوجيه والإشراف الفني والمالي والإداري والرقابة على تنفيذ العقد الإداري، والتحقق من مطابقته للشروط والمواصفات، وضمان حسن سير الأعمال، حتى ولو لم ينص على ذلك. وهو ما يميزه عن نظيره المدني الذي لا يسمح لأحد طرفيه بالرقابة إلا بموجب نص صريح لتساوى المراكز.

وقد تمتد سلطتها في توجيه أوضاع تنفيذ العقد، وتغيير بعض أوضاعه في غير الحالات المنصوص عليها في العقد، كأن تطلب من المتعاقد إتباع وسيلة معينة للتنفيذ غير تلك الطريقة التي يستخدمها أو يستعملها، بشرط ألا يصل الأمر إلى تغيير في طبيعة العقد، أو أن تحقق أهدافا ليست من أهداف المرفق المتصل بالعقد، وألا تتجاوزها إلى فرض شروط جديدة أو تعديل شروط قائمة. مثال: ما تنص عليه عقود استغلال الثروة المعدنية من رقابة للإدارة وفقا لنظام التعدين.

وتمارس الإدارة سلطتها في الرقابة المستمرة في كافة عقود الإدارة، طوال تنفيذ العقد من حيث الجودة، والمدة والالتزام الفني والإداري والمالي. مثال: عقود الالتزام ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بهدف متابعة الجودة، الجداول الزمنية، المواد المستخدمة، والتقارير المرحلية، ومراجعة دفاتر وسجلات المتعاقد، واعتماد المواد أو الآلات



المستخدمة، ومتابعة الأعمال ميدانيا، ورفض الأعمال غير المطابقة للمواصفات. يؤكد نص المادة (٧) من القانون ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ والمعدلة بالقانون رقم ٤٩٧ لسنة ١٩٥٤ بأن: (لمنح الالتزام أن يراقب إنشاء المرفق موضوع الالتزام وسيره من النواحي الفنية والإدارية والمالية وله في سبيل ذلك تعيين مندوبين عنه في مختلف الفروع والإدارات التي ينشئها الملتزم لاستغلال المرفق ويختص هؤلاء المندوبين بدراسة تلك النواحي وتقديم تقرير بذلك لمنح الالتزام..).

وقد تقل درجة الرقابة في عقود التوريد عنها في عقود الأشغال، وذلك في ضوء أحكام القوانين واللوائح ونصوص العقد وشروطه ومواصفاته. وقد نظمت المادتين (٤٣) من قانون التعاقدات، (٨٧) من لائحته التنفيذية مسؤولية إدارة العقد الإداري، وتحديد مهام المسئول بهدف الرقابة والإشراف والتوجيه، فله رقابة سابقة ولاحقة. مثل: مراجعة شروط العقد والبرنامج الزمني للتوريد، أو التنفيذ والتأكد من تنفيذه وفقا للشروط والمواصفات الفنية والمتطلبات الأخرى وفي المواعيد المحددة به. والتأكد من قيام المتعاقد بالوفاء بالتزاماته التعاقدية وحل أي خلافات تطرأ أولا بأول. وحل المشاكل الفنية والمالية والقانونية ذات الصلة بالعقد. ودون تأخير، وغيرها.

وحق الإدارة في الرقابة والإشراف ليس حقا مطلقا، بل مقيدا تحكمه عدة اعتبارات ضمانا لحق المتعاقد ضد تعسف الإدارة، مردها أمرين:

١ - مجانية الصالح العام والخروج عن دائرة المرفق العام: كأن يكون الغرض من الرقابة مخالفة الصالح العام، أو الخروج عما يتصل بسير المرفق العام موضوع التعاقد، وإلا كان فيه إساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ.

٢ - مخالفة قواعد تعديل العقد المقررة: كأنه تقوم الإدارة بتعديل موضوع العقد وطبيعته تعديلا كلياً جوهرياً، فلا يجوز لها في عقد الامتياز أن تتدخل في الإدارة الداخلية للالتزام، وإلا تحولت إدارة المرفق إلى طريق الاستغلال المباشر.

## المطلب الثاني

### سلطة التعديل الانفرادي لشروط العقد

تتمتع الإدارة، بحكم تغليب المصلحة العامة، والعمل لصالح مرفق عام بسلطة تعديل بعض شروط العقد الإداري من جانبها وحدها أثناء تنفيذه، دون حاجة إلى موافقة المتعاقد الآخر، إذ لا يجوز أن تقف الإرادة التعاقدية حجر عثرة أمام مقتضيات المصلحة العامة. يؤكدته فتاوها: "حق جهة الإدارة في تعديل العقد الإداري أو إنهائه مشروط بأن تقتضي حاجة المرفق أو المصلحة العامة ذلك، وأن حقها هذا مستمد من النظام العام، ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتنازل عنه"<sup>(١)</sup>.

---

(١) فتوى الجمعية العمومية رقم ٥٣٥ بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٤، ملف رقم ٥٢٠/١/٥٤. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٢٧ وما بعدها.

وقضى بأن: "من المسلم به في المبادئ التي تنظم نظرية العقد الإداري أن لجهة الإدارة حق تعديل العقد من جانبها وحدها بتغيير الالتزامات الناشئة عنه زيادة أو نقصاً وأن هذا الحق ينبثق من طبيعة العقد الإداري ذاته ويقوم على أساس مقتضيات المرفق أو المصلحة العامة"<sup>(١)</sup>.

### ضوابط ومعايير تعديل العقد الإداري

يتعين على إدارة التعاقدات بأن تراعي عند تعديل حجم العقد<sup>(٢)</sup>، الآتي:

- ١- وجود ضرورة وأسباب داعمة لتلك التعديلات.
  - ٢- الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو مجلس الوزراء- بحسب الأحوال- على التعديل.
  - ٣- أن تكون تلك التعديلات على بنود العقد الأصلي ذاته بالشروط والمواصفات ذاتها والأسعار المتعاقد عليها.
  - ٤- إعداد ملحق للعقد متضمناً تلك التعديلات.
  - ٥- الحصول من الإدارة المالية على سماح البند عند التعديل بالزيادة.
  - ٦- أن يكون التعديل خلال مدة تنفيذ العقد، ولا يدخل فيها مدة الضمان.
  - ٧- ألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه.
- على أن تتولى إدارة التعاقدات توثيق تلك التعديلات والمستندات المؤيدة لها وحفظها بملف العملية، ويتم النشر عن القيمة النهائية للعقد بعد التعديل على بوابة التعاقدات العامة.

---

(١) الحكم السابق في الطعن رقم ١٠٥٩ لسنة ٧ق، بتاريخ ١٩٦٣/٥/٢٥، مكتب فني، ٨، ص ١٢٢٥.  
(٢) المادة (٩٦) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.

## المطلب الثالث

### سلطة توقيع الجزاءات الإدارية

ينفرد العقد الإداري ببعض الالتزامات المرتبطة بطبيعته، ويستتبع هذه الالتزامات أخطاء عقدية خاصة لا يعرف القانون الخاص لها مثيلاً؛ نتيجة أنه خطأ ضد المرفق العام، قبل أن يكون خطأ عقدياً<sup>(١)</sup>. فعدم تنفيذ المدين التزاماته التعاقدية، أو التأخير في تنفيذها خطأ تترتب عليه مسئوليته التي لا يدرؤوها عنه إلا إثبات أنه يرفع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث فجائي أو قوة قاهرة يشترط فيهما أن يكون غير ممكن التوقع، أو خطأ من الغير، أو خطأ المتعاقد الآخر ذاته<sup>(٢)</sup>. إذ المسئولية العقدية لا تثار إلا عند عدم إمكان التنفيذ العيني، أو عند عدم عرض المدين الوفاء عينا إذا طالبه الدائن بالتعويض<sup>(٣)</sup>.

ويعرف الخطأ العقدي: "عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أياً كان السبب في ذلك، بحيث يستوي أن يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن عمد، أو إهماله، أو عن فعله دون عمد أو إهمال"<sup>(٤)</sup>. أو هو:

---

(١) د/ عبد المجيد فياض: نظرية الجزاءات في العقد الإداري، مرجع سابق، ص ١٢٢.  
(٢) فتوى الجمعية العمومية رقم ٩٦٢ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠، ملف رقم ٥٣٣٠/٢/٢٢.  
المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٢٥ وما بعدها.  
(٣) د/ عبد الرحمن عياد: المسئولية العقدية - نظرة انتقادية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، س ١٤، ٣٤، ٤، مصر، ص ٨٧.  
(٤) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٧٧ لسنة ٤٧ ق. ع، جلسة ٢٠٠٧/٧/١٠، منشور لدى د/ خالد عبد الفتاح محمد: الشامل، مرجع سابق، ص ٨ وما بعدها. والطعن رقم ٤٠٥٤، ٤٧٧١ لسنة ٤١ ق. ع، جلسة ٢٠٠٧/١/١٦، ذات المرجع، ص ١٥ وما بعدها. والطعن رقم ٧٠٥٧ لسنة ٤٧ ق. ع، جلسة ٢٠٠٦/٧/١٨. مرجع سابق. والطعن رقم ١٣٢٠، ١٣٤٠ بتاريخ ١٩٦٩/٢/١٥، لسنة ١١ ق، المكتب الفني، س (١٤)، ص ٣٧٣. والفتوى رقم ١٠٦٥ في ١٩٨٨/١٠/٢٥، ٤٣، ٤٤/٢٩٤/٨٢٧، المكتب الفني، ص ٣١٤.

"إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه الناشئ عن العقد"<sup>(١)</sup>. وقد ينجم الخطأ العقدي عن خلل غير شخصي للمتعاقد، كعدم وفاء والتزامه بتنفيذ العقد في المدد المحددة سلفاً، أو إخلاله بالمحافظة على دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد كعدم تنفيذه للعقد بحسن نية، أو عدم تنفيذه وفقاً للمواصفات والشروط المتفق عليها<sup>(٢)</sup>.

وأياً كان فللإدارة سلطة توقيع جزاءات إدارية مباشرة على المتعاقد، دون حاجة للجوء إلى القضاء، بشرط توافر الضمانات المقررة. ويمكن حصرها في: الجزاءات المالية، وغير المالية، والجنائية، والضاغطة.

### أولاً- سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات المالية

وتتمثل في: الغرامة التأخيرية، والتعويض، ومصادرة التأمينات، ودفع مقابل تأخير.

١- الغرامة: وهي بصفة عامة: جزاءات مالية تقدر مقدماً في العقد، أو في القانون، وتفرضها الإدارة في حالة إخلال المتعاقد بالتزام معين، وبخاصة في حالة التأخير في التنفيذ، دون حاجة لإثبات ركن الضرر. وعرفت الغرامة التأخيرية في مجال العقود الإدارية بأنها: ( جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بانتظام - يحق للإدارة توقيعها من تلقاء نفسها، وبمجرد وقوع المخالفة التي تقرررت الغرامة جزاء لها - لا يتوقف

(١) قراره السابق رقم ٢/ ت لعام ١٤٠٠هـ في القضية رقم ٣٥١/ ق لعام ١٣٩٧هـ، جلسة ١٩/٢/١٤٠٠هـ.

(٢) بتوسع: إبراهيم الشارف الطاهر تفوقه: مرجع سابق، ص ١١٥ - ١٣٤.

استحقاقها على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال هذا المتعاقد بالتزامه- لا يعفي المتعاقد من الغرامة إلا إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة القاهرة أو إلى خلل جهة الإدارة المتعاقد معها<sup>(١)</sup>.

وتعد الغرامة التأخيرية صورة من صور التعويض الاتفاقي، ويلزم لتوقيعها توافر الركن الأصلي للمسئولية الموجبة للتعويض وهو ركن الخطأ<sup>(٢)</sup>. وتطبق حتى ولو كان المتعاقد إحدى الجهات الإدارية<sup>(٣)</sup>.

وقضت بعدم جواز تطبيق غرامة التأخير على صاحب العطاء الذي لم يقدّم بفساد التأمين النهائي، ويقتصر حق جهة الإدارة على اقتضاء فروق الأسعار<sup>(٤)</sup>.

وإن انتهت المحكمة الإدارية العليا مؤخراً بأن زيادة الأسعار لا ترقى إلى مرتبة الأسباب القهرية، ولا تعد مبرراً للإعفاء من الغرامة، باعتبار زيادة الأسعار في شتى مناحي الحياة باتت من الأمور المألوفة على مستوى سائر التعاملات<sup>(٥)</sup>.

---

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٥٧٠٣ لسنة ٥٥٥ ق. عليا، جلسة ٢٤/١٢/٢٠١٩. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٧٦٠ وما بعدها. والطعن رقم ٢٥٥١ لسنة ٣١ ق، بتاريخ ١٩٨٩/٥/٣٠، مكتب فني ٣٤، ص ١٠٧٢.

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٩٦٨٤٣ لسنة ٦١ ق. عليا، جلسة ٢٨/١/٢٠٢٠. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٧٦١ وما بعدها.

(٣) فتوى الجمعية العمومية رقم ١٧٩٩ بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٢، ملف رقم ٤٢٧٨/٢/٣٢. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٧٨١ وما بعدها.

(٤) حكمها في الطعن رقم ٢٦٤٥٧ لسنة ٤٩ ق. عليا، جلسة ٢٨/٥/٢٠١٩. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٧٧٠ وما بعدها.

(٥) فتاها رقم ٨٣٩ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٦ في الملف رقم ٦٩٣/١/٥٤. وفتاها رقم ٥٩٤ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨ ملف رقم ٦٨٠/١/٥٤. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٥٣ وما بعدها.

٢- سلطة توقيع التعويضات أو المطالبة بها: يجوز للإدارة مطالبة المتعاقد معها بدفع مبلغ مالي، يعرف بالتعويض، جزاء إخلاله بالتزاماته، وتعويضاً لها عن الأضرار التي لحقت بها من جراء إخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد دون حاجة لإثبات ركن الضرر. ومن ثم تملك الإدارة سلطة الخصم المباشر من المستحقات المالية للمتعاقد في حدود الضرر، وفقاً للإجراءات.

إلا أن تقدير التعويض المستحق للجهة الإدارية عن الأضرار التي أصابتها بسبب تأخير المتعاقد هو من اختصاص القضاء، عدم جواز تحصيل جهة الإدارة لهذا التعويض عن طريق التنفيذ المباشر. والتعويض في العقود بصفة عامة، والعقود الإدارية خاصة نوعان: اتفاقي يتفق عليه محددًا في متن العقد. وقضائي يلجأ إليه إذا لحق أحد المتعاقدين ضرر، ومردّه للقضاء وحده<sup>(١)</sup>. وللإدارة سلطة الخصم المباشر من المستحقات المالية للمتعاقد في حدود الضرر.

شروط استحقاق التعويض من المتعاقد مع الإدارة: يشترط توافر الآتي:

- ١- أن يوجد خطأ يتمثل في الإخلال بالتزام تعاقدي.
- ٢- وأن يترتب عليه ضرر فعلي.
- ٣- وأن يتناسب مع الضرر الواقع أو الحادث.
- ٤- عدم لجوء الإدارة للقضاء بشأنه؛ بل هو مقرر قانوناً.

---

(١) فتوى الجمعية العمومية رقم ٦٤٦ بتاريخ ٢٠٠٣/٩/١٠، ملف رقم ٣٩٦/١/٥٤. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٧٨٣ وما بعدها.

ويمكن الجمع بين التعويض وجزاءات أخرى على المتعاقد.

وتختلف الغرامة عن التعويض في الآتي:

- ١ - الغرامة عامة أو تعاقدية؛ لأنها محددة سلفاً من الإدارة في العقد، أو بنص قانوني، بينما التعويض خاص أو نسبي يستفيد منه المضرور.
- ٢ - الغرامة تلقائية؛ إذ تطبق مباشرة دون حاجة لإثبات وجود ضرر للإدارة، ولا يمكن زيادتها بعكس التعويض.

٣ - الغرامة تطبق بموجب قرار إداري، بعكس التعويض فيكون بحكم.

- ٤ - الغرامة موعد استحقاقها هو التأخير عن تنفيذ العقد دون حاجة للتنبيه والإنذار بها بعكس التهديدات المالية فلها إنذار مسبق، وبالعكس التعويض فيكون لمن أضر في مركزه القانوني.

٣ - مصادرة الإدارة للتأمين أو احتفاظها بالتأمين النهائي:

يعتبر من سلطات الإدارة الاحتفاظ بالتأمين النهائي أو المؤقت أو مصادرته كضمانة لتنفيذ العقد بصفة نهائية، وفق ما نصت عليه المادتين (٤١) من قانون التعاقدات، (٨٢) من لائحته التنفيذية.

وغالباً ما يكون مصادرة التأمين النهائي مصحوباً بفسخ العقد الإداري في حالة الخطأ العقدي للمتعاقد، وذلك بإرادة الإدارة المنفردة دون اللجوء إلى القضاء؛ باعتباره امتيازاً لها؛ لتعلق العقد الإداري بالمرق العام الذي يستهدف تسييره مع حقها في الرجوع عليه بالتعويض عما أصابها من أضرار نتيجة خطأ هذا التعاقد. والتأمين النهائي لا يخرج عن أن يكون



ضماناً لجهة الإدارة لتوقى الأخطاء التي قد تصدر من التعاقد معها، كما يضمن ملاءته عند مواجهة المسؤوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري.

يؤكدده فتاوها أن إخلال التعاقد خلال تلك الفترة بالضمان يترتب عليه أحقية الجهة الإدارية في مصادرة التأمين النهائي والإصلاح على حسابه<sup>(١)</sup>.

وبجوز الجمع بينه وجزاءات أخرى؛ لذا قضى بأن: (للجهة الإدارية الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين وشطب الاسم وهذه ليست إلا جزاءات تملك توقيعها على التعاقد معها... دون انتظار لحكم من القضاء... إذا تخلف عن الوفاء بما يفرضه عليه العقد أو إذا استعمل الغش أو التلاعب في معلوماته معها... بل لها أن تنهى العقد نفسه قبل الأوان متى اقتضت المصلحة العامة ذلك)<sup>(٢)</sup>.

ولا يوجد ثمة معنى لإعذار التعاقد وجوباً على الإدارة وإنما يكون لفت انتباه إلى مخالفته أثناء التنفيذ.

#### ٤ - مطالبة التعاقد دفع مقابل تأخير

تملك جهة الإدارة سلطة مطالبة التعاقد بدفع مقابل جزاء تأخيره في تنفيذ العقد. يؤكدده نص المادة (٩٨) من اللائحة من أنه: (يتعين على

---

(١) فتوى الجمعية العمومية رقم ٥١٩ بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣، ملف رقم ٤٨٤١/٢/٣٢. المستشار د/ محمد علاء، موسوعة، مرجع سابق، ص ٦٢١ وما بعدها.

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا السابق في الطعن رقم ١١٠٩ لسنة ٨ق، بتاريخ ١٩٦٣/٢/٢٨.

مسئول إدارة العقد، بقدر الإمكان العمل على إزالة أية عقبات أو مشكلات قد تؤدي إلى التأخير في تنفيذ العقد سواء كان بسبب راجع للجهة الإدارية أو المتعاقد. وفي حالة حدوث تأخير في البرنامج الزمني، أو في تنفيذ العقد خارج عن إرادة المتعاقد فيجوز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاؤه مهلة لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل تأخير منه.

أما إذا كان التأخير راجع للمتعاقد فيحصل منه مقابل للتأخير يحسب من بداية المهلة وبما لا يجاوز النسب الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية. وفي جميع حالات تحصيل مقابل التأخير، يكون الإعفاء منه بقرار من السلطة المختصة إذا تبين أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد -كالحادث الفجائي والقوة القاهرة، وخطأ جهة الإدارة ذاتها- وللسلطة المختصة في غير هذه الحالة إعفاء المتعاقد من مقابل التأخير جزئياً أو كلياً إذا لم ينتج عن التأخير ضرر، ويجوز للسلطة المختصة استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا ارتأت ذلك.

ولا يخل تحصيل مقابل التأخير بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار.

**ثانياً - سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات غير المالية**

وهي تلك الجزاءات التي لا يكون محلها مبلغاً من المال. وتتمثل في:

١-الفسخ الجوازي للعقد أو سحب العمل والتنفيز على حساب المتعاقد: نظمت المادتين (٥١) من قانون التعاقدات، و(١٠١) من لائحته التنفيذية أحكام سلطة الإدارة في الجواز والخيار بين فسخ العقد، أو سحب العمل والتنفيز على حساب المتعاقد، فألزمت المتعاقد أولاً بأنه يتعين عليه بذل أقصى جهد للالتزام بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً لما اشتمل عليه العقد.

وبتعيين على إدارة التعاقدات في حالة إخلاله بأي شرط جوهري تضمنته شروط العقد، استنفاد كافة البدائل الممكنة للوصول إلى حلول تتفق مع شروط العقد. وعليها في حالة عدم إمكانية التوصل إلى حلول منطقية بما يحقق المصلحة العامة اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:

١-فسخ العقد: ولا يجوز في هذه الحالة إعادة طرح العملية في السنة المالية ذاتها المقرر التنفيذ فيها.

٢-التنفيز على حساب المتعاقد ما دام أن الحاجة إلى تنفيذ هذه العملية ما زالت قائمة، على أن يتم التنفيذ بالشروط والمواصفات ذاتها المعلن عنها والمتعاقد على أساسها، وذلك بإحدى الطرق القانونية المقررة قانوناً. ولا يجوز للجهة الإدارية الجمع بين الفسخ أو التنفيذ على حسابه لأي سبب<sup>(١)</sup>. ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة، يخطر به المتعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع

---

(١) م ٢/٥١ من قانون التعاقدات.

عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في الوقت ذاته بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال على عنوانه المبين في العقد.

وتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في حالات الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد، تخولها الحق في الآتي:

١ - مصادرة التأمين النهائي.

٢ - أن تخصم ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها. أو خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، وذلك في حالة عدم كفايتها، ومع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً.

ويتم عمل جرد في حالّتا فسخ العقد، أو التنفيذ على حساب المتعاقد، وتحرير كشف بالأعمال التي تمت وبالألات والأدوات التي استحضرت والمهمات التي لم تستعمل والتي يكون قد أورها المتعاقد بمكان العمل. وذلك خلال شهر من تاريخ موافقة السلطة المختصة. بمعرفة مسئول إدارة العقد من الجهة الإدارية أو مندوبيها، بحسب الأحوال، وبحضور المتعاقد بعد إخطاره بالحضور هو أو من يفوضه.

ويثبت هذا الجرد بموجب محضر. والجهة الإدارية غير ملزمة بأخذ شيء من هذه المهمات إلا بالقدر الذي يلزم لإتمام الأعمال فقط شريطة أن تكون صالحة للاستعمال، أما ما يزيد على ذلك فيكلف بنقله من

محل العمل. وفي حالة عدم قيام المتعاقد بنقل المتبقي من مهماته فتقوم  
الجهة الإدارية ببيعها لحسابه، وخصم ما تكبدته من مصروفات في  
سبيل ذلك<sup>(١)</sup>.

ويجب عدم الخلط بين التنفيذ العيني في العقود الإدارية<sup>(٢)</sup> وغيره في  
عقود القانون الخاص، والذي يتم عن طريق القضاء.

## **٢- سلطة الفسخ الوجوبي للعقد أو بقوة القانون وشطب المتعاقد**

يعد فسخ العقد أخطر الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد؛ لما  
يترتب عليه من إنهاء الرابطة العقدية، ولا يعترف به القضاء الإداري  
المصري والفرنسي إلا إذا كان الإخلال بالالتزام خطيرا، ولم يعد في وسع  
المتعاقد الوفاء بالتزاماته باعتباره من قبيل الخطأ للجسيم المبرر للفسخ،  
ووقف التوريد، والتنازل عن العقد أو التعاقد بشأنه من الباطن، والغش  
من جانب المتعاقد.

**حالاته:** يكون فسخ العقد وجوبيا، أو بقوة القانون تلقائيا، ويصاحبه  
شطب المتعاقد من سجل المتعاقدين في الحالات الآتية<sup>(٣)</sup>:

- ١- إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بغيره الغش أو التلاعب في  
تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد.
- ٢- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار .

---

(١) المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.  
(٢) د/ السيد أحمد مرجان: التنفيذ العيني للعقود الإدارية- سحب العمل والتنفيذ على  
حساب المتعاقد، دراسة مقارنة، مجلة روح القوانين، بكلية الحقوق، جامعة طنطا، عدد  
(٦٤)، ج ٤، إصدار ٢٠١٣م، ص ٨٥ وما بعدها.  
(٣) م ٥٠ من قانون التعاقدات.

٣- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .

الأمر الواجب على المتعاقد مراعاتها لتجنب حالات الفسخ الوجوبي:  
تتمثل بصفة خاصة في الآتي<sup>(١)</sup>:

١ - تقديم أي بيانات أو مستندات غير صحيحة بالذات أو بالواسطة وذلك بغرض الغش أو التلاعب.

٢ - المخالفة للحظر<sup>(٢)</sup> المنصوص عليه بالمادة (٣٣) من القانون أو التورط في أية ممارسات احتيالية، أو فساد، أو احتكار، كالتواطؤ، أو منع أية منافسة لأحد أصحاب العطاءات الآخرين، أو الاتفاق معهم على أغراض غير مشروعة، وغير ذلك من ممارسات تخل بتطبيق أحكام قانون التعاقدات ولائحته.

وتتولى إدارة التعاقدات فسخ العقد تلقائياً في هاتين الحالتين، وتقوم بإعداد مذكرة للسلطة المختصة لمخاطبة إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة؛ للوقوف على رأيها في شطب اسم المتعاقد.

على أن تتولى الإدارة فور ورود رأي مجلس الدولة إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بقرار الشطب؛ لتتولى الهيئة إصدار كتاب دوري بذلك، تنشره من خلال النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة.

---

(١) المادة (١٠٠) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات.  
(٢) ومضمونه أنه: "يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة، ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء...".

وقيده في سجل الممنوعين من التعامل، وتلتزم جميع الجهات الإدارية بقيد الممنوعين من التعامل في السجل الخاص. ويحظر التعامل معهم. وبعاد قيد المتعاقد الذي شطب اسمه في سجل المتعاملين بناء على طلبه؛ إذا انتفي سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إدارياً، أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، على أن يعرض قرار إعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة.

ولا يوجد ثمة معنى لإعذار المتعاقد وجوباً على الإدارة، وإنما يكون لفت انتباه إلى مخالفته أثناء تنفيذ العقد.

### ثالثاً - الجزاءات الضاغطة:

تتنوع وسائل وصور الضغط التي تلجأ إليها الإدارة: كوضع المشروع المدار بطريق الامتياز تحت الحراسة، أو سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة. والتنفيذ على حسابه. والشراء على حساب المتعاقد في عقود التوريد متي أخل المتعاقد بأي شرط من شروط البيع فيكون للجهة الادارية دون حاجة إلى إنذاره أو اللجوء للقضاء أن تفسخ العقد، وتقوم باتخاذ إجراءات البيع من جديد على حسابه مع حفظ حقها في الحصول على ما يكون مستحقاً لها من مبالغ نظير فروق الأسعار

والمصروفات الإدارية والتعويضات المستحقة ولا ترد إليه أية زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع.

**ثالثاً: الإلغاء الإداري للعقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات**  
إذا لم يتم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المهلة المحددة، جاز للجهة الإدارية، بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر، إلغاء العقد<sup>(١)</sup> أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها.

وبصحب التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها إذا تبين أنه المتسبب فيها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها له، أو خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى، أي كان سبب الاستحقاق في حالة عدم كفايتها، مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

**رابعاً: سلطة إنهاء العقد نهائية مبتسرة قبل حلول أجله**  
تملك الإدارة عند وجود مبررات تتعلق بالمصلحة العامة سلطة إنهاء العقد قبل مدته نهائية مبتسرة؛ بشرط تعويض المتعاقد تعويضاً عادلاً.

---

(١) مثال: إذا تأخر المورد عن توفير أصناف تعاقد على توفيرها إلى ما بعد انتهاء السنة المالية المكلف بالتوريد فيها، فإنه يجب إخطاره بإلغاء العقد عن الكمية الباقية". م(٩٥) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات الملغاة.



وهو ما يسمى بفسخ العقد لمقتضيات المرفق العام، ويختلف عن حالات الفسخ الوجوبي والجوازي، السابق ذكره.

وبجوز للإدارة فسخ العقد الإداري قبل نهاية مدته من تلقاء نفسها دون حكم قضائي؛ باعتباره حق مقرر للإدارة، حتى مع غياب النص القانوني، حفاظا للصالح العام، شريطة عدم إساءة استعمال السلطة في قرار الإنهاء، والانحراف به، مع إنذار المتعاقد قبل الإنهاء، وبيان أسبابه ومبرراته، والالتزام بتعويضه في حال كان الإنهاء لسبب غير مشروع.

والعقد الإداري ليس عقد إذعان، لكنه يخضع لاعتبارات تتجاوز مصلحة الأطراف الخاصة.

## المبحث الثاني

### التزامات الجهة الإدارية مع المتعاقد

بالرغم من تمتع الإدارة بسلطات استثنائية في مواجهة المتعاقد معها، إلا أنها تتحمل بعض الالتزامات القانونية التي تعكس مبدأ توازن العلاقة التعاقدية، واحترام القانون. وهو ما نوضحه في المطالب التالية:

#### المطلب الأول

##### الالتزام بتنفيذ العقد بحسن نية وفقاً لما تم التعاقد عليه

يترتب على كون جهة الإدارة طرفاً في العقد الإداري، الالتزام بتنفيذ ما ورد فيه من بنود واتفاقات، والوفاء بالتزاماتها التعاقدية بما يحقق التوازن العقدي ويحترم حقوق الطرف الآخر، بما يتفق ومبدأ حسن النية الذي يُعد من المبادئ العامة الحاكمة للعلاقات التعاقدية، دون تعسف أو استغلال لسلطاتها الاستثنائية.

وهو ما يفرض عليها عدم تعطيل تنفيذ العقد، أو تغيير شروطه بصورة تخل بالتوازن المالي له دون مبرر مشروع؛ بل يتعين عليها احترام التزاماتها التعاقدية، واحترام القواعد والإجراءات القانونية المقررة، بما يحقق العدالة والمساواة بين المتعاملين معها، ويؤكد مصداقيتها ونزولها على متطلبات الأحكام القانونية المنظمة لتعاملاتها مع الغير<sup>(١)</sup>. كأن

---

(١) حكمها في الطعن رقم ٣٨٠٨ لسنة ٥١ ق.ع، جلسة ٢٠٠٧/١/٦. المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، الجزء الأول من أول أكتوبر ٢٠٠٦ إلى إبريل ٢٠٠٧، القاعدة رقم (٣٦)، ص ٢٨١.

تسارع جهة الإدارة إلى سداد ثمن الأصناف الموردة متى تأكدت من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، باعتباره حق المتعاقد معها طالما أنه هو الآخر التزم حسن النية في التنفيذ بتوريد أصناف مطابقة للمواصفات والاشتراطات المتفق عليها<sup>(١)</sup>. وكالتزامها بتسليم المتعاقد مواد البناء، والذي يعنى بحسب النية المشتركة للمتعاقلين تسليم المتعاقد تصاريح الحصول على مواد البناء وليس مواد البناء ذاتها<sup>(٢)</sup>.

## المطلب الثاني

### الالتزام بتمكين المتعاقد من تنفيذ التزاماته

تلتزم الإدارة بتهيئة الظروف والبيئة الملائمة للمتعاقد؛ لبدء وتنفيذ الأعمال المتفق عليها، منها على سبيل المثال لا الحصر: ضرورة توفير الاعتمادات المالية قبل التعاقد، وحصول الإدارة على كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد وفق الإجراءات المقررة قانوناً، فكثير من العقود تستلزم أخذ موافقات أو تعليمات من الإدارة أثناء التنفيذ، ويتعين إصدارها في توقيت ملائم دون إبطاء أو تأخير. وإصدار طلب إبداء الاهتمام دون مقابل قبل الشروع في طرح العملية. وإعداد المواصفات الفنية وفق معايير البيئة المستدامة

---

(١) تقرير مفوض الدولة، في الدعوى رقم ١٠٢١٨ لسنة ٥٦ ق، هيئة مفوضي الدولة، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، غير منشور، ص ٣.  
(٢) حكمها في الطعن ١٥٠٣ لسنة ٢٧ ق. ع، جلسة ١٩٨٥/٤/٢، مكتب فنى، س ٣٠، ص ٨٨٩.

والجودة والخصائص الفنية والنوعية المطلوبة لموضوع التعاقد. وتسليم المواقع أو الأماكن أو البيانات اللازمة لبدء التعاقد في تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو التوريدات محل التنفيذ. وتوصيف العقار المطلوب شراؤه أو استئجاره توصيفا فنيا دقيقا. وتحديد مبلغ التأمين المؤقت. وإعداد كراسة الشروط والمواصفات النموذجية الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية. ووجوب الإعلان والدعوة والنشر عن العملية على بوابة التعاقدات وبالصحف ونحوه. وعقد جلسة للاستفسارات في بعض الحالات. وتشكيل اللجان المختلفة وفقا للقواعد القانونية المقررة. وسداد الدفعات المستحقة، والتسهيلات أثناء التنفيذ، وإزالة كافة العراقيل الإدارية أو المادية التي قد تحول دون تنفيذ التعاقد لالتزامه، وتسوية الخلاف والنزاعات.

ويختلف التزام جهة الإدارة هنا من عقد لآخر بحسب نوع وطبيعة العقد، وما إذا كان من عقود المقاولات، أو التوريدات، أو الانتفاع وغيره، إذ يتوجب عليها في كل الأحوال الامتناع عن اتخاذ إجراءات أو قرارات من شأنها تعطيل تنفيذ العقد، مثل: عدم إصدار التراخيص اللازمة، أو التباطؤ في تسليم الموقع خاليا من أي موانع، أو تغيير المواصفات الفنية دون اتفاق، باعتباره جزءا من مبدأ التعاون المفترض في العلاقات التعاقدية. ويعد إخلال الإدارة بالتزاماتها من قبيل الأخطاء العقدية التي ترتب مسئوليتها، وتعطي للمتعاقد الحق في المطالبة بالتعويض.

### المطلب الثالث

#### الالتزام بالأجر أو المقابل المالي المتفق عليه

تتحمل جهة الإدارة الالتزام بدفع المستحقات المالية للمتعاقد طبقاً لجدول السداد، أو الدفعات المرحلية أو الدورية المتفق عليها والمقررة في بنود العقد، لقاء تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأعمال أو الخدمات التي قام بها المتعاقد.

وقد قررت المادة ١/٤٥ من قانون التعاقدات أنه: "مع مراعاة شروط التعاقد، يصرف ثمن الأصناف الموردة أو الخدمات المؤداة في أقرب وقت ممكن وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد. وفي مقاولات الأعمال تصرف الجهة الإدارية دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل، وذلك خلال ستين يوماً تحسب من تاريخ تقديم المستخلص لها معززا بالمستندات على النحو الوارد بشروط التعاقد وقبول هذه المستندات من الجهة الإدارية، وتلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يعتمد.

ويجب على الإدارة الوفاء بالدفعات المقررة للمتعاقد في مواعيدها المحددة، طبقاً لما جاء بالعقد، وأي تأخير قد يترتب التزامها بالتعويض، طبقاً لقواعد المسؤولية العقدية. "وفي جميع الأحوال، إذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقد في المواعيد المحددة تلتزم الجهة الإدارية بأن تؤدي للمتعاقد ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو المستخلص

المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به، ويحال المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك".

#### **المطلب الرابع**

##### **الالتزام بعدم تعديل جوهرى للعقد ودون تعسف**

رغم تمتع الإدارة بسلطات وامتيازات استثنائية، مثل: سلطة تعديل بعض شروط العقد، وفسخ العقد، والانفراد بتوقيع الجزاءات، فإن استخدامها لهذه السلطات يجب أن يكون مشروعاً ومتوازناً ودون تعسف، وإلا عُدَّ إخلالاً بالتزاماتها التعاقدية.

ومن ثم لا يجوز للإدارة أن تجري تعديلات ببعض شروط العقد تمس جوهر الالتزامات، أو تخل بحقوق المتعاقد، أو بالتوازن المالى للعقد دون تعويض الطرف الآخر، ووفق الضوابط المقررة، كموافقة السلطة المختصة، وبقرار مسبب وغيره مما سبق.

#### **المطلب الخامس**

##### **الالتزام بالشفافية والرقابة وضمان السلامة المهنية والتعويض**

تلتزم الإدارة بمبدأ الشفافية، وتوفير المعلومات الفنية والمالية في كافة أنواع العقود التي تُمكن المتعاقد من التنافس، والتعاقد على أساس سليم منذ مرحلة الطرح وحتى الإسناد. كما تلتزم بالرقابة بكل صورها على

تنفيذ العقد في الحدود المعقولة المقررة قانوناً، ودون تعسف أو تدخل غير مبرر. كأن تلتزم في عقود المقاولات والأشغال باتخاذ ما يلزم من تنسيق لضمان تنفيذ الأعمال في بيئة آمنة، وتوفير الشروط التي تسهل تطبيق قواعد السلامة المهنية، بالتعاون مع المتعاقد.

ويحق للمتعاقد المطالبة في حالة إخلال الإدارة بالتزاماتها، أو إنهاء العقد بتعويض عن الأضرار، سواء عن طريق التسوية الودية، أو التظلم الإداري، أو اللجوء للقضاء المختص، أو التحكيم حسب الاتفاق.

وتلتزم الإدارة بإعادة التوازن المالي للمتعاقد، استناداً إلى النظريات الثلاثة المعروفة، والسابق ذكرها.

## الفصل الثالث

### انتهاء العقد الإداري وتسوية منازعاته

وهوما نتناوله في بحثين:

#### المبحث الأول

#### انتهاء العقد الإداري

**يقصد بها:** زواله من عالم القانون، ووضع حد لآثاره القانونية، إما لأسباب طبيعية، أو قانونية، أو قضائية، أو بنهاية غير طبيعية مبتسرة بسبب فسخه وجوبيا أو جوازيا أو إلغائه أو سحبه من المتعاقد مع الإدارة والتتفيذ على حسابه ونحوه.

**وتتعدد صور وأسباب انتهاء العقد الإداري، كالتالي:**

١- انتهاء العقد الإداري بانتهاء الغرض منه واستنفاد مضمونه أي بمجرد

الانتهاء من تنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لشروط العقد والمقرر قانونا.

فعقد الأشغال ينتهي بإتمام المقاول الأعمال المطلوبة مطابقة للمواصفات والشروط وقواعد الفن وأصول الصناعة، وتسليمها للإدارة تسليما نهائيا مع أخذ كل حقوقه. وعقد التوريد ينتهي بتوريد الأصناف والبضائع والسلع محل العقد<sup>(١)</sup>.

٢- انتهاء العقد الإداري بانتهاء المدة الزمنية المحددة لنفاذه وتنفيذه،

كانتهاء العقود المحددة المدد.

---

(١) المستشار: حمدي ياسين عكاشة: موسوعة، مرجع سابق، ص ٢٢ وما بعدها.



٣- انتهاء العقد الإداري المقترن بشرط فاسخ بتحقق الشرط الفاسخ، كما في عقود الخدمات كالترخيص للخبير الأجنبي بالعمل بعقد محدد المدة في جهة حكومية ما حتى انتهاء خدمته فيها، فإذا ما انتهت خدمته انتهى ترخيص إقامته.

٤- الاستحالة المطلقة في تنفيذ العقد الإداري، إما لانعدام محله بشكل مادي كوفاة المتعاقد مع الإدارة قبل تنفيذ العقد وعدم رغبة ورثته في التنفيذ لجهلهم بالعمل ونحوه. وإما لانعدام محله بشكل قانوني بصدور قانون يلغى عقد الامتياز للشركة المنفذة؛ لحدوث أزمة دبلوماسية ونحوه. **وينتهي العقد الإداري إدارياً بمعرفة الإدارة في حال رغبتها بإرادتها الملزمة بإنهاء العقد الإداري وإزالة آثاره، إما بإلغاء التعاقد، أو بنهايته نهاية مبتسرة قبل أوانه، أو بسحب العمل من المتعاقد، أو بالتنفيذ العيني على حساب المتعاقد، أو بفسخ العقد وجوباً أو جوازاً، وغيرها في الحالات المقررة قانوناً على نحو ما سبق.**

**وينتهي العقد الإداري قضائياً عن طريق القضاء المختص، أو بسبب نشوب منازعات ومشاكل بين المتعاقدين سابقة أو لاحقة<sup>(١)</sup> - نوضحها لاحقاً- وهو أمر طبيعي، يخول لكل طرف حق اللجوء للقضاء والتمسك بوجهة نظره دون مخالفة للقوانين واللوائح المقررة.**

---

(١) د/ السيد أحمد مرجان: حقيبة برنامج "منازعات العقود الإدارية"، معهد الإدارة العامة، الرياض، السعودية، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.

## المبحث الثاني

### منازعات العقود الإدارية

تتنوع منازعات العقود الإدارية إلى منازعات سابقة، وأخرى لاحقة.

أولاً- المنازعات السابقة على إبرام العقد الإداري:

هي ما تنحصر في المنازعات المتعلقة بالمراحل والإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري، واللازمة لتكوينه؛ باعتبارها من العمليات المركبة؛ لكونها تمر بعدة مراحل وخطوات، ويتبع فيها العديد من الإجراءات التمهيدية، والأعمال المادية والقانونية.

الأمر الذي يدفع الإدارة لاتخاذ العديد من القرارات الإدارية، سواء من قبل الإدارة ذاتها، أو اللجان المشكلة كلجنة فتح المظاريف، وفحص العروض وغيرها<sup>(١)</sup>.

وقد تدور كل المنازعات حول الإجراءات والمراحل التمهيدية المتعلقة بإعداد وثائق المنافسة، والإعلان عنها، وشروط المتقدمين بالعروض، وما تتخذه لجان فتح المظاريف، وفحص العروض من توصيات، والتي لا يمكن أن يترتب عليها التزامات تعاقدية<sup>(٢)</sup>.

والمعروفة بالمنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري؛ لكونها تسهم في عملية مركبة، ولكنها تتفصل عنه. كقرارات الترسية في العقد الإداري، وقرار نزع ملكية عقار خاص للمنفعة

(١) د/ سليمان الطماوى: الأسس العامة للعقود، مرجع سابق، ٢٠٠٥، ص ٣٤٤. أشرف حماد، سابق، ٢٠١٠، ص ٢٢.

(٢) د/ سليمان الطماوى: الأسس، المرجع السابق، ص ٣٤٨.

العامة. أما قرار شطب اسم المتعهد من عداد الموردين المحليين إذا استعمل الغش في تنفيذ التزاماته العقدية يعتبر من القرارات الإدارية النهائية التي تصدر بعد انتهاء العقد الإداري، وتطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية لا المنفصلة ويجوز الطعن فيه بالإلغاء في المواعيد المقررة قانوناً<sup>(١)</sup>.

### ثانياً - المنازعات اللاحقة على إبرام العقد الإداري:

يقصد بها: المنازعات التي يثيرها أطراف العقد الإداري أنفسهم، بسبب عقد إداري أيا كان نوعه، وذلك بعد إبرامه بشكل نهائي، والبدء في تنفيذه، والتي تخضع للقضاء الكامل، والذي يخول القاضي الإداري فيه سلطات كاملة وواسعة لحسم النزاع.

وتتخذ صوراً عدة، منها:

#### ١ - منازعات تتعلق بتنفيذ العقد:

منازعات خاصة بالمطالبة بالحصول على مبالغ مالية، أو بتمكين المتعاقد من استلام الموقع للتنفيذ، نتيجة تأخر الإدارة، أو بإبطال بعض تصرفات الإدارة العقدية، المخالفة لالتزاماتها التعاقدية<sup>(٢)</sup>. ومن أهمها:

---

(١) الطعن رقم ٧٤٢ لسنة ٢٤ ق، جلسة ١٦/١/١٩٨٢، س ص، المستشار د/ محمد أبو العينين، العقود، مرجع سابق، ص ٢٧.

(٢) د/ عاطف البناء، ١٤٠٥، ص ٣٢٩. د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة: الأسس العامة في العقود الإدارية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ٢٠٠٨م، ص ٣٢٥.

أ- دعاوى المطالبة بالحصول على مبالغ مالية متفق عليها استنادا للعقد: سواء في صورة ثمن أو أجره أو رسم أو غيره. وتخضع تلك المنازعات لولاية القضاء الكامل.

ويدخل فيها التعويض عن الأضرار التي تسبب فيها الطرف الآخر، أيا كان المتعاقد أو الإدارة؛ لأن حق الإدارة في التعويض ليس من الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها بنفسها<sup>(١)</sup>.

ب- دعاوى إبطال بعض تصرفات الإدارة العقدية، المخالفة للالتزاماتها التعاقدية: حتى ولو اقتصر طلبه على إلغاء قرار إداري صادر من الإدارة بصقتها متعاقدة.

مثال: إخلال الإدارة بتنفيذ التزاماتها الفنية بشكل كامل يحول دون وفاء المتعاقد بكافة التزاماته على النحو المطلوب.

وتخضع تلك المنازعات أيضا لولاية القضاء الكامل، مع التفرقة بين قضاء الإلغاء والتعويض.

وقد قضت بأن: (ما يصدر من القرارات تنفيذا للعقد، كالقرارات الخاصة بجزاء من الجزاءات التعاقدية أو بفسخ العقد أو إنهائه أو إلغائه فهذه كلها تدخل في منطقة العقد وتنشأ عنه، فهي منازعات حقوقية،.. وتكون محلا للطعن على أساس استعداد ولاية القضاء الكامل في فصل فيها على نحو لا يختلف عن ولاية القضاء المدني العادي"<sup>(٢)</sup>).

(١) د/عاطف البناء، مرجع سابق، ١٤٠٥، ص ٣٢٩.  
(٢) من حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ١١٨٠ لسنة ١٠٠٠، جلسة ١٩٥٦/١١/١٨، والدعوى رقم ١١٩٨ لسنة ١١٠٠، جلسة ١٩٥٧/١/٢٧. المجموعة.

## ٢- منازعات تتعلق ببطلان العقد الإداري:

وهي تلك الدعاوى التي يقيمها أحد أطراف العقد؛ بغرض المطالبة من القضاء ببطلان العقد؛ لوجود عيب جسيم يشوبه، يتعلق بتكوينه، أو صحة وسلامة أركانه، أو لمخالفته قواعد الشكل والاختصاص المحددة قانوناً، والواجب استيفائه على النحو المطلوب<sup>(١)</sup>، وسواء كان العيب في الإجراءات السابقة، أو في إبرام العقد ذاته.

ومن أمثلتها: المنازعات المتعلقة بصحة وسلامة أركان العقد الإداري، داخلية أو خارجية، كالمنازعات الخاصة بمحل وموضوع العقد، وبأهلية أطراف العقد، وبالتراضي وغيرها مما سبق ذكره.

## ٣- منازعات تتعلق بإنهاء وانقضاء العقد الإداري:

وغالباً ما تقام من قبل المتعاقد؛ نظراً لأن الإدارة المتعاقدة تملك إنهاء العقد إدارياً بنفسها دون اللجوء للقضاء، بما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة، وما لها من سلطة التنفيذ المباشر.

والمتعاقد يكون مدعياً أمام القضاء بعدم مشروعية تصرف الإدارة، كإنهائها للعقد لأسباب غير مشروعة، لأسباب شخصية؛ بهدف الانتقام منه، أو لأسباب مالية، أو عقائدية أو سياسية وغيرها<sup>(٢)</sup>. فيطلب انقضاء

---

(١) د/ محمود عاطف البناء، بحث سيادته في ندوة العقود الإدارية، معهد الإدارة العامة، الرياض، ١٤١٠هـ، ص ٣٢٩. د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة: تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيماً، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٩م، ص ٣٢٨.

(٢) د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة: دعوى التعويض الإداري، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ٢٠١٠، ص ٢٦٠.

وإنهاء الرابطة العقدية. وتبعا له فسخ العقد، ويخلى مكان العمل، ويطلب تسوية مصير الأدوات والمواد الخاصة به<sup>(١)</sup>. كما يتصور رفعها أيضا من قبل الإدارة في الحالات المقررة قانونا.

#### ٤ - منازعات تتعلق بالمطالبة بالتعويض:

وهي تلك الدعاوى التي ترفع ممن أضير من جراء تصرفات وأعمال الإدارة المادية والقانونية، عند تسييرها لأحد المرافق العامة؛ بهدف جبر الضرر الواقع عليه، ووفقا للشروط والإجراءات. ويدور نطاقها في منازعات العقود المثارة في جميع مراحل إبرام العقد الإداري<sup>(٢)</sup>. سواء توافر ركن الخطأ من جانب جهة الإدارة أم لم يتوافر.

---

(١) د/ عبد الحميد الشواربي: المشكلات العملية في تنفيذ العقد، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٨م، ص ٣٢٢.

(٢) د/ حمدي حسن الحلفاوى: ركن الخطأ في مسئولية الإدارة الناشئة عن العقد الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٢م، ص ٧٢.

## المحتويات

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| المقدمة.....                                                        | ٢  |
| الباب الأول: الإطار النظري للعقد الإداري.....                       | ٤  |
| الفصل الأول: تعريف العقد الإداري ومعياري تمييزه.....                | ٥  |
| المبحث الأول: ماهية العقد الإداري وتطوره ومعياري تمييزه.....        | ٥  |
| المبحث الثاني: التعريف بقانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية    | ٢٦ |
| المبحث الثالث: المبادئ الحاكمة لإبرام العقود الإدارية.....          | ٣٠ |
| الفصل الثاني: أركان العقد الإداري.....                              | ٣٨ |
| المبحث الأول: الرضا كركن من أركان العقد الإداري.....                | ٣٨ |
| المبحث الثاني: المحل كركن من أركان العقد الإداري.....               | ٤٨ |
| المبحث الثالث: السبب كركن من أركان العقد الإداري.....               | ٥١ |
| المبحث الرابع: الشكلية في بعض صور العقود الإدارية.....              | ٥٥ |
| الفصل الثالث: أنواع العقد الإداري.....                              | ٥٨ |
| المبحث الأول: عقد التزام أو امتياز المرافق العامة.....              | ٥٨ |
| المبحث الثاني: عقد الأشغال العامة.....                              | ٦٦ |
| المبحث الثالث: عقد المساهمة في مشروع ذي نفع عام.....                | ٧٠ |
| المبحث الرابع: عقد شغل الدومين العام والانتفاع بالأموال العامة..... | ٧٤ |
| المبحث الخامس: عقد التوريد.....                                     | ٧٩ |
| المبحث السادس: عقد النقل.....                                       | ٨٣ |
| الباب الثاني: طرق إبرام العقود الإدارية.....                        | ٨٥ |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الفصل الأول: إبرام العقد الإداري عن طريق المناقصات الأصلية والاستثنائية.....    | ٨٧  |
| المبحث الأول: المناقصة العامة الطريق الأصلي للتعاقد الإداري.....                | ٨٩  |
| المبحث الثاني: إبرام العقد الإداري بغير طريق المناقصة العامة.....               | ١١٠ |
| الفصل الثاني: إبرام العقد الإداري عن طريق المزايدات الأصلية والاستثنائية.....   | ١٥١ |
| المبحث الأول: المزايدة العامة الطريق الأصلي لإبرام العقد الإداري.....           | ١٥٢ |
| المبحث الثاني: إبرام العقد الإداري بغير طريق المزايدة العامة.....               | ١٥٩ |
| الباب الثالث: المراحل والإجراءات المنظمة لإبرام العقد الإداري ....              | ١٧٢ |
| الفصل الأول: القيود والإجراءات المقررة في مرحلة ما قبل الدعوة إلى التعاقد.....  | ١٧٣ |
| المبحث الأول: وجوب توافر الاعتمادات المالية.....                                | ١٧٦ |
| المبحث الثاني: التأمين المؤقت.....                                              | ١٨٢ |
| المبحث الثالث: إعداد كراسة الشروط والمواصفات.....                               | ١٨٩ |
| الفصل الثاني: القيود والإجراءات المقررة في مرحلة الطرح والإعلان عن التعاقد..... | ٢٠٠ |
| المبحث الأول: الاستشارات السابقة على التعاقد.....                               | ٢٠٠ |
| المبحث الثاني: الإعلان أو الدعوة للتعاقد.....                                   | ٢٠٨ |
| المبحث الثالث: التأهيل المسبق ومعرفة قدرات المتعاقد مع الإدارة.....             | ٢٠٩ |
| المبحث الرابع: آلية تقديم العطاءات.....                                         | ٢١٠ |



|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| المبحث الخامس: أحكام الوفاة والتعاقد من الباطن والفئات المحظور تعاملها        | ٢١٤ |
| الفصل الثالث: القيود والإجراءات المقررة في مرحلة الترسية وإبرام العقد الإداري | ٢٢٢ |
| المبحث الأول: قيود وإجراءات فتح مظاريف العطاءات                               | ٢٢٤ |
| المبحث الثاني: إصدار قرار الترسية وآثاره القانونية                            | ٢٣٢ |
| المبحث الثالث: الموافقات والتصاريح اللازمة للموافقة على التعاقد               | ٢٣٨ |
| الباب الرابع: الآثار المترتبة على انعقاد العقد الإداري وتنفيذه                | ٢٥٠ |
| الفصل الأول: التزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة                               | ٢٥٠ |
| المبحث الأول: التزامات المتعاقد مع الإدارة                                    | ٢٥١ |
| المبحث الثاني: حقوق المتعاقد مع الإدارة                                       | ٢٦٥ |
| الفصل الثاني: سلطات والتزامات الجهة الإدارية تجاه المتعاقد                    | ٢٨٧ |
| المبحث الأول: سلطات الجهة الإدارية مع المتعاقد                                | ٢٨٧ |
| المبحث الثاني: التزامات الجهة الإدارية مع المتعاقد                            | ٣٠٦ |
| الفصل الثالث: انتهاء العقد الإداري وتسوية منازعاته                            | ٣١٢ |
| المبحث الأول: انتهاء العقد الإداري                                            | ٣١٢ |
| المبحث الثاني: منازعات العقد الإداري                                          | ٣١٤ |
| المحتويات:                                                                    | ٣١٩ |